

Camila Cristina Murta
Tatiana Camarão
Coordenadoras

MANUAL DE CONTRATAÇÃO DE TIC SOB A ÓTICA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Colaboradores

Alexandre Ferraz
Anderson Sant'Ana Pedra
Antonio Carlos Dias
Camila Cristina Murta
Camila Lousada
Christianne De Carvalho Stroppa
Claudio Neiva
Everton Batista dos Santos
Felipe Boselli
Gabriela Verona Pércio
Jair Eduardo Santana
Juliana Picinin
Karlos Gustavo de Castro Correia
Lucas Lopes
Marcos Pires Namekata
Rafael Sérgio Lima de Oliveira
Tatiana Camarão
Victor Aguiar Jardim de Amorim

Prefácio

João Augusto Ribeiro Nardes

Apresentação

Maurício Pimentel

FORUM

CAMILA CRISTINA MURTA
TATIANA CAMARÃO

Coordenadoras

Prefácio

João Augusto Ribeiro Nardes

Apresentação

Maurício Pimentel

MANUAL DE CONTRATAÇÃO DE TIC SOB A ÓTICA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Colaboradores

Alexandre Ferraz

Anderson Sant'Ana Pedra

Antonio Carlos Dias

Camila Cristina Murta

Camila Lousada

Christianne de Carvalho Stroppa

Claudio Neiva

Everton Batista dos Santos

Felipe Boselli

Gabriela Verona Pécio

Jair Eduardo Santana

Juliana Picinin

Karlos Gustavo de Castro Correia

Lucas Lopes

Marcos Pires Namekata
Rafael Sérgio Lima de Oliveira
Tatiana Camarão
Victor Aguiar Jardim de Amorim

Belo Horizonte



2023

© 2023 Editora Fórum Ltda.

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico,
inclusive por processos xerográficos, sem autorização expressa do Editor.

Conselho Editorial

Adilson Abreu Dallari
Alécia Paolucci Nogueira Bicalho
Alexandre Coutinho Pagliarini
André Ramos Tavares
Carlos Ayres Britto
Carlos Mário da Silva Velloso
Cármem Lúcia Antunes Rocha
Cesar Augusto Guimarães Pereira
Clovis Beznos
Cristiana Fortini
Dinorá Adelaide Musetti Grotti
Diogo de Figueiredo Moreira Neto (*in memoriam*)
Egon Bockmann Moreira
Emerson Gabardo
Fabrício Motta
Fernando Rossi
Flávio Henrique Unes Pereira
Floriano de Azevedo Marques Neto
Gustavo Justino de Oliveira
Inês Virgínia Prado Soares
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes
Juarez Freitas
Luciano Ferraz
Lúcio Delfino
Marcia Carla Pereira Ribeiro
Márcio Cammarosano
Marcos Ehrhardt Jr.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
Ney José de Freitas
Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho
Paulo Modesto
Romeu Felipe Bacellar Filho
Sérgio Guerra
Walber de Moura Agra



Luís Cláudio Rodrigues Ferreira

Presidente e Editor

Coordenação editorial:
Leonardo Eustáquio Siqueira Araújo
Aline Sobreira de Oliveira

Rua Paulo Ribeiro Bastos, 211 – Jardim Atlântico – CEP 31710-430
Belo Horizonte – Minas Gerais – Tel.: (31) 99412.0131
www.editoraforum.com.br
editoraforum@editoraforum.com.br

Técnica. Empenho. Zelo. Esses foram alguns dos cuidados aplicados na edição desta obra. No entanto, podem ocorrer erros de impressão, digitação ou mesmo restar alguma dúvida conceitual. Caso se constate algo assim, solicitamos a gentileza de nos comunicar através do *e-mail* editorial@editoraforum.com.br para que possamos esclarecer, no que couber. A sua contribuição é muito importante para mantermos a excelência editorial. A Editora Fórum agradece a sua contribuição.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com a AACR2

M	Manual de contratação de TIC sob a ótica da nova lei de licitações e contratos administrativos /
2	Camila Cristina Murta, Tatiana Martins da Costa Camarão. Belo Horizonte: Fórum, 2023.
9	
4	2.230Kb. e-book
	ISBN 978-65-5518-558-4
1. Licitações. 2. Contratos administrativos. 3. TIC. 4. NLL. 5. Governança. 6. Gestão. I. Murta, Camila Cristina. II. Camarão, Tatiana Martins da Costa. III. Título.	

CDD: 342
CDU: 342.2

Ficha catalográfica elaborada por Lissandra Ruas Lima – CRB/6 – 2851

Informação bibliográfica deste livro, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

MURTA, Camila Cristina; CAMARÃO, Tatiana Martins da Costa (Coord.). *Manual de contratação de TIC sob a ótica da nova lei de licitações e contratos administrativos*. Belo Horizonte: Fórum, 2023. 2.230Kb. e-book. ISBN 978-65-5518-558-4.

PREFÁCIO

Os leitores que constatarem admirados a concretização de tanta evolução tecnológica, prevista em filmes e desenhos sobre o futuro, especialmente em um dos mais queridos – Os Jetsons, assistirão, nos próximos anos a uma série de outros avanços imaginados na mente brilhante de roteiristas inspirados, além de tantos outros inimagináveis, estou certo disso.

A inteligência artificial, com as peripécias iniciais do Chat GPT, já começa a impressionar a todos! Carros voadores, robôs de toda sorte, para múltiplas atividades! Viagens espaciais popularizadas, habitações em Marte e alhures, cirurgias realizadas por nanorrobôs, prolongamento da vida indefinidamente! O que mais nos visitará no futuro próximo, antes tão distante!!?

Quando o assunto é avanço tecnológico, nossa mente e criatividade, de fato, não têm limites e quem se aventurar nos textos primorosamente escritos nos capítulos a seguir pode ter certeza de que esta publicação, que trata da aquisição de soluções de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), é sobre esse futuro inovador, que queremos que chegue também ao setor público!

De forma simples, como veremos nesta publicação, TIC envolve o conjunto de máquinas (*hardware*), programas de computadores (*softwares*) e componentes de telecomunicação para viabilizar, por exemplo, as videochamadas, utilizadas em consultas ou reuniões virtuais, popularizadas na pandemia da covid, inspiradas, quem sabe, na vida que levava, já na década de 1960, George Jetson, sua esposa Jane, seus filhos Judy e Elroy e o não menos famoso canino Astro.

Ocorre que inovar no setor público é uma questão que ainda enfrenta dificuldades e resistências de toda sorte! Como fazer o

aparato estatal acompanhar tantas conquistas do mundo moderno, em um emaranhado de regras, normativos legais e infralegais, ainda pouco conhecidos para quem direciona e viabiliza as aquisições de TIC? Como fazer tudo isso com segurança e agilidade, de forma que os avanços de agora não se tornem obsoletos depois de sua aquisição?

Alinhados com a tese que defendemos, de que a governança pública é um desafio primário para o desenvolvimento das nações, em todos os aspectos, os autores desta publicação, após definir o que é TIC e traçar um panorama de sua aquisição pelo setor público, discorrem sobre a governança das contratações desse segmento, desde o planejamento até o controle e a fiscalização de todos esses componentes tecnológicos, que precisam ser comprados, de forma eficiente, eficaz e efetiva, para virar depois consultas e cirurgias a distância, aulas virtuais e tantos outros avanços que podem melhorar a eficiência estatal e facilitar a vida do cidadão.

Estamos falando de contratações de bilhões e bilhões de reais, na esfera federal, estadual e municipal. Em estudo sobre o mercado de compras governamentais brasileiro, o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) nos mostra que, de 2006 a 2017, essas aquisições representaram, em média, 12,5% do PIB (Produto Interno Bruto). Mantida essa média, os valores chegam à extraordinária cifra de R\$ 1,2 trilhão em compras no ano passado, sob responsabilidade de governantes e gestores públicos do país.

Uma parcela importante desse valor refere-se às aquisições de TIC. Só no Governo Federal, o Anexo VI da LOA – Lei Orçamentária Anual (que não inclui as estatais não dependentes), prevê um investimento de R\$ 6,7 bilhões na subfunção Tecnologia da Informação. Considerando as estatais, como Petrobras e Banco do Brasil, por exemplo, estima-se (a partir de proporção apurada no Acórdão nº 228/2015-TCU-Plenário) que os gastos do Governo Federal com TIC cheguem próximo à casa dos R\$ 17 bilhões.

Está claro, portanto, a partir desses valores bilionários, que, para construir o futuro que queremos no setor público, também sob inspiração do que previram William Hanna e Joseph Barbera – criadores dos Jetsons, os governantes e gestores, com suas equipes, precisam das melhores práticas possíveis para traçarem um estratégia desafiadora, mas segura.

É necessário, ainda, que essas lideranças sejam bem escolhidas e depois altamente capacitadas, de forma que possam superar entraves internos e externos. Por fim, boas práticas de controle devem ser capazes, por exemplo, de avaliar riscos e fiscalizar os gastos, também com um olhar no futuro, para evitar o propalado “apagão das canetas”, que dificulta aos inovadores sua busca pelo melhor futuro possível!

Mérito total, portanto, desse grupo de estudiosos que constatou haver uma grande carência na literatura técnica necessária para bem capacitar as lideranças e suas equipes sobre a gestão e a governança nas aquisições de TIC. A partir daí, decidiram disponibilizar aos inovadores, por meio das publicações colecionadas a seguir, um caminho mais seguro rumo às suas aspirações.

Ao se debruçarem sobre os capítulos que se seguem, os governantes e gestores encontrarão um caminho mais confortável para construir o futuro no setor público, dando as suas canetas, que direcionam ou que gerem, uma luz mais perene para inovarem, com agilidade, eficiência, eficácia e efetividade em atividades tão vitais para a população ter as melhores políticas públicas de saúde, educação, mobilidade urbana, entre outras, alinhadas ao futuro que já chega!

João Augusto Ribeiro Nardes

Ministro do TCU

[folha de rosto](#)

[Prefácio](#)

[CARTA ABERTA ABES – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE](#)

[Apresentação](#)

[expediente](#)

[CAPÍTULO 1](#)

[INTRODUÇÃO](#)

[1.1 Serviços digitais governamentais e os ressignificados da Nova Lei de Licitações](#)

[1.1.1 Suprimento de demandas governamentais: essencialidades em torno dos serviços públicos digitais](#)

[1.1.2 A Nova Lei de Licitações e os serviços digitais. Demandas instrumentais da tecnologia da informação](#)

[1.1.3 Ressignificados](#)

[1.2 Contexto legal da contratação de soluções TIC e sua evolução](#)

[1.3 Evolução da contratação de nuvem](#)

[CAPÍTULO 2](#)

[DEFINIÇÕES E DENOMINAÇÕES DE SERVIÇOS](#)

[2.1 O que são serviços de TIC?](#)

[2.2 Dos serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação](#)

[2.3 Terceirização de serviços TIC](#)

[2.4 Serviços em nuvem](#)

[Modelo NIST para computação em nuvem](#)

[2.4.1 Características essenciais](#)

[2.4.1.1 Modalidades de pagamento](#)

[2.4.1.2 Modalidades de uso](#)

[2.4.1.3 Computação sem servidor](#)

[2.4.1.4 Elasticidade](#)

[2.4.1.5 Escalabilidade](#)

[2.4.1.6 Agilidade](#)

[2.4.1.7 Disponibilidade](#)

[2.4.1.8 Segurança](#)

[2.4.2 Modelos de serviço](#)

[2.4.3 Modelos de implementação](#)

[2.5 Serviços técnicos profissionais em nuvem](#)

[2.5.1 O modelo de entrega de projeto de serviços profissionais](#)

[2.5.2 Serviços técnicos profissionais na jornada de adoção de nuvem](#)

2.6 Tecnologias emergentes

2.6.1 Modernização de dados e novas estruturas analíticas

2.7 Serviços de operação de infraestrutura e de atendimento aos usuários

a) Gerenciamento de serviços de TIC (GSTI)

b) Sustentação de aplicações

c) Armazenamento e backup

d) Sustentação de banco de dados

e) Administração de dados

f) Conectividade e comunicação

g) Segurança de TIC

h) Monitoramento de serviços de TI

i) Suporte técnico de microinformática

2.7.1 Precificação de serviços

2.7.2 Serviços de hospedagem

2.8 Segurança da informação

2.8.1 A importância da segurança da informação no processo de contratação de serviços e produtos de tecnologia da informação no governo

2.8.1.1 Avaliar as regulamentações aplicáveis

2.8.1.2 Identificar os ativos críticos

2.8.1.3 Definir políticas de segurança

2.8.1.4 Implementar controles de segurança

2.8.1.5 Conclusão

CAPÍTULO 3

GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES

3.1 A Nova Lei de Licitações e a governança das contratações

3.2 Os objetivos das contratações públicas

3.2.1 Atingir o interesse público

3.2.2 Observar a impessoalidade

3.2.3 Garantir a contratação mais vantajosa

3.2.4 Cumprir o princípio da eficiência administrativa

3.3 Governança nas contratações de TIC e o uso das ferramentas da NLLCA

3.3.1 Pré-qualificação

3.3.2 Homologação de amostras

3.3.3 Remuneração variável

3.3.4 Contrato de eficiência

CAPÍTULO 4

PLANEJAMENTO

4.1 Planejamento estratégico

4.2 Plano de logística sustentável

4.2.1 Política de contratação sustentável

4.2.1.1 Dimensão ambiental

[4.2.1.2 Dimensão econômica](#)
[4.2.1.3 Dimensão social](#)
[4.2.1.4 Dimensão cultural](#)
[4.2.2 A Política de Contratações Sustentáveis e o processo de contratação](#)
[a\) Planejamento](#)
[b\) Especificação técnica do objeto e obrigações da contratada](#)
[c\) Seleção do fornecedor](#)
[d\) Gestão e fiscalização](#)
[e\) Destinação final de resíduos e rejeitos](#)
[4.2.3 Indicadores de desempenho](#)
[4.3 Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC](#)
[4.4 Plano de Contratação Anual – PCA](#)
[4.4.1 A elaboração do Plano de Contratação Anual – PCA e seus desafios nas contratações de TIC](#)
[4.5 Planejamento das contratações](#)

[CAPÍTULO 5](#)

[ETAPA PREPARATÓRIA](#)

[5.1 Documento de Oficialização da Demanda](#)
[5.2 Justificativa técnica da contratação](#)
[5.3 Estudo Técnico Preliminar](#)
[5.3.1 Definição da solução viável nas contratações de TIC](#)
[5.3.2 Análise de soluções possíveis](#)
[5.4 Termo de Referência](#)
[5.4.1 Elementos do Termo de Referência](#)
[5.4.1.1 Definição do objeto](#)
[5.4.1.1.1 Da necessidade de avaliar o ciclo de vida do produto](#)
[5.4.1.2 Da fundamentação da contratação](#)
[5.4.1.3 Da descrição da solução como um todo](#)
[5.4.1.4 Dos requisitos da contratação](#)
[5.4.1.5 Modelo de execução do objeto](#)
[5.4.1.6 Modelo de gestão do contrato](#)
[5.4.1.7 Critérios de medição e de pagamento](#)
[5.4.1.8 Forma e critérios de seleção do fornecedor](#)
[5.4.1.9 Estimativas do valor da contratação](#)
[5.4.1.10 Adequação orçamentária](#)
[5.5 Requisitos técnicos habilitatórios da contratação TIC](#)
[5.5.1 Habilitação técnica](#)
[5.5.1.1 Linhas gerais](#)
[5.5.1.2 Documentações a serem apresentadas](#)
[5.6 Padronização](#)
[5.7 Modalidades de licitação](#)
[5.7.1 Noções gerais: a Lei nº 14.133/2021 e suas modalidades licitatórias](#)

[5.7.1.1 A dinamicidade das modalidades na Nova Lei de Licitações e a Possibilidade de modelagem da licitação](#)

[5.7.1.2 A modalidade pregão para contratação de bens e serviços “comuns” de TIC](#)

[5.7.1.3 A modalidade concorrência para contratação de bens e serviços “especiais” de TIC](#)

[5.7.2 Os critérios de julgamento das propostas](#)

[5.7.3 Os modos de disputa](#)

[5.7.4 Rito procedimental das modalidades licitatórias](#)

[5.8 Aquisições de solução TIC](#)

[5.8.1 Aquisição por técnica e preço](#)

[5.8.1.1 O critério de técnica e preço e o seu processamento](#)

[5.8.2 Ata de Registro de Preços](#)

[5.8.3 Diálogo competitivo](#)

[5.9 Procedimento para contratações de serviços em nuvem](#)

[CAPÍTULO 6](#)

[GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS](#)

[6.1 Responsabilidades](#)

[6.1.1 O gestor e sua designação](#)

[6.1.2 Fiscal de contratos](#)

[6.1.3 Da gestão e fiscalização do contrato pela área de TIC](#)

[6.2 Revisão, reajuste e repactuação](#)

[6.2.1 Introdução](#)

[6.2.2 Conceitos](#)

[6.2.2.1 Reequilíbrio econômico-financeiro enquanto gênero](#)

[6.2.2.2 Reajuste](#)

[6.2.2.3 Repactuação](#)

[6.2.2.4 Revisão](#)

[6.2.2.5 Os casos de commodities e variação cambial](#)

[6.2.2.6 O credenciamento de produtos voláteis e mercados fluidos.](#)

[6.2.2.7 Conclusão](#)

[6.3 Alteração contratual](#)

[6.4 Extinção dos contratos administrativos](#)

[6.5 Sanções](#)

[CAPÍTULO 7](#)

[CONTRATAÇÃO DIRETA DE SOLUÇÃO TIC](#)

[7.1 A inexigibilidade de licitação](#)

[7.1.1 A inexigibilidade de licitação por exclusividade em contratos de TIC](#)

[7.2 A dispensa de licitação](#)

[7.2.1 A dispensa de licitação em contratos de TIC](#)

[7.3 Conclusões](#)

[Referências](#)

[Sobre os Autores](#)

CARTA ABERTA ABES – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE

A ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software tem como propósito contribuir para a construção de um *Brasil Mais Digital e Menos Desigual*, no qual a tecnologia da informação desempenha um papel fundamental para a democratização do conhecimento e na criação de novas oportunidades, visando melhor qualidade de vida para todos e todas, de forma inclusiva e igualitária. Diante desse propósito, o objetivo da ABES é o de assegurar um ambiente de negócios propício à inovação, ético, dinâmico, sustentável e competitivo globalmente, como também um ambiente legislativo, regulatório e seguro com um conjunto de políticas públicas robustas que permitam que as organizações do nosso setor continuem contribuindo para o desenvolvimento do Brasil.

Atualmente, a ABES representa aproximadamente 2 mil empresas, sendo 76% micro e pequenas empresas, que totalizam cerca de 85% do faturamento do segmento de *software* e serviços no Brasil, distribuídas em 24 Estados brasileiros e Distrito Federal, responsáveis pela geração de cerca de 228 mil empregos diretos e um faturamento anual da ordem de US\$17 bilhões em 2022. As empresas associadas ou conveniadas à ABES fornecem produtos e serviços que impulsionam a economia brasileira, produzindo e comercializando *hardware*, *software* ou oferecendo serviços de tecnologia dos mais variados tipos.

A ABES tem a satisfação de apresentar este *Manual de contratação de TIC sob a ótica da nova lei de licitações e contratos administrativos*, que reúne aspectos técnicos e jurídicos, oferecendo uma visão prática

sobre como bem planejar a aquisição de soluções TIC. Este documento é especialmente relevante ao considerarmos a escassa produção literária sobre este tema e a importância de aprimorar o procedimento de compras públicas em face da Nova Lei de Licitações.

Esta obra foi produzida pela Líder do GT Compras Públicas, Camila Murta, em colaboração com profissionais de diversas áreas de atuação.

São Paulo, 29 de maio de 2023.

Paulo Milliet Roque

Presidente da ABES

APRESENTAÇÃO

Antes de qualquer coisa, ao saudar a iniciativa de produzirem, organizarem e publicarem um livro que busca discutir e instruir como tornar efetivos benefícios, simplificações e melhorias advindas de uma nova lei ou sistema legal, homenageio os autores e os organizadores certo de que qualquer esforço que impulsione o negócio público a um patamar de maior eficiência, de melhor resultado e de adequação às demandas da sociedade é sempre bem-vindo.

Mas o que significa maior eficiência, melhor resultado e adequação dos negócios públicos?

Penso que seja o desenvolvimento contínuo e assertivo de processos, modelos e práticas que garantam simultânea e sistemicamente a evolução do tripé formado pela (i) *objetividade e foco* nas decisões, (ii) *agilidade e adequação* ao tempo das necessidades e demandas e, por fim, (iii) *governança* traduzida por seus componentes fundamentais: transparência, integridade e prestação de contas.

Quem está acostumado à realização de negócios no ambiente público sabe quão sensível é o equilíbrio entre o controle e a efetividade das ações e decisões.

Quando se preza excessivamente pelos controles – sempre necessários –, criam-se barreiras para a celeridade, inovação e mudanças, tornando as decisões pouco ousadas e transformadoras, excessivamente demoradas e pouco alinhadas às expectativas coletivas da sociedade. Por outro lado, quando a prioridade é excessivamente orientada à agilidade, focos restritos ou a soluções

muito específicas, em condições também específicas, cria-se um enorme risco de que essas mesmas decisões sejam ruins, caras, presas a um contexto muito estreito que atende a interesses de poucos, sem questionar, pelo menos aqui, a honestidade e legitimidade dessas mesmas decisões.

Pois bem, nessas poucas linhas se desenha o desafio que este livro me parece enfrentar: como lidar com um sistema legal novo, cujo espírito é desenvolver simultaneamente os controles e a agilidade dos negócios realizados pelos entes públicos, e como orientar a área de tecnologia, inovação e transformação digital – tão afeita à agilidade, ineditismo e especificidades técnicas – a moldar-se ao novo cenário, promovendo e potencializando suas competências e soluções cada vez mais necessárias à administração e serviços públicos e vigentes por ciclos temporais menores e efetivos no alcance dos resultados almejados.

Por isso, fica claro que o mérito da presente obra não é o de descobrir e mapear as dificuldades e problemas existentes nessa relação comercial entre os compradores públicos e os ofertantes de tecnologia, mas, definitivamente, como orientar e capacitar ambas as partes à melhor e mais efetiva realização de negócios para o novo paradigma do consumo de tecnologia e inovação pelos entes públicos e sua representada, a sociedade. Ressaltando que o ambiente TIC é pouco provido de livros e artigos que tenham o condão de guiar e orientar, em especial, o agente público para a melhor tomada de decisão.

Porém, tenho a firme crença – e aqui tomo a liberdade de expressá-la – de que não são os livros escritos que mudam o mundo, mas os lidos.

Justamente por isso felicito a todos os envolvidos nesta obra, torcendo para que seja lida, relida e eleita como referência de consulta e de formação de novas e ótimas práticas para a realização de negócios de tecnologia e inovação entre empresas e entes

públicos, possibilitando assim a entrega para a sociedade e cada um dos cidadãos de benefícios, facilidades e agilidade tão desejados e comparáveis aos vistos nas relações com as empresas e negócios inovadores da iniciativa privada.

Aos autores, organizadores e apoiadores, meus cumprimentos e felicitações. Aos leitores, boa leitura!

Maurício Pimentel

Presidente do Instituto das Cidades Inteligentes (ICI)

INTRODUÇÃO

1.1 Serviços digitais governamentais e os ressignificados da Nova Lei de Licitações

Jair Eduardo Santana

“A Revolução Científica não foi uma revolução do conhecimento.

Foi, acima de tudo, uma revolução da ignorância.

A grande descoberta que deu início à Revolução Científica foi a descoberta de que os humanos não têm as respostas para suas perguntas mais importantes.”

Yuval Noah Harari, Sapiens

1.1.1 Suprimento de demandas governamentais: essencialidades em torno dos serviços públicos digitais

É surpreendentemente simples e nada inovador o que eu vou registrar adiante para abordar assunto que contrasta tema tópico (sacado de certo marco regulatório) com os serviços (públicos) digitais, perpassando pela tecnologia da informação e da comunicação (TI ou TIC).

Precisamos contextualizar o que chamamos de *demandas* e para isso é importante um resgate histórico ainda que breve.

Noah Harari¹ nos fornece subsídios para resumir a história da humanidade ao lembrar que “três importantes revoluções” definiram o percurso das civilizações: (1) *a Revolução Cognitiva*, há

cerca de 70 mil anos; (2) a *Revolução Agrícola*, por volta de 12 mil anos atrás e (3) a *Revolução Científica*, que começou há apenas 500 anos.

Recuperar tais considerações históricas é vital para compreendermos o ponto em que nos encontramos (na nossa perspectiva), notadamente no Brasil, embora tais registros também sirvam como método observacional para qualquer lugar do planeta para os fenômenos que se encontram sob nossa análise.

E nisso (já circunscrevendo o raciocínio apenas ao Brasil) pontuo que se hoje temos cerca de 213 milhões² de habitantes, em tempo não muito distante a população brasileira era sensivelmente menor: pouco mais de 9 milhões em 1872, período do 1º censo demográfico³ realizado por aqui.

Tais dados (impressionantes sob certo aspecto, especialmente porque consideram apenas cerca de um século e meio) se conectam diretamente com alguns pontos relacionados ao assunto *suprimento de demandas*.

E entender minimamente de suprimentos de demandas é tarefa que não pode desdenhar de nenhum dos seus elementos vitais, principalmente daquele protagonista (ou ator) em função do qual se justifica o desencadeamento de todo um ciclo de afazeres multidisciplinares. Estou me referindo ao *demandante primário*.

De fato, a gestão do ciclo de suprimentos (*Supply Chain Management – SCM*) é um fenômeno multifacetário integrado pelas *demandas*, de um lado, e pelo ato de *suprir*, de outra parte, descabendo aqui aprofundar nas inúmeras teorias⁴ criadas em torno desse instituto. Assim visto o processo de suprimento, pode parecer algo muito simples e ligado tão somente à produção e à logística,⁵ cujos estudos são relativamente recentes no mundo.

Mas, para o ponto que nos importa, basta registrar que a *demanda pode ser considerada um problema ao passo que o suprimento é a solução*. E o ato de *suprir* determinadas *demandas* envolve um extenso ciclo e

uma imensa série de componentes, objetivando ao fim de tudo conectar o mercado (mais especificamente o produto, o bem, o material, o serviço, o artefato, a obra, etc.) ao “consumidor”, que é o detentor da demanda.

Nisso também merece registrar que, no caso dos suprimentos públicos, *a demanda não é propriamente governamental* no sentido de que *não é Poder Público o destinatário final da demanda; mas sim a “comunidade” ao qual ele serve*. É este, em minha catalogação, o que denomino de *demandante primário*.

E, no caso presente, devemos dizer que os destinatários dos suprimentos são os cerca de 213 milhões de *demandantes* anteriormente noticiados.

Dizendo de outro modo: são os *demandantes primários* aqueles que se corporificam como sendo os *destinatários finais dos suprimentos governamentais*.

E, quando se fala de *Governo* (ou *Poder Público*) e de *demandantes* ou *destinatários dos suprimentos governamentais*, aquele só pode ser encarado como um *prestador de serviços públicos*⁶ para estes, assim dizendo de modo bem raso.

Fato é que na atualidade *há demandas comunitárias infinitas advindas de expressivo número de demandantes para serem supridas pelo Poder Público*. E os arranjos organizacionais da Administração Pública perpassam – é óbvio – pela tecnologia da informação.

O que se vê diante de todos nós é, de tal modo, um Poder Público (o Brasil) assentado em território continental, cuja missão precípua é prestar serviços públicos a mais de duas centenas de milhões de habitantes visando ao bem-estar de todos, a exemplo de: saúde, educação, segurança, dentre outros tantos que descabem até tentar enumerar, não se esquecendo de que *serviços públicos largo senso incluem os de natureza judicial, legislativa e até mesmo de controle*.

Simple de ver que a Administração Pública se encontra – nesse amplíssimo contexto – numa espécie de encruzilhada (e não apenas no Brasil), pois fato é que *há demandas infinitas e suprimentos finitos*.

Seja como for, os governos em geral vêm se socorrendo cada vez mais da prestação de serviços pela via digital, valendo-se da tecnologia da informação disponível no mercado. Ou, noutro giro, a tecnologia da informação pode estar materializada em *bens, produtos (materiais diversos ou equipamentos)* ou, ainda, em *serviços* dos mais variados.

A TI pode assumir função tanto instrumental quanto material da prestação de serviços públicos.

Ou seja, fato é que *os governos em geral estão à frente de um desafio recente: prestar seus serviços, valendo-se da tecnologia da informação*.

E isso é tarefa que pouco depende de esforços puramente normativos; mas certamente (registro com ousadia) muito mais de uma disciplina organizacional e planificadora, aspectos raramente encontráveis dentre nós brasileiros.

Assim afirmo porque a *demandada por tecnologia da informação* haverá de ser suprida direta ou indiretamente, consideradas as possibilidades de soluções existentes no mercado ou no próprio Poder Público, fato que pouco importa porque a questão central não é a origem da solução (considerada esta enquanto *suprimento*). O que ganha destaque é – como já foi dito – a disciplina organizacional e planificadora do Poder Público (que figura como *demandante secundário* em nossa catalogação).

Claro que há iniciativas louváveis e esforços consideráveis dispendidos no sentido de melhorar a performance (inter) nacional no quesito *maturidade* da governança eletrônica.⁷ Mas a realidade é que há muito por fazer em termos de *transações efetivas* feitas a título de prestação de serviços públicos, notadamente se considerarmos que a nossa federação (falando novamente do Brasil) é assincrônica e

assimétrica por circunstâncias que refogem da presente análise (simplesmente isso é um fato).

Serviços públicos digitais que se aloquem debaixo da rubrica *informativa* são mais efetivos dentre nós, como é notório. Mas o *gap* reside mesmo naquelas atividades que sejam *transacionais*.

Há uma sensível falta de aderência (percepção pessoal) entre as *demandas governamentais* e as *possibilidades mercadológicas de suprimentos*, no âmbito da tecnologia da informação, circunstância que tributo às deficiências e ineficiências decorrentes dos aspectos normativos (estou me referindo ao marco regulatório para suprir demandas públicas), posto que há tempos insistimos no Brasil em privilegiar os meios em detrimento dos fins.

Por isso é que posso afirmar que a Nova Lei de Licitações, a NLL, precisa ser (pura e simplesmente) ressignificada (abordarei isso logo adiante) no sentido de permitir a aproximação eficiente entre a *demanda* e o *suprimento*.

1.1.2 A Nova Lei de Licitações e os serviços digitais. Demandas instrumentais da tecnologia da informação

Percorrendo (novamente) olhos na História e sem qualquer preocupação científica, identificamos que no ano de 1862 foi editada a primeira norma reguladora dos suprimentos públicos. Isso ocorreu há 161 anos e, na ocasião, a estimativa da nossa população era de pouco mais de 11 milhões de habitantes.⁸ E não podemos nos esquecer de que, na época, “as províncias tinham sérias diferenças de interesses, extensas porções do território permaneciam pouco exploradas e as fronteiras seguiam sendo alvo de disputas”. Além disso, a maior parte da população vivia no campo, era analfabeta e estava fora do sistema político.

Não podemos nos esquecer também da grande população escrava, em torno de 30% do total,⁹ muito embora haja registros de que desde 1850 o Brasil gozasse de “estabilidade interna e prosperidade econômica;¹⁰ e a infraestrutura do país foi sendo desenvolvida com o progresso na construção das estradas de ferro, do telégrafo elétrico de linhas de navios a vapor que uniam o Brasil em uma entidade nacional e coesa”.

Já sob o regime da República, o Decreto-Lei nº 4.536, de 28 de janeiro de 1922, organizando o Código de Contabilidade da União, dedicou espaço para disciplinar os suprimentos públicos e, segundo dados oficiais, os *demandantes* somavam em torno de 30 milhões de habitantes.

Do Código de Contabilidade da União, de 1922, saltamos para o Decreto-Lei nº 200, em 25 de fevereiro de 1967, o qual referenciou (pioneiramente) a expressão “princípios da licitação” (que até então denominamos nós de “suprimentos governamentais ou públicos”) e, na sequência,¹¹ para o Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986.

Uma pausa nessa *evolução normativa* precisa ser feita para registrar que – sob o ponto de vista do crescimento demográfico (o qual implica diretamente a exponencialização das demandas que carecem de suprimentos) – foi em 1970 que chegamos a 90 milhões de habitantes e em pouco mais de meio século chegamos a mais de 200 milhões.

O Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, deu lugar à ainda vigente Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ambas editadas sob a égide da atual Constituição Federal, que contempla o assunto “licitações e contratos administrativos”, como é de todos sabido.

Certamente um conjunto de outras normas deveria ser mencionado (a exemplo da “Lei do Pregão”, da “Lei dos Pequenos Negócios”, da “Lei do Regime Diferenciado”, da “Lei das Estatais”,

sem prejuízo de tantas outras que direta ou indiretamente cuidam de simplesmente “suprir” as demandas governamentais (a exemplo das “concessões”, das “permissões”, etc.).

O que se quer mostrar, nesse breve apanhado, é que em pouco tempo as demandas da sociedade evoluíram e exponencializaram, juntamente com o crescimento populacional, o que soa óbvio.

De modo que a NLL (Nova Lei de Licitações, a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021), com o seu vigor previsto para eclodir em breve, é o marco regulatório principal que objetiva disciplinar *demandas antigas sob novas perspectivas de suprimentos*.

Daí a razão (antes exposta) da necessidade de se ressignificar tais circunstâncias à luz da nova roupagem, considerando (de modo simplista) que *há demandas de mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, por serviços públicos em geral, há ofertas no mercado fornecedor e, nessa tríade, o Poder Público tem o dever de suprir aquelas demandas*.

E diante disso tudo é que a tecnologia da informação (TI) haverá de se converter em *produtos, equipamentos, materiais, bens e serviços dos mais variados* para instrumentalizar direta ou indiretamente o suprimento das demandas que (como vimos) não são primariamente governamentais; mas *demandas comunitárias*.

Os *denominados serviços digitais*, na acepção que ora utilizo, abarcam todo o ferramental tecnológico afeto a objetos entrelaçados com a governança eletrônica, que nada mais é do que simples variante da *governança pública em si*.

Ou seja, a tecnologia da informação está a serviço da execução das políticas públicas e das instituições governamentais que daquela dependem para cumprir as suas finalidades precípuas.

A NLL é expressa ao estabelecer que ela se aplica “a contratações de tecnologia da informação e de comunicação” (art. 2º, inciso VII). Mas apesar da referência expressa ao tema central (“a lei se aplica às contratações de TI”), os “antigos” problemas persistirão caso não haja mudança de postura no tocante à leitura do novo marco regulatório, o qual, no momento, privilegia sobretudo o planejamento da futura aquisição.

Entendemos por “antigos problemas” todos aqueles que se referem especialmente aos indicadores de “tempo”, “qualidade” e “valor”, temas ínsitos ao planejamento dos suprimentos governamentais (veja-se, a respeito: SANTANA, Jair Eduardo. *Planejamento nas licitações e nas contratações governamentais*. Estratégias para suprimentos públicos. Curitiba: Editora Negócios Públicos, 2015).

1.1.3 Resignificados

Para ressignificar as demandas comunitárias em face das possibilidades das ofertas e disponibilidades do mercado, é necessário antes de tudo ter a exata dimensão de um contexto que não é linear ou monocular.

A afirmação, colocada como uma espécie de convite obrigatório, deve contrastar as abissais diferenças existentes (na atualidade) entre as realidades encontradas no Poder Público e no setor privado, quando o assunto é o domínio de ferramentas e de instrumentos afetos à tecnologia da informação.

Um simples ERP (“Enterprise Resource Planning”), por simples exemplo, comum no setor privado, não se transmuda para o setor público sob a forma de um GRP (“Government Resource Planning”) por uma infinidade de motivos, incluindo o antes citado “federalismo assíncrono e assimétrico”. Mas a questão aqui posta é

para simples constatação e provocação a desafios. E o exemplo poderia se multiplicar para mostrar as diferentes distâncias que se colocam entre: (a) o setor privado (enquanto demandante) e um dado suprimento tecnológico e (b) o setor público (enquanto demandante de demandas da comunidade) e esse mesmo dado suprimento tecnológico.

A diferença entre tais distanciamentos é potencializada em grande parte pelo marco regulatório, sem prejuízo de outros fatores que dele decorrem direta ou indiretamente.

Mas um principal desafio (ora proposto) é – uma vez que estejam introjetadas e assimiladas as reais demandas por tecnologia da informação – envidar ações e esforços para adequação aos novos padrões de comportamento e de relacionamento que caracterizam a sociedade atual, viabilizados pela TI ou TIC. Ou seja, a visão simplista, reducionista e monocular em torno da NLL (ou de qualquer outro marco regulatório) de nada servirá a quem quer que seja, como afirmamos há muito tempo,¹² posto que isso torna opaco todo e qualquer olhar que se tenha (ou queira ter) em relação ao suprimento de demandas.

E a partir daí (faz parte do desafio proposto) que os atores (incluindo especificamente os “compradores públicos” e o “mercado fornecedor”) se estruturam adequadamente, com uma visão estratégica bem definida e alinhada aos planos de governo; formulem planos de ações detalhados para os projetos de TIC que serão executados ao longo de determinado período (governamental).

A NLL reforça (como dito) a obrigatoriedade do planejamento, ao mesmo tempo em que impõe a busca por qualidade, segurança, inovação e produção de resultados.

Ao inverso, o que não se quer é o que já anunciamos anteriormente: traduzir o procedimento de aquisição numa formalidade insuperável que chegue ao ponto de transcender as suas

próprias finalidades. Pois, se assim for, a NLL terá o mesmo efeito daquela norma imperial editada há mais de um século e meio. E, de tal modo, restará eternizar a sensação latente de que ainda não vencemos o período da Revolução Cognitiva.

Ressignificar é, de tal modo, uma simples palavra que se mostra pertinente e de densificação obrigatória no contexto atual.

1.2 Contexto legal da contratação de soluções TIC e sua evolução^{13 14}

Tatiana Camarão

Camila Murta

O alcance da missão das organizações públicas está umbilicalmente ligado às contratações públicas, as quais servem de meios indispensáveis para o atendimento das demandas e necessidades da sociedade.

A miríade de políticas públicas colocada para as organizações públicas oferece serviços públicos adequados e de qualidade e envolve um plexo de contratações de fornecimento, compras, obras, serviços terceirizados e serviços de tecnologia da informação e comunicação.

Uma das contratações que teve crescimento expressivo nas últimas décadas é a licitação de serviços de informática e alguns normativos foram editados para orientar e sistematizar o modelo de licitação.

Segundo Leonardo Alamy Martins, “tanto a Organização das Nações Unidas (ONU) quanto a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ressaltam que o uso de tecnologias digitais permite ao setor público responder com agilidade e garantir a continuidade da prestação dos serviços

públicos em momentos de crises, como a que ocorreu em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19), quando a disponibilização de serviços on-line e, sobretudo, a produção, compartilhamento e análise de dados viabilizaram o compartilhamento de conhecimento com a sociedade, a realização de pesquisas colaborativas e a elaboração e monitoramento de políticas públicas específicas para a situação de emergência de saúde pública enfrentada”.

Continua o autor, “um bom desempenho das áreas de TI no setor público pode significar, então, além do sucesso dos próprios órgãos públicos de maneira geral na modernização e transformação digital de seus serviços e relacionamento com toda a sociedade, a garantia de continuidade da prestação dos serviços públicos em momentos de crise”.¹⁵

Cita-se como marco regulatório nas contratações de serviço de informática a publicação da *Instrução Normativa (IN) SLTI/MPOG nº 4, de 19 de maio de 2008*, que disciplinou o processo de contratação de TI para a Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.¹⁶

Esse normativo destacou a importância do alinhamento do planejamento estratégico e o planejamento de TI, estabeleceu as etapas de planejamento, análise de viabilidade da contratação e macroprocesso de contratação, as responsabilidades da área de negócios das contratações de TI, a fixação de indicadores e métricas de resultados. Além disso, reuniu as melhores práticas do mercado (por exemplo: Cobit 4.1¹⁷) e jurisprudências consolidadas do TCU sobre o tema (por exemplo: Acórdão TCU nº 1.603/2008-Plenário).¹⁸

Oportuno asseverar que o TCU, por meio do Acórdão nº 2.471/2008 – Plenário, vem firmar a forma de contratação e o entendimento de que as contratações de bens e serviços de tecnologia da informação considerados comuns, aqueles que, com base em especificações

usuais no mercado, possuem padrões de desempenho e de qualidade objetivamente definidos pelo edital, deveriam ser obrigatoriamente contratados por meio da modalidade Pregão, preferencialmente na forma eletrônica. Quando, eventualmente, não for viável utilizar essa forma, deverá apresentar justificativa.

Nesses termos e escudada na concepção de que os bens e serviços de TI são comuns, a escolha da modalidade e seu critério de julgamento ficaram restritos, na maioria dos casos de contratação dessa categoria de bens e serviços, ao pregão e ao menor preço.

No ano de 2010, foi publicada a IN nº 4, que revisou a Norma de 2008 e condensou um conjunto de boas práticas para a contratação de soluções de TI pela Administração Pública Federal no documento Modelo de Contratação de Soluções de TI – MCTI. Com efeito, foi mantido o entendimento de adotar-se o escrutínio dos bens e serviços de TI por meio do pregão de menor preço.

No mesmo ano, foi editado o *Decreto Federal nº 7.174, de 12 de maio de 2010*, o qual regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação. No seu art. 9º está prevista a adoção dos critérios de julgamento ‘menor preço’ ou ‘técnica e preço’. No entanto, o regulamento prescreve que a aplicação do tipo ‘técnica e preço’ somente poderá ser utilizada para bens e serviços de informática e automação de natureza predominantemente intelectual, que são aqueles nos quais a especificação do objeto evidencia que os bens ou serviços demandados requerem individualização ou inovação tecnológica e possam apresentar diferentes metodologias, tecnologias e níveis de qualidade e desempenho, sendo necessário avaliar as vantagens e desvantagens de cada solução.

Nova regulamentação da contratação de soluções de TI ocorreu em 2014, por meio da IN nº 4. Esse normativo tem a finalidade de reduzir o número de artefatos da fase de Planejamento da Contratação previstos na IN nº 4/2010, transferindo para a etapa do

Termo de Referência a maior parte do detalhamento desse planejamento.

Já em 2019, mais atual e adequada às necessidades e realidade da Administração Pública, foi editada a *IN nº 1/2019*, a qual reitera a importância do alinhamento das contratações da área de negócio de TI com o Planejamento Estratégico e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC. A fase preparatória ganha destaque com a exigência de elaboração do Documento de Oficialização da Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Avaliação de Risco e Termo de Referência/Projeto Básico. A feitura dos documentos relacionados ao estudo da solução e especificação do objeto passou a ser atribuição de uma equipe de planejamento multidisciplinar.

Registra-se, mais uma vez, que a *IN nº 1/2019* manteve o entendimento de prestigiar a adoção da modalidade pregão, inclusive alertando, no art. 25, parágrafo único, que é obrigatória a utilização desse procedimento nas contratações de solução de TIC enquadradas como bem ou serviço comum.

Mais de três anos depois, no final de 2022, foi publicada, pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, a *Instrução Normativa SGE/ME nº 94/2022*.^{[19](#)} Cabe mencionar que foram geradas expectativas de mudanças e melhorias na compreensão desse ambiente de negócios no período que antecedeu a divulgação do normativo, mas poucas novidades foram identificadas.^{[20](#)}

Importa alertar sobre a orientação do governo federal de que o processo de contratação de soluções de TIC, no âmbito do SISP,^{[21](#)} deve ser realizado de acordo com as instruções normativas *IN SGD/ME nº 94/22*, no caso dos processos instruídos à luz da Lei nº 14.133, de 2021, e *IN SGD/ME nº 1/19*, nos processos instruídos à luz da Lei nº 8.666, de 1993.^{[22](#)}

Por fim, sobre o tema, mais um alerta: o ambiente regulatório de TIC é tímido e fica restrito ao governo federal. São poucas as iniciativas dos órgãos e entidades dos estados e municípios.^{[23](#) [24](#)}

1.3 Evolução da contratação de nuvem

Karlos Correa

Em meados de 2000, surge uma nova forma de comercialização de capacidade computacional, a computação em nuvem. Este novo modelo, revolucionário, permitia que qualquer pessoa, a qualquer momento, pudesse ter acesso a recursos computacionais pagando somente pelo uso, ou a conhecida modalidade *on-demand*. Esse modelo foi transformador, principalmente para empresas mais jovens, como *startups*, que não tinham capital inicial para investir na construção ou aluguel de *Data Centers*, e, com a nuvem, os recursos podiam ser alocados e consumidos conforme o ritmo e o crescimento da empresa.

De certa forma, pode-se dizer que a computação em nuvem foi um catalisador para diversas gigantes da tecnologia que hoje operam em mercados de transporte de pessoas, alimentação, hospedagem, *streaming* e outros, pois permitiu que essas empresas direcionassem seus investimentos iniciais no negócio, sem ter que imobilizar e depreciar seu capital em equipamentos e infraestruturas de *Data Center* convencionais.

Hoje os mais diversos segmentos fazem uso de computação em nuvem, inclusive o setor público em diversos países, que passam a adotar em escala cada vez maior, buscando acelerar as transformações dos serviços prestados aos cidadãos. Há também uma pressão crescente nas instituições públicas para acompanhar a evolução das tecnologias emergentes no mercado, com um desejo latente de entregas mais ágeis para os cidadãos. Nessa linha, a

nuvem traz vários diferenciais quando olhamos o ritmo de evolução das tecnologias hoje em uso, pois os provedores acabam assumindo a responsabilidade de construir novos serviços para acompanhar a demanda dos clientes por novas tecnologias. Isso elimina uma boa parte dos esforços e custos de implementação e acelera a adoção de novas plataformas ao longo do tempo dentro das instituições. Para se ter uma ideia, um único provedor de nuvem pode oferecer mais de 200 opções de serviços, indo do mais básico, focado em infraestrutura de computação, até serviços de Inteligência Artificial, IoT e Analíticos.

O Reino Unido e a transformação digital – Um exemplo de uso efetivo no serviço público é o Reino Unido, que desde 2012 implementou um *framework* chamado de G-Cloud²⁵ para facilitar o acesso das instituições governamentais a serviços da nuvem. O G-Cloud opera como uma loja virtual, com acesso a diversos serviços de diferentes provedores de nuvem, eliminando a necessidade de cada instituição executar um processo de contratação distinto. O modelo adotado no Reino Unido ainda permite a contratação de serviços consultivos especializados, com foco na redução da curva de adoção das tecnologias em nuvem.

Esse modelo adotado em larga escala no Reino Unido não tem foco somente na redução de custos, mas também no aumento da eficiência operacional. O uso de nuvem permite que as instituições deixem de focar na gestão de suas infraestruturas e olhem com mais atenção o cidadão e suas necessidades, acelerando dessa forma iniciativas de digitalização dos serviços públicos e por consequência aumentando a sua eficiência.

Outro marco importante no Reino Unido foi a publicação da estratégia digital do Ministério da Defesa em maio de 2021, em que um dos pilares de tecnologia para suportar o plano é o uso de nuvem, focando nas capacidades de entrega de novos e disruptivos

serviços com a velocidade esperada para serem bem-sucedidos nas iniciativas. Na ótica dos dados, o Ministério da Defesa reconhece em seu documento a complexidade da manutenção da estratégia de dados atual baseada em silos, que dificultam o acesso e a integração, e por consequência extraíndo pouco valor destes. Esse reconhecimento serve como alicerce para adotarem modelos e estratégias mais alinhadas com as práticas de mercado, com o uso de novas tecnologias (em nuvem) e plataformas para capacitar os departamentos de defesa a extraírem maior valor dos dados. É importante ressaltar que nessa equação os times de segurança têm um papel fundacional nesta jornada, estabelecendo todos os controles necessários para garantir o acesso seguro, sigiloso e íntegro dos dados.

¹ HARARI, Yuval Noah. *Sapiens – Uma breve história da humanidade*. 11. ed. Porto Alegre: RS: L&PM, 2016.

² Fonte: IBGE. Referência 2021.

³ *Brasil: 500 anos de povoamento*. Centro de Documentação e Disseminação de Informações, Rio de Janeiro 2007. IBGE, 2007.

⁴ Há farta literatura a respeito do assunto merecendo citar, dentre outras: MENTZER, DEWITT, KEEBLER, MIN, NIX, SMITH AND ZACHARIA. *Defining supply chain management*. JOURNAL OF BUSINESS LOGISTICS, Vol. 22, n. 2, 2001; CHOPRA, Sunil, and Peter Meindl. *Supply Chain Management: strategy, planning, and operation*. Upper Saddle River, N.J.: Pearson, 2012.

⁵ COOPER, Martha C., DOUGLAS M. Lambert, and Janus D. Pagh (1997), “*Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics*,” The International Journal of Logistics Management, vol. 8, n. 1, p. 1-14. É claro que tal análise implica outro tipo e patamar diverso de coordenação entre as partes envolvidas; implica também os procedimentos, nos fornecimentos em si e nos resultados que – monitorados ou não (é dado que no momento não importa) – são específicos do setor público. O nível estratégico de considerações feitas pelo setor governamental, a propósito das suas demandas, deve levar em conta uma série de planos e programas existentes. Veja a respeito: OGC – Office of Government Commerce. *Supply chain management in public sector procurement: a guide*. London, june 2006.

⁶ Não é tarefa das mais fáceis definir *serviço público*, não somente em razão de que sua noção é dinâmica, transformando-se continuamente ao longo dos tempos, mas também porque o seu domínio é dos mais incertos. A expressão aqui utilizada considera tanto o *elemento orgânico* quanto a *acepção material* para revelar que o *serviço público é uma tarefa, uma atividade e até mesmo uma função destinada a satisfazer as necessidades de interesse geral*.

- ⁷ Vide para entendimento preliminar o GMTI (GovTech Maturity Index) do Banco Mundial: <https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2022/10/21/govtech-maturity-index-gtmi-data-dashboard>.
- ⁸ *Brasil: 500 anos de povoamento*. Centro de Documentação e Disseminação de Informações, Rio de Janeiro. IBGE, 2007.
- ⁹ FREITAS NETO, José Alves de. *História geral e do Brasil*. 3. ed. São Paulo: Harbra, 2016.
- ¹⁰ BARMAN, Roderick J. *Citizen Emperor: Pedro II and the Making of Brazil, 1825-1891* (em inglês). Stanford: Stanford University Press, 1999. ISBN 978-0-8047-3510-0.
- ¹¹ A Lei nº 5.456, de 20 de junho de 1968, não precisa ser referenciada neste instante.
- ¹² SANTANA, Jair Eduardo. Pensamentos linearcartesiano, sistêmico e complexo aplicados à governança pública: as aquisições governamentais. XVII Congresso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct. – 2 Nov. 2012.
- ¹³ Esse texto tomou como base o trabalho disponível em: <https://lpericias.com.br/quais-os-impactos-decorrentes-da-nova-lei-licitacoes-sobre-as-contratacoes-de-ti/>.
- ¹⁴ São vários os normativos que interagem com os regulamentos de TIC. Cita-se, a propósito: Decreto nº 9.507/2018; Decreto nºs 8.638/2016 e 10.332/2020; Decreto nº 8.936/2016; IN SEGES/MP nº 5/2017; Portaria STI/MP nº 46/2016; Portaria GM/MP nº 443/2018; Portaria SGD/ME nº 778/2019; Portaria SGD/ME nº 6.432/2021; Portaria SGD/MGI nº 750/2023; Portaria SGD/MGI nº 370/2023.
- ¹⁵ MARTINS, Leonardo Alamy. *Terceirização de tecnologia da informação no setor público: a influência do nível de terceirização sobre o desempenho das organizações públicas brasileiras*. 2022.
- ¹⁶ A Instrução Normativa nº 4/18 foi atualizada em 2010.
- ¹⁷ O Cobit, por sua vez, é um modelo de gestão orientado a processos e está dividido em quatro grandes grupos: Planejar e Organizar (Plan & Organise – PO), Adquirir e Implementar (Acquire & Implement – AI), Entregar e Assistir (Deliver & Support – DS) e Monitorar e Avaliar (Monitor & Evaluate – ME). O Cobit se encontra disponível no site www.isaca.org. ACÓRDÃO TCU 1603/2008 – PLENÁRIO.
- ¹⁸ Registro realizado por Diego Lopes no artigo intitulado “Quais os impactos decorrentes da Nova Lei Licitações e Contratos sobre as contratações de TI”, disponível em: <https://lpericias.com.br/quais-os-impactos-decorrentes-da-nova-lei-licitacoes-sobre-as-contratacoes-de-ti/>.
- ¹⁹ Disponível em: <https://lpericias.com.br/quais-os-impactos-decorrentes-da-nova-lei-licitacoes-sobre-as-contratacoes-de-ti/>.
- ²⁰ Em 2023 foi publicada a Instrução Normativa SGD/MGI nº 6, de 29 de março de 2023, a qual regulamenta os requisitos e procedimentos para aprovação de contratações ou de formação de atas de registro de preços, a serem efetuados por órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISF do Poder Executivo federal, relativos a bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação – TIC.
- ²¹ O Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisf) foi instituído pelo Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, com o objetivo de organizar a operação, controle, supervisão e coordenação dos recursos de tecnologia da informação da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal.
- ²² Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes>.

23 Podemos citar, a propósito, a Resolução nº 468/2022 do Conselho Nacional de Justiça, a qual dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Esse regulamento teve suas bases nos normativos federais.

24 A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão publicou o Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação com o propósito de servir como um produto do processo de revisão da Instrução Normativa nº 4, de 12 de novembro de 2010.

25 Disponível em: <https://www.gov.uk/guidance/g-cloud-suppliers-guide>.

DEFINIÇÕES E DENOMINAÇÕES DE SERVIÇOS

2.1 O que são serviços de TIC?

Camila Murta

Camila Lousada

Antes de adentrar na contratação de serviços TIC, é importante esclarecer o que são os serviços TIC.

Serviços de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) são todas as tecnologias da informação e comunicação relacionadas a *hardware*, *software* e telecomunicações que impactam a produtividade, comunicação e sucesso corporativo.²⁶

Um serviço de TI é um meio de possibilitar a cocriação de valor entre o departamento de TI, seus clientes e a organização como um todo. Esse conceito é proposto pelo ITIL (Information Technology Infrastructure Library), um dos mais reconhecidos *frameworks* sobre gerenciamento de serviços de TI do mundo. Esse *framework* estabelece um conjunto de boas práticas que devem ser adaptadas ao contexto e à maturidade de cada empresa.

Vale lembrar que serviços de TIC têm um papel vital na rotina diária das empresas. Independentemente do tipo, tudo o que se refere à TI é crítico para o sucesso de qualquer empresa, cada vez mais dependente desses recursos.

Em virtude da enorme gama de produtos e serviços de TIC oferecidos no mercado atualmente, seguem as definições do inciso VII do art. 2º Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, de acordo com as alterações trazidas pela *Instrução Normativa SGD/ME nº 47, de 9 de junho de 2022*, sendo os bens e/ou serviços aqueles que se adequam à definição de pelo menos uma das categorias a seguir:

1. Materiais e equipamentos de TIC
2. Desenvolvimento e sustentação de sistemas
3. Hospedagem de sistemas
4. Suporte e atendimento a usuário de TIC
5. Infraestrutura de TIC
6. Comunicação de dados
7. *Software* e aplicativos
8. Consultoria em TIC
9. Computação em nuvem
10. Internet das Coisas – IoT
11. Segurança da informação e privacidade
12. Análise de dados, aprendizado de máquina e inteligência artificial

Passa-se a dissertar sobre as soluções mais comumente contratadas pela Administração Pública.

2.2 Dos serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação

Camila Murta

Os *serviços de desenvolvimento e manutenção de software* correspondem ao conjunto de atividades executadas com a finalidade de atender às necessidades do ente público por meio da implementação de um novo *software*, de uma nova funcionalidade ou manutenção de funcionalidades já existentes, em conformidade com o processo de desenvolvimento de *software* por ele estabelecido e aplicados os procedimentos necessários à garantia da qualidade do *software*.

Já o serviço de sustentação de *software* corresponde ao conjunto de atividades necessárias para manter a disponibilidade, estabilidade e desempenho do *software*, do *hardware* e/ou da rede, dentro dos níveis de serviço estabelecidos pelo ente público.

Ou seja, é o suporte a toda a infraestrutura dos sistemas de TI, nos seguintes níveis:

- *Softwares*: bots, sites, ERPs, CRMs e aplicativos;
- *Hardwares*: *Data Centers*, servidores, computadores e equipamentos eletrônicos;
- *Redes*: internet, segurança da informação e componentes de rede.

Dentre as principais atividades da sustentação destaca-se:

- Recepcionar e registrar todos os chamados de suporte (via telefone, e-mail, chat etc.);
- Investigar e diagnosticar incidentes;
- Solucionar todos os incidentes;
- Encerrar chamados de suporte e solicitações dos usuários;
- Acompanhar todo o ciclo de vida do incidente: da abertura até o encerramento, controlando os SLAs;
- Identificar e registrar *workarounds*;
- Aprovar ou rejeitar a correção;

- Manter atualizada a base de conhecimento com as soluções;
- Monitorar a satisfação dos usuários em relação aos atendimentos.

A sustentação em TI, na prática, funciona através de chamados de suporte e se divide em 3 níveis de complexidade: i) nível 1: chamados simples e repetitivos, que constam na base de conhecimento; ii) nível 2: problema é analisado de forma mais aprofundada e geralmente acarreta uma melhoria no sistema; e iii) nível 3: a demanda é mais complexa e requer maior conhecimento técnico.

A *sustentação de sistemas* consiste na gestão corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas de TI utilizados diariamente na Administração Pública e é relevante, pois tem o objetivo de evitar prejuízos, erros, perda de dados e paralização dos sistemas, o que afetaria os serviços públicos.

Esses serviços são prestados através de SLA (Acordo de Nível de Serviço), que é o tempo definido para a empresa contratada atender aos chamados de dúvidas ou incidentes e solucioná-los.

Os serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação são considerados soluções de TIC e devem se orientar pelos dispositivos constantes da *Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022*, bem como pelas demais diretrizes constantes neste documento.

Segundo a *PORTARIA SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023*, que estabelece modelo para a contratação de serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP do Poder Executivo Federal, resta definido o que se segue:

Art. 3º Os serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação são considerados serviços de natureza comum, dada a existência de padrões de mercado e diversos frameworks de desenvolvimento de *software*, que permitem a fixação de padrões de qualidade e de desempenho para o referido serviço.

Art. 4º A contratação de serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação de *software* deve se pautar, preferencialmente, pela adoção de metodologias de desenvolvimento ágil.

Art. 5º O modelo de contratação de serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação de *software* admite, em uma mesma contratação ou em diferentes contratações, a adoção de uma ou mais modalidades padronizadas de remuneração, entre as descritas a seguir:

I – para serviços de desenvolvimento e/ou manutenção, o Pagamento aferido por Pontos de Função e complementado por Horas de Serviço Técnico, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço;

II – para serviços de desenvolvimento e/ou manutenção, o Pagamento de valor fixo por sprint executada, vinculado a níveis mínimos de serviço;

III – para serviços de desenvolvimento e/ou manutenção e/ou sustentação, o Pagamento por alocação de profissionais de TI, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço;

IV – para serviços de sustentação, o Pagamento de valor fixo mensal por portfólio de *softwares*, vinculado ao atendimento de níveis mínimos de serviço.

Observa-se que o Modelo de Contratação de Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Sustentação foi elaborado com vistas a atender recomendação constante do Acórdão nº 1.508/2020-TCU-Plenário,²⁷ normatizando a contratação dos serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação de *software*, em especial quanto às formas de remuneração e a necessidade de vinculação ao alcance de resultados e estabelecimento de níveis mínimos de serviços, além de outras medidas necessárias à adequada gestão e monitoramento dos contratos.²⁸

O citado acórdão do TCU recomenda que os serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação são considerados serviços de natureza comum, dada a existência de padrões de mercado e diversos *frameworks* de desenvolvimento de *software*, que permitem a fixação de padrões de qualidade e de desempenho para o referido serviço, e que a contratação de serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação de *software* deve se

pautar, preferencialmente, pela adoção de metodologias de desenvolvimento ágil.

O modelo de contratação de serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação admite, em uma mesma contratação ou em diferentes contratações, a adoção de uma ou mais *modalidades padronizadas de remuneração*, entre as descritas a seguir:

I – para serviços de desenvolvimento e/ou manutenção, o pagamento aferido por *Pontos de Função*²⁹ e complementado por *Horas de Serviço Técnico*, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço;

II – para serviços de desenvolvimento e/ou manutenção, o pagamento de valor fixo por *sprint executada*, vinculado a níveis mínimos de serviço;

III – para serviços de desenvolvimento e/ou manutenção e/ou sustentação, o pagamento por *alocação de profissionais de TI*, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço;

IV – para serviços de sustentação, o pagamento de valor fixo mensal por *portfólio de softwares*, vinculado ao atendimento de níveis mínimos de serviço.

Referidas previsões estão reunidas no site do Governo Digital – www.gov.br –, o qual traz o Modelo para a Contratação de Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Sustentação de *Software* no âmbito do SISP e apresenta os documentos relacionados, relevantes para o estudo e entendimento do planejamento desse tipo de contratação no âmbito federal:

Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023 – Estabelece modelo para a contratação de serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação de *software*, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP do Poder Executivo Federal (Portaria instruída à luz da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, regida pela Lei nº 14.133, 1º de abril de 2021).

Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023 – Estabelece modelo para a contratação de serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação de *software*, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP do Poder Executivo Federal (Portaria instruída à luz da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, regida pela Lei nº 14.133, 1º de abril de 2021).

Nota Metodológica do Modelo (Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023) – Demonstração dos procedimentos e métodos adotados na realização de pesquisa de preços para obtenção de mapa de pesquisa salarial e do fator-k limite a serem adotados na estimativa do valor mensal de contratos que utilizam o Modelo para a Contratação de Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Sustentação de *Software* instituído pela SGD.

Mapa de Pesquisa Salarial e Fator-K do Modelo (Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023) – Planilha auxiliar da Nota Metodológica – Mapa Salarial e Fator K.

Modelo de planilha de custos e formação de preços (Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023) – Planilha auxiliar do Anexo VI em formato de um arquivo de planilha Excel.xlsx.

Modelo de planilha de custos e formação de preços (Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023) – Planilha auxiliar do Anexo VI em formato de um arquivo de planilha OpenDocument.ods.

A prestação dos serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação de *software* deve observar, no que couber, os padrões e normas aplicáveis à engenharia de *software*, a exemplo de: ABNT NBR ISO/IEC-IEEE 12.207/2021 (Processos de ciclo de vida de

software), ISO/IEC-IEEE 14.764/2006 (Processo de manutenção de *software*) e ISO/IEC-IEEE 25.010/2017 (Qualidade de *Software*).

2.3 Terceirização de serviços TIC

Camila Murta

Segundo o TCU, em seu documento *Guidelines for ICT outsourcing*,³⁰ a Terceirização de TIC significa a contratação de provedores externos de serviço para realização de determinados processos ou funções de TIC. Como regra, a terceirização de TIC implica a aquisição de serviços mediante pagamento, ficando a cargo da contratante a supervisão dos serviços realizados.

O Decreto nº 9.507/2018 regulamenta a execução indireta de serviços da Administração Pública Federal, que por sua vez estão listados pela Portaria nº 443/2018, constando no inciso XXIII os serviços de tecnologia da informação e prestação de serviços de informação.

O aludido decreto ressalva que não são objeto de execução indireta na Administração Pública Federal os serviços que: i) envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle; ii) que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias; iii) que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; e iv) que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.

Considerando as ressalvas legais que recaem sumariamente nas atividades de gestão e finalísticas e/ou inerentes aos servidores, a

terceirização de TIC tem sido amplamente adotada com o objetivo de trazer maior eficiência ao serviço público, permitindo que a Administração possa dar mais ênfase às suas atividades-fim.

O Governo Federal, visando assegurar a coordenação e a governança de suas ações de TIC, mantém o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), composto pelas áreas de TIC (secretarias ou coordenações) das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. O SISP³¹ atua como estrutura de gestão estratégica de TIC, a ele competindo ações relativas à racionalização, padronização, integração, interoperabilidade, normalização, formação profissional, etc.; todas relativas aos recursos de TIC do Executivo Federal.

Os serviços terceirizados trazem como principais *vantagens*:

1. Redução de custos operacionais
2. Aumento da produtividade
3. Otimização de tempo
4. Acesso a novas tecnologias
5. Segurança de dados
6. Processos padronizados

A terceirização é, pois, uma ferramenta de gestão, materializada por meio de contrato, que possibilita a redução de custos e especialização na prestação dos serviços ou fornecimento de bens, além de permitir que o contratante se concentre em suas atividades principais, tornando-se mais eficiente.

O processo de terceirização de TI é uma prática comum, tanto na administração privada quanto na pública. Em ambas, ela é adotada

por variados motivos, que passam por aspectos econômicos, estratégico-organizacionais e políticos. Porém, no setor público, uma característica estratégico-organizacional que se destaca, sendo inclusive fator de diferenciação em relação à iniciativa privada, é a dificuldade de contratação de profissionais qualificados, socorrendo-se da terceirização como forma de acessar mão de obra especializada do mercado privado.

Importante destacar que diante do processo de transformação digital vivenciado nos últimos anos na Administração Pública, as unidades de tecnologia da informação dos entes públicos tem papel fundamental, uma vez que, a tecnologia e seu uso efetivo são os principais habilitadores da modernização dos governos e essenciais para o governo digital.

2.4 Serviços em nuvem

Camila Murta

A evolução e a redução de preços na área de tecnologia da informação (TI) nos últimos anos permitiram a exploração de um novo modelo de acesso a recursos computacionais compartilhados e de alta disponibilidade e acessibilidade: a computação em nuvem (*cloud computing*).

Segundo o National Institute of Standards and Technology (NIST) dos Estados Unidos, computação em nuvem é um modelo que permite acesso universal e sob demanda, por intermédio da rede, a um conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis (por exemplo: redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços), que podem ser rapidamente provisionados e disponibilizados com o mínimo de esforço de gerenciamento ou de interação com o provedor de serviços de TI.

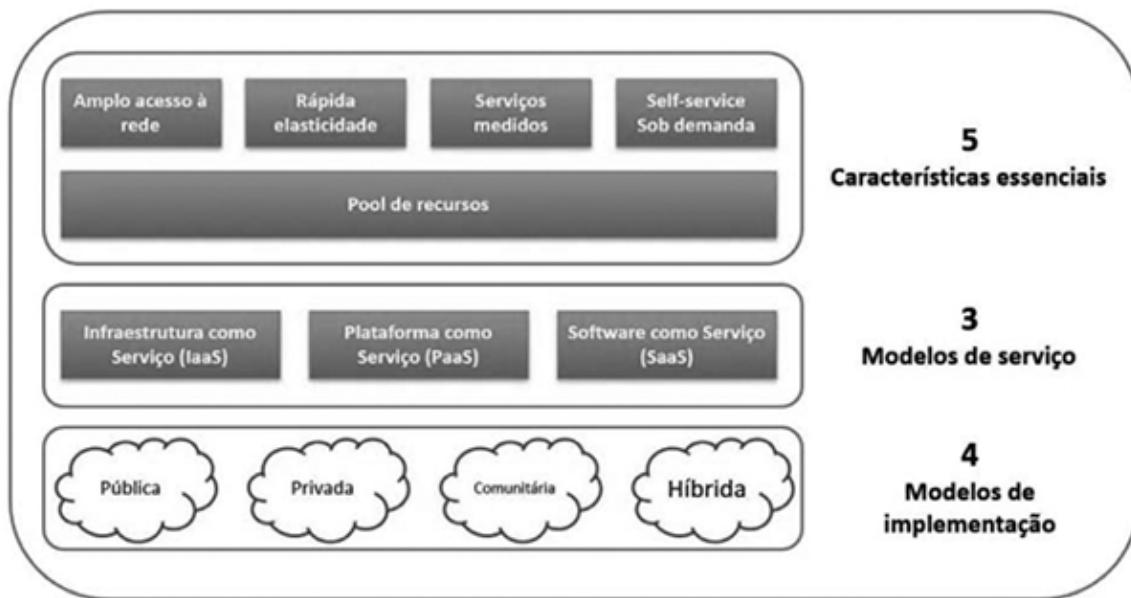
Ou ainda tem-se que: “A computação em nuvem é um modelo para habilitar o acesso por rede ubíquo, conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação (como redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que possam ser rapidamente provisionados e liberados com o mínimo de esforço de gerenciamento ou interação com o provedor de serviços”.³²

O Governo Digital define computação em nuvem como:

Ambiente que permite oferecer recursos e realizar serviços de qualquer lugar e a qualquer momento, de maneira facilitada, com acesso à internet a recursos computacionais (ex.: redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços), de forma rápida e sem esforços em conjunto a um fornecedor de serviços.³³

O modelo traz benefícios como: *maior disponibilidade, flexibilidade da oferta do serviço em função de variações na demanda, menor dependência de pessoal qualificado, possível redução de vários riscos de segurança, pagamento por uso efetivo de recursos e potencial redução de custos*. Esse novo modelo permite, assim, que o foco das organizações usuárias seja em suas funções essenciais.

Modelo NIST para computação em nuvem



2.4.1 Características essenciais

Karlos Correa

O aspecto econômico da nuvem está ancorado a alguns pilares, elasticidade, escalabilidade, agilidade e pagamento por uso. Para entender efetivamente os ganhos e benefícios desse modelo, é preciso ver a nuvem como uma plataforma de serviços e não simplesmente como um *Data Center*. O grande diferencial está justamente nas automações que os provedores de nuvem lhe proporcionam, isso garante que o usuário consiga extrair todo o potencial tecnológico e econômico para a sua carga de trabalho.

2.4.1.1 Modalidades de pagamento

Os provedores possuem ao menos dois modelos de pagamento, o primeiro, baseado no consumo ou *on-demand*, e o segundo, baseado no compromisso ou reserva antecipada de recursos.

O primeiro modelo é mais comum, é perfeito para cargas de trabalho com comportamento dinâmico e imprevisível, que oscilam bastante entre uso e ociosidade. Dessa forma, com as automações da plataforma de nuvem, é possível ajustar a capacidade a todo momento para pagar exatamente pelo que está sendo consumido. Já no segundo modelo, através de reservas de capacidade, você já especifica exatamente o que precisa e assume um compromisso de 1 a 3 anos para o uso desses recursos, assim esse custo passa a ser fixo e não mais variável. O modelo de reserva se encaixa em cargas de trabalho com comportamento mais estático e previsível, dessa forma é possível realizar projeções de uso a médio e longo prazo.

Agora, qual é a diferença do ponto de vista financeiro? O modelo *on-demand* sempre será mais caro que a reserva sob a métrica de custo, pois não existe compromisso com o provedor e o ente público pode devolver os recursos a qualquer momento e deixar de pagar por eles. Já no modelo de reserva o ente público assume um compromisso por um prazo determinado e dessa forma o provedor aplica descontos de acordo com o período contratado e o tipo de reserva.

Vale lembrar que é preciso avaliar o comportamento da aplicação e simular qual modelo seria o mais adequado do ponto de vista econômico, pois a equação pode pender para qualquer lado de acordo com a forma que a aplicação se comporta no dia a dia.

Veja os exemplos a seguir em simulação de custos entre o modelo de pagamento baseado no consumo e *on-demand*. O objetivo aqui é demonstrar que o correto entendimento da carga de trabalho versus os modelos de pagamento ofertados pelo provedor ajuda a extrair o máximo das vantagens econômicas das plataformas de nuvem.

Caso 1: aplicação com utilização durante 8h por dia,

permanecendo ociosa no restante do dia.

Premissas: Custo on-demand por hora; 0,05 centavos de dólar

Custo reservado por hora (1 ano): 0,03 centavos de dólar

Horas no mês: 730

- Custo na modalidade on-demand, desligando o recurso nos momentos de ociosidade:

$30 \text{ dias} \times 8\text{h} = 240\text{h}$ por mês

Custo mensal = $240\text{h} \times 0,05$ centavos de dólar = **12 dólares**

- Custo na modalidade de reserva, operando 730h por mês:

Custo mensal = $730\text{h} \times 0,03$ centavos por dólar = **22 dólares**

Este caso mostra que mesmo com um desconto de 40% na modalidade de reserva, dada a característica da aplicação de operar por apenas 8h no dia, a modalidade on-demand se mostra mais econômica.

Caso 2: aplicação possui uma carga mais constante durante 20h no dia, com apenas 2h de ociosidade.

- Custo na modalidade on-demand, desligando o recurso nos momentos de ociosidade:

$30 \text{ dias} \times 20\text{h} = 600\text{h}$ por mês

Custo mensal = $600\text{h} \times 0,05$ centavos de dólar = **30 dólares**

- Custo na modalidade de reserva, operando 730h por mês:

Custo mensal = $730\text{h} \times 0,03$ centavos de dólar = **22 dólares**

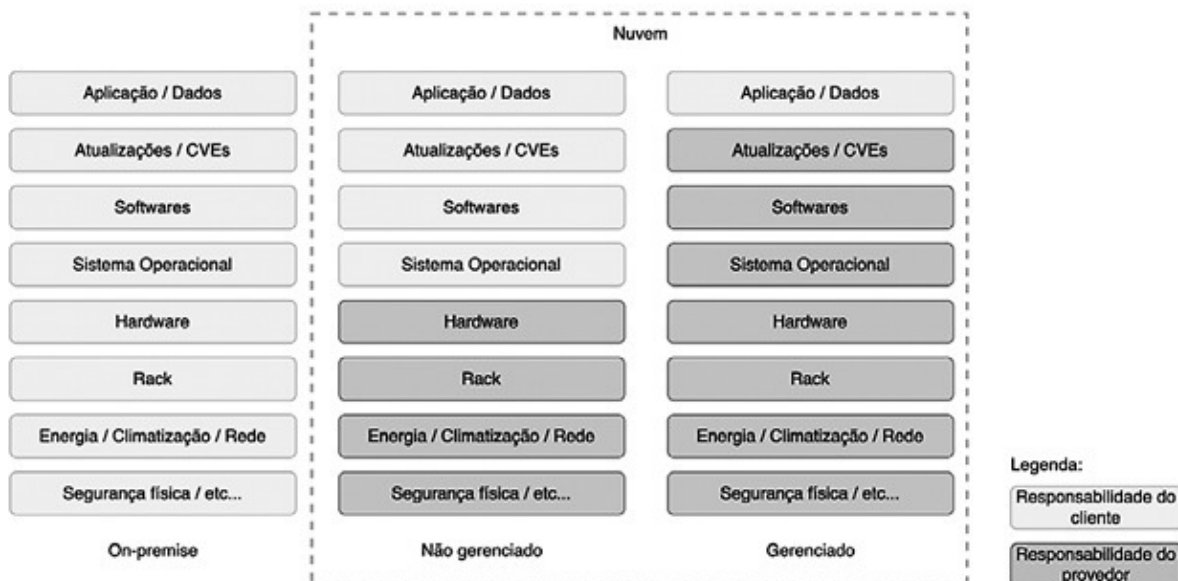
Neste segundo caso já se justifica o uso de reserva, dado que a aplicação possui um comportamento mais constante, com apenas 4h de ociosidade durante as 24h do dia, dessa forma o desconto de 40% traz um benefício econômico imediato e justifica que se assuma um compromisso com o provedor de nuvem.

2.4.1.2 Modalidades de uso

A variedade de serviços contempla também as modalidades de uso, sendo elas *não gerenciadas e gerenciadas*. A modalidade não gerenciada mantém a responsabilidade de operação e manutenção dos recursos a cargo do cliente, sendo que somente a camada mais baixa de infraestrutura é gerida pelo provedor. Já na modalidade gerenciada, grande parte da responsabilidade de sustentação do serviço cabe ao provedor de nuvem, ficando a cargo do cliente apenas a manutenção da aplicação/camada de negócio e dados por assim dizer.

A imagem a seguir reproduz um exemplo de como são divididas as responsabilidades quando da escolha do modelo de uso gerenciado e não gerenciado, fazendo também um paralelo com o modelo tradicional *on-premises*. Vale salientar que mesmo no modelo não gerenciado, no que tange ao físico para baixo já assumido pelo provedor, se obtém de imediato um ganho operacional ao movimentar cargas de trabalho para a nuvem.

Modelo de responsabilidade versus a modalidade de uso



É importante observar que o uso de serviços gerenciados retira um peso substancial dos times de operação e permite que o cliente direcione esse pessoal para atividades mais nobres, apoiando dessa forma as iniciativas de negócio, o que resulta na aceleração das entregas. No aspecto econômico, o uso de serviços gerenciados permite que os clientes reduzam os contratos focados em sustentação de plataformas e direcionem esses recursos para projetos/aplicações que necessitem de maior investimento.

2.4.1.3 Computação sem servidor

Ainda olhando na ótica de serviços gerenciados, existe outro conceito que eleva o nível de abstração na entrega dos serviços na nuvem, este conhecido pelo termo “*serverless*” ou computação sem servidor.

Esse modelo de entrega tem como principal característica o pagamento por execução e não mais por alocação de recursos. Não existe mais a necessidade de criar mecanismos para escalar recursos, pois por definição ele se ajusta dinamicamente à necessidade do cliente, que só paga pelo que foi consumido durante a execução. Esse conceito é bastante amplo e aplicado em diferentes tipos de serviços, como bancos de dados relacionais, *no-sql*, *data warehouse*, *big data*, funções, mensageria, armazenamento e outros.

Para materializar o conceito, cita-se como exemplo o modelo tradicional para a disponibilização de um banco de dados relacional. Primeiro é preciso entender a necessidade e mapear a capacidade necessária para o projeto, dessa forma será possível determinar a configuração do cluster³⁴ que será criado para sustentar o projeto. As principais variáveis de infraestrutura nessa análise são a quantidade de CPUs, memória, armazenamento (*Throughput* e *IOPS*) e quantidade de nós no *cluster*.

Tudo isso irá definir recursos que serão alocados na montagem do ambiente, dessa forma o cliente pagará sempre que tais recursos estiverem no ar (em execução), estando eles em uso ou não. Já no caso de serviços *serverless*, o provedor fornece uma única métrica de computação que normalmente define o limite de escala para a carga de trabalho, assim o cliente não precisa se preocupar com as variáveis mencionadas, basta executar a sua carga que o serviço ajustará a capacidade dinamicamente com base na sua necessidade. Neste caso o custo é diretamente proporcional aos recursos usados no momento da execução, não havendo despesa com capacidade ociosa.

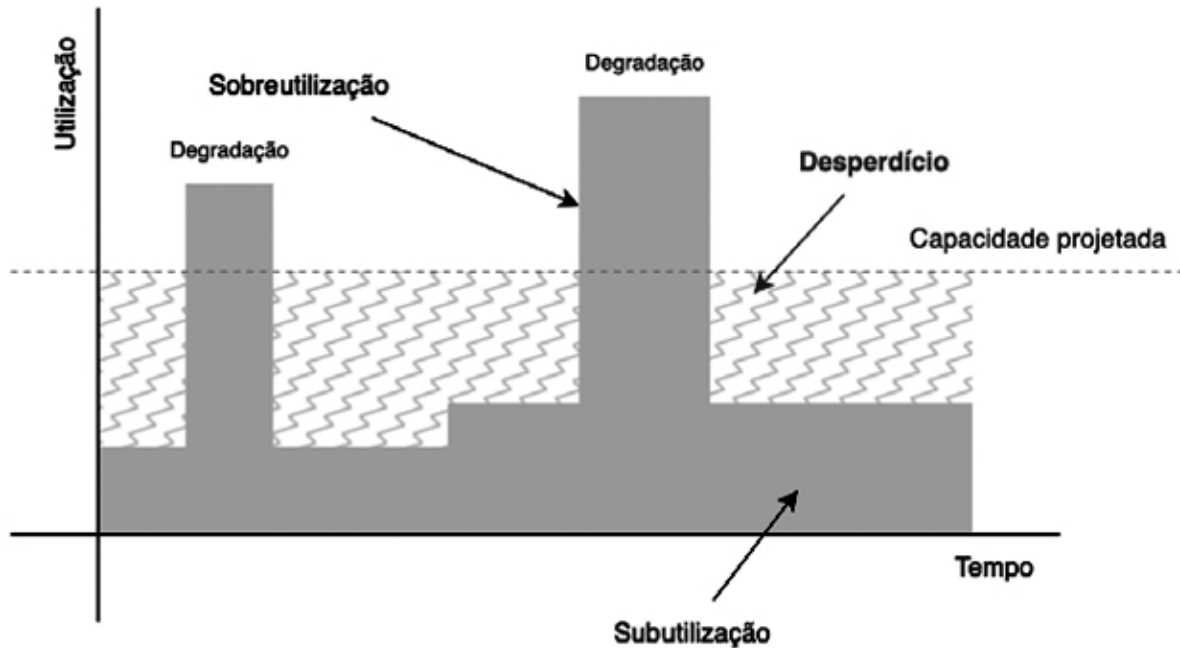
Salienta-se que, no que tange ao armazenamento, o custo da persistência dos dados permanece da mesma forma, o que muda efetivamente é que os serviços escalam a capacidade de *throughput* e IOPS dinamicamente.

2.4.1.4 Elasticidade

A elasticidade por definição é a capacidade de aumentar e reduzir os recursos de forma dinâmica conforme a demanda.

Considerando um *Data Center* convencional, as cargas de trabalho são normalmente dimensionadas pelo pico de uso, desse modo as aquisições são realizadas antecipando o pior cenário de uso. Esse modelo não é racional do ponto de vista de custo, pois fora do pico os recursos adquiridos estarão ociosos e dificilmente serão aproveitados ao máximo até atingir a sua obsolescência. Muitas vezes ainda ocorrem degradações em função de picos não projetados de uso, tornando ruim a experiência do cliente/cidadão ao utilizar os serviços nesses momentos.

Curva de consumo de uma carga de trabalho tradicional



Na imagem anterior observa-se o cenário em que uma carga de trabalho tradicional apresenta picos com degradação de performance ao longo do tempo e um período substancial com ociosidade de recursos. De acordo com o conceito da elasticidade que a nuvem oferece, a carga de trabalho não precisa ser dimensionada pelo pico e sim pela demanda efetiva, pois com as automações fornecidas pelo provedor, é possível aumentar e reduzir a quantidade de recursos dinamicamente, o que permite que a carga de trabalho não opere com capacidade ociosa, ou com restrição de recursos, reduzindo dessa forma o custo total de operação.

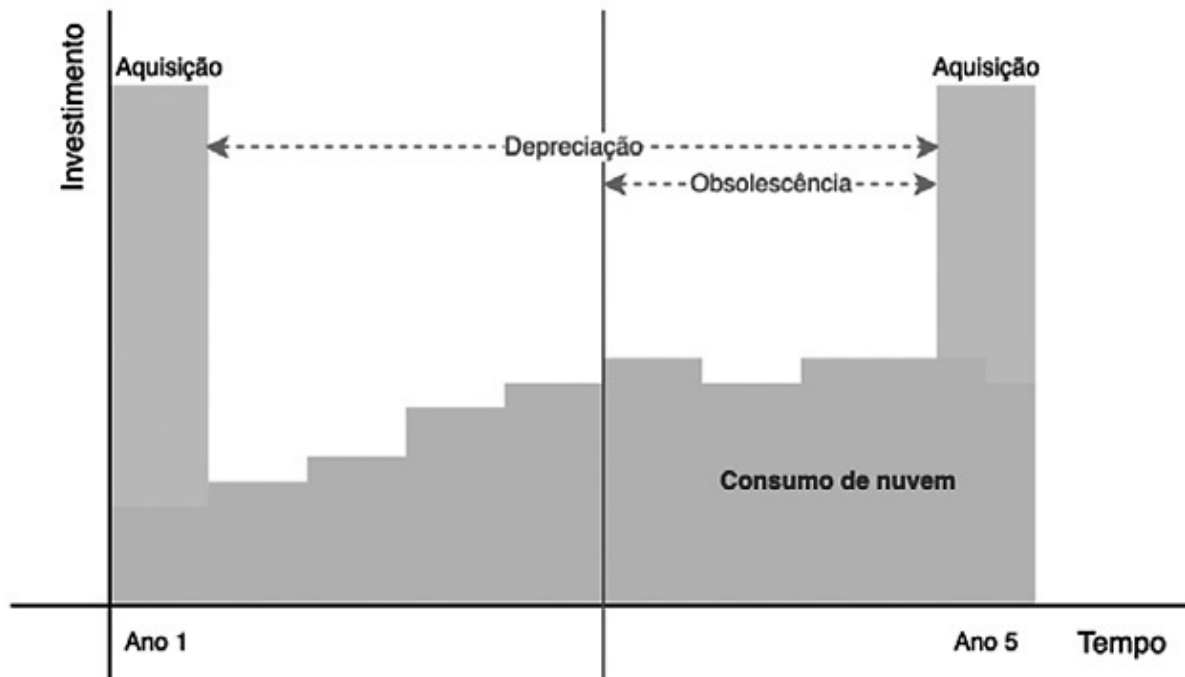
Essa estratégia casa perfeitamente com o modelo de pagamento por uso, pois dessa maneira o cliente só paga pelos recursos utilizados durante a operação da carga de trabalho. É importante salientar que as aplicações precisam ser ajustadas ou adaptadas para se beneficiar dessas automações, porém o ganho supera o esforço neste caso.

2.4.1.5 Escalabilidade

A escalabilidade permite que o cliente comece pequeno e cresça conforme a sua necessidade ao longo do tempo. Normalmente os ambientes tradicionais são adquiridos conforme a sua projeção de uso ao longo de 2 a 5 anos, o que exige um investimento inicial maior, resultando em recursos ociosos novamente e uma depreciação dos equipamentos ao longo do tempo. A nuvem, devido a sua escala, evita justamente o investimento inicial mais pesado, pois o usuário cresce conforme a demanda, sem a necessidade de alocação antecipada de recursos, evitando altos investimentos justamente quando estes não são necessários.

Outro aspecto importante é que o cliente não precisa mais se preocupar com a obsolescência de seus recursos, pois ao longo do tempo o próprio provedor de nuvem realiza a atualização tecnológica, bastando ao cliente realizar a movimentação da sua carga de trabalho para os novos ambientes, mantendo-se dessa forma sempre atualizado. Outra vantagem indireta é que o ritmo de atualização dos provedores faz com que os processos de gestão de obsolescência sejam mais eficazes e dinâmicos nas instituições, pois é preciso acompanhar os ciclos do provedor que possuem calendários estritos de descontinuidade de tecnologias obsoletas.

Ciclos de aquisição versus modelos de consumo em nuvem

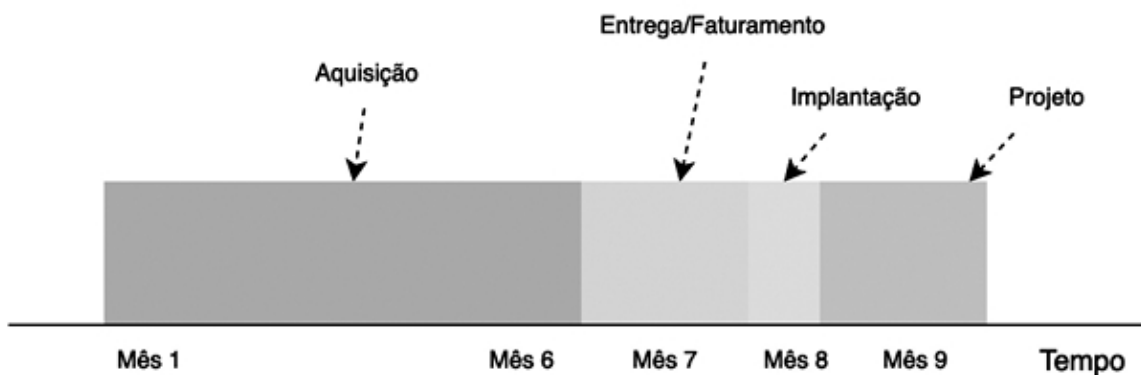


2.4.1.6 Agilidade

A agilidade entra como o cimento das duas características anteriores, pois a partir do momento que não é preciso se preocupar em adquirir e gerir todo o ciclo de vida da infraestrutura, bastando usar as automações que a nuvem fornece, o processo como um todo se torna mais ágil para o cliente final, reduzindo o tempo de entrega total.

Considerando o cenário das empresas privadas, que possuem processos mais dinâmicos de aquisição, é normal que a partir da demanda de uma área de negócio até a entrega final pela área de TI esse ciclo leve de 2 a 6 meses, isso se não houver recursos em estoque, o que resulta em entregas mais demoradas para o mercado e/ou cliente final.

Fases de aquisição e implementação



Considerando o cenário do serviço público, que possui um rito de contratação mais demorado, o impacto pode ser ainda maior no que se refere a prazos, reduzindo a agilidade de entrega de serviços para o cidadão.

A nuvem reduz esse hiato justamente por permitir a alocação de recursos em poucos minutos, o que permite que o cliente foque em aperfeiçoar as automações para acelerar as entregas e melhorar os serviços destinados aos cidadãos com entregas rápidas e contínuas.

Quais são as preocupações do time de projeto com a nuvem? A implantação dos recursos corretos conforme os processos já definidos e a execução do projeto para a disponibilização plataforma/aplicação. Se o cliente já possuir esteiras 100% automatizadas e integradas com a nuvem, tais entregas podem ocorrer em questão de horas ou até minutos, dependendo do processo institucional.

Algumas vezes vem a pergunta, será que eu não poderia investir então em uma nuvem privada com as automações que a nuvem oferece? Possível é, porém não faz sentido do ponto de vista econômico e técnico. O investimento em tecnologias de automação e serviços para implantá-las é muito elevado e exige um tempo substancial e um grande esforço dos times internos, além disso após a entrega será necessário manter e evoluir constantemente a

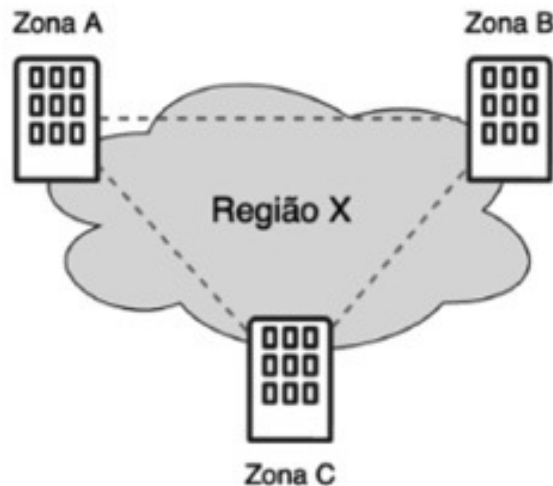
plataforma, o que exige mais investimento e mais esforço. Já os provedores de nuvem constroem e evoluem suas plataformas diariamente, pois é o pilar fundamental de seu negócio, assim o custo desse desenvolvimento é diluído na escala de clientes que as utilizam. Além da questão econômica, tecnicamente será muito difícil acompanhar o ritmo de evolução das tecnologias e disponibilizá-las com rapidez como fazem os provedores de nuvem, que possuem times dedicados e recursos para investir em inovações. Outro ponto é a escala e elasticidade, em que um ambiente de *Data Center* tradicional trabalha com capacidade fixa ou escala limitada, o que não permite uma real elasticidade para o usuário final.

2.4.1.7 Disponibilidade

A disponibilidade é um dos maiores diferenciais quando olhamos para as soluções em nuvem. Os provedores usualmente constroem suas estruturas de forma resiliente, com vários *Data Centers* separados geograficamente, uma rede robusta de interligação entre eles e tecnologias de replicação de dados para os serviços por eles prestados. Esse modelo permite que os clientes implementem arquiteturas altamente disponíveis, com baixo custo e mínimo esforço operacional.

Um modelo muito utilizado pelos grandes provedores é a distribuição em regiões e zonas de disponibilidade, dessa forma uma região é composta de várias zonas de disponibilidade separadas geograficamente e dentro de cada zona pode haver um ou mais *Data Centers*. Esse modelo garante que, em caso de uma falha ou desastre, sempre haverá pelo menos uma zona operacional para manter os serviços dos clientes no ar, desde que o cliente implemente suas cargas de trabalho de forma adequada.

Esquema do modelo de região e zonas de disponibilidade



Uma implementação semelhante em ambientes tradicionais com *Data Centers* próprios exige altos investimentos e apresenta um custo operacional significativo ao longo do tempo. Além do custo, a implementação das soluções e suas conseqüentes evoluções exigem elevado esforço operacional, sem interrupção. São vários aspectos que devem ser considerados e monitorados nesse cenário, projeto da edificação, certificações, segurança física, refrigeração, automação, combate a incêndios, desastres naturais, carga e descarga, fornecimento de energia com dupla abordagem, grupo gerador, estocagem e fornecimento de diesel, conectividade, controle de acesso, segurança dos dados, contratos de fornecimento de *hardware* e *software*, times de manutenção de infraestrutura básica, times para sustentação e operação das plataformas nos mais diversos níveis e outros. Isso serve para demonstrar a complexidade de se manter uma infraestrutura própria, tendo que direcionar esforços e orçamentos para uma área que muitas vezes não é o fim dos entes públicos.

O aspecto mais importante neste tema é a transferência de responsabilidade para os provedores de nuvem, cabendo a eles a gestão e evolução das infraestruturas que suportam as cargas de trabalho dos clientes. Cabe ao cliente apenas implementar suas

aplicações seguindo arquiteturas de referência que se aproveitem das capacidades de resiliência providas pelas plataformas de nuvem.

Para o termo de referência é importante exigir que o provedor possua ao menos duas zonas de disponibilidade nas regiões que serão ofertadas. Além disso, é interessante especificar onde podem estar localizadas as regiões, somente no Brasil ou se também podem ser usadas regiões em outros países no mundo, a depender da legislação vigente.

2.4.1.8 Segurança

A segurança é outro diferencial entregue pelas plataformas de nuvem. Por definição um ambiente em nuvem inicia completamente fechado, usando-se do conceito de “*Zero Trust*”, ou seja, é preciso que o cliente realize as liberações necessárias para disponibilizar serviço a serviço para consumo. Além disso, existe uma grande gama de serviços de segurança disponíveis que atuam em praticamente todos os níveis da plataforma de nuvem, *firewalls* de camada 4 e 7, proteção contra ataques de negação de serviços, plataformas de detecção de atividades maliciosas, detecção de intrusão, verificação de integridade de configuração e aplicação de boas práticas de segurança, mapeamento e identificação de dados sigilosos, registros detalhados de auditoria, federação para integração com plataformas de identidade, mecanismos de duplo fator de autenticação, criptografia em trânsito e em repouso, guarda segura de chaves e vários outros.

Considerando a implementação de todos esses serviços de forma integrada em um *Data Center* tradicional, é perceptível a existência de um projeto complexo com um longo período de execução e com um alto investimento, e possivelmente alguns componentes já estariam atingindo sua obsolescência ao final do projeto. Isso ocorre

porque naturalmente os clientes precisam também focar investimentos e pessoal nas áreas fins e projetos tendem a sofrer mudanças de priorização ao longo do tempo, mesmo em se tratando do tema de segurança. Já os provedores de nuvem mantêm um fluxo constante de investimento em soluções de segurança, plataformas, pessoas e processos, pois esse é um dos aspectos mais importantes quando se operam ambientes compartilhados, segregados lógica ou fisicamente.

A nuvem não necessariamente altera substancialmente os processos já adotados nos entes públicos, estes podem ser implementados e adaptados para garantir a continuidade das políticas de segurança vigentes. O que pode mudar são as tecnologias adotadas ou não, pois muitas das vezes é possível utilizar a mesma tecnologia já implantada no *Data Center* existente, podendo existir em muitos casos uma parceria entre o fornecedor do cliente e o provedor, para certificar a tecnologia na nuvem, diminuindo dessa forma a curva de aprendizado para os times de operação.

As plataformas de nuvem podem ser usadas também como um instrumento de aceleração na adoção de práticas mais modernas de segurança, pois oferecem já no ponto de partida um leque substancial de soluções já integradas. O maior desafio é garantir que os termos de referência contemplem todos os serviços necessários no dia zero e também incorporar novos serviços de segurança durante a vigência do contrato.

No que tange ao termo de referência, é importante sempre requisitar que os provedores tenham certificações de mercado que garantam a qualidade necessária nos serviços e segurança dos dados, dessa forma elimina-se o risco de se contratar provedores “aventureiros” que não possuam os controles adequados para hospedar aplicações e dados de instituições públicas.

Como referência, podem-se solicitar *certificações* como SOC1/2/3, ISO 9001-27001/17/18/701 e CSA. Além das certificações, pode-se também solicitar a aderência a LGPD, mesmo que ainda não exista uma certificação formal, pois os principais provedores já operam em conformidade com a GDPR (norma europeia), que serviu de base para a LGPD.

2.4.2 Modelos de serviço

Camila Murta

Na computação em nuvem existem três categorias principais de soluções oferecidas:

SaaS	PaaS	IaaS
Software as a service • aplicações criadas para o usuário final, entregues pela web	Plataforma as a services • ferramentas e serviços criados para tornar a codificação e entrega de SaaS mais simples e ágil	Infraestruturra as a services • hardware e software que torna possível o uso dessas soluções (servidores, redes, armazenamento, etc).

O *software como serviço (SaaS)* utiliza a *web* ou uma interface de programação para fornecer aplicações que são administradas por terceiros em uma infraestrutura na nuvem, cuja interface é acessada pelo usuário. A maior parte de aplicações SaaS pode ser executada diretamente de um *browser web* sem necessitar quaisquer *downloads* ou instalações, embora algumas precisem de *plugins*.

Serviço de plataforma de nuvem (PaaS) representa um *framework* em que os desenvolvedores podem construir e customizar aplicações na

infraestrutura da nuvem. O PaaS torna o desenvolvimento, a testagem e a execução de aplicações simples, rápidos e eficientes.

Serviços de infraestrutura em nuvem (IaaS) são modelos “self-service” para monitoramento, acesso e administração de infraestruturas de *data centers*, armazenamento, *networking* e outros recursos de computação fundamentais nos quais o consumidor pode instalar e executar *softwares* em geral, incluindo sistemas operacionais e aplicativos.

Relevante trazer o esclarecimento constante do NIST (Special Publication 800-145): uma *infraestrutura na nuvem* é o conjunto de *hardware* e *software* que habilita as cinco características essenciais da computação em nuvem. A infraestrutura na nuvem é composta por uma camada física e uma camada de abstração. A camada física consiste dos recursos de *hardware* que suportam os serviços na nuvem sendo oferecidos e geralmente inclui servidores, armazenamento e rede. A camada de abstração consiste do *software* instalado sobre a camada física, através do qual as cinco características essenciais da nuvem se manifestam. Conceitualmente, a camada de abstração assenta-se sobre a camada física.

2.4.3 Modelos de implementação

Camila Murta

De acordo com o explanado no item 2.4.1 resta evidente que a jornada de migração para a nuvem³⁵ propicia: redução de custos, maior agilidade, flexibilidade, escalabilidade e segurança, sendo estes pontos relevantes a serem considerados pelos entes públicos.

As soluções em nuvem podem ser implementadas em *quatro* modelos: *privado, comunitário, público e híbrido*.

1. *Nuvem privada* – Uma nuvem privada consiste em recursos de computação em nuvem operacionalizados e sempre gerenciados

pelo cliente ou podem ser gerenciados por empresas terceirizadas (*outsourcing*). A nuvem privada pode estar localizada fisicamente no *data center* local do cliente ou pode ser hospedada por um provedor de serviços terceirizado. Mas em uma nuvem privada os serviços e a infraestrutura são sempre mantidos na rede privada e o *hardware* e o *software* são dedicados unicamente ao cliente. Para manter a exclusividade, é necessário investir em uma infraestrutura otimizada para virtualização.

Vantagens de uma nuvem privada:

- *Maior flexibilidade* – possibilidade de personalizar o ambiente de nuvem para atender a necessidades de negócios específicas.
- *Maior controle* – os recursos não são compartilhados com outros usuários, portanto, é possível um nível maior de controle e privacidade.
- *Maior escalabilidade* – geralmente oferecem mais escalabilidade em comparação com a infraestrutura local.

2. *Nuvem comunitária* – Trata-se de uma plataforma de tecnologia virtual multiusuária que permite que alguns clientes de setores específicos, como o setor bancário, com pautas e preocupações em comum, trabalhem colaborativamente em uma plataforma compartilhada, com recursos e infraestruturas compartilhados. As nuvens comunitárias ganharam popularidade com o aumento do trabalho remoto durante a pandemia.

Vantagens de uma nuvem comunitária:

- A comunidade pode compartilhar requisitos regulatórios e operacionais em comum.
- Um provedor terceirizado de serviços na nuvem pode hospedar uma nuvem comunitária.
- A nuvem é hospedada em um centro de dados e pode ser local ou externa.

3. *Nuvem pública* – Consiste na disponibilização de recursos e serviços pelos provedores de nuvem e gerenciados por eles. São

exemplos de nuvens públicas o Microsoft Azure, o Google Cloud, AWS e Oracle.

Vantagens das nuvens públicas:

- *Redução de custos* – não há necessidade de comprar *hardware* ou *software*, pagando apenas pelo uso.
- *Sem manutenção* – a manutenção fica a cargo do provedor de nuvem.
- *Escalabilidade quase ilimitada* – recursos sob demanda estão disponíveis para atender às necessidades de negócios.
- *Alta confiabilidade* – uma ampla rede de servidores assegura contra falhas.

4. *Nuvem híbrida* – Uma nuvem híbrida é um tipo de computação em nuvem que combina infraestrutura local ou uma nuvem privada com uma nuvem pública. Nuvens híbridas permitem que dados e aplicativos se movam entre os dois ambientes. Muitos clientes escolhem uma abordagem de nuvem híbrida devido a estratégias de negócios, como atender a requisitos regulatórios e de soberania de dados, aproveitando ao máximo investimento em tecnologia local ou solução de problemas de baixa latência.

Vantagens da nuvem híbrida:

- *Controle* – possibilidade de manter uma infraestrutura privada para ativos confidenciais ou cargas de trabalho que exigem latência baixa.
- *Flexibilidade* – usufruir de recursos adicionais na nuvem pública quando precisar.
- *Custo-benefício* – capacidade de escalar para a nuvem pública.
- *Facilidade* – a transição para a nuvem pode ocorrer gradualmente, passando as cargas de trabalho ao longo do tempo.

O Governo Digital do Brasil oferece um *Guia de Boas Práticas*, orientações e vedações para contratação de Serviços de Computação em Nuvem.^{[36](#)}

2.5 Serviços técnicos profissionais em nuvem

Alexandre Ferraz

O serviço técnico profissional atua com profissionais especializados e capacitados nos recursos de nuvem com o objetivo de acelerar os resultados de negócios dos clientes a partir dos fluxos de trabalhos técnico, essenciais para a modernização digital de uma organização.

Os entes públicos, pela sua própria natureza, não conseguem contratar e treinar rápido o suficiente e, à medida que passam por sua jornada na nuvem, eles podem encontrar obstáculos que levam mais tempo para serem removidos e resolvidos. Nesse sentido, o time de serviços técnicos profissionais conta com especialistas em verticais de negócio, como também nos domínios de conhecimento técnico, pertinentes aos recursos de nuvem.

Esses profissionais especializados exercem uma atuação de forma consultiva, direcionando e resolvendo questões técnicas mais complexas dentro dos projetos executados, mas também com a preocupação de capacitar o cliente para que ele se torne independente, ao transferir conhecimento e habilidades durante todo o engajamento. Este tipo de abordagem contribui com a transformação ou adaptação cultural, necessária aos órgãos públicos e empresas privadas, com relação às pessoas e processos, rumo a um novo modelo de operação baseado em nuvem.

Os serviços técnicos profissionais podem auxiliar os clientes em várias necessidades de negócio, a partir de ofertas preexistentes que envolvem a modernização de uma plataforma, produto ou serviço, como também a redução de custos de infraestrutura de TI, boas práticas de operacionalização dos recursos de nuvem, governança e gestão financeira, além da implementação de

projetos relacionados a recursos de inovação, como *blockchain*, *machine learning* e todas as variações de projetos relacionados a dados.

2.5.1 O modelo de entrega de projeto de serviços profissionais

O time de serviços profissionais inicia suas atividades a partir da assinatura do contrato em que se estabelecem o tipo de projeto, o escopo e a distribuição de horas por perfil. Ainda assim, existem atividades de alinhamento entre a equipe de gestão e os serviços técnicos profissionais, para o entendimento dos objetivos, escopo e resultados do que será entregue e definido nas ordens de serviço. Reuniões internas são realizadas nessa passagem de conhecimento e planejamento de atividades para o início do projeto, definindo-se uma cadência de comunicação, além da ferramenta de colaboração, onde as atividades a serem realizadas ficam registradas e a execução monitorada.

Organizando-se em equipes pequenas, os membros são capazes de trabalhar em estreita colaboração, compartilhando conhecimento e habilidades. Também é mais fácil o gerenciamento, o treinamento e a orientação da equipe, proporcionando um ambiente de trabalho mais focado.

Durante a execução do projeto, serviços técnicos profissionais se utilizam da abordagem iterativa incremental. O processo de entrega iterativo incremental é uma abordagem de gerenciamento de projetos em que o trabalho é dividido em partes menores, chamadas de iterações ou incrementos, e entregue ao longo do tempo, em vez de esperar até que o projeto esteja completo para entregar tudo de uma vez.

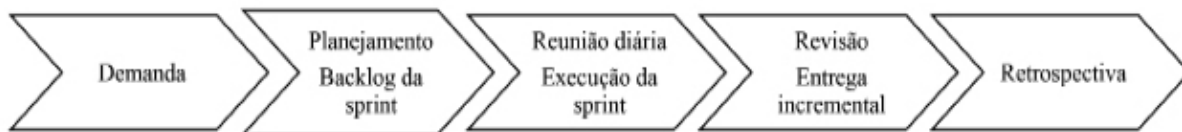
Esse processo começa com uma análise dos requisitos do projeto e, em seguida, divide-se o trabalho em pequenos incrementos. Cada incremento é então planejado, desenvolvido, testado e entregue aos gestores. Após cada incremento entregue, uma avaliação é realizada para determinar se as necessidades dos gestores foram atendidas e se mudanças precisam ser feitas antes da próxima iteração.

Esse processo de entrega iterativo incremental permite que a equipe do projeto responda rapidamente às mudanças nos requisitos ou no ambiente do projeto. Isso pode reduzir o risco do projeto e aumentar a qualidade final do produto ou serviço entregue.

O gerente de engajamento³⁷ irá estabelecer, juntamente com a equipe, uma cadência semanal de entregas (com base nas prioridades identificadas pelo cliente), constituída de cerimônias ágeis, desde o planejamento, execução, revisão até a retrospectiva. Define-se este ciclo de entrega ou iteração como *Sprint*.³⁸ Com o andar do projeto e o ganho de maturidade, podem ser definidas *Sprints* mais longas, impulsionadas por resultados bem-sucedidos.

Dependendo do tipo de contrato, as *Sprints* podem ser compostas ou substituídas por Ordens de Serviço (OS), ou seja, entregas pré-aprovadas pelo cliente, mas que seguem o mesmo padrão iterativo/incremental.

Processo de entrega iterativo incremental



Durante a execução das *Sprints*, existem atividades de gestão por parte do Gerente de Engajamento, referentes à definição e

monitoramento de marcos do projeto, visando o acompanhamento do progresso das atividades, gestão financeira, gestão de recursos, identificação e tratamento de riscos e escalonamentos necessários.

Após a realização das entregas planejadas no projeto, segue-se para a fase de fechamento.

Uma aprovação do término dos ciclos de execução deve ser obtida, aferindo-se os entregáveis, a partir do aceite da OS atestando a conclusão dos resultados definidos anteriormente.

E, em momento posterior, realiza-se um evento de lições aprendidas e encaminha-se a pesquisa de satisfação do cliente. Obter um testemunho após a conclusão de um projeto bem-sucedido reforça a satisfação da organização, fortalece a reputação da empresa, melhora a credibilidade e fornece *feedback* valioso para a melhoria de serviços técnicos profissionais.

2.5.2 Serviços técnicos profissionais na jornada de adoção de nuvem

Antonio Carlos Dias

O apoio de serviços técnicos profissionais para auxiliar na jornada de adoção de nuvem requer que os gestores públicos repensem as alternativas e a maneira como abordam seus problemas técnicos e de negócio, e como identificam novas oportunidades, inerentes a uma transformação digital. A inclusão de serviços deve ser considerada para acelerar o processo de aculturação, e a transferência de conhecimento e metodologias para o contratante.

Seguem alguns pontos que devem ser observados quando tal justificativa estiver em construção:

- *Aceleração do processo de migração e modernização de aplicações*

Uma vez concluído o processo de contratação dos recursos de computação em nuvem, o primeiro passo natural é o de migração de

aplicações existentes. Um estudo independente do IDC de 2018 sobre empresas que migraram para a nuvem encontrou uma economia média de custos de infraestrutura na faixa de 30%.^{[39](#) [40](#)}

A inclusão de serviços técnicos profissionais acelera e traz segurança a processos de migração e modernização, ao juntar ao time do ente público, que está iniciando na utilização da nuvem, profissionais com conhecimento, metodologias comprovadas e experiência em utilizá-las, assegurando velocidade, assertividade e melhores práticas, seja na migração rápida (conhecida pelo termo “as-is”) ou em uma subsequente modificação total ou parcial para maximizar o potencial da nuvem (conhecida como “modernização”).

- *Apoio metodológico para a gestão financeira do ambiente de nuvem*

A adoção da nuvem possibilita uma mudança no modelo de contabilização com a transferência de custos da TI, evitando que o ente público tenha necessidade de fazer grandes investimentos em máquinas e equipamentos de TI de forma antecipada e passando a necessitar de maior previsão no custeio da sua operação.

Esta mudança de modelo traz como consequência um cenário mais volátil, em que o consumo varia de acordo com a utilização dos recursos de computação em nuvem feito pelos diversos times envolvidos na adoção, dia a dia. Existem serviços de nuvem focados em tais controles, e a orientação por profissionais especializados com metodologias específicas para o uso eficiente de tais serviços é justificada pela necessidade de garantir tal gestão de forma proativa.

É importante que o gestor avalie a contratação de profissionais com experiência na implementação de serviços de nuvem voltados a obter previsibilidade dos custos futuros, bem como na disseminação de metodologias para fazer um de tais serviços.

- *Transformação das equipes de TI e consequentes mudanças culturais*

Para utilizar a nuvem pública em todo seu potencial, é importante desenvolver sua força de trabalho existente, o que demanda mapear

os conhecimentos atuais, construir planos de treinamento e fornecer de forma contínua os treinamentos adequados.

Uma vez mais, o acompanhamento por profissionais experientes, com a transferência de conhecimento, metodologias e mesmo de “shadowing” em projetos, se mostra uma estratégia importante no desenvolvimento da equipe técnica da organização. Além da evolução e preparação técnica dos profissionais em habilidades na nuvem, trabalhar a cultura dos times e de toda a organização é fundamental para uma adoção bem-sucedida da *Cloud*, incluindo novas abordagens como *DevOps*, práticas ágeis e metodologias de mudança organizacional.⁴¹

- *Redesenho do modelo operacional*

A adoção da nuvem traz novos desafios e oportunidades para a operação dos ambientes de TI. Segundo o IDC, a adoção da nuvem traz o potencial de aumentar em 62% a eficiência do time infraestrutura de TI, e a redução em 94% de indisponibilizações (“*Downtime*”) não programadas.⁴²

Para obter tais índices, os entes públicos precisam adotar maneiras de se adaptar e promover as mudanças necessárias na cultura, processos, competências e ferramentas para operação em *nuvem*. Existem inúmeros exemplos de escolhas importantes que se fazem necessárias: adotar modelos *DevOps/DevSecOps* centralizados ou descentralizados; realizar a gestão de nuvem por projetos ou serviços/produtos; definir novas estruturas para aproveitar serviços de *Big Data* e *Machine Learning*; fazer a readequação das políticas e práticas de segurança; etc.

2.6 Tecnologias emergentes

Alexandre Ferraz

2.6.1 Modernização de dados e novas estruturas analíticas

O potencial de criar novos resultados por meio de uma transformação digital usando banco de dados, análises, IA e ML⁴³ está ao alcance de todos os órgãos públicos. O time de serviços técnicos profissionais pode auxiliá-los a definir e implementar sua estratégia de dados, seja relacionando ao estabelecimento de uma sólida fundação de infraestrutura e recursos de dados, ou projetos de modernização de repositórios de dados e aprendizado de máquina (*machine learning*).

Normalmente este serviço inicia-se com uma avaliação de dados. Essa avaliação ajuda a estabelecer, por exemplo, os resultados de negócios desejados para uma iniciativa de *Data Lake*, incluindo armazenamento de dados, particionamento de dados, catálogo de dados, acesso e segurança de dados.

Muitas empresas desenvolvem serviços que ajudam as organizações a se tornarem organizações orientadas a dados (*data driven organization*).

Uma “*data driven organization*” é uma organização que utiliza dados e análises para orientar suas decisões e ações em todos os aspectos do negócio. Isso inclui a coleta, análise e interpretação de dados para informar estratégias de *marketing*, desenvolvimento de produtos, otimização de processos, tomada de decisões financeiras e muito mais.

Essas empresas têm uma cultura que valoriza a análise de dados e a experimentação baseada em evidências. Elas usam ferramentas de análise avançadas para coletar dados de diversas fontes, incluindo sistemas internos, redes sociais, dados de clientes e informações de mercado.

As organizações orientadas por dados são capazes de identificar tendências e oportunidades mais rapidamente do que seus concorrentes, além de tomarem decisões mais informadas e precisas. Elas são capazes de se adaptar rapidamente às mudanças nas condições de mercado e aos comportamentos dos consumidores, o

que lhes permite permanecer competitivas em um ambiente de negócios em constante mudança. Da mesma forma que um órgão público, atento às tecnologias emergentes, pode fazer uso destas visando proporcionar melhores serviços públicos, alterando a forma de prestação desse serviço ou executando-o com mais eficiência.

2.7 Serviços de operação de infraestrutura e de atendimento aos usuários

Camila Lousada

O modelo de contratação dos serviços de operação de infraestrutura e de atendimento a usuários de TI⁴⁴ estabelecido pela PORTARIA SGD/ME nº 6.432, de 15 de junho de 2021, alterada pela *Portaria SGD/ME nº 4.668, de 23 de maio de 2022*,⁴⁵ descreve no Anexo I:

2.1.1 – Entende-se por operação de infraestrutura de TIC a prestação de serviços técnicos que estão relacionados à segurança da informação, intercomunicação e rede de comunicação de voz e dados, banco de dados, servidores de rede, sistemas operacionais, sistemas de backup, recursos de armazenamento de dados, monitoramento e gerenciamento operacional.

2.1.2. A operação de infraestrutura de TIC é um serviço fundamental para a garantia da disponibilidade, integridade, resiliência e segurança de recursos tecnológicos necessários para a sustentação de quaisquer serviços baseado em TIC do órgão.

2.1.3. Já o atendimento a usuários de TIC compreende a prestação de serviços de suporte técnico de microinformática, incluindo a sustentação dos ativos e dos *softwares* relacionados às atividades dos usuários do órgão.

2.1.4. Ambos os serviços descritos neste modelo são serviços passíveis de execução indireta, nos termos da legislação vigente, e constituem em atividades de alta relevância, por apoiar processos finalísticos e administrativos das instituições que integram a Administração, contribuindo assim para manter em funcionamento as operações e funções dos diversos órgãos.

2.1.5. Estes serviços são considerados comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, sendo prestados preferencialmente por empresas fornecedoras de serviço técnico em TIC.

Ainda de acordo com o modelo de contratação descrito na Portaria SGD/ME nº 4.668, de 23 de maio de 2022, são serviços abrangidos:

Gerenciamento de serviços de TIC
(GSTI)

Sustentação de aplicações

Armazenamento e *backup*

Sustentação de banco de dados

Administração de dados

Conectividade e comunicação

Segurança de TIC

Monitoramento de serviços de TI

Suporte técnico de microinformática

a) Gerenciamento de serviços de TIC (GSTI)

Ferramentas de GSTI⁴⁶ dão suporte às operações de TI nas organizações, facilitam as tarefas e fluxos de trabalho associados ao gerenciamento e entrega de serviços de TI de qualidade. Estes são mais usados por centrais de serviços de TI e funções de entrega de serviços de TIC.

Principais atividades:

- Implantar e manter os processos de gerenciamento de serviços de TIC definidos pelo cliente, baseados nas melhores práticas, utilizando ferramenta(s) especializada(s);
- Operar, manter, atualizar e criar fluxos de processos na ferramenta de gerenciamento de serviços de TIC;
- Adaptar os fluxos básicos de incidentes, requisição, mudanças, problemas e configuração, com o desenho de formulários e criação de regras e validações;

- Criar e adaptar outros fluxos de trabalho, ancorados nos processos básicos de gerenciamento de serviços de TI, o que inclui desenho de formulários e criação de regras e validações;
- Discutir os requisitos dos fluxos de trabalho para propor a sua adequação às boas práticas de GSTI;
- Identificar melhorias nos processos básicos de gerenciamento de serviços de TIC sob a ótica das melhores práticas de GSTI preconizadas pelo ITIL;⁴⁷
- Utilizar os indicadores-chave de desempenho para apoiar a atividade de evolução dos processos;
- Difundir o conhecimento de melhores práticas para as equipes de TIC;
- Realizar a integração das ferramentas necessárias para o correto funcionamento dos processos;
- Resolver falhas relativas aos fluxos e à ferramenta de suporte ao gerenciamento de serviços de TIC;
- Elaborar, manter e atualizar os relatórios de acompanhamento dos processos e indicadores de níveis de serviço;
- Elaborar relatórios gerenciais e técnicos quando solicitados;
- Realizar a interface de comunicação entre as demais categorias de serviços e a contratante.

Abordagem adotada no ambiente de TIC: essa categoria é indicada para ambientes de TIC que possuem tanto abordagem tradicional quanto baseada em DevOps ou DevSecOps.⁴⁸

b) Sustentação de aplicações

Sustentação é o trabalho de suporte a toda a infraestrutura dos sistemas de TI, nos seguintes níveis: *softwares* – bots, sites, ERPs, CRMs e aplicativos; *hardwares* – Data Centers, servidores, computadores e equipamentos eletrônicos; *Redes* – internet, segurança da informação e componentes de rede. É, portanto, uma

espécie de monitoramento e manutenção que permitirá a continuidade, disponibilidade e qualidade tecnológica da aplicação.

Principais atividades:

- Projetar, operar, administrar e manter o conjunto de soluções, ferramentas, *softwares* e *hardwares* que compõem a camada de sustentação de serviços e aplicações do cliente;
- Operar, administrar e manter os servidores físicos e virtuais do cliente;
- Tratar incidentes, problemas, requisições e mudanças relacionadas à camada de sustentação de serviços e aplicações do cliente;
- Realizar configurações, alterações e otimizações no ambiente de sustentação de serviços e aplicações do cliente;
- Manter o ambiente atualizado observando as orientações previstas no gerenciamento de mudanças;
- Acompanhar fornecedores caso necessário;
- Elaborar e manter atualizada a documentação de todo o ambiente.

Abordagem adotada no ambiente de TIC: Essa categoria é indicada para ambientes de TIC que possuem abordagem baseada em DevOps ou DevSecOps.

c) Armazenamento e *backup*

Os *softwares* de *backup*/recuperação são projetados para fornecer *backup* de armazenamento em fita, disco ou dispositivos ópticos e recuperar esses dados quando necessário. Este segmento também inclui produtos focados especificamente no suporte ao processo de recuperação, como as bibliotecas de fitas virtuais. Também estão incluídos produtos de gerenciamento de mídia, deduplicação e relatórios de *backup*, bem como produtos de arquivamento incluídos no aplicativo de *backup*. As atividades de gerenciamento de mídia

incluem alocação, rotulagem, rastreamento, reciclagem e monitoramento de mídia, bem como gerenciamento de pool de armazenamento.

Principais atividades:

- Projetar, operar, administrar e manter o conjunto de soluções, ferramentas, *softwares* e *hardwares* que compõem o ambiente de *backup* e armazenamento do cliente;
- Executar, manter, atualizar, implantar e apoiar a criação das políticas de *backup*⁴⁹ do cliente;
- Tratar incidentes, problemas, requisições e mudanças relacionados ao ambiente de *backup* e armazenamento do cliente;
- Realizar configurações, alterações e otimizações no ambiente de backup e armazenamento do cliente;
- Realizar testes de *restore* com definição de frequência a critério do cliente;
- Manter o ambiente atualizado observando as orientações previstas no gerenciamento de mudanças;
- Acompanhar fornecedores caso necessário;
- Elaborar e manter atualizada a documentação de todo o ambiente.

Abordagem adotada no ambiente de TIC: Essa categoria é indicada para ambientes de TIC que possuem tanto abordagem tradicional quanto baseada em DevOps ou DevSecOps.

d) Sustentação de banco de dados

Principais atividades:

- Projetar, instalar, implantar, operar, administrar e manter o conjunto de ferramentas, *softwares* e *hardwares* que compõem recursos e soluções relacionadas a bancos de dados do cliente;
- Tratar incidentes, problemas, requisições e mudanças relacionadas ao ambiente de banco de dados do cliente;

- Realizar configurações, alterações e otimizações no ambiente de banco de dados do cliente;
- Manter o ambiente atualizado observando as orientações previstas no gerenciamento de mudanças;
- Acompanhar fornecedores caso necessário;
- Registrar chamados para fornecedores das soluções;
- Elaborar e manter atualizada a documentação de todo o ambiente.

Abordagem adotada no ambiente de TIC: Essa categoria é indicada para ambientes de TIC que possuem tanto abordagem tradicional quanto baseada em DevOps ou DevSecOps.

e) Administração de dados

Um sistema ETL⁵⁰ precisa ser capaz de se comunicar com bases de dados e ler diversos formatos de arquivos utilizados por toda a organização.

Principais atividades:

- Apoiar a auditoria, análise, revisão de documentação relativas à modelagem de dados;
- Construção de *queries*;
- Apoiar a manutenção de repositório de metadados;
- Manter esquemas de banco de dados;
- Elaborar e manter modelo de dados;
- Apoio na elaboração e definição de política de segurança do banco de dados;
- Realizar apuração especial;
- Confecção e manutenção de documentação e de procedimentos técnicos;
- Validação de modelos de dados quanto às melhores práticas de modelagem;
- Desenvolvimento, execução, teste e documentação de rotinas de ETL;

- Instalar, configurar, otimizar, parametrizar ferramenta ETL;
- Sugerir automatização das rotinas.

Abordagem adotada no ambiente de TIC: Essa categoria é indicada para ambientes de TIC que possuem tanto abordagem tradicional quanto baseada em DevOps ou DevSecOps.

f) Conectividade e comunicação

Alguns exemplos de serviços de comunicação: VoIP,⁵¹ conexão internet, links MPLS, WAN/LAN, soluções de videoconferência, transmissão e recebimento de mensagens de texto – SMS, gerenciamento de redes sem fio (Wi-Fi).

Principais atividades:

- Projetar, operar, administrar e manter o conjunto de soluções, ferramentas, *softwares* e *hardwares* que compõem o ambiente de conectividade e comunicação do cliente;
- Tratar incidentes, problemas, requisições e mudanças relacionadas ao ambiente de conectividade e comunicação do cliente;
- Realizar configurações, alterações e otimizações no ambiente de conectividade e comunicação do cliente;
- Manter o ambiente atualizado observando as orientações previstas no gerenciamento de mudanças;
- Acompanhar fornecedores caso necessário;
- Elaborar e manter atualizada a documentação de todo o ambiente.

Abordagem adotada no ambiente de TIC: Essa categoria é indicada para ambientes de TIC que possuem tanto abordagem tradicional quanto baseada em DevOps ou DevSecOps.

g) Segurança de TIC

Alguns exemplos de serviços de segurança em TIC: os serviços de avaliação e testes de segurança (a exemplo de testes de intrusão, *pentest*, simulação de adversários), gestão de vulnerabilidades e tratamento de incidentes, *Security as a Service* – SECaaS, segurança de redes, serviço de monitoria de eventos de segurança – SOC e serviços técnicos de consultoria em segurança da informação e privacidade

Principais atividades:

- Projetar, operar, administrar e manter o conjunto de soluções, ferramentas, *softwares* e *hardwares* que compõem o ambiente de segurança de TIC do cliente;
- Tratar incidentes, problemas, requisições e mudanças relacionadas ao ambiente de segurança de TIC do cliente;
- Realizar configurações, alterações e otimizações no ambiente de segurança de TIC do cliente;
- Realizar testes de vulnerabilidades dos sistemas e serviços de TIC do cliente, identificando os riscos e sugerindo ações para o devido tratamento;
- Apoiar a elaboração e manutenção da política de segurança do cliente;
- Apoiar a elaboração e manutenção do plano de continuidade de negócio do cliente;
- Apoiar a elaboração e manutenção do plano de gerenciamento de risco do cliente;
- Manter o ambiente atualizado observando as orientações previstas no gerenciamento de mudanças;
- Acompanhar fornecedores caso necessário;
- Elaborar e manter atualizada a documentação de todo o ambiente.

Abordagem adotada no ambiente de TIC: Essa categoria é indicada para ambientes de TIC que possuem tanto abordagem tradicional quanto baseada em DevOps ou DevSecOps.

h) Monitoramento de serviços de TI

Principais atividades:

- Realizar o monitoramento dos sistemas, aplicações, serviços e infraestrutura de TIC da contratante através de ferramenta(as) especializada(as);
- Executar o plano de comunicação realizando os acionamentos dos responsáveis pela resolução dos incidentes, bem como manter informadas as partes interessadas;
- Operar, administrar e manter o conjunto de ferramentas e *softwares* que compõem a solução de monitoramento de TIC do cliente;
- Realizar configurações, alterações e otimizações na solução de monitoramento de TIC do cliente;
- Manter o ambiente atualizado observando as orientações previstas no gerenciamento de mudanças;
- Acompanhar fornecedores caso necessário;
- Elaborar e manter atualizada a documentação de toda a solução.

Abordagem adotada no ambiente de TIC: Essa categoria é indicada para ambientes de TIC que possuem tanto abordagem tradicional quanto baseada em DevOps ou DevSecOps.

i) Suporte técnico de microinformática

Suporte técnico de TI refere-se a qualquer assistência técnica oferecida às empresas (seus usuários) em seu *hardware* e *software*. Tipicamente focada em ajudar os usuários a resolverem problemas específicos. Existem níveis de suporte dependendo do tipo do problema ou incidente

Principais atividades:

- Administrar e manter o conjunto de *softwares* e *hardwares* que compõem o ambiente de dispositivos de usuários do cliente;

- Tratar incidentes, problemas, requisições e mudanças relacionadas ao ambiente de dispositivos de usuários do cliente;
- Manter o registro de requisições de serviços solicitados e de reclamações efetuadas pelos usuários;
- Realizar a instalação, configuração e atualização de *softwares* homologados pelo cliente;
- Realizar a instalação, configuração e atualização de *hardwares* homologados pelo cliente;
- Manter o ambiente atualizado observando as orientações previstas no gerenciamento de mudanças;
- Acompanhar fornecedores caso necessário;
- Elaborar e manter atualizada a documentação de todo o ambiente;
- Identificar, mapear e atualizar o inventário de ativos de TIC.

Abordagem adotada no ambiente de TIC: Essa categoria é indicada para ambientes de TIC que possuem central de serviços ou *service desk* implantado.

2.7.1 Precificação de serviços

O governo federal, entendendo a criticidade e a complexidade da precificação de serviços, criou e compartilhou uma planilha e uma portaria onde registra e sugere as melhores práticas para suporte ao Modelo de Contratação de Serviços de Operação de Infraestrutura e de Atendimento a Usuários de TIC.

Planilha Simplificada para Estimativa do Valor Mensal do Serviços⁵² (*versão atualizada pela Portaria SGD/ME nº 4.668, de 23 de maio de 2022*) – planilha auxiliar do Modelo de Contratação de Serviços de Operação de Infraestrutura e de Atendimento a Usuários de TIC.

Nota Metodológica do Modelo⁵³ (*versão atualizada pela Portaria SGD/ME nº 4.668, de 23 de maio de 2022*) – demonstração dos procedimentos e métodos adotados na realização de pesquisa de preços para obtenção de mapa de pesquisa salarial e do fator-k limite a serem adotados na estimativa do valor mensal de contratos que utilizam o Modelo de Contratação de Serviços de Operação de Infraestrutura e de Atendimento a Usuários de TIC instituído pela Secretaria de Governo Digital.

A seguir outros serviços e soluções.

2.7.2 Serviços de hospedagem

- *Colocation*: é a disponibilização de infraestrutura para hospedar servidores de uma empresa em um *Data Center* alugado. O que se loca é o espaço físico e infraestrutura (ex.: fornecimento de energia elétrica, sistema de refrigeração, controle de acesso, detecção e combate a incêndio, monitoração por Circuito Fechado de TV (CFTV), supervisão e controle dos ativos de infraestrutura).
- *Aplicações*: objetiva a instalação, configuração e produção continuada de aplicações e sistemas em uma infraestrutura de processamento e armazenamento. Aplicações de Business Intelligence (BI), baixa plataforma, alta plataforma (sistemas que necessitem de grande volume de processamento de dados).
- *Serviços de impressões de grandes volumes*: prestação de serviços especializados de impressão de grandes volumes de documentos eletrônicos.
- *Soluções GED* (Gerenciamento Eletrônico de Documentos): tecnologia que digitaliza o processo de gestão de documentos eletrônicos ao longo de todo o seu ciclo de vida: criação ou

captura, distribuição, edição e validação, arquivamento e deletamento.

2.8 Segurança da informação

Claudio Neiva

2.8.1 A importância da segurança da informação no processo de contratação de serviços e produtos de tecnologia da informação no governo

O governo brasileiro é responsável por gerenciar e proteger uma grande quantidade de informações confidenciais e sensíveis de seus cidadãos. Por essa razão, *a segurança da informação é um aspecto crítico para a Administração Pública*. Este tópico tem como objetivo apresentar a importância da segurança da informação no processo de contratação de serviços e produtos de tecnologia da informação pelo governo, com base na Política Nacional de Segurança da Informação, princípios de governança e o *framework* do NIST e CIS-Controls.

O *framework* do NIST (*National Institute of Standards and Technology*) é um conjunto de diretrizes e boas práticas de segurança da informação para organizações governamentais e privadas nos Estados Unidos. Ele inclui um conjunto de padrões, diretrizes e recomendações para gerenciar e proteger informações sensíveis e sistemas de informação. O *framework* do NIST é composto por cinco funções principais: identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Apesar de ser um *framework* para organizações dos Estados Unidos, o NIST é aceito globalmente e proporciona uma linguagem acessível no momento da construção do plano estratégico de segurança das organizações públicas brasileiras.

Já o *CIS Controls* (*Center for Internet Security*) é um conjunto de 20 controles de segurança cibernética que fornecem um guia abrangente para a implementação de uma estratégia eficaz de segurança da informação em organizações de todos os tamanhos. Os controles CIS foram desenvolvidos com base em anos de experiência em segurança cibernética e fornecem um *roadmap* prático para abordar as ameaças mais comuns enfrentadas por organizações em todo o mundo. Eles cobrem desde questões básicas de segurança, como a instalação de *softwares* de segurança, até medidas mais avançadas, como a análise de vulnerabilidades e a implementação de políticas de autenticação forte.

O gestor de segurança da informação deve encontrar um equilíbrio entre a proteção dos dados dos cidadãos e a transparência exigida pela lei.⁵⁴ Por um lado, é importante garantir a privacidade e proteção dos dados pessoais dos cidadãos, implementando medidas de segurança da informação que garantam a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. Isso pode incluir governança de dados, criptografia, autenticação, controle de acesso, monitoramento e outras técnicas de segurança da informação.

Por outro lado, é importante atender aos requisitos legais de transparência, garantindo que as informações sejam acessíveis e disponíveis aos cidadãos quando necessário. Isso pode incluir a divulgação de informações públicas, a resposta a pedidos de acesso à informação e a publicação de relatórios e informações sobre as atividades da organização.

Para balancear esses dois requisitos, o gestor de segurança da informação deve trabalhar em conjunto com os demais gestores da organização, incluindo o responsável pela transparência, a fim de definir políticas e procedimentos que atendam aos requisitos legais de transparência, ao mesmo tempo em que garantem a proteção dos dados dos cidadãos.

Uma abordagem importante para encontrar esse equilíbrio é adotar *um modelo de governança corporativa*, que permita uma *gestão integrada dos riscos de segurança da informação e transparência*. Isso envolve a definição de políticas e processos para identificar, avaliar, gerenciar e comunicar os riscos associados à segurança da informação e à transparência, a fim de garantir que as atividades da organização sejam conduzidas de forma ética e responsável.

Outro aspecto de igual importância é a *criação de uma arquitetura contemporânea* que suporte o momento de governo que permita atender tecnologias legadas até o uso completo de nuvem como entrega dos serviços de tecnologia da informação para sociedade brasileira. Desta forma, a arquitetura precisa considerar modelos de entrega de serviços que permitam proteção unificada de “*on-premises*” (*Data Center* próprio), “*collocation*” (hospedagem de *Data Center* particular com equipamentos próprios), nuvem pública e híbrida.

Para construir uma arquitetura de segurança e políticas de segurança que permitam a conformidade com as novas regulamentações e traga eficiência na proteção dos dados, é importante seguir os seguintes passos.

2.8.1.1 Avaliar as regulamentações aplicáveis

O primeiro passo é *avaliar as regulamentações aplicáveis à organização*, incluindo leis, normas, padrões e diretrizes de segurança da informação. Isso permitirá identificar os requisitos específicos que a organização deve cumprir em relação à segurança da informação e privacidade de dados.

- *Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709/2018* – A LGPD é uma lei que estabelece regras para o tratamento de dados pessoais no Brasil. Ela foi inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia e entrou em vigor em setembro

de 2020. A LGPD estabelece diretrizes sobre a coleta, armazenamento, processamento e compartilhamento de dados pessoais, além de impor sanções em caso de descumprimento.

- *A nova lei de licitação do Brasil (Lei nº 14.133/2021)* – A lei de licitação do Brasil exige que as licitações para aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação incluam critérios de segurança da informação a fim de garantir a proteção dos dados e sistemas envolvidos. Além disso, as empresas que participam dessas licitações devem comprovar que possuem medidas de segurança da informação adequadas.

Algumas das principais orientações são:

1. *Especificação dos requisitos de segurança da informação:* É fundamental que os editais de licitação especifiquem claramente os requisitos de segurança da informação que as soluções de TI devem atender, incluindo a proteção de dados, prevenção contra ameaças cibernéticas e garantia da disponibilidade e integridade dos sistemas.
2. *Verificação da capacidade técnica das empresas licitantes:* As empresas que participam da licitação devem comprovar que possuem capacidade técnica e experiência adequadas para fornecer as soluções de TI requeridas, incluindo conhecimentos em segurança da informação.
3. *Inclusão de critérios de avaliação da segurança da informação na avaliação das propostas:* Além dos critérios de preço e qualidade das soluções de TI, é importante que a avaliação das propostas inclua também a avaliação da segurança da informação das soluções propostas pelas empresas licitantes.
4. *Uso de tecnologias emergentes com segurança:* É importante garantir que as tecnologias emergentes, como inteligência artificial e *blockchain*, sejam implementadas com segurança, para evitar riscos para a integridade e confidencialidade dos dados.
5. *Exigência de programas de integridade e compliance:* A nova lei de licitação, para as contratações de grande vulto (artigo 25, §4º),

exige a inclusão de cláusulas anticorrupção nos contratos administrativos, incluindo a exigência de que as empresas contratadas possuam programas de integridade e de *compliance*. Isso é fundamental para garantir a transparência e a ética nas contratações e evitar práticas corruptas.

Essas são algumas das principais orientações para processos licitatórios de TI, mas é importante lembrar que cada caso pode exigir medidas específicas de segurança da informação, de acordo com as necessidades e particularidades do projeto. Por isso, é fundamental contar com profissionais qualificados e experientes em segurança da informação para orientar e apoiar os processos licitatórios de TI.

- *Política Nacional de Segurança da Informação – Estratégia Nacional de Segurança Cibernética*

O Decreto nº 10.222/2020 instituiu a Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) no âmbito da Administração Pública federal. A POSIC estabelece diretrizes para a gestão da segurança da informação e comunicações em toda a Administração Pública federal, incluindo a contratação de serviços e produtos de tecnologia da informação.

- *A Política Nacional de Segurança da Informação (PNSI)*

Conjunto de diretrizes estabelecido pelo governo brasileiro para garantir a segurança das informações que circulam no ambiente governamental. Essa política define as práticas e medidas que devem ser tomadas pelas empresas terceirizadas que prestam serviços ao governo para proteger as informações sensíveis e confidenciais dos cidadãos.

Os princípios básicos da PNSI são: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esses princípios são fundamentais para garantir a proteção das informações governamentais. Além disso, a PNSI define as diretrizes para a gestão de segurança da informação, gestão de riscos, classificação das informações, gestão de incidentes de

segurança da informação e a certificação de produtos e sistemas de segurança da informação.

- *Instrução Normativa SGD/ME nº 47, de 9 de junho de 2022*

Altera a Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP do Poder Executivo Federal.

- *A Instrução Normativa nº 05/2020 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR)*

Estabelece requisitos mínimos de segurança cibernética para a Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. A norma tem como objetivo garantir a segurança dos sistemas de informação e comunicação do governo, prevenindo e combatendo ameaças cibernéticas.

Os principais requisitos da Instrução Normativa nº 05/2020 do GSI/PR são:

1. *Implementação de uma Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC):* A norma exige que todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal tenham uma POSIC, que deve estabelecer diretrizes, responsabilidades e procedimentos para garantir a segurança cibernética dos sistemas de informação e comunicação.
2. *Mapeamento dos ativos de informação:* Os órgãos e entidades devem realizar um inventário dos ativos de informação que possuem, incluindo dados, sistemas e dispositivos de rede, e manter esse inventário atualizado.
3. *Análise de riscos:* Os órgãos e entidades devem realizar análises periódicas de risco para identificar vulnerabilidades e

ameaças cibernéticas que possam afetar os sistemas de informação e comunicação.

4. *Implementação de medidas de segurança:* Com base na análise de risco, os órgãos e entidades devem implementar medidas de segurança cibernética adequadas, como controles de acesso, monitoramento de atividades de rede, criptografia de dados, entre outras.

5. *Proteção de dados pessoais:* Os órgãos e entidades devem garantir a proteção de dados pessoais, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

6. *Gestão de incidentes de segurança:* Os órgãos e entidades devem ter um plano de gestão de incidentes de segurança cibernética, que deve incluir procedimentos para detecção, resposta, investigação e recuperação de incidentes.

7. *Treinamento e conscientização:* Os órgãos e entidades devem capacitar seus colaboradores em segurança cibernética e promover a conscientização sobre a importância da segurança da informação e comunicações.

Esses são os principais requisitos da *Instrução Normativa nº 05/2020 do GSI/PR*. É importante lembrar que a norma tem caráter obrigatório para os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e que o descumprimento pode acarretar sanções administrativas e legais.

2.8.1.2 Identificar os ativos críticos

Identificar os ativos críticos da organização é imperativo, como dados, sistemas e infraestrutura, que precisam ser protegidos contra ameaças internas e externas. Isso permitirá priorizar as ações de segurança da informação e garantir a proteção dos dados mais sensíveis.

A classificação de ativos e dados é uma etapa importante para garantir a segurança da informação e comunicações em órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Tanto a Lei de Acesso à Informação (LAI) quanto a Instrução Normativa nº 05/2020 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) estabelecem a obrigatoriedade da classificação de informações em níveis de sigilo.

A classificação de ativos e dados permite identificar e priorizar os recursos de segurança cibernética necessários para proteger as informações mais críticas e sensíveis. Isso significa que os recursos de segurança podem ser alocados de forma mais eficiente, de acordo com as necessidades específicas de cada informação.

A LAI determina que as informações produzidas ou custodiadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal quando não consideradas públicas por natureza devem ser classificadas em três graus de sigilo: ultrassecreto, secreto e reservado. A classificação deve ser realizada com base em critérios como a necessidade de preservação da intimidade, da vida privada, da segurança da sociedade e do Estado, entre outros.

Já a Instrução Normativa nº 05/2020 do GSI/PR estabelece a necessidade de classificar os ativos de informação e comunicações de acordo com o seu nível de criticidade. A norma define três níveis de criticidade: alto, médio e baixo. A classificação deve ser realizada com base em critérios como o impacto da perda de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, a importância para a continuidade do negócio, entre outros.

A classificação de ativos e dados permite que os órgãos e entidades da Administração Pública Federal possam adotar medidas de segurança adequadas para proteger suas informações. Por exemplo, informações classificadas como ultrassecretas devem receber proteção máxima, com acesso restrito apenas a pessoas autorizadas e medidas de criptografia de dados. Já informações

classificadas como reservadas podem ter medidas de segurança menos restritivas.

Em resumo, a classificação de ativos e dados é fundamental para garantir a segurança da informação e comunicações em órgãos e entidades da Administração Pública Federal. A LAI e a Instrução Normativa nº 05/2020 do GSI/PR estabelecem a obrigatoriedade dessa classificação, para garantir que as informações mais críticas e sensíveis recebam as medidas de segurança adequadas.

2.8.1.3 Definir políticas de segurança

Com base nos requisitos regulatórios e na identificação dos ativos críticos, é importante definir políticas de segurança que estabeleçam as diretrizes para a gestão de segurança da informação na organização. Essas políticas devem definir as responsabilidades dos usuários e dos gestores de TI, bem como os procedimentos de segurança a serem seguidos.

Além do alinhamento com a Política Nacional de Segurança da Informação, os gestores públicos devem conhecer a missão e características peculiares às atividades desempenhadas pela sua organização. Este entendimento proporciona uma exequibilidade dos deveres e responsabilidade dos funcionários da organização. Nada pior que uma política que não tenha conexão com as atividades diárias do órgão público. Esta desconexão normalmente leva ao não cumprimento das normas da organização, expondo-a a sérios riscos de segurança.

2.8.1.4 Implementar controles de segurança

Com base nas políticas de segurança definidas, é importante *implementar controles de segurança que permitam a proteção dos dados*

críticos da organização. Esses controles podem incluir autenticação, criptografia, controle de acesso, monitoramento e outros.

1. *Realizar testes e avaliações:* é importante realizar testes e avaliações de segurança de forma regular para garantir que a arquitetura de segurança e as políticas estejam sendo seguidas e que os controles de segurança estejam funcionando corretamente. Isso permitirá identificar possíveis vulnerabilidades e corrigi-las antes que se tornem um problema.

2. *Monitorar a conformidade regulatória:* por fim, é importante monitorar a conformidade regulatória de forma regular, a fim de garantir que a organização esteja cumprindo os requisitos legais e regulatórios aplicáveis. Isso pode incluir a realização de auditorias internas e externas, a revisão de relatórios e documentos regulatórios, bem como a criação de um plano que englobe todos os processos de identificação de leis, instruções normativas e outras regras de governo que tornam o trabalho do gestor público mais complexo, “*frameworks*” conhecidos podem colaborar na implementação de controles coerentes com todos os requisitos já expostos. Segue um exemplo de *framework* baseado no NIST E CIS-CONTROLS.

Requisitos de regulações brasileiras	Framework NIST	CIS Controls
Política de Segurança da Informação	Identificação e gestão de riscos; planejamento de continuidade de negócios; gerenciamento de mudanças	Identificação de ativos; gestão de configuração; controle de acesso
Criptografia de dados confidenciais	Proteção de dados em repouso e em trânsito; gerenciamento de chaves	Proteção de dados confidenciais

Autenticação de usuários	Gerenciamento de identidades e acesso	Autenticação multifator
Controle de acesso a informações sensíveis	Gerenciamento de identidades e acesso; controle de acesso baseado em funções	Controle de acesso; privilégios de conta
Monitoramento e auditoria de acesso a informações sensíveis	Deteção de anomalias; monitoramento de eventos e incidentes; registro e auditoria de atividades de usuários	Monitoramento de eventos de segurança; deteção e resposta a incidentes
Resposta a incidentes de segurança da informação	Planejamento de continuidade de negócios; gerenciamento de incidentes de segurança da informação	Resposta a incidentes de segurança
Treinamento de usuários em segurança da informação	Conscientização em segurança da informação; educação e treinamento em segurança da informação	Conscientização em segurança da informação; treinamento e educação em segurança da informação

Em resumo: *a construção de uma política e arquitetura de segurança eficiente que permita conformidade com as novas regulamentações envolve a avaliação dos requisitos regulatórios aplicáveis, a identificação dos ativos críticos, a definição de políticas de segurança, a implementação de controles de segurança, a realização de testes e avaliações e a monitoração da conformidade regulatória.*

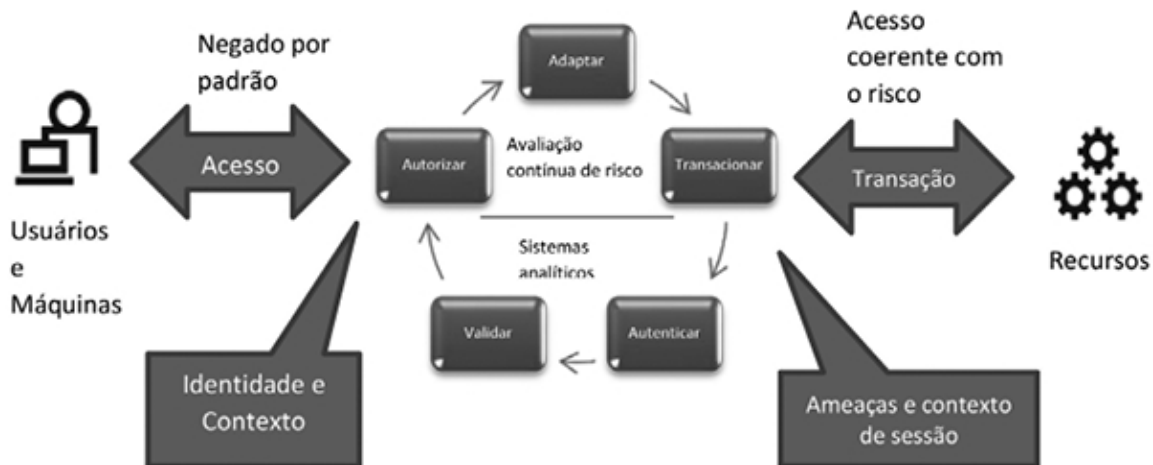
O gestor público tem dentro de suas atribuições identificar e mapear recursos tecnológicos que atendam tecnicamente os requisitos regulatórios, além de também implementar os processos de notificação de incidentes e processos de conformidade estabelecidos em regulação.

A escolha de uma filosofia de segurança da informação também pode colaborar com as escolhas de tecnologias mais adequadas e

com a definição de uma política de segurança mais coerente com as necessidades enfrentadas no âmbito público. A exemplo disso, o conceito de “*zero trust*” pode pavimentar o caminho de uma estratégia de segurança coerente com a nova lei e, ao mesmo tempo, colabora com a elevação do nível de visibilidade e controle de acesso aos dados do governo.

O *conceito de zero trust* (confiança zero) é uma abordagem de segurança da informação que parte do princípio de que não se deve confiar em nenhuma pessoa, dispositivo ou sistema, mesmo que estejam dentro da rede corporativa ou do perímetro de segurança da organização. Isso significa que todas as solicitações de acesso a recursos de TI devem ser verificadas e autenticadas, independentemente da origem ou localização do usuário ou dispositivo.

Em outras palavras, o *zero trust* trata todas as solicitações de acesso como potencialmente mal-intencionadas e requer que cada solicitação seja validada antes de conceder acesso aos recursos de TI. Para isso, utiliza-se uma variedade de técnicas de segurança, como autenticação multifator, criptografia, análise de comportamento e microssegmentação. O objetivo do *zero trust* é fornecer um nível mais alto de segurança para os sistemas de TI, protegendo contra ameaças internas e externas e reduzindo o risco de perda ou comprometimento de dados confidenciais.



2.8.1.5 Conclusão

A segurança da informação é um aspecto crítico para o governo brasileiro. A contratação de serviços e produtos de tecnologia da informação deve ser feita com base em critérios rigorosos de segurança da informação, incluindo a implementação de medidas de segurança recomendadas pelo *Framework* do NIST e pelos *CIS Controls*. Além disso, é fundamental que as empresas terceirizadas que prestam serviços ao governo sigam as normas estabelecidas pela PNSI e pelos princípios de governança.

A segurança da informação é um desafio constante para as organizações, especialmente para aquelas que lidam com informações sensíveis e confidenciais. O governo brasileiro tem o dever de proteger as informações de seus cidadãos e garantir que as empresas terceirizadas que prestam serviços ao governo cumpram as normas de segurança da informação estabelecidas. A implementação de um programa de segurança da informação efetivo é essencial para garantir a proteção dos dados sensíveis e confidenciais do cidadão brasileiro.

- 26 Disponível em: <https://blog.algartelem.com.br/inovacao/significado-de-tics-entenda-de-uma-vez-por-todas/>.
- 27 Acórdão TCU nº 1.508/2020 – o Tribunal decidiu que a UST não pode ser entendida como métrica ou unidade de medida a ser adotada pela administração caso não haja a devida padronização. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/unidade-de-servicos-tecnicos-nao-deve-ser-utilizada-em-contratacoes-publicas-sem-padronizacao.htm>.
- 28 Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/modelo-para-a-contratacao-de-servicos-de-desenvolvimento-manutencao-e-sustentacao-de-software>.
- 29 *Pontos de função*: A métrica Análise de Pontos de Função (APF) é usada para medir o tamanho funcional de um *software*, e suas unidades de tamanho funcional são chamadas Pontos de Função (PF). Na Administração Pública Federal, a contagem de Pontos de Função é usada como referência para remunerar os contratos de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas firmados entre instituições públicas e empresas prestadoras desse tipo de serviço. Existem vários benefícios em se utilizar essa métrica: regras de contagem objetivas, independência de solução tecnológica utilizada e facilidade de estimativa nas fases iniciais do ciclo de vida do *software*. A Instrução Normativa MP/SLTI nº 4, de 11 de setembro de 2014, a Portaria SLTI/MP nº 31, de 29 de novembro de 2010, e acórdãos do TCU recomendam o uso de métricas em contratos de projeto de *software* e não mais por esforço homem-hora.
- 30 *Guidelines for ICT outsourcing* (*Outsourcing* contratação externa, em tradução literal). Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0AE48C2412D0&sa=U&ved=2ahUKewjgzLa6pcj-AhWZgP0HHZmfB-0QFnoECAAQAQ&usg=AOvVaw00BTwl7ETvl1f7mqpcC7pe>.
- 31 Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/sobre-o-sisp/orgaos-do-sisp>.
- 32 Disponível em: <https://plataformanuvem.wordpress.com/2011/11/21/definicao-de-computacao-em-nuvem-segundo-o-nist/>.
- 33 Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategias-e-politicas-digitais/computacao-em-nuvem/qual-a-definicao-para-computacao-em-nuvem>.
- 34 *Cluster* – é o termo em inglês que significa aglomeração. No caso de computação, esse termo determina uma arquitetura de sistema, permitindo que vários computadores trabalhem de forma simultânea.
- 35 Migração para nuvem refere-se ao processo de transferência de dados de um ambiente físico (*data center*) para servidores em nuvem.
- 36 Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/diretrizes-para-contratacao-de-servicos-de-computacao-em-nuvem>.
- 37 *Engagement manager*: é um líder estratégico e técnico que coordena a entrega de resultados de negócios definidos para o projeto, impulsiona a agilidade e acelera a jornada de um cliente para a nuvem. Gerentes de engajamento executam uma variedade de tarefas com o objetivo de alinhar as partes interessadas, mitigar riscos e potencializar o sucesso da equipe.
- 38 *Sprint*: é o período de tempo real em que a equipe de projeto trabalhará em conjunto para concluir um incremento. Normalmente, uma *Sprint* dura duas semanas, mas pode variar de acordo com as necessidades do projeto e da equipe. Quanto mais complexo for o trabalho e mais incógnitas houver, mais curta deve ser a *Sprint*.

- 39 IDC White Paper – Fostering Business and Organizational Transformation to Generate Business Value with AWS <https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-BV%20IDC%202018.pdf?aliId=1614258770>.
- 40 Cloud computing offers the greatest benefits when strong FinOps capabilities are in place to continuously manage and optimize costs – Mckinsey <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/cloud-cost-optimization-simulator>.
- 41 Gartner: 4 Trends Impacting Cloud Adoption in 2020 – <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/4-trends-impacting-cloud-adoption-in-2020>.
- 42 IDC White Paper – <https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-BV%20IDC%202018.pdf?aliId=1614258770>.
- 43 IA: Inteligência Artificial (IA) é um campo da ciência da computação dedicado a resolver problemas cognitivos geralmente associados à inteligência humana, como aprendizado, solução de problemas e reconhecimento de padrões.
ML: Machine Learning é a ciência do desenvolvimento de algoritmos e modelos estatísticos que os sistemas de computador usam para realizar tarefas sem instruções explícitas, confiando em padrões e inferências.
- 44 Modelo de Contratação de Serviços de Operação de Infraestrutura e de Atendimento a Usuários de TIC – Governo Digital (www.gov.br).
- 45 PORTARIA SGD/ME nº 4.668, De 23 de maio de 2022 – PORTARIA SGD/ME nº 4.668, de 23 de maio de 2022 – DOU – Imprensa Nacional (in.gov.br).
- 46 GSTI (Gerenciamento de Serviços de TI): Ferramentas de GSTI dão suporte às operações de TI nas organizações, facilitam as tarefas e fluxos de trabalho associados ao gerenciamento e entrega de serviços de TI de qualidade. Estes são mais usados por centrais de serviços de TI e funções de entrega de serviços de TI.
- 47 ITIL (Information Technology Infrastructure Library): guia contendo as melhores práticas para de gerenciamento dos serviços de TI. Está estruturada em cinco livros principais para cobrir o ciclo de vida completo dos serviços: estratégia de serviço, design de serviço, transição de serviço, operação de serviço e melhoria contínua de serviço.
- 48 DevOps – é a combinação de filosofias culturais, práticas e ferramentas que aumentam a capacidade de uma organização de fornecer aplicativos e serviços em alta velocidade: evoluindo e melhorando produtos em um ritmo mais rápido do que organizações que usam processos tradicionais de desenvolvimento de *software* e gerenciamento de infraestrutura. Essa velocidade permite que as organizações atendam melhor seus clientes e concorram com mais eficiência no mercado. Em um modelo DevOps, as equipes de desenvolvimento e operações trabalham juntas em todo o ciclo de vida do produto, serviço, desde o desenvolvimento e teste até a implantação e as operações.
DevSecOps: refere-se a uma extensão do conceito de DevOps que combina dois grupos de recursos: desenvolvimento e operações. O DevSecOps integra a dimensão de segurança como terceiro grupo de recursos. É a prática de integrar testes de segurança a todas as etapas do processo de desenvolvimento de *software*. Inclui ferramentas e processos que incentivam a colaboração entre desenvolvedores, especialistas em segurança e equipes de operação para criar *software* eficiente e seguro. Assim, usando práticas, ferramentas e uma nova abordagem cultural, as equipes podem construir e entregar serviços em maior velocidade e em escala.
- 49 Backup: cópia de segurança de arquivos. É o processo de criar uma cópia dos dados de um dispositivo ou sistema de armazenamento de dados como PC, *notebooks*, servidores,

nuvem, celular, entre outros, para proteger a integridade das informações importantes em caso de falha do dispositivo ou do sistema, como uma pane de *hardware*, um ataque de vírus, um erro humano ou até mesmo um desastre natural. Uma vez tendo sido armazenados de forma segura e íntegra, podem ser recuperados e o tempo de inatividade da empresa ser minimizado. Os *softwares* de *backup/recuperação* são projetados para fornecer *backup* de armazenamento em fita, disco ou dispositivos ópticos e para recuperar esses dados quando necessário. Este segmento também inclui produtos focados especificamente no suporte ao processo de recuperação, como as bibliotecas de fitas virtuais. Também estão incluídos produtos de gerenciamento de mídia, desduplicação e relatórios de *backup*, bem como produtos de arquivamento incluídos no aplicativo de backup. As atividades de gerenciamento de mídia incluem alocação, rotulagem, rastreamento, reciclagem e monitoramento de mídia, bem como o gerenciamento de pool de armazenamento.

50 ETL (*Extract, Transform, Load*) – Extração, transformação e carregamento (ETL) correspondem ao processo de combinação de dados de várias fontes em um grande repositório central, chamado de *data warehouse*. O processo de ETL usa um conjunto de regras de negócios para limpar e organizar dados brutos e prepará-los para o armazenamento, análise de dados e *machine learning* (ML). Um sistema ETL precisa ser capaz de se comunicar com bases de dados e ler diversos formatos de arquivos utilizados por toda a organização.

51 VoIP – Voice over Internet Protocol é uma tecnologia que permite a transmissão de voz por IP, o que significa que converte sinais de áudio analógicos, como os utilizados em uma chamada telefônica convencional, em dados digitais que podem ser transferidos através da internet.

52 Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/planilha-de-estimativa.ods>.

53 Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/nota-metodologica.pdf>.

54 A lei de transparência do governo brasileiro é a Lei nº 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, também conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI). Essa lei regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas, estabelecendo regras e procedimentos para que qualquer pessoa possa solicitar informações aos órgãos e entidades públicas brasileiras. A LAI tem como objetivo garantir o acesso à informação de interesse público, promovendo a transparência na Administração Pública e permitindo que os cidadãos possam participar ativamente do controle e da fiscalização das atividades estatais. Além disso, a lei também prevê a divulgação proativa de informações pelos órgãos públicos, que devem disponibilizar em seus sites oficiais uma série de informações de interesse público, sem a necessidade de solicitação específica.

GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES

Anderson Sant'Ana Pedra

Gabriela Verona Pércio

Segundo o *Acórdão TCU nº 2.622/2015*, a governança das aquisições e contratações públicas compreende o conjunto de mecanismos de liderança, capacidades institucionais, estratégia e controle.

Ainda no âmbito da Administração Pública Federal, a Portaria SEGES/ME nº8.678/2021 definiu a governança das contratações públicas como: um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão das contratações públicas, visando a agregar valor ao negócio do órgão ou entidade e contribuir para o alcance de seus objetivos, com riscos aceitáveis.

3.1 A Nova Lei de Licitações e a governança das contratações

A Lei nº 14.133/2021, chamada de Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLCA), trouxe uma importante inovação normativa ao disciplinar a governança das contratações.^{[55](#)} As falhas de governança vinham sendo apontadas pelos Tribunais de Contas como a causa para diversos problemas detectados nos

processos de contratação que inviabilizavam, muitas vezes, a obtenção dos resultados pretendidos pela organização.⁵⁶ As novas regras representam incentivos suficientes para a implementação de medidas de governança pelos responsáveis, uma vez que a toda evidência a inércia poderá levar à responsabilização.

Segundo o parágrafo único do art. 11, ⁵⁷ a governança das contratações está sob responsabilidade da alta administração.

Ou seja, das autoridades situadas no topo da hierarquia, detentoras do poder necessário à tomada de decisões e à definição dos rumos de gestão. Tais autoridades deverão implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos do processo licitatório, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

No contexto das novas regras, é possível identificar, também, outros dispositivos específicos, inerentes à temática da governança das contratações, tais como:

- art. 6º, inc. XXIII, que traz como elementos descritivos do termo de referência os modelos de execução do objeto e de gestão do contrato;⁵⁸
- art. 7º, que trata da gestão por competências na designação de agentes para atuar no desempenho das funções essenciais;⁵⁹

- art. 7º, §1º, que trata do princípio da segregação de funções aplicado às funções mais suscetíveis a riscos, dentro de um mesmo processo de contratação;⁶⁰
- art. 8º, §3º, que traz a obrigatoriedade dos regulamentos dispondo sobre as regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos, bem como sobre a possibilidade de contarem com o apoio e o auxílio da assessoria jurídica e do controle interno;⁶¹
- art. 12, inc. VII e §1º, que trouxe o plano de contratações anual como instrumento de racionalização das contratações e fomento ao mercado fornecedor;⁶²
- art. 18, que prevê como elemento do estudo técnico preliminar a avaliação quanto às providências relacionadas à capacitação de agentes para a fiscalização e gestão contratual;⁶³
- art. 25, §4º, que obriga a exigência de implantação de programa de integridade pela empresa contratada para executar obras e serviços de grande vulto;⁶⁴
- art. 169, que trata da gestão de riscos em linhas de defesa;⁶⁵ e
- art. 169, §1º, que traz como critérios para a definição das práticas de gestão de riscos a serem implementadas os custos, os benefícios, o potencial para promover relações íntegras e confiáveis e para produzir o resultado mais vantajoso, com eficiência, eficácia e efetividade.⁶⁶

Pode-se dizer, ainda, que a própria *inserção do planejamento como princípio* que deve orientar a aplicação da Lei⁶⁷ e a elaboração da fase preparatória da contratação⁶⁸ *favorece a implementação da boa governança*, assim como a elaboração do estudo técnico preliminar,⁶⁹ que possibilita à Administração não apenas uma avaliação da melhor solução para o seu problema, mas o repensar de condutas de

consumo e a identificação de melhores resultados pretendidos em termos de economicidade e aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

Nesse contexto, é preciso entender a importância das contratações de soluções de TIC para a Administração Pública e como a governança das contratações pode auxiliar na obtenção de melhores resultados para essa área.

No tocante ao primeiro aspecto, a importância de tais contratações, torna-se evidente sua relevância quando analisada sob a ótica da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP do Poder Executivo Federal, a qual define como solução de TIC o conjunto de bens e/ou serviços que apoiam processos de negócio mediante a conjugação de recursos de TIC e que se adéquam a pelo menos uma das seguintes categorias, definidas no seu Anexo II: materiais e equipamentos de TIC, desenvolvimento e sustentação de sistemas, hospedagem de sistemas, suporte e atendimento de usuários de TIC, infraestrutura de TIC, comunicação de dados, *software* de aplicativos, consultoria em TIC, comunicação em nuvem, segurança da informação e privacidade, análise de dados, aprendizagem de máquina e inteligência artificial.⁷⁰

Em relação ao segundo aspecto, como a governança das contratações pode auxiliar na obtenção de melhores resultados para essa área, será avaliado no último tópico deste capítulo.

3.2 Os objetivos das contratações públicas

Pode-se afirmar que os *objetivos* das contratações públicas, e não diferentes os das contratações de TIC, são: i) atingir o interesse

público; *ii*) observar a impessoalidade; *iii*) garantir a contratação mais vantajosa; e *iv*) cumprir o princípio da eficiência administrativa; todos esses princípios positivados no *caput* do art. 5º da NLLCA.⁷¹

3.2.1 Atingir o interesse público

A ideia de *interesse público* decorre da própria forma republicana prevista no art. 1º, *caput*, da Constituição brasileira de 1988, que exige que a Administração Pública brasileira atue em benefício do bem comum, encontrando nesse princípio seu *fundamento* e seu *limite*.

Pode-se definir o interesse público como o *interesse coletivo*, o *interesse geral de uma determinada sociedade*, o *bem comum*, ou seja, “aquilo que é necessário para que os homens não apenas vivam, mas vivam bem”.⁷²

O princípio do *interesse público* possui algumas peculiaridades pragmáticas no Direito Administrativo, sendo importante destacar:⁷³

- i. sua definição primeira é dada por meio de instrumentos normativos primários (emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções);
- ii. a Administração apenas poderá definir o interesse público caso haja permissivo legal para tanto;
- iii. uma vez definido pelo legislador, cabe à Administração sua prossecução;
- iv. sua noção é flexível, variando de acordo com o momento (cronológico) histórico e o contexto social.

Além dessas particularidades, cabe destacar que o *interesse público* é o *motivo determinante último de qualquer contratação pública*. Assim, se uma contratação for praticada sem que se observe essa premissa – a consecução do interesse público –, ela estará viciada por *desvio de finalidade* (desvio de poder).

3.2.2 Observar a impessoalidade

O *princípio da impessoalidade* (ou da *imparcialidade*) é uma derivação do direito fundamental à igualdade (formal e material), previsto no art. 5º, *caput*, da Constituição brasileira de 1988, e no art. 5º da NLLCA, sendo que a impessoalidade está prevista no mesmo dispositivo da NLLCA e no art. 37, *caput*, da Constituição.

Sendo uma faceta do *princípio da igualdade*, o *princípio da impessoalidade* impõe que a Administração Pública dispense tratamento isonômico de oportunidades a todos, sem privilégios e direcionamentos, devendo agir com neutralidade, isento de interesses particulares (pessoais e/ou terceiros), políticos ou de grupos.

Para tanto, um eventual edital de licitação de TIC deve ser balizado por um *julgamento objetivo* fundado em parâmetros estritamente técnicos, precisos, determinados; afastando-se, assim, subjetivismos, personalismos e favorecimentos ilegítimos; de igual modo, uma contratação direta de serviços de TIC também deve receber a mesma parametrização.

3.2.3 Garantir a contratação mais vantajosa

O *princípio da economicidade* previsto no art. 70, *caput*, da Constituição brasileira de 1988 expressa o aspecto financeiro do *princípio da eficiência*, devendo ser aferido pelo desempenho do *custo-benefício* da Administração Pública, ou seja, a economicidade exige que a Administração obtenha o melhor produto ou serviço, efetuando a contratação mais vantajosa.

Deve ficar assente que o *princípio da economicidade* está longe de se resumir em uma contratação *mais barata*, pelo *menor preço*. Obediência ao *princípio da economicidade* significa realizar a contratação pelo *melhor preço* (ou *melhor proposta* ou *proposta mais vantajosa*), e não pelo *menor preço*.⁷⁴

Por vezes, a fim de almejar a *melhor proposta* (*proposta mais vantajosa*), deverá a Administração realizar uma contratação em que serão verificados outros critérios que não exclusivamente o pecuniário, a fim de promover a melhor contratação de TIC.

3.2.4 Cumprir o princípio da eficiência administrativa

O *princípio da eficiência administrativa*⁷⁵ ou o *dever de boa administração* deve traduzir uma atuação administrativa cujos atos estejam inspirados na “necessidade de satisfazer da forma mais eficiente – isto é, mais racional”,⁷⁶ cancelando a necessidade de se buscar uma Administração Pública gerencial, focada nos resultados, e abandonando uma Administração Pública burocrática e formal.⁷⁷

Pelo *princípio da eficiência administrativa* o agente público deve exercer suas competências com presteza, perfeição, sem burocracia, buscando sempre a qualidade, evitando desperdícios, garantindo a melhor entrega para a sociedade, para, ao fim, apresentar resultados efetivos (eficácia).

A Lei nº 14.129/2021 (“Governo Digital”) traz um *conjunto de princípios, regras e instrumentos para o aumento da eficiência da Administração Pública, notadamente por meio da desburocratização, da inovação e da transformação digital*.

O art. 3º da Lei nº 14.129 elenca dentre os princípios e as diretrizes para o aumento da eficiência para as contratações públicas: *i) o uso da tecnologia para otimizar processos de trabalho da Administração Pública; ii) o estímulo ao uso das assinaturas eletrônicas nas interações e nas comunicações entre órgãos públicos e entre estes e os cidadãos; iii) a adoção preferencial, no uso da internet e de suas aplicações, de tecnologias, de padrões e de formatos abertos e livres; e iv) a promoção do desenvolvimento tecnológico e da inovação no setor público*.

Por fim, deve se consignar que a *eficiência administrativa* precisa ser buscada dentro das possibilidades trazidas pela NLLCA e dentro das interpretações plausíveis que existirem, inclusive para as contratações de TIC, conforme se verá no item seguinte.

3.3 Governança nas contratações de TIC e o uso das ferramentas da NLLCA

A NLLCA trouxe ferramentas importantíssimas que possibilitam novas estratégias para a obtenção de melhores resultados nas contratações de TIC. Entre elas, podem ser citadas a *pré-qualificação de licitantes, de bens e de serviços, a homologação de amostras, a remuneração variável e o contrato de eficiência*.

A utilização ou não de cada uma dessas ferramentas deverá ser apreciada na *fase preparatória* da contratação e devidamente fundamentada, mas é possível afirmar que, se bem manuseadas, contribuirão para boas contratações de TIC.

3.3.1 Pré-qualificação

A *pré-qualificação* está definida no inc. XLIV do art. 6º como o “procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação, total ou parcial, dos *interessados* ou do *objeto*”.

Trata-se de procedimentos distintos, a *pré-qualificação de licitantes* (subjetiva) e a *pré-qualificação de bens ou serviços* (objetiva), sendo que ambas têm por finalidade tornar a licitação mais eficiente, antecipando a análise de documentos de habilitação dos futuros licitantes ou a análise do objeto que será oferecido, conforme o caso.

Em algumas situações, devidamente justificadas, será possível realizar a futura licitação apenas entre os licitantes que foram pré-

qualificados ou restrita aos bens e serviços que foram pré-qualificados.⁷⁸

A decisão de realizar a licitação restrita deverá ser tomada de forma cuidadosa, pois, apesar de autorizada pela lei, carrega consigo o risco de prejuízo à competição. Será necessário analisar o risco de atuação de licitantes em conluio, já que, em princípio, não haverá sigilo sobre a decisão de pré-qualificação. Nesse caso, deverão ser identificadas e fixadas regras que visem impedir a concretização de tal prejuízo.

O art. 80 da NLLCA trata de vários aspectos da pré-qualificação, mas há um evidente espaço para o estabelecimento de regras operacionais pelo ente federativo, visando a sua efetiva implementação.⁷⁹

3.3.2 Homologação de amostras

O procedimento de análise de amostras não é novidade da NLLCA, pois já vinha sendo amplamente utilizado pela Administração Pública em suas licitações, mediante previsão em edital, sempre que requerido pela natureza do objeto. A NLLCA trata do assunto nos seguintes dispositivos:

- art. 17, §3º: o edital poderá prever que o licitante provisoriamente vencedor deverá apresentar amostra, para que seja realizada análise e avaliação da conformidade e prova de conceito (PoC), entre outros testes de interesse da Administração;
- art. 41, inc. II: a amostra poderá ser exigida no procedimento de pré-qualificação de bens permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previsto no

edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação;

- art. 42, §2º: o edital poderá exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do licitante provisoriamente vencedor, para atender a diligência ou, após o julgamento, como condição para firmar contrato; e
- art. 42, §3º: as amostras poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional na especialidade do objeto, previamente indicada no edital.

A *homologação de amostra*, comumente denominado de PoC (prova de conceito) nas contratações de TIC, destina-se a efetivar uma contratação eficiente por permitir a Administração analisar, previamente à assinatura do contrato, a efetiva adequação entre o objeto que se pretende entregar e a necessidade administrativa trazida no Termo de Referência.⁸⁰

3.3.3 Remuneração variável

O instituto da remuneração variável vincula o pagamento aos resultados entregues pelo contratado. Trata-se, portanto, de um excelente incentivo ao contratado para a entrega de resultados ótimos: quanto melhores os resultados, melhor será a remuneração, que será ajustada conforme os parâmetros objetivos estabelecidos no contrato.⁸¹ Da mesma forma, resultados abaixo do esperado trarão prejuízos ao contratado, que deixará de receber de acordo com eventuais expectativas e poderá, inclusive, sofrer as sanções previstas.

A utilização da remuneração variável deverá ser motivada⁸² na fase preparatória do processo de contratação e, por óbvio, constar

claramente do edital, sujeita a impugnações formuladas por qualquer interessado.

O termo “remuneração variável” pode ser entendido de forma genérica para abranger, também, os pagamentos conforme o resultado em contratos que utilizem o Instrumento de Medição de Resultados (IMR) ou Acordo de Níveis de Serviço (ANS). Essa interpretação pode ser extraída do art. 144 da NLLCA, cuja redação é ampla, somada ao fato de que a Lei não disciplina, em outro dispositivo, tais ferramentas, já amplamente utilizadas no âmbito de alguns contratos de prestação de serviços celebrados pela Administração Pública, incluindo contratações de TIC.

A remuneração variável será a forma obrigatória para a remuneração do contratado quando a Administração utilizar o contrato de eficiência, uma novidade incorporada pela NLLCA, cabível em situações em que a execução do objeto tiver como objetivo proporcionar economia à Administração, na forma de despesas correntes.⁸³

3.3.4 Contrato de eficiência

O contrato de eficiência está definido no inc. LIII do art. 6º da nova lei como o “contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada”. A rigor, trata-se de uma solução que pode ter utilidade nas contratações de TIC.

Nos termos do art. 39 da NLLCA o contrato por eficiência será precedido de um julgamento por *maior retorno econômico*, que considerará a maior economia para a Administração, sendo que a remuneração desse contrato deverá ser fixada em percentual que

incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na sua execução.⁸⁴ O edital ou o contrato deverão prever parâmetros objetivos para aferir a economia gerada, podendo definir, inclusive, períodos para essa aferição (mensal, trimestral, semestral etc.).

⁵⁵ Para saber mais sobre governança pública, acesse o “Referencial Básico de Governança Organizacional para organizações públicas e outros entes jurisdicionados do TCU”, disponível em: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/RBGO_digital.-1pdf.pdf.

⁵⁶ A título exemplificativo, acessar os Acórdãos nºs 1.273/15 e 2.328/15, ambos do Plenário do TCU.

⁵⁷ “Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no *caput* deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.”

⁵⁸ “Art. 6º, XXIII – termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

...

e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;

f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;”.

⁵⁹ “Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos:

I – sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública;

II – tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e

III – não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.

§1º A autoridade referida no *caput* deste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

§2º O disposto no *caput* e no §1º deste artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.”

⁶⁰ “Art. 7º, §1º A autoridade referida no *caput* deste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação

simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.”

[61](#) “Art. 8º, § 3º As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos de que trata esta Lei serão estabelecidas em regulamento, e deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta Lei.”

[62](#) “Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

...

VII – a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

§1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do *caput* deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos.”

[63](#) “Art. 18, §1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do *caput* deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

...

X – providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;”

[64](#) “Art. 25, §4º Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento.”

[65](#) “Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:

I – primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade;

II – segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade;

III – terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da Administração e pelo tribunal de contas.”

[66](#) “Art. 169, §1º Na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se refere o *caput* deste artigo será de responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade e levará em consideração os custos e os benefícios decorrentes de sua implementação, optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos, e que produzam o resultado mais vantajoso para a Administração, com eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas.”

[67](#) “Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).”

[68](#) “Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do *caput* do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:...”

[69](#) “Art. 6º, XX – estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;”.

[70](#) Art. 2º, VII c/c Anexo II, da IN nº 94/2022-SGD/ME.

[71](#) Os *objetivos do processo licitatório* estão elencados no *caput* do art. 11 da NLLCA: *i)* assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto; *ii)* assegurar tratamento isonômico, bem como a justa competição; *iii)* evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos; e *iv)* incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. As *contratações públicas* ocorrem, em regra, mediante “processo licitatório”, mas podem ocorrer também diretamente, sem licitação, de acordo com os arts. 72 a 75 da NLLCA.

[72](#) AMARAL, Diogo Freitas do. *Curso de direito administrativo*. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2012. v. II, p. 43-44.

[73](#) PEDRA, Anderson Sant’Ana. Comentários ao art. 5º. In: FORTINI, Cristiana; OLIVEIRA, Rafael Sérgio Lima de; CAMARÃO, Tatiana. *Comentários à lei de licitações e contratos administrativos: lei 14.133, de 1º de abril de 2021*. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2023. p. 137.

[74](#) PEDRA, Anderson Sant’Ana. Comentários ao art. 5º. In: FORTINI, Cristiana; OLIVEIRA, Rafael Sérgio Lima de; CAMARÃO, Tatiana. *Comentários à lei de licitações e contratos administrativos: lei 14.133, de 1º de abril de 2021*. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2023. p. 125.

[75](#) A *eficiência administrativa* consiste em fazer as coisas de forma correta e da melhor maneira possível, dando ênfase aos métodos e aos procedimentos. Calha aqui consignar a distinção entre *eficiência administrativa* e *eficácia administrativa*, institutos que têm sede originária na ciência da gestão/administração. Enquanto a *eficiência* se preocupa com os *meios*, a *eficácia* se preocupa com os *resultados*, sendo possível afirmar que uma Administração Pública *eficiente* é a ferramenta para uma Administração Pública *eficaz*.

[76](#) AMARAL, Diogo Freitas do. *Curso de direito administrativo*. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2012. v. II, p. 46.

[77](#) PEDRA, Anderson Sant’Ana. Comentários ao art. 5º. In: FORTINI, Cristiana; OLIVEIRA, Rafael Sérgio Lima de; CAMARÃO, Tatiana. *Comentários à lei de licitações e contratos administrativos: lei 14.133, de 1º de abril de 2021*. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2023. p. 118.

[78](#) “Art. 80, §10: A licitação que se seguir ao procedimento da pré-qualificação poderá ser restrita a licitantes ou bens pré-qualificados.”

79 Mais considerações podem ser encontradas no artigo “Lei 14.133/21: um olhar pragmático sobre os procedimentos auxiliares”. Disponível em: <https://www.novaleilicitacao.com.br/2022/06/17/lei-14-133-21-um-olhar-pragmatico-sobre-os-procedimentos-auxiliares/>.

80 Ao utilizar essa ferramenta, a Administração deve viabilizar o acompanhamento dessa etapa a todos os interessados em homenagem ao princípio da publicidade (TCU, Acórdão nº 1.827/2017-Plenário).

81 “Art. 144. Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital de licitação e no contrato.”

82 “Art. 144, §2º: A utilização de remuneração variável será motivada e respeitará o limite orçamentário fixado pela Administração para a contratação.”

83 “Art. 144, §1º: O pagamento poderá ser ajustado em base percentual sobre o valor economizado em determinada despesa, quando o objeto do contrato visar à implantação de processo de racionalização, hipótese em que as despesas correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários, na forma de regulamentação específica.”

84 Nos termos do art. 110 da NLLCA os contratos de eficiência poderão ter prazos mais largos de duração.

PLANEJAMENTO

Tatiana Camarão

Camila Murta

A Nova Lei de Licitações tem como um dos principais pilares o foco no *planejamento*, constando no artigo 5º da NLLCA como um dos princípios basilares para as aquisições de bens e serviços no âmbito da Administração Pública.

Trata-se de uma etapa fundamental para que a contratação ou compra atinja o resultado esperado, inclusive no que tange ao ciclo de vida do objeto.

Portanto, *o planejamento consiste na previsão e estruturação de um conjunto coordenado de ações visando alcançar o objetivo almejado. Entretanto, é necessário destacar que existem documentos que precedem o planejamento da licitação que não podem ser desconsiderados, que são o Planejamento Estratégico, o Plano de Logística Sustentável, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação e o Plano de Contratação Anual.*

O parágrafo único, do artigo 11, da Lei nº 14.133/2021 registra a necessidade do alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias, denotando sua relevância para o sucesso das compras públicas.

Já o artigo 18 da Nova Lei estabelece que a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve ser compatibilizada com o Plano de Contratações Anual (PCA), sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação.

4.1 Planejamento estratégico

Tatiana Camarão

Camila Murta

Marcos Nemakata

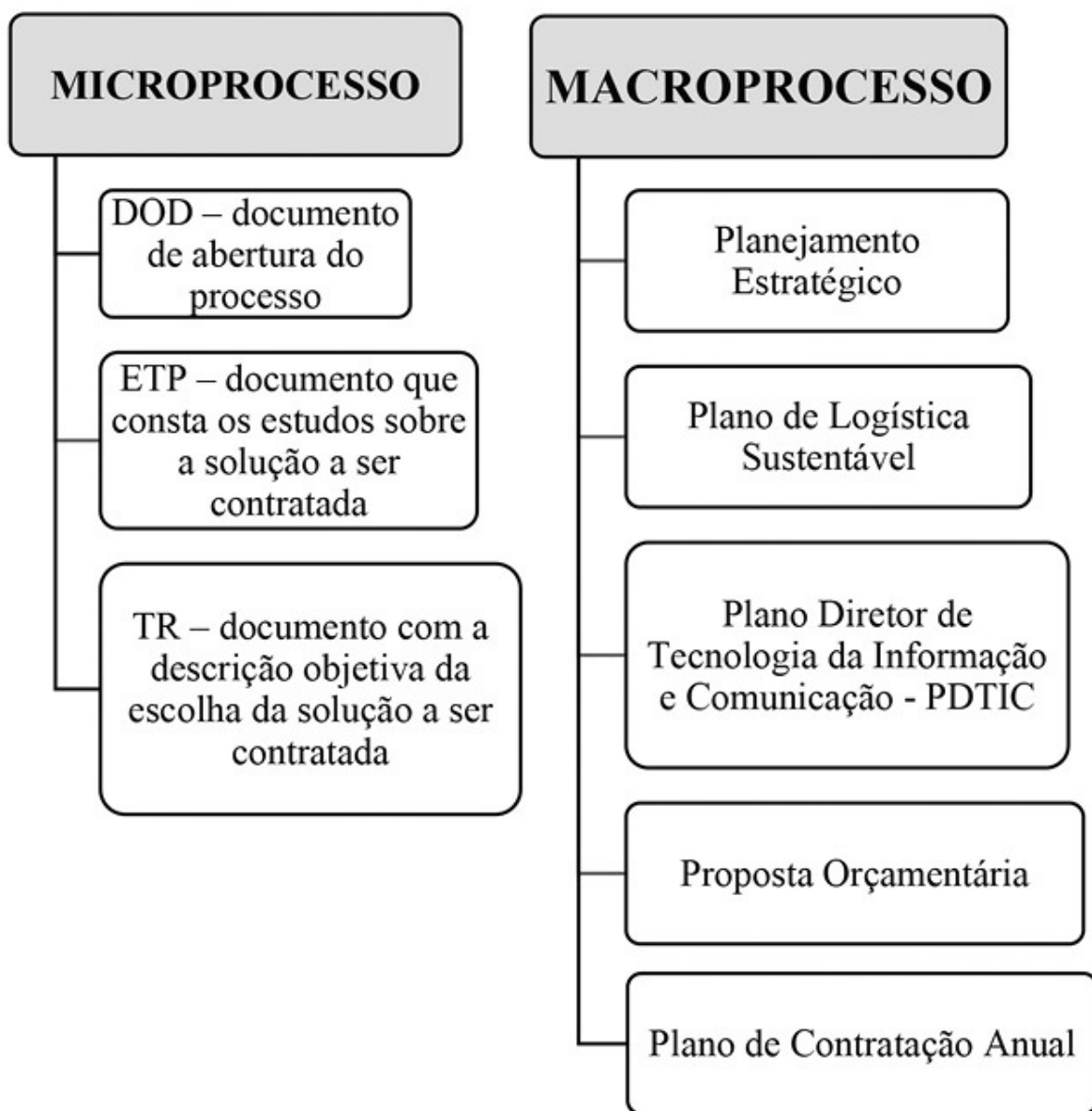
No planejamento estratégico são contempladas ações estratégicas de longo prazo e metas a serem alcançadas pelos entes públicos. Definem-se, de maneira representativa, os objetivos a serem atingidos para legitimar a atuação do ente no âmbito de sua competência, de modo a cumprir a missão estabelecida e atingir a visão de futuro pretendida.

Os objetivos e ações definidos no planejamento estratégico buscam espelhar o compromisso do órgão com a ética, a transparência, o comprometimento e a inovação e, portanto, alinhados com os atos de governança instaurados pela Lei nº 14.133/2021.

Razão pela qual o planejamento estratégico deve garantir os recursos para que os projetos e ações que gerem despesas possam ser concretizados, incluindo os serviços contínuos, as manutenções regulares, dentre outros. E tais recursos devem estar contemplados na proposta orçamentária, que por conseguinte deve fazer parte do planejamento orçamentário do Plano de Contratações Anual.

Portanto, a interligação dos instrumentos é vital para o atingimento dos objetivos estratégicos delineados pelos entes públicos. E, do ponto de vista do processo de compra públicas, têm-se duas perspectivas: a micro e a macro.

Os processos se subdividem em: i) microprocesso: que foca o planejamento em cada aquisição; e ii) macroprocesso: que foca na identificação das demandas estratégicas de contratações para o médio e longo prazos.



4.2 Plano de logística sustentável

Tatiana Camarão

Camila Murta

De acordo com o governo federal: “O Plano Diretor de Logística Sustentável (PLS) é instrumento de governança, vinculado ao planejamento estratégico do órgão ou entidade, ou instrumento equivalente, e às leis orçamentárias, que estabelece a estratégia das contratações e da logística no âmbito do órgão ou entidade, considerando objetivos e ações referentes a critérios e a práticas de sustentabilidade, nas dimensões econômica, social, ambiental e cultural”.⁸⁵



Fonte: Imagem extraída do site www.gov.br.

A Nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133/21, reitera, no art. 11, inciso IV, a sustentabilidade como propósito das contratações públicas e fortalece sua aplicabilidade apresentando, em vários dispositivos, medidas a serem adotadas para o seu efetivo alcance.

Deste modo, promover o desenvolvimento nacional sustentável se apresenta, ao lado da observância do princípio constitucional da isonomia, da seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa, da contratação de preços aceitáveis e do incentivo à inovação, como premissa indispensável às licitações públicas.

Importante destacar que a sustentabilidade é preceito constitucional, e vários dispositivos da Lei nº 14.133/21 têm como substrato os arts. 37, 170 e 225 da CF/88, os quais, respectivamente, tratam dos princípios da Administração Pública, da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa e da redução das desigualdades regionais e sociais e do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Além disso, a Agenda 2030, que contempla os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU – ODS, tem suas raízes nas dimensões econômica, social, ambiental e institucional, de forma integrada, indivisível e transversal para o atingimento das metas associadas.⁸⁶

E para assegurar que essas diretrizes sejam preservadas é mandatório na Nova Lei de Licitações que as organizações públicas implementem práticas de governança para garantir que as contratações tenham alinhamento com o planejamento estratégico e promovam um ambiente íntegro e sustentável.

O Plano de Logística Sustentável é um dos principais instrumentos de governança da NLLCA, que inclusive subsidia o Plano de Contratação Anual, e foi regulamentado pela *Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021*, que “dispõe sobre a

governança das contratações públicas no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional”, a qual traz a referência em como proceder para a elaboração do PLS.

De acordo com o art. 9º da referida Portaria, o PLS norteará a elaboração dos planos de contratações anual em nível macro e subsidiará os estudos técnicos preliminares e dos anteprojetos, projetos básicos ou termos de referência, em nível micro, das contratações realizadas pela Administração Pública federal.

Para os órgãos públicos que se utilizem das diretrizes do governo federal é obrigatório se guiar pelo art. 8º da Portaria, que traz o conteúdo mínimo, qual seja:

Art. 8º Os PLS devem conter, no mínimo:

I – diretrizes para a gestão estratégica das contratações e da logística no âmbito do órgão ou entidade;

II – metodologia para aferição de custos indiretos, que poderão ser considerados na escolha da opção mais vantajosa à Administração, relacionados às despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação, tratamento de resíduos sólidos e impacto ambiental, entre outros fatores vinculados ao ciclo de vida do objeto contratado;

III – ações voltadas para:

a) promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços;

b) racionalização da ocupação dos espaços físicos;

c) identificação dos objetos de menor impacto ambiental;

d) fomento à inovação no mercado;

e) inclusão dos negócios de impacto nas contratações públicas; e

f) divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável;

IV – responsabilidades dos atores envolvidos na elaboração, na execução, no monitoramento e na avaliação do PLS; e

V – metodologia para implementação, monitoramento e avaliação do PLS.

O Plano de Logística Sustentável deverá ainda definir as especificações técnicas do objeto, as obrigações da contratada e tratar da prova de atendimento da qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, delimitando metas e objetivos e, por conseguinte, a forma de avaliação, além de ser publicado no sítio eletrônico oficial.

O Plano de Logística Sustentável é parte da estratégia e da governança do órgão público, englobando aspectos ambientais, sociais e orçamentários, permitindo que a sustentabilidade ratifique o cumprimento da legitimidade, da legalidade e da economicidade na gestão pública.

Os ditames trazidos pela Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021, chancelados pela NLLCA, denotam uma mudança de paradigma, inserindo práticas consolidadas econômica e culturalmente, demandando, pois, a adaptação dos mecanismos de regulação ética.

O PLS traz, sobretudo, o consumo consciente, o pensar nas gerações futuras, optar por recursos renováveis e recicláveis e administrar estoques e fluxos. Portanto, configura-se como uma prática racional de compras e contratações, consolidando um conjunto de projetos, ações, metas que permitem avaliações qualitativas e quantitativas e avanços substanciais da sustentabilidade como ferramenta de estratégia em gerenciamento.

E nessa perspectiva sustentável e de responsabilidade social todas as ações e projetos do PLS devem ter como parâmetros um gerenciamento eficiente e eficaz de bens e serviços e a integração de tecnologias que tenham um impacto socioambiental menor. Assim, alguns dos principais temas relevantes para constar no PLS são:

**Temas relevantes
no PLS**

- Compras e contratações sustentáveis
- Energia elétrica, água e esgoto
- Gestão de resíduos sólidos
- Vigilância e deslocamento de pessoal

-
- Qualidade de vida
 - Capacitação socioambiental
 - Governança e sustentabilidade
 - Comunicação e sustentabilidade
-

Sobre o tema, citem-se as orientações constantes do Guia de Contratações Sustentáveis do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, edição 2021:

Os critérios de sustentabilidade nas contratações de TI devem contemplar, sempre que possível, as práticas ecologicamente corretas, que tornam mais sustentável e menos prejudicial o uso da tecnologia, priorizando a aquisição de bens e serviços de menor impacto ambiental e social, analisando todo o ciclo de vida dos equipamentos, desde a fabricação até o descarte, de forma a garantir a observância da promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

Nesse contexto, deve-se priorizar a utilização de tecnologias de virtualização, assim entendidas as soluções computacionais que permitem a execução de vários sistemas operacionais e de *softwares* a partir de uma única máquina física, visando ao melhor aproveitamento da infraestrutura existente, à redução no consumo de energia elétrica, à diminuição na geração de lixo eletrônico e a menor emissão de carbono. Deve-se priorizar também a contratação de bens e serviços fornecidos por empresas que desempenhem ações de sustentabilidade no âmbito da responsabilidade social e ambiental (a comprovação poderá ocorrer por meio de certificação ISO 14001, RoHS, Selo Procel, Selo Verde, entre outros, ou certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do

processo de fabricação, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada). Nesse ponto, é necessário atentar para as considerações realizadas neste guia no tópico sobre o uso de rotulagem e certificações.⁸⁷

4.2.1 Política de contratação sustentável

Tatiana Camarão

Camila Murta

A Política de Sustentabilidade das Contratações é um desdobramento do Plano de Logística Sustentável – PLS, o qual traz as diretrizes, objetivos e ações que servirão de guia para a elaboração da política.

Muito embora a NLLCA não aborde a Política de Contratação Sustentável, ela prevê várias ações de sustentabilidade descritas de forma dispersa nos art. 4º; art. 11, IV; art. 18, §1º, XII; art. 25, §2º; art. 34; art. 42, inciso III; art. 45; art. 60; art. 63, IV; e art. 75, IV, alínea “j” e inciso XIV, e que necessitam, para sua efetividade e aplicabilidade, de uma planificação.

Resta evidente, portanto, que a Lei nº 14.133/21 lança luz para o tratamento da sustentabilidade no seu processo e torna-se vital para sua efetividade que as organizações implementem, como desdobramento do PLS, uma política de sustentabilidade que aborde essas ações com o propósito de assegurar a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis.

Sob essa perspectiva, é fundamental que a Política de Sustentabilidade das Contratações tenha uma elaboração multifuncional e com a integração das áreas, pois esse documento se propõe a melhorar e aperfeiçoar os resultados, gerando valor para as organizações.

As contratações públicas sustentáveis previstas nas Leis nº 8.666, de 1993, e nº 14.133, de 2021, têm relação com o ODS 12 – “Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis”, em sua meta nº 7, que é a de “promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais”.

Ainda em âmbito nacional, importante ressaltar que a NLLCA traz o *desenvolvimento nacional sustentável como princípio* a ser observado na aplicação da lei e reforça essa orientação dispondo que o incentivo à inovação e ao desenvolvimento nacional sustentável são objetivos do processo licitatório. Em reforço a essa diretriz, a Lei nº 14.133/2021 dispõe que a alta administração do ente público é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos nela estabelecidos.

A IN/ME nº 40, de 22 de maio de 2020, do Ministério da Economia, estabeleceu a obrigatoriedade de elaborar os estudos técnicos preliminares – ETP, conforme as diretrizes que estabelece, para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, estendendo-se a todo tipo de contratação. As exceções à elaboração dos ETP estão previstas no seu art. 8º: facultada nas hipóteses dos incisos I, II, III, IV e XI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispensada nos casos de prorrogações contratuais relativas a objetos de prestação de natureza continuada. Conforme o art. 4º da referida Instrução Normativa, os ETPs para as contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicação deverão observar as regras específicas do Órgão Central do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – Sisp.

No art. 7º da IN/ME nº 40, de 22 de maio de 2020, estão previstos os elementos que devem constar dos Estudos Técnicos Preliminares, dentre os quais se destacam os incisos II, X e XI, que abrangem o

tema da sustentabilidade. O parágrafo único do art. 1º da IN/ME nº 40/2020 assim dispõe: “considera-se ETP o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza determinada necessidade, descreve as análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais características, dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico, caso se conclua pela viabilidade da contratação”.

O art. 2º do Decreto nº 7.746/2012, com redação dada pelo *Decreto nº 9.178, de 2017*, estabelece que, na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, a Administração Pública federal adotará critérios e práticas sustentáveis nos instrumentos convocatórios.

A Advocacia-Geral da União lançou, em agosto de 2022, a 5ª edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (GNCS),⁸⁸ detalhando a Lei nº 14.133/2021, inserindo considerações sobre o recente Plano Nacional de Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva Cidadã, bem como detalhando o Programa Agenda Ambiental na Administração Pública e o Plano de Logística Sustentável, por suas conexões com as contratações públicas sustentáveis.

No referido Guia, a AGU traz a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P),⁸⁹ que consiste em um programa cuja finalidade é fomentar e estimular os órgãos públicos a implementarem procedimentos de sustentabilidade e critérios socioambientais nas atividades do setor público. Reforça que os critérios de sustentabilidade devem ser objetivamente definidos nas peças editalícias como especificação do objeto, ou como obrigações da contratada, ou como requisito de habilitação previsto em lei especial.

As contratações de soluções e serviços TIC também fazem parte do Guia da AGU, conforme a seguir:

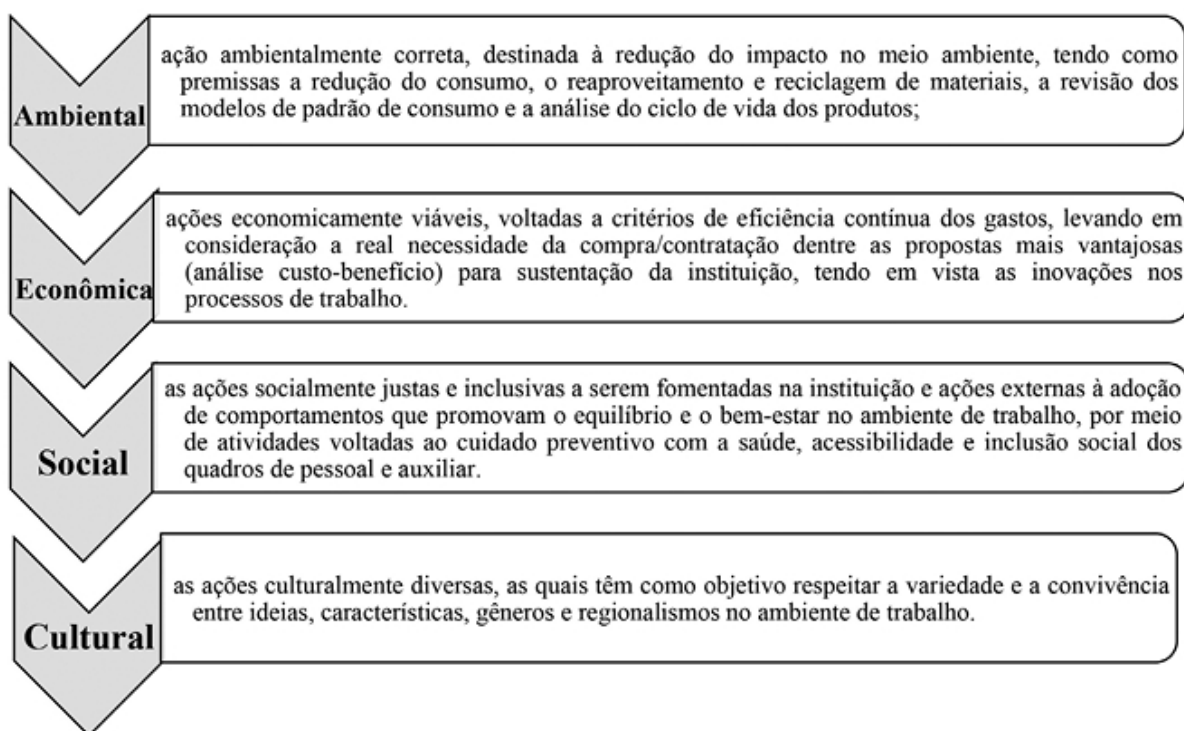
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO– AQUISIÇÃO DE (OU SERVIÇOS QUE UTILIZEM) BENS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO (fls 291/300)

Aquisição ou serviços que envolvam a utilização de bens de informática e automação previstos no Anexo A da Portaria INMETRO 170, de 2012, dos grupos: Equipamentos bancários; máquinas de processamento de dados e texto e equipamentos associados; Equipamentos eletroeletrônicos para uso em escritórios; e outros equipamentos de tecnologia da informação.

Exemplo: computadores de mesa, computadores portáteis (notebook, laptop e netbook), equipamentos digitalizadores de texto e imagem (scanners), impressoras, fragmentadora, grampeador e encadernador elétricos, projetores datashow, smartphones, entre outros.

Registre-se que há previsão de instituição do Plano de Logística Sustentável nos órgãos do Poder Judiciário, com fundamento na Resolução nº 400/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Em geral, o Plano de Logística Sustentável prevê as seguintes ações a serem observadas pelas organizações:



Percebe-se que o PLS é um ecossistema que envolve várias ações, entre elas a sustentabilidade das contratações. Essa diretriz toma corpo com a implementação da Política de Sustentabilidade das Contratações, a qual considera objetivos e ações referentes às dimensões sociais, econômicas, culturais e ambientais das contratações. A Nova Lei de Licitações descreve critérios e práticas sustentáveis que espelham essas diretrizes e devem constar da planificação das organizações públicas.

4.2.1.1 Dimensão ambiental

i) *Reaproveitamento e reciclagem de materiais*: o art. 26 da Lei nº 14.133/21 prevê que no processo de licitação poderá ser estabelecida margem de preferência para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras e bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento.⁹⁰

ii) *Impacto ambiental da solução*: o novo marco legal de licitações e contratos deixa claro que a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública é aquela que gera melhor resultado de contratação, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Para tanto, a Nova Lei previu que a fase preparatória da licitação deve destinar atenção à avaliação de todo o contexto de funcionamento do objeto que se pretende contratar, para efeito de indicar a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros.⁹¹

Inclusive, a Nova Lei também prevê que o Estudo Técnico Preliminar (ETP) deve conter o elemento descritivo de análise da demanda e os possíveis impactos ambientais, com as respectivas medidas mitigadoras, incluídos os requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como a logística reversa⁹² para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável,⁹³

para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa para a Administração Pública.

iii) Descrição com padrão de sustentabilidade/análise de ciclo de vida dos produtos: para o melhor atingimento desse objetivo, o art. 19, inciso II, da Nova Lei determina a utilização de catálogos eletrônicos padronizados, com especificações de produtos adequadas aos requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança.⁹⁴

Seguindo essa diretriz, para auxiliar os gestores frente às opções pelo atendimento dos padrões de sustentabilidade, vários órgãos disponibilizam catálogos e guias, como o caso do Guia Prático de Compras Públicas Sustentáveis da Advocacia-Geral da União (AGU).⁹⁵

Resta evidente, portanto, que a Nova Lei de Licitações e Contratos dá ênfase à qualidade das contratações, evitando o prejuízo passivo da falta que dela decorre.

iv) Coleta seletiva e reciclagem: A lei prevê no art.75, inciso IV, alínea “j”, como hipótese de dispensa da licitação, a coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizado por associações ou cooperativas formadas, exclusivamente, por pessoa físicas de baixa renda reconhecidas pelo Poder Público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Novamente, verifica-se o papel do Poder Público de fomentar a participação das associações de catadores no setor econômico, já que se trata de um querer universalmente reconhecido porque vontade de todos.

v) Maior retorno econômico: o contrato de eficiência está previsto no art. 6º, inciso LIII, da Nova Lei,⁹⁶ cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na

forma de redução de despesas correntes, remunerando o contratado com base em percentual da economia gerada.

4.2.1.2 Dimensão econômica

i) Adoção de critérios de eficiência contínua dos gastos, levando em consideração a real necessidade da compra/contratação dentre as propostas mais vantajosas (análise custo-benefício): para melhorar os resultados das contratações é importante aferir, permanentemente, o desperdício passivo, por meio de uma avaliação crítica da real necessidade da contratação, ou se é possível atender à demanda com contratações já formalizadas pela organização.

A racionalização dos gastos públicos e a promoção de boas práticas com o uso de evidências e dados permitirão melhorias e o aperfeiçoamento da qualidade das contratações. Esses levantamentos devem ser realizados no Estudo Técnico Preliminar, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação e que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução.

ii) Política de interação com o mercado: tem o propósito de atenuar a assimetria de informação, a qual impacta diretamente as relações negociais públicas por meio dos princípios da transparência e da informação plena. O art. 21 da Nova Lei prevê a audiência e consulta pública para dar concretude a essa diretriz.

Além disso, como diz Márcio Fedichina,⁹⁷ “é necessário estabelecer estratégias, como a de competição pelo menor preço (redução e otimização dos custos e recursos operacionais e organizacionais), pelo melhor produto ou serviço (elevada qualidade e inovação na elaboração e desenvolvimento), pelo relacionamento estreito com o cliente (ações que aumentam o entendimento da demanda e do cliente) e pela melhoria das operações da cadeia de suprimentos (estabelecimento de ações que visam à otimização de informações

trocadas entre fornecedores, empresa e clientes, aumentando assim sua competitividade e mercado)”.⁹⁸

iii) Melhoria e inovação dos processos de trabalho: os processos de trabalho devem ser revisitados para identificação de possibilidades de melhoria dos documentos e fluxos e dar maior celeridade na tramitação. Para tanto, é importante inovar eliminando os focos de desperdício com tempo, hora técnica de servidores e recursos públicos com práticas desatualizadas, as quais invertem a lógica de eficiência das contratações.

iv) Compras centralizadas: A realização das compras colaborativas, por meio da central de compras, é diretriz essencial para dar fluidez às contratações nos órgãos e entidades públicas. Nesse sentido, o art. 19, inciso I, da Nova Lei determinou que os órgãos e entidades da Administração Pública devem, preferencialmente, realizar a contratação por meio do consumo compartilhado. A economia compartilhada, decorrente do volume das compras e do rateio de recursos, tem recebido atenção dos gestores, pois vem apresentando resultado com inúmeras vantagens, se comparado ao modelo de contratação tradicional.

v) Compras compartilhadas: são contratações em rede, as quais se darão por meio do levantamento das demandas comuns de vários órgãos e entidades públicas que poderão formalizar uma contratação única, com valores mais vantajosos para a Administração Pública.

vi) Desenvolvimento da economia local: na Nova Lei, tem-se como premissa inquestionável a imprescindibilidade de adotar nas contratações os privilégios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 para as microempresas e empresas de pequeno porte.⁹⁹ O incentivo e fomento à participação do pequeno empreendedor no mercado de contratações públicas é uma política pública amparada nos arts. 170, inc. IX, e 179 da CF/88.

vii) Incentivo à inovação: a Nova Lei tem como um dos seus objetivos a inovação, presente no art. 11, inciso IV.¹⁰⁰ Esse propósito das

contratações tem razão de ser, pois a melhoria incremental das contratações só será possível com uma cultura digital atual, metodologias ágeis e o aperfeiçoamento da gestão. Nesse sentido, Sandro Malgadi alerta: “As inúmeras possibilidades presentes atualmente na sociedade compõem o território onde as batalhas se desdobram. A sede desmedida de aproveitar todas as oportunidades, rompendo as barreiras do pensamento tradicional, é o combustível para a expansão. Utilizando um termo do campo da tecnologia, é necessário dar um *reboot* e reiniciar a mente dos atuais líderes com essa nova mentalidade, a qual não despreza as possibilidades anteriores, porém as ressignifica, trazendo um conjunto de opções até então inexistentes”.¹⁰¹

viii) Critério de julgamento do menor dispêndio: a Lei apresenta, no art. 34,¹⁰² avanços ao prever que na identificação do menor preço deve ser considerado o menor dispêndio para que a proposta seja declarada vencedora. Portanto, para efeito de aferição da proposta mais vantajosa, devem ser considerados não apenas o preço, mas, sobretudo, o ciclo de vida do bem ou serviço, a questão da operação, a manutenção e a disposição final dos produtos propriamente ditos. Não restam dúvidas de que estamos diante de uma mudança de paradigma nas contratações públicas, na medida em que temos que abandonar o pensamento exclusivamente no preço como única referência abalizadora do negócio público para incluir a avaliação do menor dispêndio que o produto apresenta.

4.2.1.3 Dimensão social

i) Exigência de percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação constituído por mulheres vítimas de violência doméstica e oriundos ou egressos do sistema prisional: a Nova Lei prevê a possibilidade do edital, na forma disposta em regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído

por mulheres vítimas de violência doméstica e oriundos ou egressos do sistema prisional.^{103 104 105}

*ii) Da exigência habilitatória e reserva de cargos para pessoa com deficiência:*¹⁰⁶ o art. 63, IV, da Nova Lei prevê que na fase de habilitação das licitações será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Além disso, o art. 116 da Lei nº 14.133/21, que faz referência à gestão e fiscalização de contrato, determina ao contratado que cumpra durante a execução do ajuste o percentual destinado à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.¹⁰⁷ Verifica-se que a Nova Lei está sendo utilizada para o exercício de ações afirmativas.

iii) Contratação de associação de pessoas com deficiência: o art. 75, XIV,¹⁰⁸ da Nova Lei traz o incentivo da participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, inclusive prevendo a possibilidade de contratação direta por dispensa de licitação de entidade destinada a essa finalidade.

iv) Critério de desempate: o art. 60 da Nova Lei prevê a utilização do parâmetro da sustentabilidade como critério de desempate entre duas ou mais propostas. Segundo esse artigo, após realizada a disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação, será aferida a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão, preferencialmente, serem utilizados registros cadastrais para efeito de atestado de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei. Em seguida, permanecendo o empate entre os licitantes, será analisado o desenvolvimento de ações de equidade

entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento a ser editado.

v) *Da centralidade no cidadão-usuário*: uma das premissas vitais da sustentabilidade nas organizações é que as decisões devem ser tomadas considerando o cidadão-usuário como cliente principal. É importante quando da identificação da demanda que se enxergue o problema a partir da necessidade que a sociedade apresenta. Como diz João Kepler:¹⁰⁹ “A centralidade no cliente não deve ser apenas um valor da cultura organizacional. Ela deve ser debatida internamente para que seu significado seja entendido por todos. Para, assim, refletir nas decisões que vão de fato levar à maior satisfação dos consumidores”.

A Nova Lei, incentivando a participação da sociedade na avaliação da prestação de serviços, previu no art. 123, que “a Administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato”.

4.2.1.4 Dimensão cultural

i) *Ações culturalmente diversas*: elas têm como objetivo respeitar a variedade e a convivência entre ideias, características, gêneros e regionalismos no ambiente de trabalho.

Por fim, para demonstrar a ênfase dada pela Nova Lei às questões voltadas para a sustentabilidade, o art. 147, que trata da nulidade do contrato, traz alguns aspectos que devem ser considerados antes do desfazimento do ajuste. São indicadas hipóteses que envolvem questões ambientais, sociais, econômicas, as quais levam os gestores a precaverem-se antes de tomada de decisão. São eles:

- I – impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;
- II – riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;
- III – motivação social e ambiental do contrato;
- IV – fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação;

4.2.2 A Política de Contratações Sustentáveis e o processo de contratação

Tatiana Camarão

Camila Murta

À vista de tudo quanto foi exposto, resta claro que a Política de Contratações Sustentáveis é o documento que agrega as ações e atividades de sustentabilidade, estabelecendo as diretrizes a serem observadas pelas unidades envolvidas no processo de contratação, com o propósito de avaliar as dimensões descritas e incluir, nas suas demandas, práticas de gestão sustentável, racionalização e consumo consciente, que compreendam, no que couber, as seguintes recomendações:

Processo de Contratação Sustentável

- verificação da real necessidade de aquisição do produto e/ou serviço, nas fases de elaboração do Plano Anual de Compras e Contratações;
 - análise da série histórica de consumo, na fase de atendimento das demandas, de forma a fomentar o alcance do ponto de equilíbrio;
 - inovações no mercado fornecedor; e
 - o ciclo de vida do produto.
-

Importante destacar que, como compradores em grande escala, a Administração Pública é responsável por considerar as questões e requisitos sustentáveis em suas aquisições, incentivando o sistema produtivo a oferecer produtos, serviços, obras públicas mais sustentáveis.

O documento “Sustentabilidade nas Contratações Públicas”, no Portal de Compras do Governo Federal,^{[110](#)} traz importantes considerações sobre o que já foi explanado nesse Manual, sintetizado pela figura:



Fonte: figura extraída do site <https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/logistica-publica-sustentavel/sustentabilidade-nas-contratacoes-publicas>.

E, em especial, dá direcionamentos importantes para o atendimento do princípio do desenvolvimento nacional sustentável desde o planejamento das contratações. Tais como:

a) Planejamento

Nessa etapa deve-se:

- (i) refletir sobre as reais necessidades do órgão, inclusive possibilidades de reaproveitamento;
- (ii) realizar o levantamento de eventuais normativos que determinem regras específicas para a contratação de determinado

objeto;

- (iii) analisar as soluções disponíveis no mercado que causem menor impacto ambiental;
- (iv) estudar possíveis impactos negativos durante a execução da contratação e as medidas mitigadoras correspondentes;
- (v) estudar a possibilidade de realizar a aquisição de forma centralizada ou compartilhada.

A atividade de planejamento ajuda a coibir o consumo desnecessário bem como a promover a avaliação do impacto socioambiental do ciclo de vida dos produtos contratados, levando à escolha de produtos e serviços mais sustentáveis.

b) Especificação técnica do objeto e obrigações da contratada

A inclusão de práticas e critérios de sustentabilidade na especificação do objeto e nas obrigações da contratada deve sempre resguardar o caráter competitivo do certame.

O Decreto nº 7.746, de 2012, em seu art. 4º, apresenta uma lista não exaustiva de critérios e práticas sustentáveis que podem ser utilizados. Veja:

- I – baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
- II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
- III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
- IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
- V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
- VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
- VII – origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e
- VIII – utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento.

Para apoiar os gestores de compras, o Catálogo de Materiais (CATMAT) já apresenta alguns itens classificados como sustentáveis. Ao pesquisar um item em sua base, é possível observar uma marcação (folhinha verde) que indica que aquele item foi classificado como sustentável.

c) Seleção do fornecedor

As exigências de sustentabilidade poderão ser inseridas nos instrumentos convocatórios por meio de especificação técnica do objeto, obrigações da contratada ou requisito previsto em lei especial. A aferição da qualidade ou conformidade do produto ou do processo de fabricação pode ser comprovada por meio de certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada.

Em caso de inexistência da certificação para o objeto a ser contratado, o instrumento convocatório poderá estabelecer que, após a seleção da proposta e antes da adjudicação do objeto, o contratante poderá realizar diligências para verificar a adequação do bem ou serviço às exigências do instrumento convocatório. Ressalta-se, contudo, que o caráter competitivo do certame deve ser preservado.

Sobre o tema, é importante acentuar que “a rotulagem e a certificação socioambiental, em regra, decorrem da atuação do setor privado e constituem parâmetro de análise por parte dos consumidores, pois permitem avaliar o histórico de impacto ambiental dos produtos e serviços e a responsabilidade socioambiental da empresa. No âmbito das contratações públicas, a utilização de rótulos e certificações ambientais é tema que sofreu alteração pela Lei nº 14.133/2021 e, portanto, deve perpassar novas discussões na doutrina e na jurisprudência. Isso porque, até então,

sob a égide da Lei nº 8.666/1993, havia consolidação de entendimento no sentido de não ser admitida como regra a exigência de certificados como requisito de aceitação de proposta ou habilitação. Com o advento da Lei nº 14.133/2021, nova perspectiva sobre o tema foi lançada (...)" ¹¹¹.

d) Gestão e fiscalização

Durante a execução, os fiscais devem observar o cumprimento das obrigações previstas em contrato. De nada adianta adquirir um bem ou serviço baseado em critérios de sustentabilidade se durante a execução houver desperdício ou mau uso do objeto. Para que essas situações sejam evitadas, é importante investir em capacitação, conscientização e sensibilização dos servidores e colaboradores.

e) Destinação final de resíduos e rejeitos

Desde o planejamento da contratação já é importante pensar nos meios de gerenciar os resíduos que serão produzidos durante sua execução, inclusive prevendo a necessidade de ações complementares (contratações correlatas) a fim de realizar a coleta seletiva e/ou a logística reversa dos produtos utilizados.

Com essa roteirização de algumas medidas sugestivas será possível aprimorar os pedidos e adequá-los aos padrões de sustentabilidade previstos na Nova Lei de Licitações e Contratos.

4.2.3 Indicadores de desempenho

A Política de Contratações Sustentáveis deve contemplar os indicadores sociais, econômicos, ambientais e culturais apropriados, em consonância com a estratégia fixada pela organização. Dessa

forma, será possível monitorar os resultados e com essa base de conhecimento orientar de maneira específica a tomada de decisão visando à melhoria contínua das contratações sustentáveis.¹¹²

O primeiro passo ao pensar em indicadores é definir quais métricas são mais importantes para cada organização. Com base nisso, iniciar um trabalho de criação, manutenção, acompanhamento e divulgação desses indicadores. O simples fato da sua existência não comprova sua eficácia. Métricas sustentáveis devem ser de médio e longo prazos. O acompanhamento é importante, pois servirá como base para novas contratações, renovações ou mesmo continuidade dos contratos. Servirá como suporte para os fiscais dos contratos.

Os indicadores são divididos nas categorias ambiental, social e de governança. Vale lembrar que o principal objetivo das métricas sustentáveis não é o ganho financeiro. Portanto, ao se criar um indicador para o consumo de energia, por exemplo, esse não será baseado no valor da conta de luz e sim na unidade de medida de consumo (kWh) ao longo de um determinado período analisado. A seguir alguns exemplos, mas não limitados, de indicadores que podem ser criados:

Ambiental	Social	Governança
▪ Consumo de água ▪ Consumo de energia ▪ Emissão de Carbono ▪ Reuso de água ▪ Reciclagem	▪ Práticas de saúde e segurança do trabalhador ▪ Diversidade e Inclusão ▪ Equidade ▪ Métricas referentes a políticas de direitos humanos e trabalho ▪ Desenvolvimento social da comunidade	▪ Política de Transparência ▪ Políticas de anti-corrupção ▪ Código de Conduta ▪ Política de Conformidade ▪ Relatório de Sustentabilidade

Por fim, a sustentabilidade é um conceito plástico que envolve questões ambientais, culturais, tecnológicas, sociais, econômicas, entre outras, e a Nova Lei, como não poderia ser diferente, prima pela adoção de padrões de sustentabilidade nas contratações, já que é um compromisso assumido no plano constitucional.

Além disso, a sustentabilidade se apresenta como princípio da governança das organizações e, por isso, deve se fazer presente nos diversos elos da cadeia das contratações.

4.3 Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC

Tatiana Camarão

Camila Murta

PDTIC: instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período.
Art. 2º, inciso XXV, da IN nº 01/2019, de 4 de abril de 2019.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) contempla o conjunto de metas e ações, alinhadas ao planejamento estratégico do órgão, com base nas políticas e recursos necessários para a solução de TIC, visando, pois, apoiar políticas públicas e definir prioridades dos entes públicos, no tocante à infraestrutura, ao desenvolvimento e/ou manutenção de soluções, *softwares* e aplicativos e demais ativos de TIC, de modo que atinjam com maior eficiência seus objetivos estratégicos.

Portanto, o PDTIC representa um instrumento de governança para a execução das ações de TIC dos órgãos, permitindo justificar os recursos aplicados em TIC, minimizar o desperdício, garantir o controle dos recursos, destinar recursos para o que é estratégico e relevante para o órgão e, prioritariamente, melhorar o gasto público e o serviço prestado ao cidadão. Ou seja, *o PDTIC tem como função o planejamento e a definição dos projetos da área de TIC, em sua missão de apoiar o alcance dos objetivos estratégicos do órgão.*

Assim, considerando o PDTIC como uma ferramenta de governança que tem duração mínima de dois anos, deve ser revisto e atualizado periodicamente de modo a acompanhar as mudanças e necessidades do órgão no contexto TIC, vez que a sua finalidade é manter o alinhamento do setor de TIC às estratégias do órgão. Deve, ainda, ser publicado e divulgado no âmbito do órgão (portal institucional), abrangendo públicos interno e externo. O PDTIC constitui um importante complemento ao planejamento institucional, compreendendo diretrizes e ações transversais que suportam objetivos de negócio, bem como estruturais e regimentais da instituição.

O processo de elaboração do PDTIC compõe-se de três fases: preparação, diagnóstico e planejamento.

A *fase de preparação* representa o início do Projeto de Elaboração do PDTIC, com a formação de uma equipe de trabalho voltada a criar as ações essenciais para a elaboração do plano.

A equipe de trabalho essencialmente deve ser composta por servidores dotados de conhecimentos sobre as estratégias e prioridades de negócio do órgão e que representem cada unidade do órgão, atuando de forma colaborativa entre si e com a Alta Administração, representados no Comitê de Governança Digital.¹¹³

Essa equipe tem autonomia para definir a metodologia de elaboração do PDTIC, juntamente com a identificação dos

documentos de referências, princípios e diretrizes, bem como a identificação das necessidades SWOT da TIC, definição de critérios de priorização das demandas de TIC, consolidação da proposta orçamentária de TIC ao Plano, criação de indicadores e, por fim, a elaboração da minuta do plano para aprovação.

A *fase de diagnóstico* representa a compreensão da situação atual da TIC no órgão para identificar as necessidades de TIC (problemas ou oportunidades) que se espera resolver, utilizando-se de análise comparativa da estratégia anterior, avaliando a situação das ações anteriormente planejadas: se estão em andamento, se foram canceladas, se foram atendidas ou se necessitam de alinhamento.

Essa segunda fase demanda grande interação com todas as unidades do órgão, pois realiza extensa coleta de dados e análises de documentos, sendo que o principal ativo do diagnóstico é o inventário das necessidades de TIC.

Na terceira e última, a *fase do planejamento*, estabelecem-se os planos e as ações adequadas para o alcance dos objetivos esperados, a partir da priorização das necessidades e do planejamento de metas e ações, abrangendo aspectos de pessoal, orçamento e riscos.

Com base no levantamento de necessidades, a equipe de trabalho identifica as prioridades (resultado da multiplicação dos pesos da prioridade dentro das áreas, da obrigatoriedade e da criticidade), procura compreender o escopo de cada ação e estabelecer prazos e cronograma de entregas com base nos recursos humanos (servidores e prestadores de serviço) e nos recursos financeiros disponíveis no orçamento. Posteriormente, as demandas são consolidadas e submetidas à aprovação do Comitê de Governança Digital.

Cumpridas as três fases, tem-se a materialização do PDTIC. Contudo, existem fatores críticos que são requisitos importantes para o sucesso do plano. A ausência de um ou de vários desses requisitos, ou mesmo sua presença de forma precária, gerará impacto na estratégia e, conseqüentemente, no negócio do órgão:

Fatores críticos para o sucesso do PDTIC

- patrocínio da alta administração para execução das ações;
 - disponibilidade orçamentária para as aquisições relacionadas;
-
- priorização das ações alinhadas com os objetivos estratégicos organizacionais;
 - escopo (e não escopo) das demandas bem definido e especificado, e devidamente acordado entre as áreas executoras e demandantes;
-
- comunicação permanente entre TIC e usuários;
 - quadro de pessoal em quantidade e qualidade adequadas.
-

Por fim, no cenário de constantes mudanças, o PDTIC se constitui em importante ferramenta de apoio à tomada de decisão, habilitando ações proativas, considerando as ameaças e as oportunidades que constantemente se apresentam.

Relevante aqui abordar que o Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, que instituiu a EGD – *Estratégia de Governo Digital* – para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, também colabora nas diretrizes do PDTIC. A EGD orienta e integra as iniciativas relativas à *governança digital*, contribuindo para aumentar a efetividade da geração de benefícios para a sociedade brasileira por meio da expansão do acesso às informações governamentais, da melhoria dos serviços públicos digitais e da ampliação da participação social. Busca também convergir os esforços de infraestruturas, plataformas, sistemas e serviços dos órgãos que compõem o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) com as iniciativas de governo digital.

Portanto, a agenda de *transformação digital* é uma prioridade do governo federal e visa promover a simplificação na solicitação de

serviços, que com isso reduz tempo e recursos gastos pelo cidadão e pelo setor produtivo em deslocamentos e transações desnecessárias.

4.4 Plano de Contratação Anual – PCA

O PCA – Plano de Contratações Anual é o documento que consolida todas as compras e contratações que o órgão pretende realizar e contempla bens, serviços, obras e também soluções de tecnologia da informação.

Previsto no Decreto-Lei nº 200/1967, o planejamento é um princípio fundamental da Administração Pública que deve nortear todas as suas atividades. Assim, com o intuito de fortalecer esse importante princípio e consubstanciado no Acórdão TCU nº 2.622/2015, foi publicada a Instrução Normativa nº 1, de 2019, simplificando os procedimentos para a elaboração do PCA.

O PCA, que deve estar alinhado com o Planejamento Estratégico, PLS e o PDTIC, é o documento que consolida todas as compras e contratações que o órgão ou entidade pretende realizar ou prorrogar e contempla bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação.

Nesse contexto, a Lei nº 14.133/21 prevê no art. 12, inciso VII, que é dever¹¹⁴ dos entes públicos produzirem o seu plano para racionalizar e dar mais transparência às compras públicas.

Art. 12, inciso VII. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada

ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

§1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do *caput* deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos.

O Plano de Contratação Anual – PCA, como dito, é um documento que consolida todas as contratações que o órgão ou entidade pretende realizar ou prorrogar no exercício financeiro subsequente, inclusive renovações.

A elaboração do PCA se dá pela observação e encaminhamento, pelas unidades administrativas, das suas demandas para o setor de compras devido, o qual consolidará as informações e enviará para aprovação da autoridade competente da organização.

A divulgação do PCA no portal do órgão permitirá o acompanhamento, pelos cidadãos e agentes públicos, da sua execução para a correção de desvios.

Nesse sentido, as contratações de soluções de TIC deverão constar no Plano de Contratações Anual, conforme previsto no artigo 7º da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, e, seguindo as diretrizes do artigo 8º do Decreto nº 10.947, de 2022, o qual traz os procedimentos necessários para a elaboração do PCA que se concretiza via Documento de Formalização da Demanda – DFD.^{[115](#)}

Art. 8º Para elaboração do plano de contratações anual, o requisitante preencherá o documento de formalização de demanda no PGC com as seguintes informações:

I – justificativa da necessidade da contratação;

II – descrição sucinta do objeto;

III – quantidade a ser contratada, quando couber, considerada a expectativa de consumo anual;

IV – estimativa preliminar do valor da contratação, por meio de procedimento simplificado, de acordo com as orientações da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia;

V – indicação da data pretendida para a conclusão da contratação, a fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades do órgão ou da entidade;

VI – grau de prioridade da compra ou da contratação em baixo, médio ou alto, de acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou pela entidade contratante;

VII – indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda para a sua execução, com vistas a determinar a sequência em que as contratações serão realizadas;

VIII – nome da área requisitante ou técnica com a identificação do responsável.

Instrução Normativa SGD/ME n. 94/2022.

Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa, considera-se:

X – Documento de Formalização da Demanda: documento que contém o detalhamento da necessidade da Área Requisitante da solução a ser atendida pela contratação, contendo no mínimo as informações constantes do art. 8º do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022;

O governo federal, visando apoiar a elaboração do PAC, disponibilizou o “Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC)”, onde devem ser registradas todas as demandas que irão compor o PCA. O PGC permite a tramitação de demandas entre os setores requisitantes e o setor de licitações que irá avaliar as demandas para consolidar o PCA, bem como o encaminhamento para a autoridade competente que irá realizar a aprovação final e o envio ao Ministério da Economia.¹¹⁶

Contudo, é bastante pertinente que cada instituição, por meio de regulamentação própria, defina rotinas, prazos internos e

responsabilidades para cada etapa do processo de elaboração do PCA, considerando as peculiaridades de sua estrutura e observadas as diretrizes da IN nº 94, de 2022.

Neste ponto, cabe um esclarecimento, esses regulamentos se aplicam para os órgãos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional. É importante os Estados e Municípios editarem seus regulamentos adequados a sua realidade.

O PCA é benéfico para a sociedade e para o Poder Público, visto que torna possível ampliar a realização de compras conjuntas, o que propicia economia de escala para as unidades administrativas, além de sinalizar ao mercado fornecedor as pretensões de aquisições desta, de modo que ele pode se preparar, adequadamente e com antecedência, para participar dos certames licitatórios.¹¹⁷

O PCA permite, ainda, que os órgãos e entidades públicas planejem suas ações, conectando-as às diretrizes do seu planejamento estratégico, do plano diretor de tecnologia da informação e comunicação, do plano de programação financeira de desembolso, da política de sustentabilidade das contratações, da política de gestão e controle de estoque nas compras, da política de contratação de serviços sob o regime de execução indireta.

Para além dos benefícios e avanços citados, o PCA ainda permite à área requisitante ter mais e melhores informações para a elaboração de um estudo técnico preliminar e termo de referência, visto que será feita uma dupla checagem do que se está a contratar (a demanda do ano seguinte e a atual), e assim será possível organizar os recursos orçamentários, os servidores terão tempo para a confecção dos documentos e mitigar as contratações de última hora por meio do estímulo da eficiência processual.

Por fim, vale destacar que a prévia disponibilização das demandas de contratações e aquisições dos órgãos públicos em *website* assegurará maior transparência e controle social.

Como boa prática sugere-se, para os órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP,¹¹⁸ a consulta ao portal de compras do governo federal, que auxilia na elaboração do PCA e provê o passo a passo para o acesso ao sistema do PGC.

Portal de Compras
GOVERNO FEDERAL

Buscar no portal

Perguntas frequentes | Posso ajudar?

BOAS-VINDAS INSTITUCIONAL **GESTOR PÚBLICO** FORNECEDORES TRANSPARÊNCIA

PÁGINA INICIAL > SISTEMA PGC E PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

INSTITUCIONAL

- Novo Portal de Compras
- Departamento de Normas e Sistemas de Logística
- SISG
- Processo Eletrônico Nacional
- Central de Compras
- Legislação
- Publicações
- Perguntas Frequentes
- Links Úteis
- Posso ajudar?
- Últimas Notícias

ACESSO AOS SISTEMAS

GESTOR PÚBLICO

Sistema PGC e Plano Anual de Contratações

Perguntas e Respostas

NORMATIVO

- 1 - O que é o Plano Anual de Contratações?
- 2 - Qual o objetivo da elaboração do Plano Anual de Contratações?
- 3 - Que contratações devem integrar o Plano Anual de Contratações?
- 4 - A elaboração do Plano Anual de Contratações é obrigatória?
- 5 - Deverá ser elaborado apenas um Plano Anual de Contratações por órgão/entidade?
- 6 - Para fins de elaboração do Plano Anual de Contratações, qual o papel do setor de licitações?
- 7 - Como se dá o processo de elaboração do Plano Anual de Contratações?
- 8 - Ao incluir um item no Plano Anual de Contratações (PAC), que informações devem ser registradas?
- 9 - Durante o ano de sua elaboração, o Plano Anual de Contratações pode ser modificado?
- 10 - É possível realizar alterações no Plano Anual de Contratações no ano de sua execução?
- 11 - É obrigatória a publicação do Plano Anual de Contratações no sítio eletrônico do órgão/entidade?
- 12 - Quando da efetiva execução, o Plano Anual de Contratações deve ser observado?
- 13 - As contratações que contenham informações sigilosas devem constar do Plano Anual de Contratações?
- 14 - As contratações realizadas de forma centralizada ou conjunta devem fazer parte do Plano de Contratações de cada órgão/entidade ou daquele responsável por realizar o procedimento licitatório?
- 15 - As contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) seguem as diretrizes da IN nº 1, de 2019, para fins de preenchimento do Plano Anual de Contratações?
- 16 - Os gastos com capacitação de servidores realizados por meio de treinamentos pagos com Gratificação de Encargo de Curso ou Concurso – GECC devem constar no PGC?
- 17 - Os contratos continuados, cuja vigência não precisará ser prorrogada/renovada no ano seguinte, precisam ser cadastrados no PGC?

SISTEMA

- 1 - Como acessar o Sistema PGC?
- 2 - Quem pode ter acesso ao PGC?
- 3 - Como solicitar acesso ao PGC?
- 4 - Como escolher o perfil do PGC?
- 5 - O órgão/entidade pode cadastrar vários usuários em um mesmo perfil?
- 6 - O mesmo usuário pode ter mais de um perfil?

4.4.1 A elaboração do Plano de Contratação Anual – PCA e seus desafios nas contratações de TIC

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 12, inciso VII, recomendou para todos os entes públicos a necessidade de elaboração do Plano de Contratação Anual – PCA, o qual deverá ser constituído a partir de documentos de formalização de demandas. E, por sua vez, a feitura do DFD foi regulamentada pelo Decreto nº 10.947/2022.

Quanto ao Decreto nº 10.947/2022, percebe-se nos primeiros artigos que o normativo retirou a exigência de registrar no PCA as prorrogações contratuais, ficando apenas obrigatório o cadastramento das novas contratações.

Embora as prorrogações estejam dispensadas, para os órgãos do governo federal, compete a cada um manter o controle orçamentário dos contratos prorrogados, bem como o fluxo de acompanhamento junto às áreas requisitantes em relação à manifestação do interesse em prorrogar, tendo em vista a instrução processual exigida nessa fase do processo.

Para a efetividade do PCA é importante criar e padronizar o Documento de Formalização da Demanda – DFD. Contudo, esse documento tem exigido uma série de informações, muitas delas impertinentes, pois a solução sequer foi estudada e já se quer saber o objeto que se pretende contratar.

Observa-se que o governo federal disponibilizou um passo a passo de preenchimento do DFD,¹¹⁹ exemplificando a necessidade de compra de canetas esferográficas e num dado momento o sistema solicita o preenchimento do material da ponta da caneta, o material do corpo da caneta, o revestimento da caneta, a cor, a quantidade e o valor unitário.

Materiais

Classe: 7510-Artigos para escritório X

PDM: 99-Caneta esferográfica X

Foram encontrados 1 opções de material

Código	Nome do Material	Ações
--------	------------------	-------

Caneta Esferográfica

Material: Metal

Quantidade Cargas: 1 Un

460551

Material Ponta: Esfera Em Aço

Tipo Escrita: Média

Cor Tinta: Azul

Características Adicionais: Conforme Modelo

Revestimento: Couro Sintético

Adicionar

+

Limpar Filtros

CARACTERÍSTICAS

Material Ponta

Esfera Em Aço

x

Material

Metal

x

Revestimento

Selecione

v

Características Adicionais

Selecione

v

Cor Tinta

Azul

x

Fechar

99 - Caneta esferográfica : 460551 - Caneta Esferográfica

Termo a ser pesquisado

caneta

Unidade de Fornecimento

Unidade

x

Quantidade

650.00000

Valor Unitário (R\$)

1.5000

Materiais

Classe: 7510-Artigos

Limpar Filtros

Cancelar

Salvar

Ações

+

460551

Material: Metal

Quantidade Cargas: 1 Un

Material Ponta: Esfera Em Aço

Tipo Escrita: Média

Cor Tinta: Azul

Características Adicionais: Conforme Modelo

Revestimento: Couro Sintético

Fechar

Ora, se num exemplo trivial como a aquisição de canetas já é possível observar certa dificuldade em preencher todos os campos do DFD, que é um documento apenas de formalização da demanda, prévio ao ETP e TR, dá para vislumbrar a dificuldade de estabelecer, antecipadamente, os objetos mais complexos, em momento que o ente público ainda não dispõe de todas as informações. Nesse cenário, enquadra-se a contratação de TIC, em que a complexidade do objeto, certamente, não permitirá que o ente público tenha de antemão todas as informações e dados para o preenchimento do DFD.

Com a elaboração e publicação do PCA, serão realizadas, no exercício seguinte, as contratações que foram prospectadas, ficando a cargo das áreas demandantes dar início à fase preparatória da licitação.

Planejamento da Contratação

- Estudo Técnico Preliminar
- Mapa de Gerenciamento de Riscos
- Termo de Referência/Projeto Básico

No caso de contratações de TIC, a área de Tecnologia da Informação e Comunicação das organizações é, em regra, responsável pelo planejamento das contratações de soluções de TIC. Com efeito, esse momento de concepção do processo de contratação não é feito de forma isolada, demandando a criação de uma equipe

de planejamento multidisciplinar composta por representante da área de TIC, representante da área requisitante da solução e representante da área administrativa.¹²⁰

Cada integrante da equipe de planejamento da contratação tem sua função definida na IN nº 94/2022. A mesma nomenclatura é aplicada na Resolução nº 468,¹²¹ do CNJ, a qual traz as diretrizes para as contratações de solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça. O encaminhamento do Documento de Oficialização da Demanda – DOD, com a instituição da equipe de planejamento da contratação, é o primeiro passo da fase preparatória da licitação. O segundo passo será a elaboração do estudo técnico preliminar da contratação e, posteriormente, a elaboração do termo de referência.

4.5 Planejamento das contratações

Tatiana Camarão

Camila Murta

A Lei nº 8.666/93, desde sua promulgação, recebeu várias críticas por ser complexa, excessivamente formal e não atender, efetivamente, à dinâmica da máquina administrativa. À luz dessas dificuldades, a Nova Lei oferece expressivos avanços e aperfeiçoamentos, especialmente no que diz respeito ao planejamento das contratações.

Nesse contexto, o art. 5º estabelece, entre os princípios que devem ser observados na aplicação da lei, o planejamento, destacando sua necessidade como parte inicial que precede os processos de contratações públicas. E o artigo 18 da Nova Lei traz os contornos da instrução do processo licitatório, apresentando o planejamento como

característica da fase preparatória ou fase interna da licitação, vejamos:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do *caput* do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I – a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

II – a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;

III – a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;

IV – o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

V – a elaboração do edital de licitação;

VI – a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

VII – o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII – a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX – a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X – a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI – a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei:

§1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do *caput* deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo

a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I – descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II – demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

III – requisitos da contratação;

IV – estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V – levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

VI – estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII – descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII – justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX – demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

X – providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XI – contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII – descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII – posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

§2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do §1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas.

§3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação

do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

85 Disponível em: <https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/logistica-publica-sustentavel/plano-de-gestao-de-logistica-sustentaveis>.

86 A Resolução nº 400 do CNJ, que dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito do poder Judiciário, traz informações muito ricas sobre o tema e a política de sustentabilidade. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf>.

87 Disponível em: https://www.tjsc.jus.br/documents/3526468/5872852/_guia_contratacoes_sustentaveis_VE_RSAO_FINAL_compressed.pdf/f62d973c-8b35-af82-34ab-a8c99f139fde?t=1634652156571#:~:text=O%20guia%20de%20contrata%C3%A7%C3%B5es%20sustent%C3%A1veis,e%20ambientais%20nas%20contrata%C3%A7%C3%B5es%20p%C3%ABlicas.

88 Disponível em: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf.

89 A3P – institucionalizada por meio da Portaria MMA nº 326, de 23 de julho de 2020.

90 Art. 26, incisos I e II.

91 Art. 18, VIII, da Lei nº 14.133/21.

92 Lei nº 12.305/2010.

93 Art. 18, §1º, XII, da Lei nº 14.133/21.

94 Art. 40, §1º, da Lei nº 14.133/21.

95 Sobre o tema, cumpre alertar que a Câmara Nacional de Sustentabilidade, colegiado do Departamento de Orientação de Órgãos Jurídicos da Consultoria-Geral da União, orientou, em síntese, por meio do PARECER 01/2021/CNS/CGU/AGU, que os órgãos e entidades que compõem a Administração Pública são obrigados a adotar critérios e práticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade nas contratações públicas, nas fases de planejamento, seleção de fornecedor, execução contratual, fiscalização e na gestão dos resíduos sólidos. A impossibilidade de adoção de tais critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações públicas deverá ser justificada pelo gestor competente nos autos do processo administrativo, com a indicação das pertinentes razões de fato e/ou direito. Recomendou, ainda, que os agentes da Administração Pública federal encarregados de realizar contratações públicas consultem, no exercício de suas atribuições funcionais, o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União.

96 Instrução Normativa SEGES/ME nº 96/2022: dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por maior retorno econômico, na forma eletrônica, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

97 FEDICHINA, Marcio A. H. *Gestão de compras e estoques*. 1. ed. Curitiba: IESDE, 2021, p. 78.

98 A propósito, cite-se a Resolução nº 23.702/2022, do Superior Tribunal Eleitoral, a qual prevê, no art. 17, que “A área de contratações do Tribunal Eleitoral deve fomentar ações de interação com o mercado, de forma que as equipes de planejamento sejam orientadas a: I – promover regular e transparente diálogo quando da elaboração dos estudos técnicos preliminares, de forma a se obterem soluções disponíveis no mercado que possam atender à necessidade/demanda do Tribunal, bem como a identificação de insumos para a otimização das especificações dos objetos a serem contratados, dos parâmetros de mercado

para melhor técnica e custo das contratações, e das obrigações da futura contratada; e II – estabelecer exigências sempre proporcionais ao objeto a ser contratado, para assegurar que as oportunidades sejam projetadas de modo a incentivar a ampla participação de concorrentes potenciais, incluindo novas empresas e pequenas e médias empresas”.

99 Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

100 São exemplos de procedimentos inovadores previstos na Nova Lei: contratação de *startup* (art. 81, §4º) e o procedimento do diálogo competitivo (art. 28, V).

101 MAGALDI, Sandro; SALIBI NETO, José. *Gestão do amanhã: tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na 4ª Revolução Industrial*. São Paulo: Editora Gente, 2018, p. 187.

102 “Art. 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, por técnica e preço considerará o menor dispêndio para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação.

§1º Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento.”

103 Art. 25, §9º, incisos I e II.

104 Sobre o tema, cite-se, como boa prática, o Ato da Comissão Diretora nº 04 do Senado Federal – Programa de Assistência a Mulheres em situação de vulnerabilidade econômica em decorrência de violência doméstica e familiar, que prevê percentual a ser destinado nas contratações a mulheres vítimas de violência doméstica.

105 O governo federal regulamentou essa matéria por meio do Decreto nº 11.430, de 8 de março de 2023, fixando o percentual mínimo de 8% das vagas a serem ocupadas.

106 A Lei nº 8.213/91 trata do tema de percentual que deve ser preenchido por pessoas portadoras de deficiência e reabilitados da previdência.

107 A Lei nº 10.097/2000 trata da quota a ser destinada aos aprendizes.

108 “Art. 75, XIV – para contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da Administração Pública, para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência”.

109 KEPLER, João. *O poder do equity: Como investir em negócios inovadores, escaláveis e exponenciais e se tornar um investidor-anjo*. São Paulo: Gente, 2021. p. 129.

110 Texto extraído do site: <https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/logistica-publica-sustentavel/sustentabilidade-nas-contratacoes-publicas>.

111 Disponível em: https://www.tjsc.jus.br/documents/3526468/5872852/_guia_contratacoes_sustentaveis_VE_RSAO_FINAL_compressed.pdf/f62d973c-8b35-af82-34ab-a8c99f139fde?t=1634652156571.

112 “Avaliar o desempenho é uma metodologia de trabalho pertencente à gestão de empresas que visa identificar, analisar e avaliar o comportamento dos processos organizacionais (de trabalho, das pessoas, das atividades, das operações e dos recursos) mediante padrões de análise (métricas e indicadores) previamente estabelecidos” (FEDICHINA, Marcio A.H. *Gestão de Compras e estoques*. 1. ed. Curitiba: IESDE, 2021, p. 148).

- 113 Decreto nº 10.332/2020 – Para os órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.
- 114 Considerando que o planejamento é um princípio da Nova Lei, entende-se que se trata de poder-dever dos entes públicos implementarem o PCA.
- 115 Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao>.
- 116 Disponível em: <https://antigo.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cartao-de-pagamento/1090-pac-page>.
- 117 Disponível em: <https://antigo.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/pacepgc-faq>.
- 118 O Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp) foi instituído pelo Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, com o objetivo de organizar a operação, controle, supervisão e coordenação dos recursos de tecnologia da informação da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/sobre-o-sisp#:~:text=O%20Sistema%20de%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20dos,aut%C3%A1rquica%20e%20fundacional%20do%20Poder>.
- 119 Disponível em: <https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/sistema-de-planejamento-e-gerenciamento-de-contratacoes/DFDnaprtica2.pdf>.
- 120 A Instrução Normativa SGD/ME nº 94/22 prevê no art. 2º, IV – Equipe de Planejamento da Contratação: equipe responsável pelo planejamento da contratação, composta por: a) Integrante Técnico: servidor representante da Área de TIC, indicado pela autoridade competente dessa área; b) Integrante Administrativo: servidor representante da Área Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa área; e c) Integrante Requisitante: servidor representante da Área Requisitante da solução, indicado pela autoridade competente dessa área.
- 121 Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4663>.

ETAPA PREPARATÓRIA

Tatiana Camarão

Camila Murta

5.1 Documento de Oficialização da Demanda

A fase preparatória da contratação tem início com a elaboração do Documento de Oficialização de Demanda – DOD pelo setor requisitante. Esse documento deverá informar qual a demanda, o alinhamento entre a demanda e o Planejamento Estratégico Institucional ou Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do órgão e o Plano Anual de Contratações, as razões de fato e direito que justificam a contratação, os resultados pretendidos, as fontes dos recursos para a contratação e a indicação dos servidores para compor a equipe de planejamento da contratação.^{[122](#)}

Como elaborar um DOD?

Devem constar no documento os seguintes campos:

1. Identificação da área requisitante

2. Identificação e ciência do integrante requisitante
3. Identificação da demanda
4. Motivação/Justificativa
5. Resultados a serem alcançados
6. Fonte de recursos
7. Identificação e ciência do integrante técnico
8. Decisão da autoridade competente
9. Identificação e ciência do integrante administrativo

Em âmbito federal, esse documento deve ser elaborado pela área requisitante, contendo os elementos indicados no art. 10, §1º, da IN SGD nº 94/2022.

Vale registrar que o DOD é o primeiro documento a ser elaborado pela área requisitante em qualquer hipótese de contratação, seja por licitação ou por contratação direta, tendo em vista que a obrigatoriedade da sua feitura consta expressamente do art. 72, inciso I, da Lei nº 14.133/21.

5.2 Justificativa técnica da contratação

Camila Murta

A justificativa da contratação deve contemplar as razões de fato e de direito que fundamentam a demanda dos produtos ou do serviço que se pretende contratar, apontando claramente os benefícios a serem alcançados pela contratação.

Relevante pontuar que as justificativas devem demonstrar a necessidade da contratação, trazendo motivações claras e precisas do que se pretende contratar e, em especial, a contextualização histórica e fática para a contratação da solução TIC.

5.3 Estudo Técnico Preliminar¹²³

Tatiana Camarão

Camila Murta

Após iniciado o processo de contratação, por meio do Documento de Oficialização da Demanda – DOD, é necessário elaborar o Estudo Técnico Preliminar – ETP, que tem uma função estratégica na engrenagem das contratações públicas, pois pavimenta o caminho para o atendimento correto e assertivo da demanda ao avaliar os cenários projetados e comprovar a viabilidade técnica e econômica das soluções disponíveis.

De acordo com o art. 6º, inciso XX, da NLLCA, o estudo técnico preliminar é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação.

Portanto, o ETP se destina a identificar e analisar a necessidade projetada pela unidade administrativa ao realizar o seu planejamento estratégico e o plano anual de contratação, buscando evidenciar o problema a ser resolvido, assim como as soluções possíveis, com fins de avaliar as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

A lei se preocupa, ainda, em descrever os elementos que devem compor esse estudo. De acordo com o art. 18, parágrafo 1º, o *estudo*

técnico preliminar conterá os seguintes elementos:

- I – descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;
- II – demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;
- III – requisitos da contratação;
- IV – estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;
- V – levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;
- VI – estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;
- VII – descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;
- VIII – justificativas para o parcelamento ou não da contratação;
- IX – demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;
- X – providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;
- XI – contratações correlatas e/ou interdependentes;
- XII – descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;
- XIII – posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

Segue-se a explanação sobre os incisos trazidos pela legislação de licitações quanto à elaboração do ETP:

i) *Da descrição da necessidade da contratação* – Neste item, temos a contextualização da necessidade e do problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. É necessário informar o que se deseja alcançar com a contratação e quais as soluções encontradas pelos outros órgãos ou entidades da Administração Pública.

ii) *Demonstração da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual* – Neste item, deve ser informado se a demanda tem alinhamento com outros instrumentos de planejamento do órgão, como Planejamento Estratégico, Plano de Logística Sustentável, PDTIC, Plano de Contratação Anual.¹²⁴

iii) *Requisitos da contratação* – Este item trata do conjunto de especificações funcionais de negócios e técnicas necessárias para definir a solução a ser contratada.

Ao eleger os requisitos da solução, deve-se avaliar se não há direcionamento do objeto por caracterização excessiva, bem como pela padronização indevida. Deve-se, pois, realizar estudos que justifiquem a adoção obrigatória das funcionalidades exigidas e suas correlações com as necessidades do órgão, que refletirão nos requisitos exigidos no TR. Para tanto, o gestor deve apresentar argumentos técnicos consistentes que demonstrem que a restrição que está sendo feita é estritamente necessária e acarreta uma série de benefícios que atendem ao interesse público.¹²⁵

O agente público deve se abster de incluir, nos instrumentos convocatórios, excessivo detalhamento do objeto, de modo a evitar o direcionamento da licitação ou a restrição de seu caráter competitivo, devendo justificar e fundamentar tecnicamente quaisquer especificações ou condições que restrinjam o universo de possíveis fornecedores dos bens ou prestadores de serviços objeto do certame.¹²⁶

Da mesma forma, deve-se evitar a indicação indevida de marca. Por exemplo, a eventual identificação de *hardware* especialista sendo destinado para suportar unicamente o sistema gerenciador de banco

de dados deverá estar fundamentada em justificativa clara pela sua exclusividade com a indicação de marca baseada em estudos técnicos e econômicos demonstrando que apenas determinada marca ou produto atende às necessidades da contratação, ou demonstrando a impossibilidade da coexistência heterogênea entre fabricantes diferentes, da necessidade de se manter compatibilidade com a marca dos equipamentos que seriam substituídos.¹²⁷ A propósito, deve-se ponderar se os benefícios de indicar marca superam os custos com a restrição que está sendo imposta e realizar análise quanto à impossibilidade de adoção de soluções alternativas a essa marca.¹²⁸

Vale esclarecer, ainda, que o princípio da padronização não conflita com a vedação de preferência de marca, que não constitui obstáculo à sua adoção, desde que a decisão administrativa, que identifica o produto pela marca, seja circunstanciadamente motivada e demonstre ser essa a opção, em termos técnicos e econômicos, mais vantajosa para a Administração.¹²⁹

Nas contratações de *software* recomenda-se a definição de soluções padronizadas baseadas em *softwares* e serviços agregados, de modo a desonerar as organizações públicas de levantar, entender e utilizar os modelos de comercialização dos grandes fabricantes de *software*.¹³⁰

Com relação à requisição, recomenda-se observar:

- a) as políticas, premissas e especificações técnicas definidas de interoperabilidade. No Poder Judiciário temos o Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI);
- b) a aderência às regulamentações da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), quando houver necessidade de utilização de certificação digital, observada a legislação sobre o assunto;
- c) no caso do Poder Judiciário, a observância às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais definidas no

Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos do Poder Judiciário (Moreq-Jus).

Em suma, os requisitos descritos para a contratação da solução devem ser apresentados com fundamentos suficientes, claros e coerentes, ficando prejudicada qualquer justificativa que se limita a indicar ou reproduzir ato normativo, sem explicitar sua relação com o caso contratado, que empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso ou sendo genérica.^{[131](#)}

iv) Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala – este item trata da verificação da demanda existente a fim de estimar a quantidade adequada dos itens da solução, evitando sempre o superdimensionamento dos quantitativos. Para evitar essa irregularidade, é necessário demonstrar a relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada acompanhada das memórias de cálculo ou outro método utilizado para definir os quantitativos. O importante é que o quantitativo seja apresentado de forma detalhada, motivada e justificada, inclusive quanto à forma de cálculo.

Por fim, vale alertar que nas contratações de *software* é imprescindível definir o quantitativo de licenças estritamente necessário, vinculando o pagamento dos serviços agregados às licenças efetivamente utilizadas, principalmente em projetos considerados de alto risco ou de longo prazo, nos quais o quantitativo deve ser atrelado à evolução do empreendimento e devidamente documentado nos estudos técnicos preliminares, podendo ser utilizado o Sistema de Registro de Preço, que viabiliza o ganho de escala na compra ao mesmo tempo em que proporciona a aquisição no momento oportuno.^{[132](#)}

v) *Levantamento de mercado* – esse item trata da análise das alternativas disponíveis no mercado e da justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União tem alertado que os órgãos devem identificar um conjunto representativo dos modelos existentes e suas adequações ao mercado antes de elaborar as especificações técnicas e a cotação de preços.¹³³

Por isso, em contratações de *software* é essencial verificar, nos estudos técnicos preliminares, no caso de indicação pelo fabricante de necessidade de produtos específicos para viabilizar a utilização da solução a ser contratada, a compatibilidade de produtos alternativos que atendam as regras de comercialização do fabricante e viabilizem a utilização da solução, de modo a não aceitarem que se condicione o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de solução específica, conforme disposto na Lei nº 8.078/1990, art. 39, inciso I (parágrafos 150 a 152).¹³⁴

Como *melhor prática* recomenda-se, consultar:

- as soluções existentes no Portal de *Software* Público Brasileiro (<http://www.softwarepublico.gov.br>);
- a capacidade e as alternativas do mercado de TIC, inclusive a existência de *software* livre ou *software* público;
- os diferentes modelos de prestação do serviço;
- Nos processos de aquisição recomenda-se, ainda, realizar análise de viabilidade para locação de equipamentos avaliando os princípios da vantajosidade e economicidade para administração pública, conforme determina o art. 44 da Lei nº 14.133/21.¹³⁵

vi) Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação

Realizar a análise e a comparação entre os custos totais das soluções de TIC identificadas, levando-se em conta os valores de aquisição dos produtos, insumos, garantia, manutenção e serviços complementares, quando necessários à contratação.

A pesquisa para o estabelecimento do preço referencial da contratação deverá ser realizada pelo integrante técnico, observadas as atribuições do integrante administrativo, conforme item III do art. 11 da Resolução, para elaboração do orçamento detalhado composto por preços unitários, considerando preferencialmente os preços praticados pelos órgãos e entidades da Administração Pública na contratação de objetos similares à solução de TIC.

vii) Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso – justificar a solução de TIC escolhida informando:

- a) descrição sucinta, precisa, clara e suficiente da solução de Tecnologia da Informação e Comunicação escolhida, indicando os bens e/ou serviços que a compõem;
- b) alinhamento em relação às necessidades de negócio e requisitos tecnológicos;
- c) identificação dos benefícios a serem alcançados com a solução escolhida, além dos aspectos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização, os aspectos qualitativos em termos de benefícios para o alcance dos objetivos da contratação;
- d) relação entre a demanda prevista e a quantidade dos bens e/ou serviços a serem contratados.
- e) demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis;

- f) a possibilidade de aquisição na forma de bens ou contratação como serviço; e
- g) a ampliação ou substituição da solução implantada.

viii) *Justificativas para o parcelamento ou não da contratação* – justificar o parcelamento ou não da solução quando necessária para a individualização do objeto.

ix) *Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis* – justificar caso a caso, a depender da solução pretendida e objetivos estratégicos do ente público.

x) *Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual* – avaliar necessidades de adequação do ambiente do órgão para viabilizar a execução contratual, abrangendo, no mínimo: infraestrutura tecnológica; infraestrutura elétrica; logística de implantação; espaço físico e mobiliário.

xi) *Contratações correlatas e/ou interdependentes* – se houve contratos relacionados, descrever, do contrário somente atestar a não aplicação do item ao caso concreto.

xii) *Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para o desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável* – Trazer as justificativas com base no estudo preliminar realizado sobre a solução escolhida combinado com a política de sustentabilidade do ente público.

xiii) *Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina*¹³⁶ – elaborar a declaração da viabilidade ou não da contratação da contratação, contendo a justificativa da solução escolhida, que deverá abranger a

identificação dos benefícios a serem alcançados em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade.

A Nova Lei faz uma ressalva no art. 18, parágrafo 2º, registrando que os elementos constantes dos incisos I, IV, VI, VIII e XIII são essenciais e, para os demais elementos, quando não figurarem no documento, devem ser apresentadas as justificativas.

Em âmbito federal, esse documento deve ser elaborado pela equipe de planejamento indicada no DOD, visto se tratar de artefato que demanda contribuição multissetorial, conforme prescrito no art. 9º, II, e art. 11 da IN SGD nº 94/2022.

5.3.1 Definição da solução viável nas contratações de TIC

Tatiana Camarão

Camila Murta

Como já dito, o Estudo Técnico Preliminar – ETP tem como propósito jogar luz para várias soluções a fim de resolver a problematização apresentada pela área demandante.

É praxe, em diversos órgãos públicos, a escolha de soluções baseada no “achismo”, sem identificação da demanda e avaliações prévias. Ações sem critérios definidos e decisões tomadas sem evidências e dados se tornaram práticas do dia a dia e geram desperdício passivo ou comprometimento de prioridades já validadas no planejamento estratégico.

Por isso é importante que se destine atenção à elaboração desse documento com o objetivo de identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

5.3.2 Análise de soluções possíveis

Na análise de soluções de TIC é relevante pontuar, analisar e verificar os seguintes itens:

- A disponibilidade de solução similar em outro órgão ou entidade da Administração Pública;
- As alternativas do mercado;
- A existência de *software* público brasileiro;
- As políticas, os modelos e os padrões de governo, quando aplicáveis;
- As necessidades de adequação do ambiente do órgão ou entidade para viabilizar a execução contratual (exemplo: mobiliário, instalação elétrica, espaço adequado para a prestação do serviço, meio ambiente (não obrigatório), entre outros);
- A possibilidade de aquisição na forma de bens ou contratação como serviço;
- Os diferentes modelos de prestação do serviço;
- A opção entre comprar e locar;
- Os diferentes tipos de soluções em termos de especificação, composição ou características dos bens e serviços integrantes;
- A ampliação ou substituição da solução implantada. Com base neste levantamento, cenários ou arranjos poderão ser formados para compor as soluções possíveis para o atendimento da necessidade.

De igual relevância, destacam-se as seguintes *recomendações balizadas em decisões do TCU*:

- Avaliar o grau de dependência da solução a ser contratada e o planejamento de ações para minimizar impactos causados pela eventual necessidade de substituir a solução a ser adquirida (Acórdão nº 2.569/2018 Plenário);
- Avaliar a relação custo-benefício de manter a solução implantada ou de substituí-la, em casos que, mesmo havendo alto impacto na migração da solução, haja ganhos financeiros para a organização (Acórdão nº 2.569/2018 Plenário);

- Avaliar o custo/benefício de contratar os serviços de suporte técnico e de atualização de versões, sejam ambos ou somente um deles, ou de não contratar nenhum desses serviços, considerando elementos como a necessidade de negócio que motive a contratação desse serviço e o preço praticado por esse serviço, de acordo com a Constituição Federal, art. 37, *caput* (parágrafos 287 a 290 e 299 a 302) (Acórdão nº 2.569/2018 Plenário);
- Avaliar o impacto orçamentário e financeiro das contratações de *software* baseadas em modelos voltados totalmente para serviços, a exemplo de SaaS e Computação em Nuvem, de forma a subsidiar o planejamento para a mudança na forma de custeio da TI governamental ao longo dos anos (parágrafo 377 no Acórdão nº 2.569/2018 Plenário).

5.4 Termo de Referência

Tatiana Camarão

Camila Murta

O Termo de Referência é o documento que condensa as principais informações da fase interna da licitação e, por isso, deve ser construído com cuidado e atenção, já que seus dados servem de substrato para a elaboração do edital e contrato administrativo.

O Termo de Referência deve estar em sintonia com a solução viável identificada no Estudo Técnico Preliminar – ETP. A desconexão entre o idealizado e os objetos que se pretendem contratar gera inúmeros incidentes e deve ser evitada.

Por óbvio, esse alinhamento entre os dois documentos (ETP e TR) não pode ser tratado de maneira inflexível. É possível que se tenha que fazer adequações nas soluções eleitas em virtude de novas necessidades ou da realidade da área demandante. Daí decorre que

o TR é um documento adaptativo, que necessita de engajamento e atenção dos responsáveis pela sua elaboração para que seja eficaz.

Além disso, a área requisitante deverá avaliar a adequação da demanda com a necessidade posta, a fim de evitar o que comumente ocorre, que é a dissintonia entre a necessidade e o objeto, consubstanciando desperdício para a unidade administrativa.¹³⁷

5.4.1 Elementos do Termo de Referência

No Termo de Referência devem constar os elementos essenciais que servirão de base para a feitura do edital e minuta de contrato. Nesse sentido, o art. 6º, inciso XXIII, da Lei nº 14.133/21 estabeleceu os parâmetros e elementos que devem ser informados pela equipe de planejamento:

- a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
- b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;
- c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
- d) requisitos da contratação;
- e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;
- f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;
- g) critérios de medição e de pagamento;
- h) forma e critérios de seleção do fornecedor;
- i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos

que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;

j) adequação orçamentária.

No âmbito federal, os elementos do Termo de Referência estão previstos no art. 12 da IN SGD 94/2022 e deve ser utilizado o modelo de Termo de Referência elaborado pela Secretaria de Governo Digital, conforme art. 8º, §2º, do mesmo normativo.

5.4.1.1 Definição do objeto

Podemos citar como elementos sensíveis para a contratação de TIC a especificação do objeto, a forma e critério de julgamento e pesquisa mercadológica.

Para mitigar esses desafios de levantamento de informações para elaboração do Termo de Referência, a Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, em seu artigo 12, §5º, previu a possibilidade de interação com o mercado e descreve que:

§5º O Termo de Referência, a critério da Área Requisitante da solução ou da Área de TIC, poderá ser disponibilizado em consulta ou audiência pública, a fim de avaliar a completude e a coerência da especificação dos requisitos, a adequação e a exequibilidade dos critérios de aceitação, conforme disposto no art. 21 da Lei nº 14.133, de 2021.

De acordo com a Súmula 177 do TCU, “a definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição

do objeto do pregão”. Dessa feita, o agente público deve precaver-se evitando descrições que deixem dúvidas para a Administração e os licitantes, bem como que sejam excessivas, irrelevantes e desnecessárias.

A título de exemplo, há que se observar na descrição do objeto:

- a. Utilização da métrica UST (quando aplicável)
- b. Catálogo de serviços (quando aplicável): Para facilitar a descrição, é indicado verificar se há no Catálogo de Materiais – Catmat ou Catálogo de Serviços – Catser, disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal, código do objeto relacionado ao item que se pretende contratar. A utilização do catálogo eletrônico, é um comando da Nova Lei, conforme previsto no art. 19, inciso II, e consiste em sistema informatizado, com gerenciamento centralizado e indicação de preços, destinado à padronização de itens a serem adquiridos pela Administração Pública e que estarão disponíveis para licitação.

Art. 19. Os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão:

II – criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;

- c. Níveis mínimos de serviço (quando aplicável): Nas contratações de software estabelecer de padrões de Acordos de Níveis de Serviço, para servirem de referência à contratação de serviços de suporte nos casos em que estes sejam providos diretamente pelos fabricantes e para as soluções de TI mais disseminadas. (Acórdão 2.569/2018-TCU-Plenário).

Acresça-se que na descrição deve constar o quantitativo pretendido e no item da justificativa é importante informar os critérios de medição utilizados ou outros documentos probatórios que justifiquem o dimensionamento da contratação.

Segue a tabela seguinte, meramente exemplificativa, elaborada pelo governo federal:¹³⁸

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATAMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1						
2						
3						
.						
.						
.						

5.4.1.1.1 Da necessidade de avaliar o ciclo de vida do produto

O novo marco legal de licitações e contratos deixa claro que a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública é aquela que gera melhor resultado de contratação, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto.

Para tanto, a nova lei previu que a fase preparatória da licitação deve destinar atenção à avaliação de todo o contexto de funcionamento do objeto que se pretende contratar, para efeito de indicar a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros.¹³⁹

Inclusive, a lei nova prevê que o estudo preparatório da contratação (ETP) deve conter o elemento descritivo de análise da demanda e os possíveis impactos ambientais, com as respectivas

medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável,¹⁴⁰ para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa para a Administração Pública.

A propósito, a Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, em seu artigo 11, descreve que:

III – análise comparativa de custos, que deverá considerar apenas as soluções técnica e funcionalmente viáveis, incluindo:

a) cálculo dos custos totais de propriedade (Total Cost Ownership – TCO) por meio da obtenção dos custos inerentes ao ciclo de vida dos bens e serviços de cada solução, a exemplo dos valores de aquisição dos ativos, insumos, garantia técnica estendida, manutenção, migração e treinamento; e

Não resta dúvida de que é essencial para evitar o desperdício passivo na Administração pública contratar considerando os parâmetros necessários e inescapáveis da qualidade e do preço justo.

A despeito da importância de se prestigiar o melhor preço conjugado com a qualidade do produto, contrariamente ao que recomenda a Nova Lei, o que se tinha é a imposição de restrições à aferição de melhores produtos, quer seja pela vedação a qualquer indicação de marca ou pela fixação de critério de julgamento de menor preço.

A propósito, o Tribunal de Contas da União, na análise de contratação sob a égide da Lei nº 8.666/1993, entendeu que a vantajosidade não se confunde com o menor preço, conforme preceitua o julgado do TCU – Acórdão nº 1.978/2009 – Plenário.

Relatório – 8.1.1 o conceito da proposta mais vantajosa, inserido no caput do artigo 3º da Lei nº 8.666/1993, não se confunde com o de “mais barato”, visto que sua compreensão pressuporia o atendimento das exigências constitucionais de economicidade e eficiência; em seguida, ampara o entendimento nos ensinamentos de Antônio Carlos Cintra do Amaral, textualmente: “É comum considerar-se que a maior vantagem para a Administração está sempre no

menor preço. Isso reflete o entendimento, equivocado, de que a lei consagra a tese de que o mais barato é sempre o melhor, sem contemplação com a técnica e a qualidade. Esse entendimento não corresponde ao disposto na Lei 8.666/93 e conflita com os princípios da razoabilidade, eficiência e economicidade, que regem os atos administrativos, inclusive os procedimentos licitatórios”.

Sobre o assunto, é importante acentuar que a Nova Lei apresenta, no art. 34, avanços ao prever que na identificação do menor preço deve ser considerado o menor dispêndio para que a proposta seja declarada vencedora. Essa é a dicção desse festejado artigo:

Art. 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, por técnica e preço considerará o menor dispêndio para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação.

§1º Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento.

Como se observa, para efeito de aferição da proposta mais vantajosa, devem ser considerados não apenas o preço, mas, sobretudo, o ciclo de vida do bem ou serviço, a questão da operação, a manutenção e a disposição final dos produtos propriamente ditos. Gestores inteligentes “não mais consideram o meio ambiente como um peso que representa mais custos, mas, sim, um investimento que compensa muito”.^{[141](#)}

Não restam dúvidas de que estamos diante de uma mudança de paradigma nas contratações públicas, na medida em que temos de deixar de pensar exclusivamente no preço como única referência balizadora do negócio público para, também, avaliar se o produto que se está a comprar é o que apresenta o menor dispêndio.

5.4.1.2 Da fundamentação da contratação

Neste item do Termo de Referência devem ser descritas sinteticamente e com base no ETP, apontando para o documento ou processo administrativo de contratação que contém os referidos estudos, as razões que motivam e justificam a contratação. É importante, ainda, indicar o alinhamento com o planejamento estratégico, PCA e PDTIC.

Neste item, deverá, ainda, constar a justificativa da viabilidade de realizar o parcelamento da solução de TIC a ser contratada em tantos itens quanto se comprovarem tecnicamente viáveis, observado o disposto nos §§2º e 3º do art. 40 e §1º do art. 47 da Lei nº 14.133, de 2021. Outrossim, a participação de consórcio é obrigatória, devendo ser justificada decisão contrária, e a subcontratação da solução de TIC deve ser autorizada observado o disposto nos arts. 15 e 122 da Lei nº 14.133, de 2021.

É importante esclarecer que as condições que se fazem presentes no edital devem ser justificadas no texto do Termo de Referência, conforme preceitua o art. 18, inciso IX, da Lei nº 14.133/21, tais como as exigências relativas à qualificação técnica e econômico-financeira, os critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas e as regras pertinentes à participação de empresas em consórcio ou subcontratação da solução de TIC.

O art. 15 da IN SGD nº 94/2022 informa que a justificativa deve ser clara, precisa e suficiente, sendo vedadas justificativas genéricas, incapazes de demonstrar as reais necessidades da contratação, e deve conter os seguintes elementos mínimos.

I – o alinhamento da solução de TIC com os instrumentos de planejamento elencados no art. 6º;

II – a relação entre a necessidade da contratação da solução de TIC e os respectivos volumes e características do objeto;

III – a forma de cálculo utilizada para a definição do quantitativo de bens e serviços que compõem a solução;

IV – os resultados e benefícios a serem alcançados com a contratação; e

V – a motivação para permitir adesões por parte de órgãos ou entidades não participantes, nos casos de formação de Ata de Registro de Preços passível de adesões.

5.4.1.3 Da descrição da solução como um todo

Essa informação deve ser uma síntese do que consta do ETP. Vale lembrar que o art. 18, §1º, inciso VII, diz respeito a esse elemento que servirá de substrato para a elaboração desse item.

5.4.1.4 Dos requisitos da contratação

Os requisitos da contratação dizem respeito à conformidade técnica e legal do objeto com a indicação das normas técnicas e legais, caso existam, as quais a solução de Tecnologia da Informação e Comunicação deverá estar aderente. A título de exemplo, não podem faltar os requisitos e obrigações de Segurança da Informação e Privacidade – SIP.

De acordo com a IN SGD nº 94, de 2022, a especificação dos requisitos da contratação deve ser realizada conforme preceitua o art. 16, I e II, desde que estejam devidamente alinhados.

Art. 16. Na especificação dos requisitos da contratação, compete:

I – ao Integrante Requisitante, com apoio do Integrante Técnico, definir, quando aplicáveis, os seguintes requisitos:

- a) de negócio, que independem de características tecnológicas e que definem as necessidades e os aspectos funcionais da solução de TIC;
- b) de capacitação, que definem a necessidade de treinamento, de carga horária e de materiais didáticos;
- c) legais, que definem as normas com as quais a solução de TIC deve estar em conformidade;
- d) de manutenção, que independem de configuração tecnológica e que definem a necessidade de serviços de manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva (melhoria funcional);
- e) temporais, que definem datas de entrega da solução de TIC contratada;

- f) de segurança e privacidade, juntamente com o Integrante Técnico; e
- g) sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a solução de TIC deve atender para estar em conformidade com costumes, idiomas e ao meio ambiente, dentre outros, observando-se, inclusive, no que couber, o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, e suas atualizações, elaborado pela Câmara Nacional de Sustentabilidade da Controladoria Geral da União/Advocacia Geral da União;

II – ao Integrante Técnico especificar, quando aplicáveis, os seguintes requisitos tecnológicos:

- a) de arquitetura tecnológica, composta de *hardware*, *software*, padrões de interoperabilidade, linguagens de programação, interfaces, dentre outros;
- b) de projeto e de implementação, que estabelecem o processo de desenvolvimento de *software*, técnicas, métodos, forma de gestão, de documentação, dentre outros;
- c) de implantação, que definem o processo de disponibilização da solução em ambiente de produção, dentre outros;
- d) de garantia e manutenção, que definem a forma como será conduzida a manutenção, acionamento da garantia e a comunicação entre as partes envolvidas;
- e) de capacitação, que definem o ambiente tecnológico dos treinamentos a serem ministrados, os perfis dos instrutores, dentre outros;
- f) de experiência profissional da equipe que executará os serviços relacionados à solução de TIC, que definem a natureza da experiência profissional exigida e as respectivas formas de comprovação dessa experiência, dentre outros;
- g) de formação da equipe que projetará, implementará e implantará a solução de TIC, que definem cursos acadêmicos e técnicos, formas de comprovação dessa formação, dentre outros;
- h) de metodologia de trabalho;
- i) de segurança da informação e privacidade, juntamente com o Integrante Requisitante; e
- j) demais requisitos aplicáveis.

5.4.1.5 Modelo de execução do objeto

O modelo de execução e de gestão do contrato refere-se a forma como o ajuste será executado e gerido desde o início até o seu encerramento.

Neste item devem ser informados:

- a) o regime de execução do contrato de prestação de serviços;

- b) a dinâmica de execução com a definição de etapas, logística de implantação, cronogramas, prazos, horários de fornecimento de bens ou prestação dos serviços e locais de entrega, quando aplicáveis, entre outros pertinentes;
- c) a forma de acompanhamento, das rotinas de execução, com a definição de processos e procedimentos de fornecimento da solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), do atendimento aos prazos de garantia ou aos níveis mínimos de serviços exigidos;
- d) a forma de comunicação e acompanhamento da execução do contrato entre o órgão e a empresa contratada, adotando-se preferencialmente as ordens de serviço ou fornecimento de bens;
- e) a forma de recebimento provisório e definitivo, bem como de avaliação da qualidade dos bens e/ou serviços entregues, procedimentos de teste e inspeção.

É importante, ainda, constar desse item o prazo de execução do objeto. Vale lembrar que a Nova Lei inovou ao prever a possibilidade de prorrogação de contrato de fornecimento, que era expressamente vedada na Lei nº 8.666/93. Além disso, alargou o prazo de vigência dos contratos permitindo que se tenha contratação de até 5 anos, podendo ser prorrogada por até 10 anos.

Nessa perspectiva o prazo de vigência de fornecimento não contínuo, o qual se trata de uma entrega de bens sem que haja demanda de caráter permanente, o prazo a ser fixado deve ser o suficiente para a entrega do objeto e adoção das providências, conforme previsto no art. 105 da Lei nº 14.133/21. Se for o caso de fornecimento contínuo, o qual se caracteriza por ser essencial e de necessidade permanente, é possível prever que o prazo de vigência da contratação é de até 5 anos, prorrogável para até 10 anos, na forma dos art. 106 e 107 da Lei nº 14.133/21.

No caso de operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação, conforme previsto no art. 114 da Lei nº

14.133, de 2021, o prazo de vigência da contratação pode ser previsto em até 15 anos, incluindo prorrogações.

5.4.1.6 Modelo de gestão do contrato

Neste item devem ser descritos os papéis a serem desempenhados pelos principais atores do órgão e da empresa envolvidos na contratação.

A título de exemplo, citam-se algumas responsabilidades das partes:

– *Definição das obrigações da contratante* contendo, pelo menos, a obrigação de:

- 1) nomear gestor e fiscais técnico, administrativo e demandante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos;
- 2) encaminhar formalmente a demanda por meio de ordem de serviço ou de fornecimento de bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência;
- 3) receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas;
- 4) comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base na Avaliação de Resultado;
- 5) aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável;
- 6) liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;
- 7) comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC);
- 8) definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

por parte da contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável; e

9) prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, pertençam à Administração.

– *Definição das obrigações da contratada* contendo, pelo menos, a obrigação de:

1) indicar formalmente preposto apto a representá-lo junto à contratante, que deverá responder pela fiel execução do contrato;

2) atender prontamente quaisquer orientações e exigências da equipe de fiscalização do contrato, inerentes à execução do objeto contratual;

3) reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela contratante;

4) propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária;

5) manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;

6) quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para o fornecimento da solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC);

7) quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) durante a execução do contrato; e

8) ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração.

Além disso, o modelo de gestão de contratos envolve as informações relacionadas aos instrumentos formais de solicitação de fornecimento dos bens e/ou de prestação de serviços, documentação mínima exigida, observando modelos adotados pela contratante, padrões de qualidade e completude das informações, a exemplo de modelos de desenvolvimento de *software*, relatórios de execução de serviço e/ou fornecimento, controles por parte da contratada, ocorrências, entre outros.

Neste item há necessidade, também, de fixar a metodologia, formas de avaliação da qualidade e adequação da solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) às especificações funcionais e tecnológicas:

- i) quantificação ou estimativa prévia do volume de serviços demandados ou quantidade de bens a serem fornecidos, para comparação e controle;
- ii) definição de mecanismos de inspeção e avaliação da solução, a exemplo de inspeção por amostragem ou total do fornecimento de bens ou da prestação de serviços;
- iii) adoção de ferramentas, computacionais ou não, para implantação e acompanhamento dos indicadores estabelecidos;
- iv) origem e formas de obtenção das informações necessárias à gestão e à fiscalização do contrato;
- v) definição de listas de verificação e de roteiros de testes para subsidiar a ação dos fiscais do contrato; e
- vi) garantia de inspeções e diligências, quando aplicáveis, e suas formas de exercício.

Há que se ter a fixação dos critérios de aceitação dos serviços prestados ou bens fornecidos, abrangendo métricas, indicadores e

níveis mínimos de serviços com os valores aceitáveis para os principais elementos que compõem a solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

No caso de necessidade de realização de prova de conceito, os procedimentos e critérios objetivos a serem utilizados na avaliação no processo deverão constar deste item.

5.4.1.7 Critérios de medição e de pagamento

Este item estabelece o prazo máximo de pagamento e como este ocorrerá, se mediante apresentação de nota de empenho de despesa, ou outra forma, se for o caso. Além disso, devem ser informados o número de parcelas e outros critérios para pagamento.

É importante constar, também, os procedimentos para retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, que só deverão ocorrer quando a contratada:

- i) não atingir os valores mínimos aceitáveis fixados nos critérios de aceitação, não produzir os resultados ou deixar de executar as atividades contratadas; ou
- ii) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

5.4.1.8 Forma e critérios de seleção do fornecedor

Neste item deve ser informado o procedimento da contratação: concorrência, pregão, pregão para registro de preços, contratação direta, credenciamento, diálogo competitivo, bem como o tipo de licitação: menor preço, maior desconto, técnica e preço, melhor técnica, melhor conteúdo artístico e maior retorno econômico.

5.4.1.9 Estimativas do valor da contratação

Trata-se da pesquisa de mercado, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado.

A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo:

- I – identificação do agente responsável pela cotação;
- II – caracterização das fontes consultadas;
- III – série de preços coletados;
- IV – método matemático aplicado para a definição do valor estimado; e
- V – justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inexecutáveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável.

Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso. A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

- I – painel de preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldepregos, desde que as cotações se refiram a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;
- II – aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

III – dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo data e hora de acesso; ou

IV – pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

Recomenda-se priorizar, na pesquisa de preços, as fontes dos sistemas oficiais de governo, como painel de preços, e contratações similares feitas pela Administração Pública, devendo ser justificada no procedimento de coleta a impossibilidade de utilização desses parâmetros.

Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores deverá ser observado:

I – prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;

II – obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:

a) descrição do objeto, valor unitário e total;

b) número do Cadastro de Pessoa Física – CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do proponente;

c) endereço e telefone de contato; e

d) data de emissão.

III – registro, nos autos da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação.

5.4.1.10 Adequação orçamentária

A adequação orçamentária, o cronograma físico-financeiro orçamentário e o cronograma físico-financeiro são elaborados pelos

integrantes da equipe de planejamento, requisitante e técnico, contendo:

a) a estimativa do impacto no orçamento do órgão ou entidade, com indicação das fontes de recurso; e

b) cronograma de execução física e financeira, contendo o detalhamento das etapas ou fases da solução a ser contratada, com os principais serviços ou bens que a compõem, e a previsão de desembolso para cada uma delas.

5.5 Requisitos técnicos habilitatórios da contratação TIC

Everton Batista

5.5.1 Habilitação técnica

Preliminarmente é essencial explorar os requisitos sob a ótica da habilitação técnica na Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021) de maneira ampla aplicável a todas as contratações e então traçar um paralelo com as normas específicas que versam sobre Tecnologia da Informação e Comunicações.

Neste cenário tem-se que em linhas gerais a habilitação técnica visa a comprovar aptidões e experiência profissional necessárias para a execução do objeto pretendido pela Administração, bem como o domínio para a sua performance compatível em termos de prazos e quantidades, aparelhamento, equipe, dentre outros.

5.5.1.1 Linhas gerais

A *habilitação técnica* visa a comprovar aptidões e experiência profissional necessárias para a execução do objeto pretendido pela Administração, bem como o domínio para a sua *performance*

compatível em termos de prazos e quantidades, aparelhamento, equipe, dentre outros.

O rol do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021, ressalvados os requisitos previstos em lei especial, é *taxativo* e deve ser observado diante da especificidade de cada contratação, se complexa ou não, visando à não exigência de documentos que podem restringir a competitividade (princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – art. 5º da Nova Lei).

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

I – apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

II – certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do §3º do art. 88 desta Lei;

III – indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

IV – prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;

V – registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI – declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

§1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

§2º Observado o disposto no caput e no §1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

§3º Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo, a critério da Administração, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento.

§4º Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

§5º Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos.

§6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do caput deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

§7º Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso V do caput deste artigo por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

§8º Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos I e III do caput deste artigo.

§9º O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

§10. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica:

I – caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

II – caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para

contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

§11. Na hipótese do §10 deste artigo, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio.

§12. Na documentação de que trata o inciso I do caput deste artigo, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Por sua vez, vale destacar as definições de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional. Nesse sentido, trazem-se à baila as definições os autores Ache e Fenili (2021, p. 559):

Capacidade operacional refere-se, pois, a predados estruturais da licitante, mormente em nível mesmo de análise, enquanto capacidade de gestão e experiência empresarial, congregada em ativos físicos e em capacidade de condução processual. Já a *capacidade profissional* refere-se ao capital intelectual de seus membros, no nível de análise do indivíduo, com competências manifestas via educação formal ou experiência acumulada e comprovada.

Cabe ainda sobrelevar a jurisprudência da Corte Federal de Contas, o Acórdão nº 2208/2016 – Plenário TCU sobre o tema, o qual enfatiza a interdependência e a abrangência entre qualificações técnico-profissional e técnico-operacional:

Enquanto a *capacitação técnico-profissional* está relacionada à qualificação do corpo técnico, a *capacitação técnico-operacional*, por sua vez, é bem mais ampla e alcança requisitos empresariais, tais como estrutura administrativa, métodos organizacionais, processos internos de controle de qualidade, etc. Na prática, a *qualificação comprovada de um profissional não é suficiente para garantir a experiência operacional da empresa à qual esse profissional esteja vinculado*, seja na condição de prestador de serviço ou na condição de sócio, e, conseqüentemente, a qualidade da execução contratual poderá ser comprometida.

5.5.1.2 Documentações a serem apresentadas

Conquanto a redação *do artigo 67, inciso I*, da NLLCA possa, em leitura preliminar, restringir a qualificação técnico-profissional e técnico operacional ao campo de engenharia, arquitetura, agronomia e urbanismo, haja vista a exigência de atestado de responsabilidade técnica, esta não é a melhor intelecção.

Segundo os autores Andréa e Fenili (2021, p. 559) “ao que ressoa, possível é o baralhamento entre os conceitos de *Anotação de Responsabilidade Técnica* (ART) e *Atestado de Responsabilidade Técnica*, sendo que apenas o último é tocado pelo inciso em análise. E, de toda sorte, não são limitados às profissões citadas, haja vista suas previsões no campo da medicina veterinária, nutrição, química, enfermagem, entre inúmeras outras”.

Ato contínuo, assim, os autores esclarecem:

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é o documento que define que o responsável técnico por uma obra ou serviço de engenharia, arquitetura ou agronomia é profissional com formação na área correspondente. Refere-se sempre à pessoa física. Alude, assim, a instrumento basilar para a fiscalização profissional, e deve ser obtido antes do início da execução do objeto. É instituído pela Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1997, sendo o documento emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), de acordo com Resolução do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA).¹⁴² Já o atestado de responsabilidade técnica é documento emitido apenas após a conclusão da obra ou do serviço. Tem a finalidade de comprovar que determinado responsável técnico conduziu o objeto até a sua conclusão. Uma ART, per si, é prévia à execução e não constitui prova de capacidade técnico-profissional. Apenas a baixa da ART, via um atestado, certifica a efetiva prestação. No campo da engenharia, o somatório de atestados profissionais – seu acervo – é comprovada via a Certidão de Acervo Técnico (CAT).¹⁴³

Assim, há que se esclarecer que *este inciso exige a comprovação de que o licitante dispõe de profissional que já atuou, com êxito, no papel de responsável técnico em obra ou serviço congênere ao objeto a ser contratado, sem a necessidade de que o profissional responsável técnico seja componente*

do quadro permanente da licitante. Neste caso, permite contratos temporários de prestação de serviços.

Sobre o *artigo 67, inciso II da NLCCA*, cabe esclarecer o que seja (i) certidões ou atestados de capacidade técnico-operacional; e (ii) documentos comprobatórios de avaliação do contratado.

Em sede jurisprudencial, pacificado é que o *atestado de capacidade técnico-operacional prescinde de registro em conselho profissional* – diferentemente do que ocorre com os atestados de responsabilidade técnica profissional. Tal é o explicitado, ilustra-se, pelos seguintes acórdãos da Corte Federal de Contas:

[...] só cabe exigir que o atestado de capacidade técnica seja visado, reconhecido, autenticado ou averbado pelo conselho de fiscalização profissional se a legislação especial aplicável à atividade em questão previr que a entidade de fiscalização mantenha controle individualizado sobre cada trabalho realizado, o que não ocorre com a maior parte das profissões regulamentadas. (Acórdão nº 1.452/2015 – Plenário TCU)

[...] a exigência de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA dos atestados de qualificação técnico-operacional não tem amparo legal e está em desacordo com os acórdãos 128/2012-2ª Câmara, 1.452/2015-Plenário e 655/2016-Plenário e com a Resolução 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea; (Acórdão nº 7.260/2016 – Segunda Câmara TCU)

É irregular a exigência de que a atestação de capacidade técnico-operacional de empresa participante de certame licitatório seja registrada ou averbada junto ao Crea, uma vez que o art. 55 da Resolução Confea 1.025/2009 veda a emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome de pessoa jurídica.

A exigência de atestados registrados nas entidades profissionais competentes deve ser limitada à capacitação técnico-profissional, que diz respeito às pessoas físicas indicadas pelas empresas licitantes. (Acórdão nº 1.674/18 – Plenário TCU)

Ainda, a Nova Lei de Licitações absorve, explicitamente, a vedação temporal (e geográfica) a atestados, bem como apõe restrição de exigência às parcelas de maior relevância do objeto, provendo contornos mais previsos a tal caráter subjetivo. É o que dispõem os §§1º e 2º do art. 67:

Art. 67, §1º A exigência de atestados será *restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação*, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

§2º Observado o disposto no *caput* e no §1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. (destaques dos autores)

Para mais, o legislador adotou como critério limitador a valoração individual das parcelas que compõem o objeto a ser licitado (§1º do art. 67). Há, na verdade, uma decomposição dos custos para mensurar a exigência, todavia, limitado ao valor individual mínimo de 4% do valor total estimado da contratação, assim nominadas de parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação¹⁴⁴. Nesse quesito, pontua-se distinção com relação à Lei nº 8.666/93, que delega a definição de parcela mais relevante para o instrumento convocatório.

Lado outro, o §2º do art. 67 assenta jurisprudência consolidada da Corte de Contas Federal e admite a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, para comprovação da qualificação técnica. Ou seja, ultrapassar tal percentual afronta o novel diploma, e estabelece indevida restrição à competitividade. A premissa posta é a de que a capacidade técnico-operacional pode ser verificada via atestados com até metade do quantitativo demandado, referentes aos itens economicamente mais relevantes.

Vale anotar o §5º do art. 67, quando aborda o domínio dos *serviços contínuos*:

Art. 67, §5º Em se tratando de serviços contínuos, o edital *poderá* exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos.

A rigor, mitiga possíveis riscos do negócio e os casos onde a execução é complexa. É de instrumentalidade facultativa, e consigna limitação temporal da experiência da licitante – sucessiva ou não –, como forma de não direcionamento. A partir disso, considerando que §5º do art. 67 não tem caráter mandatório, propugna-se a adequada fundamentação da Administração, baseada nos estudos técnicos preliminares e na experiência pretérita, que indiquem ser indispensável para assegurar a prestação do serviço em conformidade com as necessidades específicas do órgão ou entidade contratante, por força da sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra particularidade.

Permite à Administração exigir do licitante, além dos atestados ou certidões que demonstrem a sua capacidade operacional para a execução do objeto, o *documento comprobatório da avaliação de desempenho na execução dos contratos já firmados com a Administração*, constante do sistema de registro cadastral unificado (§3º do art. 88).

Insurge, neste ponto, a possibilidade de, a mera comprovação de conclusão do objeto ser suficiente para fins de habilitação ou, de forma diversa, o atingimento de determinado nível de performance, objetivamente aferida, ser indispensável para a aludida habilitação. Tal opção deverá ser alvo de regulamentação infralegal, inevitavelmente.

Em verdade, esse documento comprobatório de desempenho pretérito mostra-se como um mecanismo de verificação atualizado e real dos licitantes, via sistema de *rating* ou, quiçá, um *ranking* de fornecedores melhores pontuados. Isso, por regra, incentiva os contratados na melhoria contínua do seu desempenho e amplia a transparência instrumental para a Administração, que, na maioria das vezes, não tem informações suficientes para balizar a futura contratação pela notabilidade das performances contratuais já realizadas com a Administração.

A *ratio legis*, neste caso, será municiar a Administração de elementos capazes de *comparabilidade* entre o já executado pelo licitante e o que se pretende contratar, com base no histórico relacional com o poder público, e decidir se o licitante tem capacidade técnica operativa para a execução do objeto licitado, podendo, a depender do caso, levar à inabilitação.

O exame, nesse quesito, é exclusivamente da performance pretérita contratual do licitante vencedor – preponderando a inversão de fases –, não havendo prejuízo se outro licitante participante do mesmo certame detiver performance superior à apresentada por ele. A avaliação é singular: do licitante vencedor.

No tocante ao que prevê o *artigo 67, inciso III da NLCCA* entende-se que são conteúdos que, ordinariamente, integram a proposta do licitante (JUSTEN FILHO, 2021). Em verdade, são variáveis operacionais (instalações, aparelhamento) e profissionais (pessoal técnico e qualificação dos membros responsáveis pelos trabalhos).

Na esteira do inciso III, o resguardo recai sobre a efetiva viabilidade de, ao longo da execução do contrato, o corpo técnico indicado pela licitante, seja como responsáveis técnicos, seja como dotados das competências imprescindíveis para a avença disponha da necessária carga horária para prestação do objeto, sem atrasos.

O *artigo 67, inciso IV da NLCCA* propugna que a depender do objeto que será contratado, há necessidade de se atender a determinados requisitos previstos em lei especial, sejam de ordem ambiental, sanitária, técnica, tecnológica ou de licença para funcionamento, a exemplo do certificado de boas práticas de fabricação e controle (CBPFC), emitido pela ANVISA.

Já o *artigo 67, inciso V da NLCCA* lastreia-se na Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 170¹⁴⁵, que assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos; não obstante, para o exercício de

algumas atividades, seja necessário registro ou inscrição na entidade profissional competente, sob pena de impedimento do exercício da profissão.

Essa entidade profissional competente é incumbida regimentalmente de exercer a fiscalização e a regulamentação do exercício profissional de acordo com as classes em que se abrangem: CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia); CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo); OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), CRM (Conselho Regional de Medicina), dentre muitos.

Para que não se caracterize irrelevante ou impertinente ao objeto que será executado, nem configure avessas ao caráter competitivo da licitação – princípio da competitividade (art. 5º da Lei), a Lei nº 6.839/80, em seu art. 1º, estabelece que *o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.*

Em outros termos, *o registro ou a inscrição na entidade profissional competente deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante da licitação, consoante jurisprudência consolidada da Corte de Contas Federal.*

Por fim, o *artigo 67, inciso VI da NLCCA*, em certo prisma, guarda zona de interseção com o exarado pelos §§2º e 3º do art. 63, que cuida de avaliação prévia do local de execução, com a faculdade de vistoria ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Como aplicação prática, mais do que a comprovação da qualificação técnica em si, fragiliza-se qualquer argumento ulterior da contratada acerca de desconhecimento de determinada obrigação

ou de característica física ou logística local, já em sede de eventual processo de apuração de penalidade.

Assim, de forma ampla, devem-se observar os limites exarados na Lei Geral conforme exposto anteriormente.

Sobre a análise para a abrangência específica de Tecnologia da Informação e Comunicações – TIC, a *Instrução Normativa SGD/ME nº 94*, de 23 de dezembro de 2022, regida pela Lei nº 14.133, de 2021, em seu art. 23, *estabelece que os critérios de habilitação técnica* devem seguir ao disposto art. 67 da Lei 14.133/21 de forma direta não apresentando nenhum tratamento diferenciado.

O que permite concluir que a aplicabilidade das regras existentes na Lei Geral deve ser rigorosamente seguida de forma exaustiva. Reforça-se este pensamento, pois no Anexo I da IN nº 94/2022 que versa sobre diretrizes específicas de planejamento da contratação dos diversos tipos de contratações não indica nenhum procedimento além dos já ilustrados.

No âmbito das certificações para as compras de TIC, de forma geral, é vedado qualquer exigência antes da contratação. Porém para algumas contratações são requeridas a comprovação de certificações como por exemplo para a contratação de infraestrutura de centro de dados, serviços em nuvem, sala-cofre e sala segura, conforme dispõe a IN SGD/ME nº 94/22:

4. CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CENTRO DE DADOS, SERVIÇOS EM NUVEM, SALA-COFRE E SALA SEGURA:

4.1. Os órgãos e entidades que necessitem criar, ampliar ou renovar infraestrutura de centro de dados deverão fazê-lo por meio da contratação de serviços de computação em nuvem, salvo quando demonstrada a inviabilidade em estudo técnico preliminar da contratação.

4.2. As contratações de serviços em nuvem devem observar as normas correlatas publicadas pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – GSI/PR.

4.2.1. Os órgãos e entidades devem exigir mediante justificativa prévia, no momento da assinatura do contrato, que fornecedores privados de serviços em nuvem possuam certificações de normas de segurança da informação aplicáveis ao objeto da contratação, assim como outros requisitos que objetivem mitigar riscos relativos à segurança da informação.

5. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

5.1. Nas contratações realizadas com empresas públicas de TIC, os órgãos e entidades do SISP deverão solicitar, junto com a proposta comercial, os demonstrativos de formação de preços de cada serviço e sistema objeto da proposta, em nível de detalhamento que permita a identificação dos recursos produtivos utilizados (insumos), com as respectivas quantidades e custos.

8. AQUISIÇÕES DE ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

8.1. Nas aquisições de bens de tecnologia da informação e comunicação, o instrumento convocatório deverá prever que:

I – as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou por outra entidade credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos requisitos de segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia serão exigidas como requisito de qualificação dos bens a serem adquiridos; e

II – serão aceitas certificações emitidas, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, coordenado pelo

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, como também aquelas emitidas por organismos acreditados por esse Instituto, os quais podem ser consultados por meio do endereço <https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/acreditacao/organismos-acreditados>.

8.2. Nos casos de comprovada inviabilidade técnica para a obtenção de certificações ou de aquisição de bens de elevada singularidade e personalização, o órgão poderá, de forma justificada, dispensar as certificações previstas no item 8.1.

8.3. Os bens de tecnologia da informação e comunicação abrangidos pelas certificações de que trata o item 8.1 são aqueles listados no Anexo A da Portaria Inmetro nº 170, de 10 de abril de 2012, com exceção do Grupo “Equipamentos eletroeletrônicos para uso em escritórios”.

Pelo que se pode perceber da leitura destas exigências de certificações o legislador se preocupa bastante com os requisitos de segurança de durabilidade, confiança nos casos de bens e equipamentos, bem como de integridade humana e outros aspectos de segurança da informação, nos casos de serviços de TIC.

5.6 Padronização

Tatiana Camarão

Camila Murta

Padronizar consiste na uniformização, standardização ou sistematização de determinado bem ou serviço. Trata-se de criar um modelo ou referencial de especificações técnicas e de desempenho, tendo em vista as condições de manutenção, assistência técnica e garantia já existentes na Administração.

A Lei nº 14.133/2021 prevê no seu *art. 40, inciso V*, que a compra deverá atender ao princípio da padronização e prescreveu, no *art. 43*, os documentos que o processo de padronização deverá conter:

Documentos para o processo de padronização

- parecer técnico sobre o produto, considerando especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de manutenção e garantia;
 - despacho motivado da autoridade superior, com a adoção do padrão;
 - síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial.
-

É importante ressaltar que a NLLCA previu a padronização de Serviço no *art. 47*, desde que se tenha demonstrada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho.

No que diz respeito ao princípio da padronização em relação a produtos de informática, entendeu o TCU que a indicação de marca pode ser aceita frente ao princípio da padronização, desde que a decisão administrativa que venha a identificar o produto pela sua marca seja circunstanciadamente motivada e demonstre ser essa opção, em termos técnicos e econômicos, mais vantajosa para a administração (TCU, Acórdão nº 747/08, Plenário, Rel. Min. Valmir Campelo. *DOU*, 25 abr. 2008).^{[146](#)}

Na revista *ILC*, publicada pela Editora Zênite,¹⁴⁷ aborda algumas premissas que deverão ser observadas para instauração de processo de padronização:

- a) a padronização não pode ser, a toda evidência, o disfarce de um capricho do administrador para favorecer tal ou qual produto de sua preferência pessoal; é o resultado de verificação científica, a ser subscrita por técnicos qualificados, e sem a qual a exclusão da competição seletiva nada mais é do que uma farsa;
- b) descabe interpretação analógica ou extensiva quando se trata de aprovar padronização, devendo cada caso ser alvo de estudos e pareceres que, alicerçados em sólida comprovação, aconselhem a medida.

Vale ressaltar, por fim, que além da padronização a ser implementada por meio de processo específico, conforme relatado anteriormente, temos a padronização que serve como sistemática de redução de variedades consolidada por meio de catálogo eletrônico (ver item 5.4.1.1).

5.7 Modalidades de licitação

Victor Amorim

Rafael Oliveira

5.7.1 Noções gerais: a Lei nº 14.133/2021 e suas modalidades licitatórias

A partir de uma leitura dos artigos 17 e 28 da Lei nº 14.133/2021, constata-se que a nova Lei de Licitação não se dignou a “romper” – em termos substanciais – o padrão adotado na Lei nº 8.666/1993.

Foram extintas as modalidades “tomada de preços” e “convite” e mantidas as modalidades “concorrência”, “leilão” e “concurso”, não

podendo nos esquecer da consagração da modalidade “pregão”, com vida *quase*¹⁴⁸ própria na Lei nº 10.520/2002. E, com não pouco alarde, foi criada a modalidade “diálogo competitivo”,¹⁴⁹ com clara inspiração no modelo denominado “diálogo concorrencial” adotado na União Europeia, conforme regulamentação vertida no art. 30º da Diretiva 2014/24/UE.¹⁵⁰

Segue no quadro delimitação das modalidades conforme os conceitos legais informados na NLLCA:

CONCORRÊNCIA	<i>“modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser: a) menor preço; b) melhor técnica ou conteúdo artístico; c) técnica e preço; d) maior retorno econômico; e) maior desconto” (art. 6º, XXXVIII) (grifou-se).</i>
PREGÃO	<i>“modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto” (art. 6º, XLI) (grifou-se).</i>
LEILÃO	<i>“modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance” (art. 6º, XL) (grifou-se).</i>
CONCURSO	<i>“modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor” (art. 6º, XXXIX) (grifou-se).</i>
DIÁLOGO COMPETITIVO	<i>“modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos” (art. 6º, XLII) (grifou-se).</i>

Assim como na Lei nº 8.666/1993, tem-se na NLLCA a manutenção das premissas de cabimento das modalidades “leilão” (para *alienação* de bens da Administração) e “concurso” (para *seleção de trabalho* de natureza técnica, científica ou artística mediante concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor).

Uma distinção¹⁵¹ a que se ressaltar reside no fato de que, com a Lei nº 14.133/2021, o “leilão” passa a ser a modalidade absoluta para alienação de bens da Administração, sejam móveis ou imóveis, independentemente do valor estimado ou da forma de transferência ou aquisição do patrimônio pela Administração.

Afora contratações específicas (alienações e seleção de trabalho de natureza técnica, científica ou artística), no tocante à *contratação de obras e serviços e aquisição de bens*, o grande desafio do aplicador da norma – assim como se passava nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002¹⁵² – relaciona-se aos critérios para o adequado enquadramento da modalidade licitatória: *concorrência*, *pregão* ou *diálogo competitivo*?

Sabe-se que a nova Lei, para as modalidades que se prestam à contratação do mesmo tipo de objeto (obra, serviço e bem), abandona o critério de observância do valor estimado então adotado no art. 23 da Lei nº 8.666/1993 para a *concorrência*, a *tomada de preços* e o *convite*.

Baseada na experiência observada no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520/2002, sustentada em conceitos jurídicos indeterminados,¹⁵³ a Lei nº 14.133/2021, quanto à *concorrência*, ao *pregão* e ao *diálogo competitivo*, estrutura a avaliação de definição da modalidade a partir de três critérios, cuja incidência é cumulativa:

Tipo do objeto	Obra
	Serviço

	<i>Bem</i>
	<i>Comum</i> (há domínio)
Domínio uniforme do mercado relevante acerca da execução e/ou fornecimento	<i>Especial</i> (não há domínio)
"Viabilidade de definição precisa e/ou "disponibilidade no mercado" da solução apta ao atendimento da necessidade da Administrativa	Presente
	Ausente

Na Lei nº 14.133/2021, o enquadramento de um bem ou serviço como “comum”, tem como parâmetro os seguintes conceitos jurídicos indeterminados vertidos no inciso XIII do art. 6º e no *caput* do art. 29: “padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos pelo edital” e “especificações usuais no mercado”.

Por ser a redação do inciso XIII do art. 6º da NLLCA idêntica àquela adotada no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520/2002, entende-se pela viabilidade de aplicação dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais acerca dos “bens e serviços comuns” já desenvolvidos desde o início da década de 2000.

Não há antinomia intrínseca entre bens e serviços “comuns” e “complexos”. A perspectiva de adjetivação do objeto da contratação deve ser pautada pela ótica do mercado relevante. Afinal, ainda que ostente características complexas de execução e que demande o acompanhamento de um responsável técnico detentor de qualificação profissional específica, tal serviço será considerado “comum” se houver, por parte do mercado relevante, pleno domínio das técnicas de sua realização, permitindo uma proposição objetiva e padronizada de execução do objeto. É esse o entendimento que se extrai da expressão “especificações usuais de mercado” utilizada no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520/2002.¹⁵⁴ [grifou-se]

Na linha do que já resta assentado pelo Tribunal de Contas da União,

[...] a complexidade do serviço não é o fator decisivo para inseri-lo, ou não, no conceito de 'serviço comum', mas sim o domínio do mercado sobre o objeto licitado. Caso apresente características padronizadas (de desempenho e de qualidade) e se encontre disponível, a qualquer tempo, em um mercado próprio, o serviço pode ser classificado como serviço comum [...] “bem ou serviço comum” deve ser entendido como aquele que detém características padronizadas, identificável por denominação usual no mercado. Portanto, a noção de “comum” não está vinculada à estrutura simples de um bem ou de um serviço. Do mesmo modo, a estrutura complexa também não é razão bastante, por si só, para retirar a qualificação de “bem ou serviço comum”.¹⁵⁵ [grifou-se]

Nessa linha, merece destaque o Enunciado nº 26 da I Jornada de Direito Administrativo do Conselho da Justiça Federal, realizada no mês de agosto de 2020:

A Lei nº 10.520/2002 define o bem ou serviço comum baseada em critérios eminentemente mercadológicos, de modo que a complexidade técnica ou a natureza intelectual do bem ou serviço não impede a aplicação do pregão se o mercado possui definições usualmente praticadas em relação ao objeto da licitação.¹⁵⁶

Para tanto, considerando serem o “menor preço” e o “maior desconto” os critérios de julgamento admitidos para as licitações de bens e serviços comuns (art. 6º, XIII, NLLCA), somente será possível a adoção do pregão se as especificações do bem ou do serviço, dada a maturidade do mercado relevante (ainda que especializado ou com universo de *players* reduzido), forem passíveis de incorporação no edital do certame, em disposições objetivas e padronizadas.¹⁵⁷ Ou seja, apenas em tal contexto, no qual se poderá mensurar com objetividade e segurança o resultado final da futura contratação, é que será adequado empreender uma disputa concorrencial tendo como critério o “menor preço” ou o “maior desconto”.

Com efeito, o enquadramento de um bem ou serviço como comum dependerá das particularidades do caso concreto, não se mostrando viável que eventual regulamento venha a estabelecer uma lista taxativa ou predefinida. Ocorrendo tal configuração, há que se adotar a modalidade pregão, independentemente do valor estimado para a contratação. Daí nosso entendimento quanto à imprescindibilidade de manifestação da área técnica na fase de planejamento da licitação, quanto ao enquadramento do bem ou serviço como “comum” ou não.

5.7.1.1 A dinamicidade das modalidades na Nova Lei de Licitações e a Possibilidade de modelagem da licitação

Ainda que a Lei nº 14.133/2021 tenha se pautado por uma predefinição clássica das modalidades, é preciso salientar que, em tal estatuto, as modalidades – em especial a concorrência, o pregão e o diálogo competitivo, assumem uma feição dinâmica, porquanto, partem de um rito procedimental básico, que poderá estar sujeito a alterações.

A rigor, o legislador concedeu ao gestor uma “caixa de ferramentas”, devendo este escolher qual a ferramenta adequada para a montagem do procedimento. Vejamos o que diz o art. 18, inciso VIII, da NLLCA a esse respeito:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

[...]

VIII – a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais

vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

Há no art. 18, inciso VIII, e em outros dispositivos a concessão de uma *discricionariedade técnica* à Administração. Cabe ao gestor eleger as peças do procedimento, justificando a sua escolha com base em critérios técnicos, mercadológicos e de gestão. Tal decisão será controlada nos termos do art. 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), que reclama a motivação das decisões administrativas – assim como o princípio da motivação inserto no art. 5º da NLLCA, considerando a demonstração adequação da medida, a necessidade e as razões de sua escolha diante de outras medidas possíveis.

É preciso, considerar, entretanto, que a Lei nº 14.133/2021, embora conceda a discricionariedade técnica a que fizemos referência, prevê em seu texto uma via comum, cuja adoção não requer maiores motivações. A necessidade de motivação cresce a partir do momento que se decide por uma peça de aplicação excepcional. Citamos, a título de exemplo, os critérios de julgamento. A NLLCA não traz qualquer condição para o uso do critério de julgamento de menor preço ou maior desconto (art. 34), razão pela qual a sua adoção não requer maiores motivações. Já os demais critérios, têm sua aplicação condicionada a determinados requisitos legais, motivo pelo qual o uso da técnica e preço (art. 36-38), da melhor técnica ou conteúdo artístico (art. 35 e 37-38), do maior lance e do maior retorno econômico (art. 39) exigem justificativas mais robustas.

No caso das modalidades de licitação, não é diferente. É possível dizer que, em dada medida, a Lei nº 14.133/2021 *elegeu o pregão como a modalidade-regra para a aquisição de bens e serviços*. Como visto no tópico anterior, a NLLCA define o pregão como modalidade de licitação *obrigatória* para aquisição de bens e serviços comuns (art. 6º,

inciso XLI). Ou seja, o pregão deve ser obrigatoriamente utilizado sempre que o “bem” ou o “serviço” for enquadrado como “comum”.

Note-se, então, que a adoção de outra modalidade de licitação depende do enquadramento do bem ou serviço a ser contratado fora das raias da natureza comum do objeto. Teria, então, que tal *objeto ser considerado especial, hipótese em que se aplicaria a concorrência*, o que, como diz o inciso XIV do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, requer “justificativa prévia do contratante”, o que o texto legal não exige em relação à natureza comum do objeto. Para além disso, seria possível o uso do *diálogo competitivo*, devendo haver a demonstração de que se está diante de uma das situações previstas em um dos incisos do art. 32 da NLLCA;¹⁵⁸ ou também seria possível o uso do concurso, desde que o objeto a ser contratado se refira a trabalho técnico científico ou artístico (art. 6º, inciso XXXIX).

No caso de objetos relacionados a bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação – TIC, vislumbra-se a possibilidade de aplicação de todas as modalidades referidas no parágrafo anterior, com destaque para o caso do pregão e da concorrência.

Em relação ao diálogo competitivo, também bastante útil para situações específicas de TIC, remetemos o leitor para os comentários de Rafael Sérgio de Oliveira ao art. 32 na obra *Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*.¹⁵⁹

5.7.1.2 A modalidade pregão para contratação de bens e serviços “comuns” de TIC

Desde a sua criação com a Medida Provisória nº 2.026, de 04 de maio de 2000, o pregão é uma modalidade de licitação cujo objeto não sofre limitação de valor. O que determina a sua utilização é o bem ou serviço a ser licitado, independentemente do valor inicialmente estimado pela Administração. Nos termos do art. 1º da

Lei nº 10.520/2002, o pregão era cabível nos casos em que a licitação tenha por objeto a contratação de bens e serviços considerados comuns. O mesmo ocorre com a Lei nº 14.133/2021, que no conceito da modalidade em questão determina que o pregão é obrigatório para licitações voltadas à contratação de bens e serviços comuns (art. 6º, inciso XLI).

Antes de abordar a problemática envolvendo a definição de *bem ou serviço comum*, destaca-se que o pregão pode ter por objeto: a contratação, que é aquela que ocorre na forma clássica, em que à adjudicação sucede a assinatura do contrato; e o registro de preço,¹⁶⁰ no qual, após a adjudicação, assina-se uma ata para contratações futuras (art. 6º, XLV, da Lei nº 14.133/2021).

O grande problema relativo ao cabimento do pregão é o que se pode considerar *bem e serviço comuns*. O inciso XIII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021 define esses bens e serviços como “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.

Na origem da regulamentação da modalidade em análise, ainda sob égide da Lei nº 10.520/2002, consideravam-se comuns os bens e serviços constantes da lista do Anexo II do Decreto nº 3.555/2000.¹⁶¹ Essa lista foi excluída do ordenamento pátrio com o Decreto nº 7.174/2010, de modo que se passou a aplicar o pregão àqueles bens que se encaixam na definição do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520/2002. O Decreto nº 10.024/2019, que regulamentou o pregão eletrônico da Lei nº 10.520/2002 em nível federal, foi mais adiante disse que não se poderia ter um enquadramento do bem ou serviço comum a priori. De acordo com o §1º do art. 3º do então regulamento federal, “a classificação de bens e serviços como comuns depende de exame predominantemente fático e de natureza técnica”.

É notório que o pregão foi ganhando cada vez mais espaço quando da vigência da Lei nº 10.520/2002 combinada com a Lei nº 8.666/1993, chegando a corresponder a mais de 90% (noventa por cento) das licitações federais.¹⁶² Assim, atualmente são licitados por pregão diversos bens e serviços que outrora eram considerados fora do campo de incidência dessa modalidade.

Um bom exemplo desse movimento expansivo do pregão são os bens e serviços de TIC, uma vez que, no passado, a aplicação do pregão a esse tipo de objeto foi bastante questionada. Já há algum tempo, entretanto, tornou-se pacífico o entendimento pela possibilidade de aplicação do pregão para a contratação de soluções de TIC,¹⁶³ o que foi cristalizado inclusive em norma infralegal editada já à luz da Lei nº 14.133/2021 (Instrução Normativa SGD nº 94/2022¹⁶⁴).

O fato é que cada vez mais tem caído por terra o argumento de que o pregão é inaplicável para a contratação de objetos considerados intelectuais ou complexos. No Acórdão nº 1046/2014 – Plenário do TCU, admitiu-se o uso da modalidade em estudo para a contratação de serviço de *auditoria independente* com o argumento de que não é a complexidade do serviço *per si* que o faz comum ou não para fins de aplicação do pregão. Outro julgado relevante do TCU neste ponto é o Acórdão nº 1667/2017 – Plenário, que analisou licitação cujo objeto foi a contratação de serviço técnico especializado de tecnologia da informação voltado para o Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros – Scorpions. Este último julgado está na jurisprudência selecionada do TCU com o seguinte enunciado:

A identificação do bem ou serviço como sendo comum, para fim de adoção do pregão, independe da sua complexidade. É a definição objetiva dos seus padrões de desempenho e qualidade, mediante especificações usuais no mercado, que o caracteriza como comum.¹⁶⁵

O critério empregado pela Lei nº 14.133/2021¹⁶⁶ (art. 6º, XIII) baseia-se no domínio do mercado sobre o bem ou serviço a ser contratado. Ou seja, ainda que o objeto seja complexo, ele poderá ser licitado por pregão se o mercado possui definições precisas usualmente praticadas na comercialização desse objeto. Sendo assim, a Administração é capaz de definir no instrumento convocatório os padrões corriqueiramente utilizados pelo mercado para contratar o bem ou serviço dentro dos parâmetros de desempenho e qualidade desejados, motivo pelo qual é plenamente possível o emprego da licitação na modalidade pregão.

Os bens e serviços que não podem ser licitados por pregão são aqueles considerados especiais (art. 6º, XIV, da Lei nº 14.133/2021), que são definidos pela Lei nº 14.133/2021 como “aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso XIII do *caput* deste artigo, exigida justificativa prévia do contratante”. Ou seja, a Lei nº 14.133/2021 traz o conceito de bem ou serviço comum e, por antítese, trouxe a definição de bem ou serviço especial para afastar a licitação de certos bens e serviços do pregão. Nota-se que a Lei nº 14.133/2021 apresenta uma espécie de conceito por exclusão, pois condiciona o enquadramento do bem ou serviço como especial à exclusão do campo de incidência do inciso XIII do art. 6º da NLLCACACA, que traz o conceito de bem ou serviço comum. Entretanto, é preciso verificar que o legislador apresentou as causas para tal exclusão, que são a “alta heterogeneidade ou complexidade” (art. 6º, inciso XIV).

A Lei nº 14.133/2021 trata o bem ou serviço comum baseada em critérios eminentemente mercadológicos (possibilidade de definir, de acordo com as práticas usuais de mercado, os critérios de desenvolvimento e qualidade de forma objetiva no edital). Desse modo, em obediência ao parâmetro legal, não seriam a heterogeneidade ou a complexidade técnica que, por si só,

determinariam se o objeto é *especial* para fins de enquadramento da modalidade pregão. Esse é o sentido que extraímos dos incisos XIII e XIV do art. 6º da NLLCA.

Sendo assim, repita-se, se os padrões de qualidade e desempenho do bem ou serviço são passíveis de definição objetiva no instrumento convocatório em razão do domínio pelo mercado, pouco importa a natureza do bem propriamente dito, sendo possível a sua licitação por meio do pregão. Por isso, o intérprete da *novel* Lei deve estar atento para o fato de que, nos termos da conceituação da Lei nº 14.133/2021, a alta heterogeneidade ou complexidade técnica do bem ou serviço podem ser a causa para a ausência de parâmetros objetivos para a definição do objeto do certame no edital, o que afastaria a aplicação do pregão. Nota-se que, de acordo com o texto da Lei, esse elemento técnico é apenas o fundamento. O que determina o afastamento do pregão é o não enquadramento do bem ou serviço no inciso XIII do art. 6º da NLLCA.

Nessa toada, *tem-se admitido o uso do pregão para diversos objetos*, inclusive para muitos cuja aplicação do instituto era considerada incabível. Seguem alguns exemplos:

- Serviço de call center: Acórdão nº 767/2010-Plenário do TCU;
- Serviço de tecnologia da informação: Acórdão nº 2471/2008 – Plenário do TCU;
- Serviço de auditoria interdependente: Acórdão nº 1046/2014 – Plenário do TCU;
- Serviço de fornecimento de infraestrutura para realização de shows: Acórdão nº 6504/2017 – 2ª Câmara do TCU;
- Serviços de assessoria de imprensa, *clipping*, *media training* e monitoramento de redes sociais: Acórdão nº 1074/2017 – Plenário do TCU;

- Concessão remunerada de uso de bem público: Acórdão nº 478/2016 – Plenário do TCU;¹⁶⁷
- Serviço de gestão de folha de pagamento de órgão público: Acórdão nº 1940/2015 – Plenário do TCU;
- Serviços de engenharia considerados comuns: Súmula nº 257 do TCU;
- Serviço de manutenção predial: Acórdão nº 727/2009 – Plenário do TCU;
- Serviço de engenharia de manutenção do sistema de distribuição de energia elétrica: Acórdão nº 2314/2010 – Plenário do TCU;
- Serviço de supervisão e consultoria em engenharia rodoviária: Acórdão nº 2932/2011 – Plenário do TCU.¹⁶⁸

Em relação às soluções de TIC, é inegável que muitas podem se encaixar na categoria de bens e serviços comuns, mas há espaço para uma expansão do enquadramento de tais objetos na qualidade de bens e serviços especiais. É sabido que o mercado de TIC conta com uma heterogeneidade considerada na qualidade e desempenho de suas soluções. Além disso, deve-se considerar que na NLLCA, ao contrário do que ocorria no regime anterior, a concorrência tem muito mais vantagens do que o pregão, sobretudo pela possibilidade de adoção de outros critérios de julgamento, a exemplo da técnica e preço (art. 36, §1º, inciso III).

No regime tradicional, o da Lei nº 8.666/1993 combinado com a Lei nº 10.520/2002, houve, de certo modo, um incentivo ao uso do pregão, dado o fato de que naquele regime o pregão trazia muito mais vantagens do que as modalidades da Lei nº 8.666/1993, o que não mais ocorre na Lei nº 14.133/2021.

5.7.1.3 A modalidade concorrência para contratação de bens e serviços “especiais” de TIC

A concorrência é destinada na Lei nº 14.133/2021 a licitações voltadas a contratações de bens e serviços considerados especiais e de obras e serviços de engenharia, comuns ou especiais. No caso de soluções de TIC, interessam os bens e serviços especiais.

Essa categoria de objetos da contratação está definida no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 14.133/2021, que diz:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XIV – *bens e serviços especiais*: aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso XIII do caput deste artigo, *exigida justificativa prévia do contratante; (grifo nosso)*

Primeiramente, repare que o conceito aqui estudado se por exclusão. Ou seja, é especial aquilo que não pode ser considerado comum, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021. Já se viu no item anterior desta obra que o objeto comum se caracteriza pela padronização comercial dos elementos de desempenho e qualidade, incluindo aí a padronização linguística (definição objetiva no edital com base em especificações usuais de mercado).

O bem ou serviço especial, de outra banda, é aquele cuja aceitação pela Administração em uma dada licitação não é padronizada. Ou seja, no caso de bem ou serviço especial, não se adota um padrão comercial. A especificação do bem ou serviço, então, não é “fechada”. Admite-se uma variação do bem ou serviço, conforme especificações diversas de desempenho e qualidade.

Segundo a NLLCA (art. 6º, XIV), tal situação poderia decorrer da alta heterogeneidade ou complexidade do bem ou serviço. Como anteriormente mencionado quanto à visão do TCU em relação à complexidade técnica. Entende-se, no entanto, que diferente é a

situação do bem ou serviço heterogêneo tecnicamente. A heterogeneidade *parece* ser incompatível com a ideia de padronização, motivo pelo qual não se poderia concluir que um bem ou serviço heterogêneo tenha um padrão de mercado apto a uma definição objetiva dos seus requisitos de desenvolvimento e qualidade. Portanto, em princípio, dificilmente um bem ou serviço heterogêneo seria considerado comum para fins de enquadramento da modalidade pregão.¹⁶⁹

A rigor, como o inciso XIV do art. 6º, que define o bem ou serviço especial, faz referência ao conceito de bem ou serviço comum, contido no inciso XIII do mesmo artigo, é preciso considerar a natureza especial do bem ou serviço também com base nos mesmos critérios mercadológicos tomados em conta para o enquadramento da natureza comum do bem. Ou seja, existindo a heterogeneidade comercial do bem ou serviço, ele deve ser considerado especial e, por isso, ser licitado por concorrência.

Nas situações de contratação de solução de TIC existe um enorme potencial do uso da concorrência, sobretudo em razão da possibilidade de emprego de outros critérios de julgamento, notadamente da técnica e preço.

A despeito disso, verifica-se que os órgãos regulamentares continuam ainda muito focados no pregão. Em nível federal, por exemplo, a Instrução Normativa SGD nº 94/2022, que versa sobre a contratação de soluções de TIC no Poder Executivo federal, nada fala em relação ao uso da concorrência. O parágrafo único do art. 25 desse regulamento se refere ao pregão e ao diálogo competitivo, mas não faz referência à concorrência.¹⁷⁰ Percebe-se em postura como

essas um forte risco de fracasso do regime implementado pela Lei nº 14.133/2021, que veio para tornar a contratação pública nacional mais versátil e mais adaptada à variação de soluções que existe no mercado, sendo que a concorrência é das modalidades a mais adequada para enfrentar um mercado multiforme e dinâmico, notadamente nos casos de solução de TIC.

5.7.2 Os critérios de julgamento das propostas

Os critérios de julgamento da proposta devem ser condizentes com a estrutura do objeto licitado e consistirem no meio mais adequado para se alcançar, de forma mais eficiente possível, a vantagem da contratação almejada pela Administração. Afinal, de acordo com o inciso I do art. 11 da NLLCA, um dos objetivos da licitação é “assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública”.

Nesse sentido, um dos aspectos a serem contemplados na fase de planejamento da licitação é justamente avaliar “a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto” (art. 18, VIII).

Os *critérios de julgamento* previstos na Lei nº 14.133/2021 encontram-se arrolados no art. 33:

CRITÉRIO DE JULGAMENTO	PARÂMETRO	MODALIDADE APLICÁVEL
------------------------	-----------	----------------------

CRITÉRIO DE JULGAMENTO	PARÂMETRO	MODALIDADE APLICÁVEL
MENOR PREÇO (art. 34)	considerará o menor dispêndio para a Administração, apurado a partir do valor nominal (R\$) da proposta	Pregão Concorrência Diálogo Competitivo ¹⁷¹
MAIOR DESCONTO (art. 34)	considerará o menor dispêndio para a Administração, apurado a partir do percentual de desconto (%) sobre o valor estimado do objeto em disputa	
MELHOR TÉCNICA OU CONTEÚDO DO ARTÍSTICO (art. 35)	o fator preponderante para a escolha do vencedor não é o preço, mas critérios de qualidade e especificidade indispensáveis para o alcance do interesse público	Concurso Concorrência
TÉCNICA E PREÇO (arts. 36 a 38)	os fatores “técnica” e “preço” serão considerados de acordo com proporções previamente consignadas em edital. Não há, pois, prevalência de qualquer dos fatores, mas um procedimento objetivo de aferição da média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço	Concorrência Diálogo Competitivo
MAIOR LANCE	será considerada a melhor proposta aquela que corresponder ao maior valor nominal ofertado	Leilão
MAIOR RETORNO ECONÔMICO (art. 39)	utilizado exclusivamente para a celebração de <i>contrato de eficiência</i> , ¹⁷² considerará a maior economia para a Administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato	Concorrência Diálogo Competitivo

De se notar que o rol dos critérios de julgamento e o regramento atinente à possibilidade de combinação ou adoção isolada dos modos de disputa adotado na Lei nº 14.133/2021 foram, quase que integralmente, inspirados na experiência do *Regime Diferenciado de Contratação* (RDC), mais precisamente nos artigos 18 a 23 da Lei nº 12.462/2011. Tal constatação, notadamente no tocante ao critério de “maior retorno econômico”, é salutar no sentido de incorporação das práticas e dos entendimentos sedimentados para a modelagem das licitações objetivando a celebração dos chamados “contratos de eficiência”.

Cumprе salientar que o §2º do art. 37 preconiza ser necessária adoção dos critérios de julgamento da proposta de “melhor técnica” ou “técnica e preço” para as licitações, com valor estimado superior a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais),¹⁷³ e que se destinem à contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual previstos nas alíneas *a*, *d* e *h* do inciso XVIII do *caput* do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, quais sejam:

- estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos;
- fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços;
- controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição do inciso XVIII do art. 6º da NLLCA.

Diante da contratação de tais serviços, deverá ser estabelecido no edital o critério de “melhor técnica” (art. 35) ou de “técnica e preço” (art. 36). A regra do §2º do art. 37 torna-se preferencial em face dos pressupostos de enquadramento dos citados critérios de julgamento definidos no parágrafo único do art. 35 e no §1º do art. 36:

Art. 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores.

Parágrafo único. O critério de julgamento de que trata o *caput* deste artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística.

Art. 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta.

§1º O critério de julgamento de que trata o *caput* deste artigo será escolhido quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração nas licitações para contratação de:

I – serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado;

II – serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação;

III – bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação;

IV – obras e serviços especiais de engenharia;

V – objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação.

Como regra geral, de acordo com o §2º do art. 36 da NLLCA, adotado o critério “técnica e preço”, a partir dos elementos levantados na fase preparatória, deverá ser observada a ponderação proporcional entre as propostas técnicas e as propostas de preços, havendo a limitação máxima de 70% de valoração para a proposta técnica.

Contudo, quando utilizado o critério “técnica e preço” para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual previstos nas alíneas “a”, “d” e “h” do inciso XVIII do *caput* do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, em

conformidade com o inciso II do §2º do art. 37, a proporção de ponderação entre a proposta técnica e a proposta de preço será, necessariamente, de “70% (setenta por cento) de valoração da proposta técnica”. Trata-se, pois, de uma regra especial, pela qual a ponderação entre as propostas “técnica” e “de preço” já foi fixada *ex lege*.

5.7.3 Os modos de disputa

Nos termos do art. 56 da NLLCA, serão admitidos na fase de seleção do fornecedor, os seguintes “modos de disputa” que, a depender do critério de julgamento da proposta, serão adotados *de forma isolada ou conjunta*:

MODO DE DISPUTA	DEFINIÇÃO
ABERTO	“hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes”
FECHADO	“hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação”

Ao prever, na parte final do *caput* do art. 56, a possibilidade de combinação dos dois modos de disputa, a Lei nº 14.133/2021 admite, por conseguinte, a estruturação de mais dois modos de disputa: “aberto e fechado” e “fechado e aberto”.

Note-se ser intrínseco ao modo de disputa “aberto” (e, também, para a etapa “aberta” dos modos “aberto e fechado” e “fechado e aberto”) a realização de uma fase de lances. Contudo, não consta da NLLCA maior detalhamento acerca do fluxo operacional da fase de

lances, seja na adoção isolada no modo aberto, seja na combinação entre os modos aberto e fechado. O que há, em verdade, é a definição de “lances intermediários” no §3º do art. 56¹⁷⁴ e a previsão, no §4º do art. 56¹⁷⁵ e no art. 57,¹⁷⁶ quanto à possibilidade de: a) estabelecimento, no edital, de intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances; b) reabertura da disputa aberta quando “a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento)”.

Por seu turno, o modo de disputa “fechado”, assim como consagrado nas modalidades da Lei nº 8.666/1993, segue a clássica modelagem de preços selados, com uma única oferta por licitante que se mantém sigilosa até o momento procedimental para sua revelação, não havendo, portanto, oportunidade de redução dinâmica ao longo do procedimento.

Será admitida a utilização, de forma isolada, do modo “aberto” para os critérios de julgamento: “menor preço”, “maior desconto”, “maior oferta” e “maior retorno econômico” (o lance corresponderá ao percentual de economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária). A própria NLLCA, de forma expressa no §2º do art. 56, estabelece que “a utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço”. Por sua vez, será admitida a utilização, *de forma isolada*, do modo “fechado” quando adotado o critério de julgamento “melhor técnica e preço”, “melhor técnica ou conteúdo artístico” e “maior retorno econômico”.

Já o §1º do art. 56 da Lei nº 14.133/2021 preconiza que “a *utilização isolada* do modo de disputa “fechado” será vedada quando adotados os critérios de julgamento de “menor preço” ou “maior desconto” (grifou-se).

Dessa forma, consoante regramento da NLLCA, é possível assim resumir a correlação entre os modos de disputa e os critérios de

julgamento das propostas:

MODO DE DISPUTA	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
<i>Aberto</i> (adoção isolada)	Menor preço Maior desconto Maior oferta Maior retorno econômico
<i>Fechado</i> (adoção isolada)	Melhor técnica e preço Melhor técnica ou conteúdo artístico Maior retorno econômico
<i>Aberto-Fechado</i> (adoção combinada)	Menor preço Maior desconto Maior retorno econômico
<i>Fechado-Aberto</i> (adoção combinada)	Menor preço Maior desconto Maior retorno econômico

Sob a égide da Lei nº 10.520/2002, o Poder Executivo Federal, por meio do Decreto nº 10.024/2019, ao regulamentar o pregão eletrônico, estabeleceu, em seus artigos 32 e 33, o delineamento operacional dos modos “aberto” e “aberto e fechado”, tratando-se de importante orientação para a análise das potencialidades da estruturação dos modos de disputa previstos na Lei nº 14.133/2021, em especial diante de licitações do tipo “menor preço” ou “maior desconto”. Já, com o advento da NLLCA, a matéria passou a ser regulamentada no âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional vinculada ao Poder Executivo Federal pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, que, em comparação com o citado Decreto nº 10.024/2019, repetiu a mesma conformação dos modos

“aberto” (art. 23¹⁷⁷) e “aberto e fechado”(art. 24¹⁷⁸), trazendo a regulamentação do modo “fechado e aberto” (art. 25¹⁷⁹) de forma similar àquela existente para o pregão presencial no então Decreto nº 3.555/2000.

A possibilidade de “escolha” do modo de disputa não se trata de uma novidade inaugurada pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, haja vista a previsão contida no art. 16 da Lei nº 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações Públicas) e no art. 52 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais).

Na mesma linha do que se observa nas Leis nº 12.462/2011 e nº 13.303/2016, também no art. 56 da NLLCA não sobressai nenhum comando, premissa ou preferência entre os modos de disputa ou mesmo instituição de critérios atrelados ao objeto da contratação quando da “escolha” pelo agente público competente.

Com efeito, entende-se que tal “escolha” não está normativamente vinculada, de modo que, em termos jurídicos, o agente público não se encontra ancorado ou aferrado a nenhuma orientação apriorística.

Em suma, é válido concluir que, observadas as expressas vedações previstas nos §§1º e 2º do dispositivo, há uma presunção jurídica de eficiência e adequação de qualquer um dos modos de disputa instituídos pelo art. 56 da Lei nº 14.133/2021.

A NLLCA não fixou, de forma pontual, o momento procedimental e nem qual agente público seria competente para estabelecer o modo de disputa a ser adotado no procedimento licitatório, apesar de preconizar, no inciso VIII do art. 18, que a definição do modo de disputa já deve ser contemplada no bojo da fase preparatória da licitação.

De plano, não obstante ser discricionária, a opção pelo modo de disputa deverá ser delineada de forma clara nos instrumentos de planejamento da licitação (estudo preliminar e/ou termo de referência).

Após o apontamento do modo de disputa mais adequado conforme critérios de cada órgão ou entidade promotora da licitação, em atenção ao art. 18, VIII, da NLLCA, se faz necessária a expressa definição da “opção” no ato convocatório. A formalização da decisão sobre qual a forma de disputa a ser adotada se materializada com a aprovação, por parte da autoridade competente, da minuta de edital.

Conclui-se que, por restar materializada na etapa de planejamento da contratação (antes de publicação do aviso de licitação), a competência e/ou a responsabilidade pela “escolha” do modo de disputa não recai sobre o agente de contratação responsável pela condução da fase externa do certame (art. 8º da NLLCA), de forma que sua atribuição quanto ao tema restringe-se aos aspectos operacionais, a partir da seleção da “opção” de disputa (conforme preconizado no ato convocatório) no ato do cadastro da licitação no sistema.

A investigação acerca da adequação da escolha do modo de disputa demanda uma compreensão para além de uma perspectiva jurídico-normativa, considerando que a aferição da adequação do desenho do mecanismo de disputa tem como parâmetro a busca pela eficiência na realização da licitação.

Em termos diretos, o melhor modo de disputa possível não é aquele que simplesmente tenha o condão de esgotar ao máximo as possibilidades de lances (como uma leitura fácil e opaca poderia sugerir ser o caso do modo “aberto”), mas sim aquela forma de disputa que venha a materializar uma concepção adequada da eficiência do processo licitatório sem descuidar das necessidades primárias e secundárias da Administração. Com efeito, o melhor modo de disputa seria aquele que correspondesse a um “mecanismo de concorrência” que conjugasse, em equilíbrio, a “maximação das ofertas” e a “razoável duração do processo licitatório”.^{[180](#)}

Afinal, não se mostraria eficiente um modelo de disputa que, a despeito de esgotar a possibilidade lances, fosse, em potencial, de execução morosa e complexa para a Administração, demandando um dos recursos mais caros para a atividade administrativa e para a sociedade: o tempo! Logo, ainda que haja um mecanismo ideal para a obtenção do “menor preço”, para aferir a sua eficiência, devem ser, necessariamente, contemplados os custos transacionais para a Administração.

5.7.4 Rito procedimental das modalidades licitatórias

Ainda que a Lei nº 14.133/2021 tenha conferido considerável margem para regulamentação atinente ao fluxo operacional das licitações, em especial no que tange à forma eletrônica – que passa a ser uma regra de preferencialidade (art. 17, §2º) –, a estrutura procedimental elementar das modalidades licitatórias foi fixada no art. 17 (concorrência e pregão); no art. 30 (concurso); art. 31 (leilão) e art. 32 (diálogo competitivo).

Logo, considerando que a edição de atos normativos secundários – decorrentes da função regulamentar (art. 84, IV, CF) – para a fiel execução da lei não poderá acarretar inovação na ordem jurídica, será inviável que os regulamentos venham a subverter o “esqueleto” estrutural dos procedimentos das modalidades licitatórias então fixados na NLLCA, de modo que o espaço de conformação regulamentar deverá ficar adstrito ao fluxo operacional propriamente dito.^{[181](#)}

A rigor, *para todas as modalidades é preferível a forma eletrônica*, devendo, por se tratar de exceção à regra, ser devidamente justificada na fase preparatória do procedimento a adoção da forma presencial. A se observar a experiência de justificativas então adotadas a partir dos comandos externados no já revogado art. 1º,

§2º, do Decreto Federal nº 5.504/2005 e no art. 1º, §4º, do Decreto Federal nº 10.024/2019, além de eventual desvantagem contextual para a Administração no uso da forma eletrônica, caso seja alegado motivo de ordem operacional, é crucial que a justificativa seja lastreada em elementos empíricos que comprovem a eventual inviabilidade técnica.

De todo modo, adotada a forma presencial, como dispõe o §2º do art. 17 da NLLCA, deverá a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

5.8 Aquisições de solução TIC

5.8.1 Aquisição por técnica e preço

Rafael Sérgio Lima de Oliveira

O critério de técnica e preço e o Best Value for Money (BVfM) nas contratações de TIC – a expressão inglesa Best Value for Money (BVfM) pode ser traduzida para o português como “melhor relação entre qualidade e preço”. Isto é, significa a maximização da qualidade do objeto desejado em troca do numerário que irá se despendar. Veja que aqui não importa apenas o preço no critério de escolha da solução, mas também a qualidade da entrega que será feita. A seleção do futuro contratado é resultado de uma ponderação entre custo e benefício (público). A proposta dos concorrentes, nesse modelo, é julgada por aspectos multidimensionais, sendo o preço apenas uma dessas dimensões.

O objetivo de estabelecer parâmetros do BVfM é melhorar a flexibilidade, a qualidade e a eficiência das compras públicas através de um adequado procedimento licitatório, partindo de uma abordagem mais ampla e considerando aspectos de transparência e equidade.¹⁸² Essa análise de eficiência, qualidade e flexibilidade

requer uma avaliação dos custos e benefícios relevantes juntamente com uma avaliação dos riscos, atributos que vão além do preço e custo total da aquisição.

Em matéria de contratação pública, esse é um ponto que tem ganhado destaque.¹⁸³ É sabido que a busca pelo menor preço acarreta muitas vezes a compra de um objeto de baixa qualidade, que tem o potencial de gerar mais prejuízos para a Administração com outros custos ou com a baixa satisfação das necessidades públicas.

Por isso, o BVfM é a consagração de um critério de julgamento da licitação pública que considere o preço e as utilidades que as variações da solução desejada apresentem no mercado. É um parâmetro de julgamento das propostas adequado para os bens, serviços e obras que existem de forma heterogênea – aqueles considerados *serviços especiais*, nos termos do inciso XIV do art. 6º da Lei nº 14.133/2021.

Ou seja, é um bom critério para os casos de bens que se diferenciam no mercado em razão de eventuais valores agregados. Cabe dizer, que no caso das contratações públicas, esse valor agregado que diferencia o objeto daqueles considerados comuns deve ser útil ao interesse público, o que significa que a relação entre o custo e o benefício deve indicar que este último prestigia o interesse público, e não a satisfação do agente público.

Outro aspecto que deve ser verificado é a admissão de critérios relacionados a políticas públicas indiretamente ligadas à contratação governamental. Trata-se da conhecida função horizontal da compra estatal, que também é considerada entre os critérios ponderados quando da busca pela melhor relação qualidade e preço.¹⁸⁴

No âmbito internacional, várias são as organizações que estimulam os países a selecionarem as propostas pelo BVfM. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em um de seus instrumentos legais sobre licitação, aponta em diversos quesitos que a Administração Pública deve buscar o

Value for Money (melhor relação qualidade e preço) nas contratações públicas.¹⁸⁵

O Acordo de Compras Públicas da OMC, em seus arts. X, nº 9, e XV, nº 5, admite expressamente que se considere a qualidade como critério de julgamento das licitações, inclusive com expressa menção a fatores ambientais.

No mesmo sentido é o previsto na *Model Law on Public Procurement* da Uncitral, a comissão das Nações Unidas (ONU) voltada à promoção do comércio internacional. Segundo Nicola Dimitri, o primeiro dos objetivos da lei modelo da Uncitral aponta para o *BVfM*.¹⁸⁶ Tal objetivo é o de maximizar a economia e a eficiência em contratações públicas,¹⁸⁷ o que, de fato, é o sentido do *BVfM*.

Ainda na esteira das lições de Nicola Dimitri,¹⁸⁸ verifica-se que o *BVfM* tem sido priorizado pelo ordenamento jurídico de diversos países.¹⁸⁹ Como alerta Pedro Fernández Sánchez, é crescente a preferência por um critério de julgamento multidimensional, considerando também fatores qualitativos, tudo pela convicção expressada no ditado popular de que “o barato sai caro”.¹⁹⁰

O caso europeu é um bom exemplo. Antes mesmo da edição da Diretiva Europeia nº 2014/24/UE, que versa sobre contratação pública, a Comissão Europeia, órgão de execução da União Europeia, já anunciou, em 2011, que a desejada reforma que resultaria naquela Diretiva tinha como um de seus objetivos melhorar a eficiência pelo *Value for Money*.¹⁹¹ Nesse sentido, o art. 67º, nº 2, da Diretiva nº 2014/24 expressamente admite que os Estados-Membros da União Europeia proíbam em suas leis a seleção das propostas baseadas exclusivamente no critério do preço. Note-se que a União deixa a decisão para o Estado-Membro, mas já demonstra com isso a sua preferência pelo critério de julgamento multidimensional.

Ainda sobre o Direito Europeu, um ponto relevante à luz da Nova Lei de Licitações brasileira, é que a Diretiva nº 2014/24/UE determina que o diálogo competitivo, modalidade importada no art. 32 da Lei nº 14.133/2021,¹⁹² deve ser julgado “exclusivamente com base no critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta a melhor relação qualidade/preço” (art. 30, nº 1, da Diretiva nº 2014/24/UE). Ou seja, no caso do diálogo competitivo, o Direito Europeu impõe o uso do *BVfM*, afastando o julgamento da proposta com base exclusivamente no preço.¹⁹³

No Brasil, não há na legislação vigente um critério que se baseie propriamente na relação qualidade e preço. Em solo pátrio, o que mais se aproxima do *BVfM* é o critério de técnica e preço, tradicionalmente previsto no art. 45, §1º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993 e agora presente no art. 33 c/c o art. 36 da NLLCA.

A técnica e preço é, de fato, um critério multidimensional, mas ela não pode ser considerada uma medição da melhor relação qualidade e preço, porque os critérios técnicos levados em consideração pendem mais para questões curriculares dos concorrentes do que para os benefícios entregues na execução do contrato.¹⁹⁴

É fato que a qualificação e a experiência do contratado potencializam a qualidade da entrega, mas não é garantia. Além disso, devemos reconhecer que o texto do art. 37 da Nova Lei de Licitações também se refere a elementos estranhos a questões curriculares, como é o caso da metodologia e dos produtos que serão entregues (inciso II). Ainda assim, esses fatores têm capacidade limitada para garantir a qualidade do objeto contratado.

A rigor, pode-se dizer que a Lei nº 14.133/2021 avança no sentido do *BVfM*, sobretudo porque amplia o uso da técnica e preço quando comparada com a Lei nº 8.666/1993. Segundo o art. 46 desse último diploma legal, a técnica e preço pode ser usada apenas para a seleção

de propostas relativas a serviços de natureza predominantemente intelectual.

Já a Lei nº 14.133/2021 traz a possibilidade do uso do critério em comento para os serviços de natureza predominantemente intelectual e para os seguintes casos: a) serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito; b) bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação; c) obras e serviços especiais de engenharia; d) objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução (art. 36, §1º). Com certeza, trata-se de um avanço, inclusive porque passa a admitir o julgamento pela ponderação dos aspectos de técnica e preço nas contratações de bens. Porém, vejamos que o uso desse critério ainda está sujeito a condicionantes legais, o que indica que a Lei não estimula o seu uso.¹⁹⁵

Esses contornos da legislação nacional apontam para o fato de o sistema de licitação brasileiro ainda ter um verdadeiro fetiche pelo menor preço, o que só pode ser mudado com uma nova compreensão dos métodos de seleção da proposta mais vantajosa (art. 11, I, da NLLCA). Entretanto, como dito, há um avanço na Nova Lei de Licitação, especialmente na área de TIC, já que a legislação admite o uso da técnica e preço sempre que o bem ou serviço da área de TIC seja especial, nos termos do art. 6º, inciso XIV.

5.8.1.1 O critério de técnica e preço e o seu processamento

O critério de técnica e preço se pauta por uma avaliação multidimensional da proposta por considerar os aspectos pecuniário e qualitativo da oferta do licitante. Nos termos do *caput* do art. 36 em comento, ao adotar esse critério de julgamento das propostas, a Administração prevê no edital uma pontuação objetiva para fatores de ordem técnica e de preço. Em nível federal, o procedimento da

licitação julgada por técnica e preço deve observar a Instrução Normativa SEGES nº 02/2023. Na área de TIC, acresce ainda as regras da Instrução Normativa SGD nº 94/2022.

A Lei nº 14.133/2021 não prevê uma distribuição estática do peso de cada um desses critérios a serem ponderados. O §2º do seu art. 36 se limita a estabelecer que o edital pode conferir à proposta técnica um peso de até 70% (setenta por cento), o que significa que o preço sempre corresponderá a, no mínimo, 30% (trinta por cento).

No momento da licitação, deverão ser avaliados primeiro os aspectos técnicos, para, posteriormente, calcular-se a nota relativa ao preço das propostas de cada um dos concorrentes (art. 36, §2º, da NLLCA). Essa já é uma postura consolidada internacionalmente, cujo foco é a garantia da imparcialidade no julgamento do certame. Entende-se que a apreciação das propostas de preço antes da técnica tem o potencial de influenciar no juízo dos elementos desta última, favorecendo o candidato com a proposta de menor preço.¹⁹⁶

A nota técnica de cada proposta é atribuída por uma banca formada especificamente para esse fim, conforme previsto no inciso II e no §1º, ambos do art. 37 da Nova Lei de Licitações.¹⁹⁷ Vale dizer que a licitação será conduzida por um Agente de Contratação (art. 8º da NLLCA) ou por uma comissão de contratação (§2º do art. 8º da Lei nº 14.133/2021), cabendo à banca a que se refere o inciso II e o §1º do art. 37 da NLLCA apenas a atribuição das notas técnicas das propostas, o que farão, inclusive, sob a supervisão administrativa dos responsáveis pela condução do certame (inciso II do §1º do art. 37 da Lei nº 14.133/2021).

Os fatores passíveis de serem considerados a título de *notas técnicas* estão previstos no art. 37, que diz:

Art. 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por:

I – verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados;

II – atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues;

III – atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida nos documentos comprobatórios de que trata o §3º do art. 88 desta Lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

§1º A banca referida no inciso II do *caput* deste artigo terá no mínimo 3 (três) membros e poderá ser composta de:

I – servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração Pública;

II – profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme o disposto no art. 7º desta Lei.

§2º Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual previstos nas alíneas “a”, “d” e “h” do inciso XVIII do *caput* do art. 6º desta Lei cujo valor estimado da contratação seja superior a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o julgamento será por:

I – melhor técnica; ou

II – técnica e preço, na proporção de 70% (setenta por cento) de valoração da proposta técnica.

Atente-se, no entanto, para o peso que a NLLCA dá para o desempenho pretérito do proponente na execução de contratos que ele eventualmente tenha firmado com a Administração Pública. A Lei nº 14.133/2021 chega a ser enfática em relação ao dever do edital de considerar esse aspecto na pontuação da proposta técnica, já que se refere a esse elemento no §3º do art. 36 e no inciso III do art. 37.

Atribuídas as notas técnicas das propostas pela banca designada para esse fim, passa-se à análise e atribuição de notas às propostas de preços.

Com as notas de caráter técnico e de preço, cabe à autoridade responsável pela condução do certame realizar a ponderação de ambas, valendo-se, para tanto, dos pesos previstos no edital, obedecidos os limites fixados no §2º do art. 36 da Nova Lei de Licitações. No âmbito do Poder Executivo federal a nota técnica é calculada com base na fórmula contida no inciso III do art. 13 da Instrução Normativa SEGES nº 02/2023.

Obtidas as notas finais, deve a Administração elaborar a lista classificatória, sendo o vencedor do certame aquele que alcançar a maior nota resultante da ponderação das dimensões técnicas e de preço.

5.8.2 Ata de Registro de Preços

Tatiana Camarão

Camila Murta

Um dos procedimentos mais utilizados, pois se destina a contratação de bens comuns de uso frequente é o *sistema de registro de preços*.

O Registro de Preços cria a possibilidade de a Administração, ao longo do período de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, adquirir o objeto que necessita conforme planejamento previamente aprovado, sem ter que produzir várias licitações, sendo necessário apenas a instauração de um único procedimento, na modalidade de concorrência ou por pregão,¹⁹⁸ conforme dispõe o art. 82 da Lei nº 14.133/21, que resultará na formalização da ata de registro de preços.

O procedimento para implantação do registro de preços se diferencia dos demais que não se propõe a esta finalidade, porque as propostas comerciais terão valores unitários e ao final, no lugar do

contrato, é formalizada a ata de registro de preços e não obriga a Administração a realizar as contratações que dela poderão advir no todo ou em parte do quantitativo registrado, como se ficasse à disposição da Administração Pública um arquivo de preços, e de acordo com a necessidade, a Administração emitirá o empenho.¹⁹⁹

Quais são as vantagens da implantação do sistema de registro de preços?

Sistema de Registro de Preços

- redução do número de licitações;
 - controle de qualidade;
 - rapidez nas contratações;
 - redução dos estoques de material no almoxarifado;
 - redução da área física necessária para o armazenamento;
 - diminuição do desperdício de material e desnecessidade de indicação de recursos orçamentários.
-

A Lei nº 14.133/21, ao enfrentar a temática das compras que serão levadas a efeito no âmbito da Administração pública, orienta que se dê preferência para as contratações processadas por meio de sistema de registro de preços.^{200 201}

Ocorre que, a Lei de Licitações não exaure o tratamento normativo da matéria. Ao contrário, optou o legislador por remeter expressamente ao decreto a regulamentação do sistema de registro de preços, atentando para a necessidade de se considerarem as peculiaridades regionais.²⁰² Em âmbito federal, foi publicado o *Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023*.

Em se tratando da Administração Pública Federal, a Nova Lei traz um dispositivo em específico que deve ser observado quando se tratar de órgão ou entidade interessada em aderir à Ata de Registro

de Preços conforme descrito no art. 9º, §3º, da IN nº 94: “O órgão ou entidade interessada em aderir à Ata de Registro de Preços deverá registrar no Estudo Técnico Preliminar o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme o disposto no §2º do art. 86 da Lei nº 14.133, de 2021”.

Nesse sentido, a Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, em seu artigo 9º, estabelece a condição para a adesão a Ata de Registro de Preço:

§8º A publicação do Estudo Técnico Preliminar da Contratação em sítio eletrônico de fácil acesso, pelo órgão interessado em aderir a Ata de Registro de Preço, é condição para viabilizar a autorização de adesão exarada pelo órgão gerenciador, observadas as demais disposições legais.

E em se tratando de solução escolhida constante do Catálogo de Soluções de TIC com condições padronizadas, o mesmo normativo, no art. 9º, prevê o seguinte procedimento:

§6º Caso a solução escolhida, resultante do Estudo Técnico Preliminar, contenha item presente nos Catálogos de Soluções de TIC com Condições Padronizadas publicados pelo Órgão Central do SISP no âmbito do processo de gestão estratégica das contratações de soluções baseadas em *software* de uso disseminado previsto no §2º do art. 43 da Lei nº 14.133, de 2022, os documentos de planejamento da contratação deverão utilizar todos os elementos constantes no respectivo Catálogo, tais como: especificações técnicas, níveis de serviços, códigos de catalogação, PMC-TIC, entre outros.

Os itens obrigatórios a constarem no edital para a realização do Sistema de Registro de Preços, de acordo com o artigo 82 da NLLCA, são:

- especificidades do objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida;

- quantidade mínima a ser cotada;
- possibilidade de prever preços diferentes: i) quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes; ii) em razão da forma e do local de acondicionamento; iii) quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote; iv) por outros motivos justificados;
- possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital;
- critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou o de maior desconto sobre a tabela de preços praticada no mercado;
- condições para alteração de preços registrados;
- registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação;
- vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital;
- hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços.

5.8.3 Diálogo competitivo

Camila Murta

O conceito do processo de diálogo e negociação para a Administração contratar seus fornecedores já existe há algum tempo na prática das contratações públicas. Mas, para poder fazer isso, era necessário “fugir” da Lei nº 8.666/93, sendo utilizado em duas hipóteses: i) a *contratação por dispensa* – como para casos envolvendo

segurança nacional ou inovação tecnológica –, o ente público responsável emitia um “request for proposal – RFP” para potenciais fornecedores apresentarem suas soluções. Após essa etapa, caberia ao ente público escolher, a partir dos critérios definidos no RFP, a mais vantajosa; ii) as *encomendas tecnológicas*, regulamentadas pelo art. 27, Decreto nº 9.283/18. Aqui, novamente, configura a dispensa de licitação para a contratação de inovação (art. 24, XXXI, Lei nº 8.666/93), a partir da qual o ente público pode fazer consultas a potenciais interessados, definir a solução a ser encomendada e negociar “a celebração do contrato de encomenda tecnológica, com um ou mais potenciais interessados” (art. 27, §8º).²⁰³

O diálogo competitivo é uma nova modalidade de licitação, introduzida no rol do artigo 28, inciso V, da NLLCA e que está definida no artigo 6º, inciso XLII, nos seguintes termos:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: (...)

XLII – diálogo competitivo: modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos;

Pela leitura do dispositivo legal pode-se concluir que a nova modalidade tem por foco a contratação de serviços ou produtos que não se enquadram como bens e serviços comuns. Servem sim para contratar bens e serviços técnicos e específicos.

De acordo com o artigo 32, inciso I, da Nova Lei de Licitações, o diálogo competitivo deve ser empregado na contratação de inovações tecnológicas ou técnicas e outros motivos, veja-se:

Art. 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a Administração:

I – vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: a) *inovação tecnológica ou técnica*; b) *impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado*; e c) *impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração*;

II – verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: a) a solução técnica mais adequada; b) os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida; c) a estrutura jurídica ou financeira do contrato;

Ou seja, a modalidade do diálogo competitivo deve ser empregada somente em casos de inovação tecnológica, quando existe a impossibilidade do ente público ter suas necessidades satisfeitas por soluções disponíveis no mercado ou quando há especificações técnicas muito próprias, que precisem ser definidas pela Administração Pública.

O diálogo competitivo define-se no processo em que existem conversas da Administração com os possíveis licitantes que apresentam, de forma transparente, projetos que buscam atender aos critérios definidos para a escolha da melhor solução.

O procedimento inicia-se na *fase do diálogo*, com a definição das necessidades e os critérios de pré-seleção dos licitantes por parte do ente público, a partir da publicação do edital, com prazo mínimo de 25 dias para manifestação dos interessados. Em ato subsequente, são organizadas reuniões com os interessados, promovendo um diálogo entre as partes para obter informações e alternativas de soluções que atendam às necessidades do ente público. O diálogo se estende até que seja definida a solução mais adequada à situação, para que então seja iniciada a fase competitiva.

A *fase competitiva* inaugura-se pela publicação de novo edital para contratação da solução desejada, com critérios de seleção explícitos, com prazo não inferior a 60 dias. A partir daí, os participantes da fase de diálogos podem apresentar suas respectivas propostas para a realização do projeto em questão.

O rito procedimental explanado no §1º do artigo 32 transparece a morosidade que o instrumento impõe aos possíveis licitantes, sendo imperioso questionar se tal procedimento será apto a propiciar a inovação tecnológica, bem como abre flanco para o questionamento sobre o nível de maturidade do ente federativo.

Ressalta-se que, na prática, a própria Lei de Licitações trouxe outros instrumentos mais céleres capazes de sanear a lacuna quanto à “impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado” e à “impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração, são eles: consulta pública e audiência pública (art. 21)”.

Além desses pontos, de plano observado, entende-se que a operacionalização do procedimento traz outros desafios, dos quais cita-se: i) como definir os critérios de seleção dos licitantes se o objeto não está claramente delineado?; ii) como equilibrar a transparência com o sigilo das soluções propostas?; iii) por quanto tempo a fase de diálogo se dará? e iv) como e qual o momento para definir a escolha da melhor solução?

5.9 Procedimento para contratações de serviços em nuvem

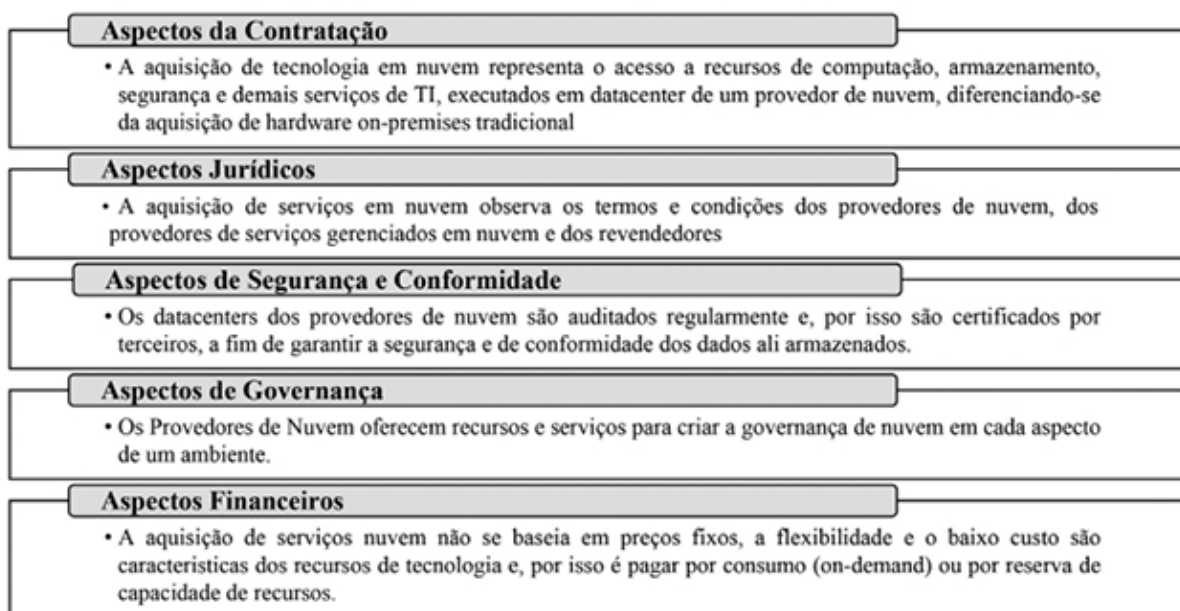
Lucas Lopes

Destaca-se que, antes de adentrar na modelagem que estabelecerá a criação do estudo técnico preliminar, justificativas, estimativas de custos, quantitativos, volumétrica, etc., e demais aspectos elementares da contratação de solução de TIC, é essencial refletir em como pensar, planejar e relacionar os elementos essenciais para uma assertiva contratação de serviços de nuvem.

Nesse sentido o modelo de contratação de nuvem é intencionalmente diferente de modelos tradicionais de contratação

de TI. A computação em nuvem representa uma mudança fundamental na maneira que os entes públicos adquirem serviços de computação para operar sistemas de negócios e serviços digitais.

Diferentes aspectos levam à adoção da nuvem e oferecem suporte a ela. O ente público precisa sempre considerar a contratação porque, se não puder comprar ou acessar a nuvem, todos os outros elementos da jornada para a nuvem serão interrompidos. Mesmo que a contratação seja um tópico central de sua jornada para a nuvem, há outros aspectos importantes que se sobrepõem e se vinculam entre si.



Nesse sentido, é possível afirmar que as estratégias de contratação de tecnologia legada não funcionam para a nuvem e isso às vezes inclui políticas e estruturas dos entes públicos. Para obter os benefícios da nuvem, é preciso mudar o racional de aquisição dos serviços TIC.

O processo de contratação de nuvem é dinâmico. Novos recursos e serviços são adicionados continuamente, e os preços são reduzidos conforme as economias de escala são passadas aos clientes.

Processos de contratação flexíveis permitem o acesso às inovações mais recentes com os melhores preços.

Estratégias de contratação de nuvem bem-sucedidas ajudam a garantir que toda a Administração Pública se beneficie das características da nuvem, que são: flexibilidade, elasticidade, disponibilidade, segurança e escalabilidade.

O *manual CISPE*²⁰⁴ traz importantes considerações sobre a forma de contratação dos serviços de nuvem, traçando boas práticas executadas por Administrações Públicas da Europa.

Outro ponto relevante a traçar é a diferença entre a contratação de serviços em nuvem e a contratação de mão de obra para usar os serviços em nuvem. Estratégias de nuvem bem-sucedidas separam a tecnologia de nuvem fornecida por um provedor de nuvem de serviços e mão de obra práticos ou outros serviços gerenciados necessários para usar a tecnologia de nuvem.

A tecnologia de nuvem e os serviços de mão de obra podem ser fornecidos por parceiros como uma solução abrangente ou adquirida separadamente. A tecnologia em nuvem deve ser considerada um serviço separado com funções e responsabilidades, acordos de níveis de serviços e termos e condições distintos.

Outro ponto relevante, na aquisição de serviços nuvem, é a atenção aos aspectos relacionados a *preço; segurança; responsabilidades do cliente; responsabilidades do provedor de nuvem e governança*.

Sobre o preço, como já dito neste manual, o contrato precisa prever o pagamento pelos serviços à medida que são consumidos, sob demanda. Sendo, pois, flexíveis o suficiente para flutuarem com base nos preços de mercado, para que o ente público possa aproveitar as vantagens da natureza dinâmica e competitiva dos preços da nuvem.

Essa modalidade auxilia o ente público a avaliar qual será o uso, em vez de adivinhar e adquirir em excesso e, para tal, os provedores

de nuvem devem fornecer preços e ferramentas atualizados e disponíveis publicamente que permitam avaliar seus preços, como a calculadora mensal, além de fornecerem ferramentas para gerar relatórios de cobrança detalhados e personalizados para atender às necessidades de negócios e conformidade.

Sobre a segurança importante destacar que as responsabilidades de segurança e conformidade são compartilhadas entre o ente público e os provedores de serviço. Em um modelo de infraestrutura como serviço (IaaS), permitindo que o ente público controle como arquitetar e proteger suas aplicações e os dados que coloca na infraestrutura.

Os provedores de nuvem são responsáveis por fornecer serviços por meio de uma infraestrutura altamente segura e controlada e por fornecer uma ampla gama de recursos de segurança adicionais. A responsabilidade do ente público e a dos provedores de nuvem dependem do modelo de implantação de nuvem empregado: infraestrutura como serviço (IaaS), *software* como serviço (SaaS) ou plataforma como serviço (PaaS). Em suma, os provedores de nuvem são responsáveis pela separação do acesso físico e lógico da nuvem. E os clientes mantêm a propriedade e o controle de seu conteúdo para atender aos objetivos de segurança compartilhados.

Sobre a responsabilidade do cliente, estes são responsáveis pela segurança *na* nuvem. Embora a infraestrutura em nuvem seja protegida e mantida pelos provedores de nuvem, o cliente é responsável pela segurança de tudo o que colocar na nuvem, tendo controle total sobre seu conteúdo e sendo responsável por gerenciar os requisitos de segurança de conteúdo críticos.

Sobre a responsabilidade dos provedores de nuvem, estes se responsabilizam pela segurança da nuvem, ou seja, são responsáveis por proteger a infraestrutura que executa todos os serviços oferecidos na nuvem, incluindo regiões, zonas de disponibilidade e pontos de presença.

Sobre a governança, o ente público deve manter total controle e propriedade sobre seus dados e ser capaz de escolher as localizações geográficas nas quais deseja armazená-los. Os provedores de nuvem devem fornecer controles de identidade e acesso para restringir o acesso à infraestrutura e dados do cliente, devendo o ente público compreender claramente suas responsabilidades em relação a como armazena, gerencia, protege e criptografa seus dados.

Um grande benefício da computação em nuvem em comparação com a infraestrutura de TI tradicional é que o cliente tem a flexibilidade para evitar o aprisionamento ao fornecedor tradicional. Os clientes da nuvem não estão comprando ativos físicos. Os provedores de nuvem oferecem a capacidade de subir e descer a pilha de TI conforme necessário, com maior portabilidade e interoperabilidade do que o antigo paradigma de TI.

[122](#) É importante alertar que os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação devem ter ciência expressa das suas indicações e das suas respectivas atribuições antes de serem formalmente designados.

[123](#) A IN Seges nº 58/22 dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares – ETP, para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

[124](#) O art. 18, §1º, da Lei nº 14.133/21 prevê que o estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do *caput* deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: II – demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração.

[125](#) Acórdão nº 488/2019-TCU-Plenário, da relatoria da Ministra Ana Arraes.

[126](#) Acórdão nº 2.407/2006-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Benjamin Zymler.

[127](#) Acórdão nº 488/2019-TCU-Plenário, da relatoria da Ministra Ana Arraes.

[128](#) Acórdão nº 488/2019-TCU-Plenário, da relatoria da Ministra Ana Arraes.

[129](#) Acórdão nº 488/2019-TCU-Plenário, da relatoria da Ministra Ana Arraes.

[130](#) Acórdão nº 2.569/2018-TCU-Plenário.

[131](#) Especificações com potencial de restringir o caráter competitivo da licitação devem ser adequadamente fundamentadas, com base em estudos técnicos que indiquem a sua essencialidade para atender as necessidades do órgão ou da entidade contratante (TCU, Acórdão nº 1.973/2020 – Plenário).

[132](#) TCU, Acórdão nº 2.569/2018-TCU-Plenário.

[133](#) Acórdão nº 2.383/2014-TCU-Plenário.

[134](#) Acórdão nº 2.569/2018-TCU-Plenário.

- [135](#) Art. 44. Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa.
- [136](#) De acordo com a IN SGD nº 94/2022, o Estudo Técnico Preliminar da Contratação deve ser aprovado e assinado pelos Integrantes Técnico e Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação e pela autoridade máxima da Área de TIC.
- [137](#) O Termo de Referência deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação e pela autoridade máxima da área de TIC, com posterior aprovação pela autoridade competente.
- [138](#) Disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/14133/modelos-da-lei-14-133-21-para-bens-e-servicos-de-tic/arquivos/modelo-contrato-tic-compras-lei-14-133.docx>.
- [139](#) Art. 18, VIII, da Lei nº 14.133/21.
- [140](#) Art. 18, §1º, XII, da Lei nº 14.133/21.
- [141](#) OTTMAN, Jacquelyn A. *As novas regras do Marketing*. São Paulo: M Books, 2012, p. 24.
- [142](#) A elaboração de projetos, a execução de obras e a realização de quaisquer outros serviços técnicos no âmbito da arquitetura e urbanismo ficam subordinados à emissão do Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, estatuído pela Resolução nº 91, de 9 de outubro de 2014 – art. 1º.
- [143](#) A Certidão de Acervo Técnico – CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, as atividades registradas no Crea, que constituem o acervo técnico do profissional. O acervo técnico do profissional é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo de sua vida profissional compatíveis com suas competências e registradas no Crea por meio de Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs. O profissional pode requerer sua CAT no Crea para fazer prova da sua capacidade técnico-profissional, com base nas atividades desenvolvidas e registradas em ARTs. Disponível em: <https://www.confea.org.br/servicos-prestados/certidao-de-acervo-tecnico-cat>. Acesso em: 25 out. 2021.
- [144](#) Em termos históricos, esse critério paramétrico já era adotado por órgãos como o DNIT, por exemplo.
- [145](#) CF 88, Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
[...]
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
- [146](#) DICAS do Mês. ILC – *Informativo de Licitações e Contratos*, p. 825.
- [147](#) PERGUNTAS e respostas. ILC – *Informativo de Licitações e Contratos*, p. 468.
- [148](#) Digamos “quase própria” em razão do comando estabelecido no art. 9º da Lei do Pregão de aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/1993.
- [149](#) Em relação ao diálogo competitivo, também bastante útil para situações específicas de TIC, remetemos o leitor para os comentários de Rafael Sérgio de Oliveira ao art. 32 na obra: OLIVEIRA, Rafael Sérgio Lima de. Comentários ao art. 32. In: FORTINI, Cristiana; OLIVEIRA, Rafael Sérgio Lima de; CAMARÃO, Tatiana. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Fórum: 2022, p. 389-421.
- [150](#) Inteiro teor, em língua portuguesa, disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014L0024>.

- 151 Conforme sistemática da Lei nº 8.666/1993, a alienação de bens imóveis por meio da modalidade leilão dar-se-ia somente quando: i) avaliados, isolada ou globalmente, até R\$ 1.430.000,00 (art. 17, §6º); ii) quando a integração do respectivo bem imóvel ao patrimônio da Administração haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento (art. 19). Assim, afora tais hipóteses, seria a concorrência a modalidade, por excelência, para a alienação de bens imóveis.
- 152 Para tanto, vide: AMORIM, Victor Aguiar Jardim de. *Licitações e contratos administrativos: teoria e jurisprudência*. 3. ed. Brasília: Senado Federal, 2020. p. 84-85.
- 153 “Padrões de desempenho e qualidade”, “objetivamente definidos pelo edital” e “especificações usuais no mercado”.
- 154 AMORIM, Victor Aguiar Jardim de. *Licitações e contratos administrativos: teoria e jurisprudência*. 3. ed. Brasília: Senado Federal, 2020. p. 93.
- 155 Trecho do voto do Ministro Benjamin Zylmer no Acórdão TCU nº 1.046/2014-Plenário.
- 156 Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/Jornada%20de%20Direito%20Administrativo%20-%20Enunciados%20aprovados/jornada-de-direito-administrativo-enunciados-aprovados/@@download/arquivo>. Acesso em: 15 abr. 2021.
- 157 Cf. AMORIM, Victor Aguiar Jardim de. *Licitações e contratos administrativos: teoria e jurisprudência*. 3. ed. Brasília: Senado Federal, 2020. p. 94.
- 158 Isso inclusive é o que está dito no parágrafo único do art. 25 da Instrução Normativa SGD nº 94/2022, que diz: “É obrigatória a utilização da modalidade Pregão para as contratações de que trata esta Instrução Normativa sempre que a solução de TIC for enquadrada como bem ou serviço comum, podendo-se utilizar o Diálogo Competitivo nos casos específicos previstos no art. 32 da Lei nº 14.133, de 2021, desde que devidamente justificado nos autos.”
- 159 OLIVEIRA, Rafael Sérgio Lima de. Comentários ao art. 32. In: FORTINI, Cristiana; OLIVEIRA, Rafael Sérgio Lima de; CAMARÃO, Tatiana. *Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*. Fórum: 2022, p. 389-421.
- 160 O instituto do registro de preço está conceituado no art. 6º, inciso XLI, da Lei nº 14.133/2021.
- 161 Referido Decreto foi editado quando vigorava uma das Medidas Provisórias, mais especificamente a de nº 2.026-3/2000, que antecederam a Lei nº 10.520/2002.
- 162 Dados coletados no Painel de Compras do Governo Federal.
- 163 Acórdão nº 2.471/2008-Plenário e Acórdão nº 237/2009-Plenário, ambos do TCU.
- 164 Instrução Normativa nº 94/2022 da Secretaria de Governo Digital do então Ministério da Economia, regulamenta as contratações de solução de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC com base na Lei nº 14.133/2021 no âmbito do Poder Executivo federal.
- 165 A título de informação transcrevemos aqui orientação do TCU acerca do significado dos enunciados da sua *Jurisprudência Seleccionada*: “O enunciado procura retratar o entendimento contido na deliberação da qual foi extraído, não constituindo, todavia, um resumo oficial da decisão proferida pelo Tribunal. Tampouco objetiva representar o posicionamento prevalecente no TCU sobre a matéria”.
- 166 O mesmo que havia sido empregado na Lei nº 10.520/2002 (parágrafo único do art. 1º).
- 167 Nesse mesmo sentido: Acórdão nº 2050/2014 – Plenário e Acórdão nº 2844/2010 – Plenário, ambos do TCU.
- 168 Sobre engenharia consultiva, destacamos o recente Acórdão nº 713/2019 – Plenário do TCU.

[169](#) Ressaltamos também que dificilmente será vantajoso para a Administração a licitação de um bem ou serviço tecnicamente heterogêneo por pregão. Nesses casos, a heterogeneidade, além de dificultar a padronização de critérios objetivos de desempenho e qualidade, faz com que o objeto possa ser mais bem avaliado por meio de critérios multidimensionais (técnica ou técnica e preço), e não exclusivamente pelo seu preço.

[170](#) Parágrafo único do art. 25 da Instrução Normativa SGD nº 94/2022, que diz: “É obrigatória a utilização da modalidade Pregão para as contratações de que trata esta Instrução Normativa sempre que a solução de TIC for enquadrada como bem ou serviço comum, podendo-se utilizar o Diálogo Competitivo nos casos específicos previstos no art. 32 da Lei nº 14.133, de 2021, desde que devidamente justificado nos autos.”

[171](#) Ainda que nos pareça de difícil aplicação, não se pode eliminar a possibilidade hipotética de cabimento dos critérios “menor preço” e “maior desconto” para a modalidade diálogo competitivo.

[172](#) De acordo com o inciso LIII do art. 6º da NLLCA, entende-se por contrato de eficiência o “contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada”.

[173](#) Valor anualmente atualizado de acordo com o art. 182 da NLLCA.

[174](#) “§3º Serão considerados intermediários os lances:

I – iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance;

II – iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento”.

[175](#) “§4º Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações”.

[176](#) “Art. 57. O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta”.

[177](#) Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração desta etapa.

§1º A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

§2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no §1º, a etapa será encerrada automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme disposto no §2º do art. 22.

§3º Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação ou a comissão de contratação, quando o substituir, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitação, para a definição das demais colocações.

§4º Após o reinício previsto no §3º, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

§5º Encerrada a etapa de que trata o §4º, o sistema ordenará e divulgará os lances conforme disposto no §2º do art. 22.

178 Art. 24. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 22, a etapa de envio de lances terá duração de quinze minutos.

§1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

§2º Após a etapa de que trata o §1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até dez por cento superiores ou inferiores àquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

§3º No procedimento de que trata o §2º, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

§4º Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o §2º, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no §3º.

§5º Encerrados os prazos estabelecidos nos §§2º e 4º, o sistema ordenará e divulgará os lances conforme disposto no §2º do art. 22.

179 Art. 25. No modo de disputa fechado e aberto, de que trata o inciso III do caput do art. 22, somente serão classificados automaticamente pelo sistema, para a etapa da disputa aberta, na forma disposta no art. 23, com a apresentação de lances, o licitante que apresentou a proposta de menor preço ou maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela, conforme o critério de julgamento adotado.

§1º Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no caput, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos, na forma disposta no art. 23.

§2º Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação ou a comissão de contratação, quando o substituir, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitação, para a definição das demais colocações.

§3º Após o reinício previsto no §2º, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários, podendo optar por manter o seu último lance.

§4º Encerrada a etapa de que trata o §3º, o sistema ordenará e divulgará os lances conforme disposto no §2º do art. 22.

180 Para melhor compreensão, vide: AMORIM, Victor. *A fase de lances na nova Lei de Licitações sob a perspectiva da 'teoria dos leilões'*: contributos para a futura regulamentação dos modos de disputa. Observatório da Nova Lei de Licitações, abr. 2022. Disponível em: <https://www.novaleilicitacao.com.br/2021/04/26/a-fase-de-lances-na-nova-lei-de-licitacoes-sob-a-perspectiva-da-teoria-dos-leiloes-contributos-para-a-futura-regulamentacao-dos-modos-de-disputa/>.

181 Acerca da temática dos “regulamentos e hierarquia normativa”, vide: AMORIM, Victor Aguiar Jardim de. *Licitações e contratos administrativos: teoria e jurisprudência*. 4. ed. Brasília: Senado Federal, 2021. p. 37-39.

- ¹⁸² Cf.: Value of Money: guide Note on Procurement. *Asian Development Bank*, jun. 2018. Disponível em: <https://www.adb.org/sites/default/files/procurement-value-money.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2021.
- ¹⁸³ SÁNCHEZ, Pedro Fernández. *Direito da Contratação Pública*. Lisboa: AAFDL, 2020. p. 310.
- ¹⁸⁴ Nesse ponto é referência internacional o caso *Concordia Bus Finland* (C-513/99 do TJUE), julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, no qual se admitiu a valoração da proposta com base em critérios ambientais. Vide: CARANTA, Roberto. *I Contratti Pubblici*. 2. ed. Torino: G. Giappichelli, 2012. p. 490.
- ¹⁸⁵ Cf.: Recommendation of the Council on Public Procurement. *OECD/LEGAL/0411*, 2019. Disponível em: <https://legalinstruments.oecd.org/en/>. Acesso em: 14 jul. 2021.
- ¹⁸⁶ DIMITRI, Nicola. “Best value for money” in procurement. *Journal of Public Procurement*, v. 13, n. 2, p. 149-175, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/JOPP-13-02-2013-B001>. Acesso em: 14 jul. 2021.
- ¹⁸⁷ O Preâmbulo da *Model Law* da Uncitral se refere a esse objetivo com o seguinte texto: “(a) Maximizing economy and efficiency in procurement”. É possível encontrar o mesmo objetivo no sistema de contratação pública federal americano. O item 1.102, (b), 1, do *Federal Acquisition Regulation – FAR* diz: “(b) The Federal Acquisition System will- (1) Satisfy the customer in terms of cost, quality, and timeliness of the delivered product or service by, for example- (i) Maximizing the use of commercial products and services; (ii) Using contractors who have a track record of successful past performance or who demonstrate a current superior ability to perform; and (iii) Promoting competition”.
- ¹⁸⁸ DIMITRI, Nicola. “Best value for money” in procurement. *Journal of Public Procurement*, v. 13, n. 2, p. 149-175, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/JOPP-13-02-2013-B001>. Acesso em: 14 jul. 2021.
- ¹⁸⁹ A título de exemplos, vide: AUSTRALIA. Government of South Australia. *Value for Money in Procurement Guideline*. Jan. 2018. Disponível em: <https://spb.sa.gov.au/sites/default/files/Value%20for%20Money%20Guideline%20v%201.0%20January%202018.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2021; NSIAH-ASARE, Evelyn; PREMPEH, Kwadwo Boateng. Measures of Ensuring Value for Money in Public Procurement: a Case of Selected Polytechnics in Ghana. *Munich Personal RePEc Archive*, mar. 2016. Disponível em: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/70051/>. Acesso em: 14 jul. 2021.
- ¹⁹⁰ SÁNCHEZ, Pedro Fernández. *Direito da Contratação Pública*. Lisboa: AAFDL, 2020. p. 310.
- ¹⁹¹ EUROPEAN UNION. Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Public Procurement. European Commission, Brussels, 896 final, 20 dez. 2011. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:EN:PDF>. Acesso em: 14 jul. 2021.
- ¹⁹² Sobre o diálogo competitivo, vide: OLIVEIRA, Rafael Sérgio Lima de. O diálogo competitivo do projeto de lei de licitação e contrato brasileiro. *Portal L&C*. Disponível em: <http://licitacaocontrato.com.br/exibeArtigo.html?assunto=oDialogoCompetitivoProjetoLeiLicitacaoEContratoBrasileiro>. Acesso em: 14 jul. 2021.
- ¹⁹³ No caso do diálogo competitivo brasileiro, a regulamentação dessa modalidade em nível federal admite o uso do menor preço e do maior desconto para o julgamento das propostas na fase competitiva (art. 4º, inciso III, da Instrução Normativa SEGES nº 73/2022).

- 194 No sistema da Lei nº 8.666/1993, segundo o inciso I do §1º e do art. 46 da Lei nº 8.666/1993, a dimensão técnica do julgamento das propostas deve considerar: “a capacitação e a experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua execução” (vide §2º do mesmo art. 46).
- 195 Os requisitos legais para aplicação da técnica e preço previstos na Lei nº 14.133/2021 são replicados no art. 3º da Instrução Normativa SEGES nº 02/2023, que versa sobre o procedimento da licitação cujo critério de julgamento for técnica e preço.
- 196 FANTINI, Stefano; SIMONETTI, Hadrian. *Le Basi del Diritto dei Contratti Pubblici*. Roma: Giuffrè, 2017. p. 77-78.
- 197 Sobre a banca de atribuição de nota técnica, vide comentários ao art. 37, nesta obra.
- 198 Art. 6º, inciso XLV, da Lei nº 14.133/21: sistema de registro de preços é um conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras.
- 199 Representação convertida de parecer da auditoria interna. Discussão a respeito da legalidade da dispensa de termo de contrato e da utilização de outros documentos nas hipóteses de compras com entrega imediata. fixação de entendimento. possibilidade de dispensa de termo contratual. (Acórdão TCU nº 1234/2018 – plenário).
- 200 Art. 40, inciso II, da Lei nº 14.133/21.
- 201 No mesmo sentido é a orientação do TCU, que tem estimulado os órgãos e entidades públicas a usarem o sistema de registro de preços para a contratação de bens e serviços comuns de uso frequente. Cite-se: Acórdão nº 214/06 – Plenário e Acórdão nº 991/09 – Plenário.
- 202 Art. 82, §5º, inciso II, da Lei nº 14.133/21.
- 203 Marina Fontão Zago – Diálogo competitivo: Para o quê e para quem? Publicado junho de 2021, disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/346368/dialogo-competitivo-para-o-que-e-para-quem>.
- 204 O CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe, <https://cispe.cloud>) é um grupo independente do setor sem fins lucrativos. O CISPE representa fornecedores de serviços de infraestrutura de *cloud* na Europa e trabalha com o setor e os legisladores para fornecer orientação e informação sobre os serviços de *cloud*, melhores práticas de contratação e a função que desempenham no setor.

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

6.1 Responsabilidades

Jair Santana

Tatiana Camarão

Não há como negar que no Brasil exista – em torno do tema gestão e fiscalização dos contratos administrativos – uma imensa série de dificuldades que acaba por produzir resultados negativos para os contratantes, contratados e, o que é pior, para a sociedade, que se coloca num dos eixos das relações estabelecidas, já que é ela (a sociedade) a única e verdadeira destinatária dos produtos ajustados entre Poder Público e particular.

Ou seja, a finalidade última de se bem gerir um contrato administrativo é garantir resultados ótimos para a sociedade na prestação de serviços, no fornecimento de bens ou na utilização de imóveis (derivados da “obra”). Aliás, esse é o comando da nova lei, que prevê no art. 11, inciso, I, o propósito de assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso.

De qualquer modo, o controle e a inspeção do contrato administrativo são feitos com o fim de verificar a execução do objeto contratual de forma integral e avaliar se o serviço está atendendo o interesse público, pois dessa forma o sistema se retroalimenta.

Enfim, fiscalizar a execução de um contrato não é apenas uma atividade formal, deve-se levar em conta a prestação do serviço, a entrega, bem como a qualidade e a quantidade, conforme o previsto no pacto contratual.

A propósito, vale destacar que cada organização goza de autonomia para formular suas próprias normas de controle e fiscalização dos contratos administrativos, conforme se depreende do art. 18 da CF/88 e em mais detalhe no art. 187, que dispõe que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, caso não tenham regulamento próprio, poderão aplicar aqueles editados pela União para execução da nova lei. Segundo Jessé Torres Pereira Junior, em *Comentários à lei das licitações e contratações da Administração Pública* (2002, p. 678), “As normas procedimentais não se compadecem com o caráter geral das normas principiológicas”. Ainda segundo Jessé Torres, assim como se dá no Direito Processual, em face da competência legislativa conforme o art. 24, XI, da CF/88, ocorre o mesmo nos procedimentos de cunho operacional.

A propósito, vale destacar que a União regulamentou, por meio da Instrução Normativa nº 94/2022, as responsabilidades e atribuições do gestor de contrato, fiscal técnico, fiscal administrativo e fiscal setorial.

Art. 2º, inciso V – *Equipe de Fiscalização do Contrato*: equipe responsável pela fiscalização do contrato, composta por:

- a) *Gestor do Contrato*: servidor com atribuições gerenciais, preferencialmente da Área Requisitante da solução, designado para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual, indicado por autoridade competente;
- b) *Fiscal Técnico do Contrato*: servidor representante da Área de TIC, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato;
- c) *Fiscal Administrativo do Contrato*: servidor representante da Área Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos;

d) *Fiscal Requisitante do Contrato*: servidor representante da Área Requisitante da solução, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista de negócio e funcional da solução de TIC; e

e) *Fiscal Setorial do Contrato*: servidor representante de setores distintos ou em unidades desconcentradas de um órgão ou uma entidade, indicado pela autoridade competente dessa área para o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos;

No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ disciplinou, por meio da Resolução nº 468/2022, o encargo do gestor do contrato, do fiscal demandante, do fiscal técnico, do fiscal administrativo e do fiscal setorial.

Portanto, pode-se chegar à conclusão de que, como *a gestão de contratos trata de procedimento operacional*, cada ente da Administração dispõe sobre a matéria conforme convenha às suas respectivas organizações e estruturas. Não deixando, entretanto, de aplicar a regra disposta na Lei nº 14.133/21, principalmente nos arts. 89 e 105, assim como as penalidades elencadas nos arts. 156 a 163 dessa mesma lei, pois se trata de normas gerais de gestão e devem ser seguidas para a construção da norma singular de fiscalização, conforme aprouver a cada ente administrativo.

6.1.1 O gestor e sua designação

O *gestor* é quem irá representar a Administração na execução do contrato e pode ser nomeado entre os servidores que tenham o conhecimento técnico do objeto contratado ou o titular da unidade organizacional formada para fiscalizar a obrigação contratual.²⁰⁵

Não se pode confundir o gestor com o fiscal do ajuste. Embora as atividades de ambos possam ser realizadas por pessoa física única, o que não se recomenda, a depender das circunstâncias presentes em cada caso, o fato é que gestor e fiscal devem manter suas atividades em perfeita sincronia porque, ao fim de tudo, objetivam algo comum: a perfeita execução do contrato.

O gestor contratual, diz o nome, é designado, por meio de imposição legal, para tomar as providências necessárias para o fiel cumprimento do contrato em termos mais gerenciais e não necessariamente operacionais, acaso conte com o auxílio do fiscal. As estratégias de execução e as atividades menos subalternas estarão sob seu encargo.

Comumente suas *atribuições* são o controle geral dos prazos de vencimento ou de renovação dos contratos, questões relacionadas ao equilíbrio econômico-financeiro, à documentação, aos pagamentos, entre outras de cunho geral. Trata-se de um serviço administrativo que pode ser realizado por um representante da Administração ou por um órgão fiscalizador.

De outra parte, o *fiscal* será nomeado para atuar pontualmente no cumprimento da obrigação contratual, ou seja, é ele quem estará incumbido da “fiscalização” da execução “física” e “documental” do contrato.

Vale registrar que há que se ter um fiscal para cada contrato. Nesse sentido, é o comando do art. 117 da nova lei. [206](#) [207](#)

Art. 117 da Lei nº 14.133/21. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no

art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

§1º O fiscal do contrato anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

§2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

§3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

É fundamental escolher o fiscal que tenha tempo hábil²⁰⁸ para executar seu “múnus” da melhor forma possível²⁰⁹ e conhecimento para supervisionar e acompanhar a execução contratual.

Evidentemente que, a depender de cada caso, apenas um gestor fará as suas próprias vezes e as vezes do fiscal. Noutros casos, um gestor terá que contar com a colaboração de inúmeros fiscais. É possível, ainda, que se tenha uma unidade para gerir todos os contratos e sejam designados fiscais para cada contrato.

Seja como for, é importante alertar que é obrigatória a designação de um fiscal para cada ajuste e este poderá se valer até de terceiros (estranhos à Administração Pública) para lhe auxiliar. O *caput* do art. 117 da nova lei prevê essa prerrogativa de contratação de terceiro para assistir e subsidiar os fiscais com informações pertinentes a essa atribuição.

É possível, ainda, que o fiscal solicite a colaboração da assessoria jurídica e controle na execução de sua função. Essa é a previsão do art. 117, §3º, que dispõe sobre o auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno no esclarecimento de dúvidas e apoio com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

Noutro giro, vale alertar, que na falta da fiel execução do avençado, tanto o contratado quanto o fiscal que não respeitar as normas impostas deverão sofrer as consequências legais em decorrência da má execução de sua função. Por isso, é importante os fiscais receberem treinamento, contarem com ferramentas e processos que contribuam para melhor execução de suas atividades. A respeito, cumpre citar que o art. 19, inciso III, da nova lei, estabelece que os órgãos e entidades públicas devem instituir sistema informatizados de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo.

É vital, outrossim, que o fiscal seja designado por um ato específico, antes da assinatura do contrato, e a ciência do comando deve ser juntada aos autos. Vale registrar que no referido ato de designação deverão constar as suas principais atribuições.

6.1.2 Fiscal de contratos

Como já dito, a figura do gestor de contratos não se confunde com o fiscal de contratos. A propósito, Jessé Torres Pereira Junior e Marinês Restelatto Dotti ensinam:

A fiscalização é atividade de controle e inspeção sistemática do objeto contratado pela Administração, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações previstas no contrato.

Em resumo, é o acompanhamento cotidiano do contrato em seu local de execução, com o fim de certificar-se a Administração de que se executa o que se contratou, nem mais, nem menos. Tal é o papel que se espera do fiscal.

O gestor de contrato é a autoridade superior a que o fiscal remeterá às decisões e providências que ultrapassam a sua competência. Cabe-lhe gerenciar o contrato e decidir sobre eventuais e possíveis alterações das condições avançadas. Ao gestor, e apenas a ele, caberá a responsabilidade pela tomada de decisões gerenciais relativas à execução do contrato e à celebração de seus aditamentos.

A designação do fiscal, inclusive, poderá ficar a cargo do gestor de contrato.^{[210](#)}

Nomeado o *fiscal* e instruído sobre suas *atribuições* (Acórdão nº 634/2006, 1ª Câmara), é da competência dele obter cópia do contrato, do edital/anexos e da proposta vencedora da licitação para análise e arquivo. É uma boa prática que a indicação do fiscal do contrato ocorra preferencialmente na fase interna da licitação e o ato de designação deverá ser entranhado aos autos do respectivo processo.

Poderá atuar como fiscal de contratos o servidor no sentido amplo, em consonância com o previsto no art. 117 da Lei nº 14.133/21, que traz a definição de servidor público como “aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público”. Como podemos ver, trata-se de conceito lato, que abrange os sujeitos que mantêm vínculo estatutário, compreendendo os detentores de cargos efetivos e comissionados; os empregados públicos, contratados pelo regime da legislação trabalhista e os contratados por prazo determinado por excepcional interesse.²¹¹ De outra banda, é vedada a indicação de prestador de serviço terceirizado como fiscal de contratos, pois só pode contribuir com assessoramento. Nesse sentido é a orientação do TCU no Acórdão nº 100/2013.

Mais uma vez, vale reiterar que o servidor não pode se recusar a assumir a atribuição de fiscal de contratos, mesmo que não tenha conhecimento técnico específico ou condições precárias para realizar seu trabalho, devendo, para tanto, solicitar apoio de assessoramento e os meios necessários para exercer seu encargo. O TCU, no Acórdão nº 2.917/2010 – Plenário,²¹² deixou assentado que “5.7.7. O servidor designado para exercer o encargo de fiscal não pode oferecer recusa, porquanto não se trata de ordem ilegal. Entretanto, tem a opção de expor ao superior hierárquico as deficiências e limitações que possam impedi-lo de cumprir diligentemente suas obrigações. A opção que não se aceita é uma atuação a esmo (com imprudência,

negligência, omissão, ausência de cautela e de zelo profissional), sob pena de configurar grave infração à norma legal”.

É indicado que a designação do fiscal deve recair em técnico da área da qual está sendo executado o serviço, tendo em vista que o atesto por alguém sem o devido conhecimento poderá gerar prejuízo à Administração Pública.²¹³ No Acórdão nº 2.917/2010 – Plenário,²¹⁴ o TCU defende que devem ser designados fiscais de contrato servidores qualificados para a gestão dos contratos, de modo que sejam responsáveis pela execução da atividade e/ou pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos serviços.

O fiscal precisa conhecer as cláusulas do contrato para o qual foi designado a acompanhar, buscando esclarecer as dúvidas que tiver junto ao gestor ou área instituída para gestão do contrato. Além disso, deverá ter tempo hábil suficiente para o desempenho das funções a ele confiadas.²¹⁵

Fato é que o órgão ou entidade contratante deverá assegurar ao fiscal de contratos os meios necessários para que ele desempenhe suas funções com eficiência e eficácia, evitando que lhe seja atribuído um número desarrazoado de contratos para acompanhamento. Cabe invocar, mais uma vez, o magistério de Jessé Torres Pereira Junior e Marinês Restelatto Dotti:

Em vista da probabilidade de que um único agente designado para fiscalizar a execução de vários contratos não consiga desempenhá-los com eficácia, é prudente atribuir para cada agente ou comissão de fiscalização um número delimitado de contratos, agrupados segundo a similitude do objeto e suas especificidades.²¹⁶

No Acórdão nº 839/2011 – Plenário²¹⁷ ficou consignado que é possível elidir a responsabilidade do fiscal quando comprovado que não foi ofertada condição de trabalho para o exercício da função.

Para melhor exercer o seu mister, o TCU tem recomendado que se constitua um fiscal para cada contrato (Acórdão nº 3.156/09).

Os prazos para entregas, horários e materiais utilizados devem ser de inteiro conhecimento do fiscal e em caso de necessidade o fiscal poderá requisitar apoio especializado para assisti-lo ou assessorá-lo em informações técnicas (art. 117, *caput*, Lei nº 14.133/21). O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para regularização das falhas ou defeitos observados (art. 117, §1º, Lei nº 14.133/21).

Nesse ponto, é importante alertar que os registros anotados pelo fiscal durante a execução do contrato servirão de substrato para a instauração de processo administrativo próprio sancionatório, com possível rescisão, no caso de ocorrência reiterada de faltas. Portanto, se houver omissão destas anotações, o fiscal responderá por infração disciplinar e sofrerá a consequente punição. Esse registro poderá ser feito em livro próprio, fichas ou arquivos/processos eletrônicos, devendo constar anotações referentes ao monitoramento dos trabalhos, incidentes, providências e resultados. A transferência da guarda destes documentos originais, ao final da avença, é recomendada mediante entrega com recibo, devendo o fiscal manter em seu poder cópia desses documentos.

Em suma, o fiscal de contratos deve ser diligente e agir com proatividade, presteza e rendimento funcional, exercendo uma ação fiscalizadora de modo sistemático e permanente, de maneira a fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condições, qualificações e especificações previstas no instrumento contratual.

6.1.3 Da gestão e fiscalização do contrato pela área de TIC

A gestão e fiscalização das contratações que envolvem a área de TIC deverão ser regulamentadas pelo órgão para dar segurança

jurídica aos agentes públicos, conforme preceitua o art. 30 da LINDB.²¹⁸

É possível que se preveja no regulamento que o gestor do contrato, os fiscais demandantes, técnico e administrativo do contrato poderão ser os mesmos servidores que realizaram o planejamento da contratação desde que atendam aos princípios da vantajosidade e economicidade para a Administração Pública.

Lado outro, na supervisão e acompanhamento do contrato, os papéis de fiscal técnico e demandante não poderão ser acumulados pelo mesmo servidor, salvo em casos excepcionais, mediante justificativa fundamentada nos autos e aprovadas pelo superior imediato do dirigente da área de TIC.

Vale destacar que o fiscal administrativo deverá ser designado pela autoridade competente e não poderá ser servidor da área de TIC, salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas.

Essa vedação tem razão de ser, pois os servidores da área de TIC deverão assumir atribuições diretamente relacionadas com as suas habilidades e conhecimentos técnicos, sendo certo que o acompanhamento de documentos administrativos não se encontra nesse cardápio de atividades.

6.2 Revisão, reajuste e repactuação

Juliana Picinin

6.2.1 Introdução

A Constituição Federal determinou que nas relações contratuais firmadas pela Administração Pública com o mercado houvesse o cuidado de se preservar as *condições efetivas da proposta* (art. 37, inc. XXI).

Isso significa, em primeiro lugar, o reconhecimento do legislador de que as relações contratuais sofrem o influxo do tempo e de todas as vicissitudes ocorridas nesse, sem que seja possível ignorar a necessidade de ajustes imprescindíveis a partir disso.

Os contratos, nesse sentido, possuem uma tessitura a ser mantida, a partir do que inicialmente desenhado.

Malgrado essa tessitura permita adaptações necessárias à sua sobrevivência e melhor vivência, há um núcleo essencial que não deve se desfigurar para que a relação que nasceu equilibrada entre as partes não se dissolva.

A forma como isso será feito dependerá, no entanto, da afetação dessa tessitura, exigindo para cada grupo de ocorrências um tipo de resposta.

É assim que veremos, neste artigo, que ajustes se produzem nos contratos firmados pela Administração Pública com o mercado (aqui chamados de contratos administrativos) e de que maneira se diferenciam, direcionando o olhar a contratos que envolvam Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC).

6.2.2 Conceitos

6.2.2.1 Reequilíbrio econômico-financeiro enquanto gênero

O primeiro ponto é compreender que existe um gênero de ajustes, que aqui vamos denominar de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a que se acoplam as espécies de reajuste, repactuação e revisão (ou reequilíbrio em sentido estrito).

O fato de as nomenclaturas se aproximarem na imprecisão da fala cotidiana faz com que muitos equívocos ocorram, reforçando a importância da diferenciação técnica para que, de uma acidental e

desavisada superposição, não se dê mais (ou menos) do que se deveria.

O segundo ponto é compreender que do gênero se extrai a noção básica de que o objetivo é restituir o contrato às tais condições efetivas da proposta referidas no texto constitucional.

Não se dá mais do que o combinado, não se aumentam os direitos ou deveres de uma parte ou outra: apenas se recompõe o acordado, para que continue expressando tudo quanto fora feito à época.

Portanto, isso exige um *mindset* aos operadores: não se trata de uma renegociação das bases contratuais, de uma reestruturação, de uma mudança de regras, de um *plus* a nenhuma das partes, mas de uma mera recomposição da expressão numérica do valor e da capacidade remuneratória do contrato.

A decorrência primeira e imediata disso é que não faz sentido espíritos resistentes (ou renitentes) a operar sua ocorrência.

Se fosse possível combater, estritamente, o *mindset* transversal que acaba aparecendo nas situações práticas, grande parte dos embates entre contratantes e contratados simplesmente se dissolveria.

No entanto, é importante compreender que, até que se processe uma mudança de cultura, que leva tempo, repetição e novos hábitos conscientemente praticados, a dissolução das resistências perpassa pela clareza e objetividade no momento de tratar os temas.

O início disso será, então, não confundir conceitos básicos. Isso não é mais admissível.

Em assim sendo, entendam-se as espécies.

6.2.2.2 Reajuste

A primeira delas é o reajuste, cujo objetivo é tão somente a *recomposição do poder aquisitivo da moeda*, recorrentemente expresso na aplicação de um índice ou fórmula de correção monetária que

permita, para o objeto contratual, a melhor expressão das ocorrências inflacionárias (para mais ou para menos), não se constituindo em um efetivo e material aumento da lucratividade contratual.²¹⁹

Os contratos administrativos devem prever, desde seu nascedouro, o que fazer a título de reajuste: prevendo um índice (geral ou específico) ou uma fórmula paramétrica (a conjunção de índices que melhor expressem os principais insumos envolvidos na prestação do objeto, considerando que alguns desses têm lógicas muito particulares de alteração, inclusive à luz das *commodities* que comportam).

Esse índice ou fórmula passará a ser aplicado, a cada intervalo de 12 meses, a partir de um marco temporal específico.

Na antiga lei geral (Lei federal nº 8.666/93) esse marco poderia ser, conforme escolha editalícia, a data da apresentação da proposta ou do orçamento estimado pela Administração Pública e a que a proposta se refere (art. 40, inc. XI).

Na lei geral das estatais (Lei Federal nº 13.303/16) permitiu-se a escolha editalícia (art. 69, inc. III), além da possibilidade de que a entidade discipline em regulamento próprio temas como esse para gerir os casos futuros.

Na atual lei geral (Lei Federal nº 14.133/21) fixou-se como marco a data do orçamento estimado pela Administração (art. 25, §7º).

A medida de maior justiça é que seja, de fato, a data da orçamentação pública, que serviu de norte para os preços unitários e totais estabelecidos no edital, sob pena de a defasagem entre a data do orçamento estimado e a data da apresentação da proposta (que pode ser extensa e significativa) afetar a competitividade e/ou a atratividade do certame, a adequação dos preços à realidade de mercado, a relação mais transparente e menos renitente entre as partes, retirando o jogo de disputa entre contratantes e contratados, rumo ao *mindset* de parceria e interação.

Afinal, não é uma relação que nasce de fato equilibrada se uma das partes, pelo tempo alongado das fases internas dos certames, por responsabilidade própria, impõe que a outra suporte as perdas do período sem possibilidades de diálogo.

Isso gerará propostas de preço mais inchadas, como compensação das perdas havidas nesse ínterim, o que repercutirá sobre todo o contrato, esticando a corda do relacionamento harmonioso que se poderia ter, com o risco de se romper desmesuradamente.

Por isso, para os casos em que os licitantes ainda vejam, nas alternativas permitidas pelo legislador, a previsão editalícia de reajustes apenas com base na data da apresentação da proposta, é salutar que questionem o órgão licitante (via impugnação ou pedido de esclarecimentos), demonstrando de que forma, na realidade concreta, essa previsão de não reajuste (no interregno entre orçamento estimado e apresentação da proposta) se mostra significativa e impactante na coleta do real preço de mercado e a vantajosidade de, para garantir competitividade, bons preços e bons concorrentes, se altere a data-base em questão.

Não se aconselha uma insurgência genérica, mas a demonstração analítica do impacto e a necessidade de o administrador, avaliando as consequências práticas do seu decidir e as soluções alternativas disponíveis, para melhor moldar suas ações (arts. 20 a 22 da LINDB).^{[220](#)}

Outro ponto importante é que a nova lei geral previu que, mesmo nos casos em que os contratos sejam inicialmente previstos para durarem menos de 12 meses, é fundamental que exista a previsão de índice de reajuste que vá operar a partir de determinado ponto.

De um lado, porque há um erro interpretativo em se achar que apenas contratos com mais de 12 meses têm a necessidade de previsão de reajuste, já que o cálculo de 12 meses para fins de reajuste não é o do tempo de execução do contrato, mas da distância

entre a data do orçamento estimado e a data dos pagamentos a serem praticados nesse.²²¹

De outro lado, porque contratos podem ser prorrogados e, assim, atingir-se a distância de mais de 12 meses entre a data do orçamento estimado e o tempo de algum pagamento contratual.

Essa prorrogação, na nova lei geral, pode se dar de duas formas: a) a prorrogação automática pelo tempo necessário à resolução do contrato por escopo (arts. 6º, inc. XVII, e 111); ou b) a prorrogação decidida pelas partes (porque o contrato é de natureza contínua ou de trato continuado ou porque necessária uma reprogramação de cronograma de entregas ou decorrente de alguma situação fática outra que tornou indispensável a extensão contratual, a exemplo dos arts. 107 e 115, §5º).

Assim, compensa que o edital já tenha previsto o sistema de reajuste aplicável, dispensando que, no curso do contrato, seja necessária negociação sobre o índice ou fórmula e isso requeira a celebração de termo aditivo.

Afinal, havendo definição no edital do índice ou fórmula aplicável, sua adoção se dará por mera apostila, sem necessidade da formalização de termos aditivos que, como sabemos, tensionam ainda mais essa relação (art. 65, §8º, da antiga lei geral; art. 81, §7º, da lei das estatais; art. 136, inc. I, da nova lei geral).

À exceção dos casos em que o próprio edital preveja que o reajuste tenha de ser formalmente solicitado pelo contratado (por se o entender como direito disponível), o reajuste é possível na vivência contratual de forma menos burocrática: ao contratante caberá apostilar; ao contratado caberá emitir as notas fiscais com os valores reajustados, sem maiores formalidades.

Assim, o reajuste é uma vivência contratual que pode ser menos afetada por animosidades, sedimentado que já está que o tempo

afeta o preço do contrato e a norma constitucional determinou que as relações se mantivessem tal qual foram definidas desde o início.

Última consideração relevante é que, em se tratando de contratos de TIC, firmados na esfera federal ou com recursos da União, atualmente há uma *definição padronizada de índice utilizável*, conforme se vê no art. 24 da IN nº 94/22, que é o ICTI – *Índice de Custos de Tecnologia da Informação* mantido pelo IPEA.²²²

6.2.2.3 Repactuação

A segunda das espécies é a *repactuação*, destinada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra (art. 6º, inc. LIX, da nova lei geral).

Para essa será necessário pedido expresso dos contratados porque, nesse momento, terão de demonstrar os valores que comporão essa repactuação, pois os dados necessários se encontram em seu poder.

O objetivo é também correcional, mas neste caso vinculado a *custos decorrentes de mercado* (quanto aos insumos em geral) e a *acordo, convenção coletiva ou dissídio coletivo* da categoria (ou das categorias) que compõem a mão de obra envolvida.

Haverá, portanto, uma *demonstração analítica da variação dos custos* (art. 92, §4º, inc. II) por meio de *apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação* (art. 135, §6º) e, diferentemente do reajuste, com avaliação do intervalo a partir da *data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação* (art. 135, §3º).

Outra importante diferença do reajuste é que é possível fracionar a repactuação, dado que os acordos, dissídios e convenções têm datas-base próprias e, por isso, é possível fragmentar a repactuação em

discussões esparsas ao longo do ano, em que pese não se perca de vista que o ajuste, no conjunto das repactuações parciais, dirá respeito ao interregno anual, contado a partir da data da apresentação da proposta (art. 135, §4º).

Essa compartimentalização é vantajosa a contratantes e contratados, pois a postergação de repactuação de parte dos valores pode impactar sobremaneira o equilíbrio do contrato e tornar exigível, nesse sobrepeso, outras compensações financeiras ou risco de sustentabilidade contratual (especialmente porque os custos com mão de obra são a parcela mais significativa da composição de custo total do contrato).²²³

6.2.2.4 Revisão

A terceira das espécies é a revisão, para as situações em que o reajuste e/ou a repactuação não foram capazes de, por si sós, restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

Isso pode se dar em decorrência de *força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado* (art. 124, inc. II, alínea “d” da nova lei geral; art. 65, inc. II, alínea “d” da antiga lei geral; art. 81, inc. VI, da lei das estatais, guardadas as sutis e relevantes diferenças na redação dessas leis), decorrentes da *teoria da imprevisão*.²²⁴

Com efeito, o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato pode vir a ser atingido por outras vicissitudes, de distintas fontes, a requerer que as partes dialoguem sobre como proceder à recomposição.

De plano, vale destacar que esse caso deve ser decorrência de pedido expresso e requer um processo administrativo para sua condução e concessão.

Cada dia mais aumenta o número de normativos a respeito de como se processa e se regula esse processo nas distintas esferas de governo (e é conveniente que o órgão, de fato, predetermine, normativamente, como irá tratar essas situações),²²⁵ bem como cada dia mais aumenta a solicitação de que a solução (sofrida, muitas vezes) se dê a partir de métodos alternativos de solução de controvérsias e com base em diálogos mais francos e amadurecidos (a exemplo da nova lei geral, art. 151, como hipóteses possíveis a conciliação, a mediação, os *dispute boards* e a arbitragem, sem prejuízo de outros).

O fato é que, nesse capítulo, está um dos mais desgastantes tópicos do relacionamento contratante-contratado na história recente dos contratos administrativos.

Alguns fatores contribuem para isso, podendo ser exemplificados os seguintes:

a) o relacionamento contratante-contratado, historicamente, é permeado de uma desconfiança quanto aos propósitos de contratar.

É possível perceber pensamentos, tais como: contratantes acreditando que os contratados têm como intenção aproveitar-se do espaço de contratação pública para fins espúrios ou pouco nobres, como lucratividade excessiva, desova de produtos inservíveis ao mercado privado, baixa qualidade de produto ou serviço, sobrepreço ou superfaturamento.

Por isso, contratantes absorvem um comportamento de sangria de fornecedores a partir do preço, de busca desenfreada de redução dos espaços de lucratividade, desconfiança crônica de propósitos privados, resistência a pedidos de revisão, relação baseada em antagonismo, uso de supremacia como instrumento de força, pressão ou opressão.

b) muitos pleitos de revisão costumam ser formulados de maneira genérica, sem explicitação técnica, objetiva e fundada das razões pelas quais cada insumo permite a revisão do ajuste (ou com

referência a insumos isolados, sem avaliação global do impacto sobre o contrato²²⁶).

Em um número considerável de vezes vemos pedidos com base em citações doutrinárias e jurisprudenciais genéricas, citando precedentes inaplicáveis, usando jurisprudências que são pertinentes a outras leis de regência, desacompanhados de dados técnicos, planilhas e demonstrativos, bem como desconsiderando a preexistência de uma matriz de alocação de risco que exclui a necessidade ou possibilidade do ajuste.²²⁷

c) em razão da imposição legal de fixação de uma matriz de alocação de riscos a alguns casos, somada à renitência pública de assumir responsabilidades na matriz que lhe são próprias e a imaturidade na vivência de uma distribuição de riscos, as matrizes foram sendo, historicamente, montadas de maneira desajustada, falseando uma distribuição real e equitativa de riscos, em face das quais também houve a imaturidade de não discutir no momento procedimental adequado a sua concertação (impugnação ou pedido de esclarecimentos na fase de pré-abertura de propostas).

d) em outras situações, a Administração Pública com dificuldades em honrar pagamentos, mas não podendo prescindir dos objetos, alongou as discussões de reequilíbrio para poder pagar mais por menos, postergando as diferenças de preços e as lançando a próximas gestões ou exercícios financeiros ou, até mesmo, torcendo pela prescrição ou pela desistência dos valores (e cansaço do contratado).

e) considerando que, em alguns casos, a revisão devida comporta valores numéricos expressivos, que chamam à atenção, instalou-se uma cultura de medo administrativo, obrigando a que contratados judicializem suas pretensões, mesmo que isso signifique um aumento do valor despendido (a exemplo das despesas com honorários contratuais e/ou de sucumbência, juros

e multa, custas judiciais, gastos com perícia e assistente técnico etc.).

- f) considerando a ausência adequada de provisionamento e planejamento públicos, levando à situação de indisponibilidade de reservas que levem ao efetivo pagamento, a postergação de concessões de revisão para exercícios financeiros posteriores; dentre outros fatores relevantes.

Inobstante esse seja um dos mais desgastantes capítulos, os próximos anos podem nos sinalizar a melhora dessa relação, a partir de alguns contributos, por exemplo, da nova lei geral:

- i) a existência de uma bem estruturada matriz de alocação de riscos entre as partes, capaz de antecipar as possíveis causas de desequilíbrio e a forma como podem ser resolvidas, diminuindo os espaços de discussão e imprecisão (arts. 6º, inc. XXVII, 22 e 103, com seus parágrafos);
- ii) a previsão de que o reajuste será contabilizado a partir do orçamento estimado pode diminuir defasagens de preços que forcem tensão entre as partes desde o início da relação (art. 25, §7º);
- iii) a previsão de resolução de controvérsias por mecanismos conciliatórios e pacificadores (art. 151), com uso de terceiros vocacionados;
- iv) a previsão de ser obrigação da Administração resolver, de uma vez e em um mesmo instrumento, os pedidos de revisão para a celebração de termos aditivos (art. 130), diminuindo a eternização forçosa dessas demandas;^{[228](#)}
- v) a previsão de prazo máximo de resposta aos pedidos de revisão, também findando com a eternização forçosa dessas demandas e constituindo em mora a Administração Pública (arts. 92, §6º, e 123, parágrafo único);
- vi) a impossibilidade de alteração executória-fática em desalinho com a previsão contratual, forçando a que as novas regras executórias dependam (como deveriam depender, mesmo sem

essa previsão) necessariamente da formalização de termos aditivos (art. 132), ganhando esses termos a natureza constitutiva das novas regras (e não meramente declaratórios e com efeitos repristinatórios);

vii) a ampliação das hipóteses de extinção contratual por parte do contratado, como instrumento de pressão (e alerta) à inércia administrativa (art. 137, §2º);

viii) as obrigações próprias da governança, nessas se incluindo: melhor planejamento das aquisições (o que pode diminuir o tempo entre orçamento e pagamento), reavaliação dos contratos após seu término (levando os aprendizados ao planejamento dos casos futuros), aumento dos mecanismos de diálogo e interação (o que pode contribuir fortemente na mudança de *mindset*), a realização de treinamentos periódicos (o que permite aprimorar o conhecimento e a superação dos gargalos neste artigo referidos, além do aprimoramento do *mindset*).

Não bastasse, a normatização dos procedimentos administrativos de revisão, em que pese ainda alguns abusos localizados e decorrentes de *mindsets* distorcidos, pode auxiliar em muito na objetivação e na aceleração dessas medidas.²²⁹

A revisão, vale lembrar, é excepcional, não se constituindo em uma medida genérica, automática e obrigatória em todos os contratos administrativos.

Bom seria, aliás, que ela não se mostrasse necessária.

Se sua incidência é requerida, é porque estamos diante de um excepcional desequilíbrio, oriundo de situações como:

- a) força maior, ou seja, fatos humanos ou naturais que impactaram a execução contratual, tais como tempestades, furações, guerras e outros;
- b) caso fortuito, ou seja, evento imprevisível e inevitável, tais como indisponibilidade de insumo no mercado, descontinuidade de insumo ou produto utilizado na execução, inacessibilidade do local de execução e outros;

- c) fato do príncipe, ou seja, o *exercício legítimo dos poderes de autoridade fora da relação contratual*, mas que afetam o equilíbrio dessa,²³⁰ tais como alterações tributárias, regulamentação que afeta a prestação de bens e serviços, restrições decorrentes de isolamento ou distanciamento social, vedação de importação de insumos e outros;
- d) circunstâncias imprevisíveis ou previsíveis e de consequências incalculáveis.

6.2.2.5 Os casos de *commodities* e variação cambial

Para essas últimas é necessário realçar as situações que se tornaram ordinárias e previsíveis, como é o caso da oscilação do preço das *commodities* em razão da alteração do preço de mercado, sua interligação com o preço do petróleo, da ocorrência de estiagem ou chuva que afete a produção, assim como da variação cambial e do custo de insumos regulados por moedas estrangeiras.²³¹

Todas essas situações se tornaram conhecidas das partes contratantes e necessariamente avaliáveis por essas na formulação de seus preços ou orçamentos. Portanto, a só variação cambial ou influência do custo da *commodity* (e os outros exemplos retrorreferidos) não autoriza a revisão de contratos. O que pode, no entanto, permitir que, mesmo previsível, ainda possibilite a revisão dos preços é se a oscilação foge à curva ordinária em um determinado contexto ou recorte temporal.

Há remansosa jurisprudência sobre isso e recomendações das Cortes de Contas²³² para que, somente no caso concreto e considerando circunstâncias objetivas e individualmente avaliadas, se possa concluir se a oscilação fugiu ou não à curva ordinária, de que forma isso de fato impacta o contrato ou deve alterar o preço do custo total.²³³

Inobstante os precedentes jurisprudenciais tenham se constituído em período anterior, a alteração da LINDB em 2018 pela Lei Federal nº 13.655 sedimentou essa ocorrência, impondo ao administrador público avaliar as consequências práticas de seu decidir à luz das ocorrências concretas, não impondo aos sujeitos atingidos ônus ou perdas anormais ou excessivos, além de considerar os obstáculos e dificuldades reais encontrados no período (arts. 20 a 22).

Na avaliação dessas ocorrências, também se impõe que o administrador público corretamente fundamente sua opção (pela revisão ou por sua negativa), avaliando as circunstâncias do caso concreto com todos os seus dados, deixando claro de que forma decide e de que forma sua decisão impacta o contrato:

- a) na sua sustentabilidade econômico-financeira a curto, médio e longo prazo;
- b) na possibilidade de o contrato ser executado pelo contratado;
- c) na capacidade de o contrato chegar a seu termo e alcançar eficiência.

Afinal, não se firmam contratos por mera exigência procedimental, senão para que possam alcançar os resultados pretendidos e viabilizar a execução das políticas públicas que consubstanciam (art. 37 da Constituição Federal).

6.2.2.6 O credenciamento de produtos voláteis e mercados fluidos.

Esses são aspectos que, até o momento, se tornaram clássicos na avaliação técnico-jurídica dos contratos, seus insumos e realidades.

No entanto, queremos levar à reflexão uma forma de lidar com essas contingências desde o momento do planejamento da contratação e possibilitar que, nas situações de volatilidade, já se desenhe a contratação de soluções que a pressuponham (e terminem infundáveis discussões de realinho de preços).

Com efeito, a nova lei geral de licitações trouxe uma alternativa a se considerar, que é o credenciamento de produtos voláteis e de mercados fluidos (art. 79, inc. III).

De início se diga que a nova lei geral trouxe o credenciamento à categoria de procedimento auxiliar das contratações públicas e, assim, pode propiciar um novo modo de adquirir (art. 6º, inc. XLIII): um processo licitatório para credenciar e, a partir daí, contratações diretas com os credenciados.

Para os mercados fluidos e produtos voláteis previu o credenciamento quando a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.

Nesses casos, a Administração deverá *registrar as cotações de mercado vigentes no momento da aquisição e não no momento do credenciamento ou da contratação* (para operar durante todo o tempo do contrato), ou seja, sem a prévia definição de preços e com a aceitação de preços dinâmicos²³⁴ (também chamados de preços em tempo real ou preços algorítmicos).

Isso porque os preços podem mudar em razão de demanda, oferta, preço da concorrência, preços de produtos substitutos ou complementares ou, até mesmo, de cliente para cliente em razão de seus hábitos de compra. Podem alterar em razão de sazonalidade de produto, região demográfica ou área e rota de entrega, histórico de compras, proximidade da data de vencimento, volume de estoque e outros. Essa é uma hipótese, inclusive, a preços fortemente impactados por variação cambial.

Estarão os fornecedores aptos a prestar o objeto à Administração e, no momento da efetiva aquisição, os preços serão cotados com os credenciados/contratados e verificada a melhor hipótese naquele contexto, diminuindo-se, assim, o *custo transacional burocrático*.

É possível, inclusive, que a Administração Pública, gerenciando corretamente seus estoques, estude a melhor época de adquirir os produtos, aproveitando-se da volatilidade do mercado. Mais responsável, inclusive, que adote o comportamento de estoques inteligentes e de aquisições dinâmicas que, em lugar de criticar a fluidez do mercado, se aproveite de sua ocorrência.

Isso significa algumas alterações significativas, a saber:

- a) a Administração Pública terá, em seus *Estudo Técnico Preliminar* e *Termo de Referência*, diagnosticado e previsto que aquele caso específico é de mercado fluido e que a melhor hipótese é apurar o preço no momento da aquisição;
- b) com isso, a pesquisa prévia de preços que fará, na fase interna de seu procedimento, será tão somente para comprovar a oscilação constante dos preços e que não há uma estabilidade de valor que permita orçar tão antecipadamente e garantir que as contratações futuras possam se dar por preços estabilizados e sem revisões constantes;
- c) a dotação orçamentária e o provisionamento que a Administração Pública fará não significarão limite máximo de aquisições, podendo existir aportes posteriores (inclusive por apostila) na medida em que as oscilações de preço sinalizarem a necessidade de sua ocorrência;
- d) mesmo que o orçamento estimado inicialmente exista, ele não vincula a oferta dos credenciados, já que o efetivo preço só se apura ao tempo da aquisição, servindo esse orçamento apenas como uma referência para dotação orçamentária e provisionamento provisórios;
- e) os contratos não terão preços unitário e global, sendo o preço averiguado ao tempo das aquisições com os contratados/credenciados, acostumando-se a essa checagem ao tempo da efetiva aquisição.

Essa hipótese é possível, ao menos em tese, em objetos de TIC, competindo à Administração Pública verificar, no caso concreto, se

as oscilações são significativas o bastante para se aplicar o conceito e fazer essa escolha.

Considerando que esse tipo de credenciamento, em que pese a nova lei geral tenha estabelecido bases mínimas para sua ocorrência (art. 79, parágrafo único), deverá ter a sua vivência conforme regulamentação do órgão público interessado, competindo ao mercado acompanhar a edição dessa regulamentação, contribuir para a sua melhoria e observar suas determinações.

A recomendação que se dá é que as empresas de TIC parem de olhar apenas os editais de licitação e comecem a acompanhar, com genuíno interesse, as regulamentações editadas pelos órgãos públicos. Podendo contribuir na melhora dessas, devem atuar concomitantemente às suas discussões e edições, evitando-se a alegação surda e tardia ao tempo da publicação dos editais.

6.2.2.7 Conclusão

O primeiro ponto conclusivo é compreender que reequilíbrio econômico-financeiro não é remodelar a tratativa inicial e apor novas bases à relação das partes contratantes. Ao contrário: é ressuscitar a tratativa inicial, revigorando as condições efetivas em que se deu.

Essa compreensão é a matiz que pode gerar a revisão do *mindset* ultrapassado que tem, toxicamente, prejudicado as relações contratuais, de ambas as partes.

De fato, se a relação não será remodelada, mas apenas reavivada, proceder ao reequilíbrio é do interesse de ambos, rumo à potência de o contrato produzir os resultados desejados.

O segundo ponto conclusivo é compreender que nem todas as vicissitudes que afetam as partes vão permitir o reequilíbrio, guardando-se respeito ao que integra o risco (e, portanto, a

responsabilidade) de cada parte, mesmo que se possa constantemente amadurecer na distribuição equitativa deste.

O terceiro ponto conclusivo é compreender que existem outras formas de adquirir e que melhor expressam as oscilações pelas quais passam o produto ou o mercado no caso concreto e, com isso, ao invés de estressar a relação das partes na vivência do contrato, é possível modificar, previamente, na fase de planejamento, a solução mais adequada de relacionamento que pode ser estabelecida.

Nessa esteira, sugere-se verificar, nas contratações de TIC, os casos de produtos voláteis e mercados fluidos e ampliar o espectro de utilização dos credenciamentos na nova lei geral de contratações públicas. Paralelamente, que as entidades de TIC se atentem à maneira pela qual essas hipóteses estão sendo regulamentadas e, em sendo possível, contribuam em sua construção.

6.3 Alteração contratual

Christianne de Carvalho Stroppa

Sobre a execução dos contratos, ressalta-se da Lei nº 14.133/2021, dentre as cláusulas identificadas como prerrogativas da Administração Pública, expressamente enumeradas no art. 104, a temática atinente à alteração contratual (inciso I), à extinção dos contratos (inciso II), bem como o tema da sanção (inciso IV), cuja sistematização merece um destaque.

Em complemento, utiliza-se, quando possível, ou seja, quando expressamente referida a temática abordada, a Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022, que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP do Poder Executivo Federal.

O dever de fiel execução dos contratos decorre da circunstância de que eles tornam concreto o interesse público, objetivam a subjetividade do pacto e buscam assegurar os direitos e obrigações; para tanto, devem utilizar uma linguagem clara, precisa e objetiva e prever modelos de execução e gestão contratual (art. 6º, incisos XII e XXIII).²³⁵

Quando a Administração Pública formaliza um contrato, tem por objetivo que ele seja plena e efetivamente adimplido pelas partes, em especial, nos termos inicialmente pactuados. Dessa forma, uma vez definida a especificação do objeto a ser contratado, durante a vigência do pacto formalizado, sua alteração pode ocorrer, entretanto, deverá atentar para as condições indicadas nos arts. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021.

A possibilidade de *alteração dos contratos* tem sua compostura e extensão qualificadas no art. 124, de forma muito semelhante ao que já estava previsto na Lei nº 8.666/1993:

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I – unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;
- b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

II – por acordo entre as partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

§2º Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II do *caput* deste artigo às contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado.

De forma sistemática, podemos indicar que há *duas grandes espécies de alteração*, cujas justificativas devem estar evidenciadas nos autos do processo de contratação:

- (i) a primeira, mantida como prerrogativa da Administração Pública (inciso I, art. 104), implica a possibilidade de *alteração unilateral* dos contratos administrativos: e
- (ii) decorrente de consenso entre as partes, está a segunda espécie. A denominada *acordo entre as partes* deve atender aos seguintes requisitos:
 - a) Tendo como fundamento a necessidade de adequação do interesse público, decorre de imposição do ente público, não sendo necessária a expressa concordância do contratado.
 - b) Se limita à modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos (alteração qualitativa) ou à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto (alteração quantitativa).
 - c) Fernando Vernalha Guimarães enumera duas vantagens em se utilizar o instituto da alteração qualitativa, caso haja necessidade. A primeira delas refere-se à melhoria do atendimento ao interesse público, pelo aprimoramento técnico da execução. A segunda está na salvaguarda do resultado que se pretendia obter originariamente com a contratação, diante da possibilidade de prejuízos ao interesse público, decorrentes das situações imprevistas que atingiram a relação contratual.²³⁶

- d) Sobre a diferenciação entre modificações unilaterais qualitativas e quantitativas, apresenta as lições de Simone Zanolello de Oliveira que, se valendo das lições de Gabriela Verona Pécio,^{[237](#)} para quem é necessário “verificar qual o interesse público que rege a atuação administrativa: se há modificação das características do objeto (sem lhe alterar a essência), a modificação será qualitativa; se há modificação apenas das quantidades (dimensão), ela será quantitativa. No entanto, a autora também observa que: ‘da qualitativa podem decorrer o aumento ou a diminuição de quantidades de produtos ou insumos, mas apenas como consequência da modificação do projeto ou das especificações, pois o objetivo principal não recai sobre o aumento ou diminuição de quantidades’. Em razão disso, não podemos deixar de considerar que modificações qualitativas podem resultar em modificações quantitativas”.^{[238](#)}
- e) Para Ronny Charles, a realidade da Administração Pública demonstra que, na prática, as alterações qualitativas também podem gerar alterações quantitativas no valor contratual, se caracterizando como uma alteração qualitativo-quantitativa.^{[239](#)}
- f) Independentemente de ser qualitativa ou quantitativa, deve estar limitada ao montante de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, serviços ou nas compras (art. 125).
- g) No caso de reforma de edifício ou de equipamento, de forma excepcional, admite o montante de 50% (cinquenta por cento) (art. 125).
- h) O primeiro limite para a alteração do contrato decorre do objeto da contratação. Referido limite é também de natureza constitucional, na medida em que o art. 37, XXI, da Constituição Federal preceitua que as contratações públicas deverão ser precedidas de licitação ou de processo de contratação direta.^{[240](#)} Como consequência, essa alteração não pode transfigurar o objeto da contratação (art. 126), ou seja, deve estar contido nos estritos

termos do que foi pactuado, porquanto, a depender da alteração, seria possível transformar a natureza do objeto em algo distinto daquilo que fora licitado.

- i) Quando da execução contratual poderá ser identificada a necessidade de inclusão de materiais, insumos, serviços, inclusive de engenharia, ou obras novas, imprevistos no contrato original. Certo, então, que o contrato não contempla preços de referência para os novos itens que devem ser incorporados à contratação. A Administração Pública deverá identificar no mercado específico o preço de referência para os insumos, materiais, serviços ou obras que pretende incluir no encargo contratual quando da alteração, utilizando-se dos parâmetros fixados no art. 23. A definição dos preços a serem incorporados ao contrato será feita “por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei” (art. 127).
- j) Como já previsto na Lei nº 8.666/1993 (§1º, art. 65), nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, a Administração Pública deverá realizar o pagamento pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo, desde que devidamente comprovados, caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão (art. 129).
- k) Independentemente de se tratar de alteração qualitativa ou quantitativa, ocorrendo o desequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, com expresse fundamento constitucional (inciso XXI, art. 37), terá o contratado direito ao reequilíbrio, porquanto “constitui uma ‘precificação’ dos encargos em face das oportunidades de ganhos previstos no regime remuneratório ao contratado”²⁴¹ (art. 130).
- l) A formalização do termo aditivo se apresenta, em regra, como condição para que o contrato continue sendo executado (arts. 130

e 132).

Destaca Irene Patrícia Nohara que a “*alteração ou modificação unilateral dos contratos fundamenta-se no fato de os interesses públicos serem variáveis e indisponíveis*. Por conseguinte, pode a Administração Pública instabilizar, fundada no *ius variandi*, o contrato, para que haja melhor persecução das finalidades públicas, desde que ela respeite os direitos do contratado”.²⁴²

Como decorrência, por serem alterações impostas pela Administração Pública, sua formalização independe de concordância – até certo ponto – do particular contratado. Destarte, deve sempre estar pautada em *justificativa plausível*, o que implica a necessidade de existir adequada motivação da alteração, evidenciada pela superveniência de motivo justificador.

Nessa linha, aponta Marçal Justen Filho que “cabe demonstrar a necessidade da alteração, a adequação da solução cogitada, a economicidade da alternativa, e assim por diante”.²⁴³

Como já indicado pelo Tribunal de Contas da União, os acréscimos e diminuições não se compensam. Ou seja, se um contrato hoje for aditivado em 15% (quinze por cento), os aditivos que aumentem ou diminuam ficarão limitados a 10% (dez por cento); por sua vez, tendo sido aditivado em 25% (vinte e cinco por cento), os aditivos ficarão limitados a 0% (zero por cento).

Em razão desse fato, “os limites mencionados nos §§1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 devem ser verificados, separadamente, tanto nos acréscimos quanto nas supressões de itens ao contrato, e não pelo cômputo final que tais alterações (acréscimos menos decréscimos) possam provocar na equação financeira do contrato” (Acórdão nº 1.733/2009 – Plenário).²⁴⁴

Por outro lado, quando a alteração afeta diretamente o conjunto de cláusulas denominadas econômicas (garantia, regime de execução, modo de fornecimento, forma de pagamento, caso

fortuito, força maior, fato do príncipe, fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis), já que afetam diretamente o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente fixado entre as partes, a concordância do contratado se faz obrigatória.

Tendo o reequilíbrio o objetivo de “restabelecer a condição anterior à ocorrência dos aditivos contratuais, utilizando como referência a representação do contrato em estado de equilíbrio”,²⁴⁵ mesmo que o contrato administrativo seja extinto, tal circunstância não representará óbice para que seja reconhecido o direito ao equilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que o contratado receberá uma indenização por meio de termo indenizatório. Deve-se atentar, apenas, que o pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deve ser realizado ainda durante a vigência do contrato, inclusive, antes de eventual prorrogação, para os contratos de serviços e fornecimentos contínuos (art. 131).

Na específica hipótese de os contratos envolverem a prestação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, o reequilíbrio decorrerá de suas repactuações, nos termos detalhados nos parágrafos do art. 135.

A regra sobre transfiguração do objeto (art. 126) também se aplica à alteração por acordo entre as partes, especialmente se invocados como fundamentos os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica (art. 5º).

Para que as alterações contratuais possam ser executadas pelas partes, independentemente de serem unilaterais ou por acordo, devem ser antecedidas de formalização por termo aditivo (art. 132), devendo o órgão ou entidade providenciar sua publicação, em sítio eletrônico de fácil acesso, em até 30 (trinta) dias após sua assinatura (inciso II, art. 34 da Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022).

De forma excepcional, desde que expressamente justificado pela Administração Pública, será possível antecipar os efeitos do aditamento, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

A possibilidade de ser dispensada a formalização de termo aditivo, formalizando-se os registros por simples apostila, decorre de situações que não caracterizam alteração do contrato (art. 136), tais como:

- I – variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato;
- II – atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato;
- III – alterações na razão ou na denominação social do contratado;
- IV – empenho de dotações orçamentárias.

A instrução processual necessária para que as alterações sejam processadas, inserida na atividade de monitoramento da execução do contrato, deve ficar a cargo do gestor do contrato (art. 33, inciso I, alíneas “d” e “e”, da Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022).

6.4 Extinção dos contratos administrativos²⁴⁶

Christianne de Carvalho Stroppa

Sobre a temática da execução dos contratos, o art. 115 possui o mesmo conteúdo do art. 66 da Lei nº 8.666/1993: o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

O dever de fiel execução dos contratos pressupõe que cheguem a termo de forma satisfatória tanto para a Administração contratante quanto para o contratado. Assim, sua extinção, em especial, de

forma antecipada, se coloca como situação excepcional, merecedora de cuidados por parte do legislador.

Novidade na lei é a referência à necessidade de expedição de regulamento para especificar os procedimentos e critérios para verificação da ocorrência dos motivos justificadores da extinção do contrato. Trata-se de previsão que não existe na Lei nº 8.666/1993, ademais, ao permitir que sejam editados atos normativos pelas diversas esferas de governo, abre-se espaço para práticas distintas.

Ponto importante também, como já apontado, é que, nos moldes do contido no art. 131, a extinção do contrato não se coloca como um impedimento para que se reconheça o direito do contratado ao reequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que a indenização será concedida por meio de termo indenizatório.

O art. 137 indica: (i) a necessidade de motivação formal nos autos do processo; (ii) a plena garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa; e (iii) o enquadramento nas hipóteses justificadoras.²⁴⁷

A essas regras se somam os comandos da *LINDB*, especialmente diante do dever de ponderação das consequências fáticas, práticas e jurídicas do decidir e de ponderação de possíveis soluções alternativas.

As situações que podem levar à extinção podem ser assim classificadas:

- (a) comportamentos atribuíveis ao contratado (art. 137, “caput”, incisos I a IV, VI, VII e IX);
- (b) comportamentos atribuíveis à Administração (art. 137, incisos I a V);
- (c) razões de interesse público justificadas pela máxima autoridade do contratante (art. 137, “caput”, inciso VIII); e
- (d) ocorrência de caso fortuito ou força maior, desde que impeditivos da execução do contrato (art. 137, “caput”, inciso

V).²⁴⁸

São comportamentos atribuíveis ao contratado:

- (i) não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;
- (ii) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;
- (iii) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
- (iv) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
- (v) atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
- (vi) atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;
- (vii) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

Na hipótese dos itens (v) e (vi), as situações ensejadoras da extinção podem ocorrer com ou sem culpa do contratado, atraindo, em cada caso, as consequências respectivas.²⁴⁹ Ambas as hipóteses, como se verifica do §5º, art. 25,²⁵⁰ podem ser previstas como de responsabilidade do contratado; por sua vez, o art. 124, §2º,²⁵¹ reconhece que podem existir circunstâncias impeditivas, que independem da vontade e da atuação do contratado.²⁵²

Quando da ocorrência das demais situações, está a Administração Pública autorizada a extinguir unilateralmente o contrato administrativo, invocando a culpa do contratado. As consequências estão expressas no art. 139.

Saliente-se que os emitentes de garantias de que cuida o art. 96 deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, conforme prevê o art. 137, §4º. A medida é necessária porque para além da aplicação de sanção poderá ocorrer a execução das garantias.²⁵³

Também é possível a extinção unilateral do contrato nas hipóteses dos incisos V (caso fortuito ou força maior) e VIII (razões de interesse público), situações em que não há culpa do contratado.

São comportamentos atribuíveis à Administração:

- (i) supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125;
- (ii) suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;
- (iii) repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;
- (iv) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;
- (v) não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas

a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

Percebe-se uma redução dos prazos de tolerância com atrasos e suspensões da Administração Pública, se promovida uma comparação com os incisos XIV e XV do art. 78 da Lei nº 8.666/1993.²⁵⁴

A diferença mais significativa está na expressa referência ao *direito à extinção do contrato* pelo contratado, quando da ocorrência de uma das hipóteses arroladas no §2º do art. 137.²⁵⁵ Ou seja, é possível afirmar que a Lei nº 14.133/2021 cria situação de extinção unilateral a favor do contratado, em decorrência de comportamentos atribuíveis à Administração Pública,²⁵⁶ isso implica dizer que a Lei “adotou um tratamento mais severo para hipóteses de rescisão por inadimplemento da Administração”.²⁵⁷

Como anotado na Lei nº 8.666/1993, o contratado, apenas após o transcurso dos prazos nela referidos (atraso de pagamento superior a 90 dias, por exemplo), é que poderia pleitear a paralisação das atividades e a rescisão do ajuste, invocando, para tanto, a *exceptio non adimpleti contractus*.²⁵⁸ Não se verificava hipótese de rompimento de vínculo unilateralmente pelo contratado, posto que dependente da aquiescência da Administração Pública.

Situação diversa é a indicada no §2º do art. 137 da Lei nº 14.133/2021, posto que, ocorrendo uma das hipóteses descritas nos seus incisos, bem como evidenciado que não estão presentes as exceções descritas no §3º do mesmo dispositivo, basta que o contratado comunique, formal e motivadamente, sua vontade em extinguir o contrato, não competindo à Administração Pública qualquer juízo de valor sobre o solicitado. Trata-se de expressão de competência vinculada da Administração Pública.²⁵⁹

Certamente, não há posição uniforme na doutrina. No sentido de se tratar de direito do contratado, invoca-se que a Nova Lei de

Licitação não deixou lacunas acerca desse assunto. O contratado, ou seja, aquele que presta serviços para qualquer órgão público, também tem o direito de extinguir o contrato quando se sentir lesado.

Destaca-se, todavia, que à luz do §3º do mesmo art. 137, para as hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do §2º deste artigo,²⁶⁰ deve se considerar que:

- a) não serão admitidas as hipóteses propostas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;
- b) garante-se ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A Administração Pública poderá extinguir o contrato por razões de interesse público desde que devidamente justificadas pela máxima autoridade. Não se ignora que o contrato pode não mais interessar à Administração Pública desde que se indique uma razão real e sólida. Não se permitem caprichos. Não se permite que usando essa prerrogativa se pretenda, por exemplo, romper o contrato para em seguida convocar o remanescente, à luz do §7º do art. 90, para beneficiar um apadrinhado.

Deve ser recordado que o *caput* do art.137 menciona expressamente o dever de previamente ofertar ampla defesa e contraditório. Inclusive porque o contratado pode trazer aos autos informações que contribuam para o aprimoramento da decisão administrativa. Eventualmente, a fala do contratado pode ajudar a enxergar uma via alternativa menos traumática que a rescisão. Alterar o contrato, nos limites autorizados, pode se revelar mais adequado, por exemplo.

O pagamento de indenização, mesmo que silente a Lei, será devido desde que os prejuízos estejam regularmente comprovados, aplicando-se as mesmas consequências previstas nos incisos, do §2º, art. 138.

A ocorrência de caso fortuito ou força maior somente será aceita como motivo da extinção se ficar evidenciado o impedimento da execução do contrato.²⁶¹

Pode, então, ser invocada tanto pela Administração quanto pelo contratado, sendo necessário e preferencial o consenso entre as partes, para formalização dessa extinção. Entretanto, a judicialização por parte do contratado não pode ser descartada, já que não há obrigatoriedade do esgotamento da esfera administrativa para que o contrato seja extinto.

Também nessa categoria de extinção contratual se enquadra a onerosidade excessiva, prevista no inciso II, §2º, art. 22 da Lei nº 14.133/2021, já que significa “a constatação de uma ocorrência independente da vontade das partes, que gera efeitos de extrema gravidade quanto à execução da prestação assumida por uma das partes, produzindo a inviabilidade material ou econômica quanto à execução do contrato. Diante de tal cenário, o contrato deverá ser extinto, sem que se configure o inadimplemento de qualquer das partes. O particular será remunerado pelo que tiver executado até a data em que se configurou o evento danoso e o contrato será resolvido sem sancionamento para os contratantes”.²⁶²

A extinção poderá ser:

- pelo cumprimento do objeto contratual – forma de extinção natural;
- pelo advento do termo final – em especial nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos;

- determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta (*non venire contra factum proprium*);
- consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; e
- determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

Discussão interessante envolve a extinção de contratos “velhos”. Com esteio no contido do art. 191 da Lei nº 14.133/2021, com a redação dada pela MP nº 1.167/2023, até o dia 29 de dezembro de 2023, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 (Pregão) e arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462/2011 (RDC), e a opção escolhida deverá ser expressamente indicada no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as demais.

É o que doutrinariamente se denomina ultratividade da lei no tempo,²⁶³ porquanto situações iniciadas sob a égide da lei anterior e que se perpetuam na sua existência jurídica sob o período de vigência temporal da lei nova. Dessa forma, a ultratividade implicará a exclusão dos efeitos imediatos e futuros da lei em vigor, no que tange particularmente a situações ou relações em curso no momento da alteração legislativa.²⁶⁴

Como consequência, possível afirmar que os contratos formalizados com fundamento nas citadas legislações continuarão sendo por elas regidas mesmo após o dia 30 de dezembro de 2023.

Quando da extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo, com o fito de dar efetividade aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV), sem escusar, ainda, da observância das regras da LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/1942, com as alterações trazidas pela Lei nº 13.655/2018).

Superando o modelo trazido pela Lei nº 8.666/1993, a Lei nº 14.133/2021 indica uma preferência pela extinção consensual do contrato, desde que haja interesse da Administração Pública. Poderá também fazê-lo por conciliação, mediação (ambas disciplinadas pela Lei nº 13.140/2015) ou por comitê de resolução de disputas. A utilização dos meios alternativos de resolução de disputas encontra-se prevista nos arts. 151 a 154. No tocante à disciplina do uso da arbitragem, o tema é tratado pela Lei nº 9.307/1996.

Essa possibilidade de uso de meios extrajudiciais, não obstante o silêncio da Lei nº 8.666/1993, foi resolvida pelo Enunciado nº 10, aprovado na Plenária da I Jornada de Direito Administrativo, pelo Conselho da Justiça Federal: “Em contratos administrativos decorrentes de licitações regidas pela Lei nº 8.666/1993, é facultado à Administração Pública propor aditivo para alterar a cláusula de resolução de conflitos entre as partes, incluindo métodos alternativos ao Poder Judiciário como mediação, arbitragem e *dispute board*”.

Sobre o limite para a utilização da extinção consensual, sob a égide da Lei nº 8.666/1993, há entendimento no sentido de que não pode ser utilizada nas situações em que seria cabível a extinção unilateral. “Nesse sentido, o TCU, em acórdãos relatados pelo Ministro Benjamim Zymler, entendeu que a extinção amigável do contrato ‘tem aplicação restrita e não é cabível quando configurada outra hipótese que dê ensejo a rescisão unilateral ou anulação do ajuste’ e, também, que ela ‘não é medida adequada para solucionar contratação com superestimativa de quantitativos’.”²⁶⁵ Trata-se de

raciocínio que pode ser aplicável também ao novo regime da Lei nº 14.133/2021”.²⁶⁶

Dentre as consequências da extinção decorrente de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. De maneira expressa, a Lei faz alusão ao direito a:

- devolução da garantia;
- pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; e
- pagamento do custo da desmobilização.

Necessário que esses direitos sejam efetivamente garantidos ao contratado.

Sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, a lei prevê as seguintes consequências:

- a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração; e
- b) ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade. O ato administrativo a ser expedido deverá ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado, do secretário estadual ou do secretário municipal competente, conforme o caso.
- c) execução da garantia contratual para: (i) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; (ii) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; (iii) pagamento das multas devidas à Administração Pública; e (iv) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;
- d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

A utilização das medidas de assunção imediata do contrato e da ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados está inserida no âmbito da competência discricionária da Administração Pública, entretanto somente se justificam se a finalidade for dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

No caso de ter exigido garantia, nas modalidades previstas no art. 96, os emitentes deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

Por oportuno, importante indicar que a NLLC prevê outra hipótese de extinção do contrato, vinculada a não disponibilidade de crédito orçamentário para sua continuidade ou quando a Administração Pública entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem (art. 106, inciso III e §1º). Nesse caso, afora não gerar qualquer direito de indenização ao contratado, está condicionada a um critério temporal,²⁶⁷ qual seja:

- a) a extinção ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
- b) caso a notificação da não continuidade do contrato ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

6.5 Sanções

Christianne de Carvalho Stroppa

Antes de falar propriamente da sanção, convém distingui-la da infração. A infração é a conduta, o comportamento antijurídico, contrário à previsão legal, que, quando praticada, gerará uma consequência ao agente. A sanção é o ato punitivo que a

Administração Pública impõe, em decorrência de uma infração, após regular procedimento administrativo de apuração.

Ressalta-se que infração e sanção administrativa são temas indissoluvelmente ligados.

A infração é prevista em uma parte da norma, e a sanção em outra parte dela. Assim, o estudo de ambas tem que ser feito conjuntamente, pena de sacrifício da inteligibilidade quando da explicação de uma ou de outra.

Infração administrativa é o descumprimento voluntário de uma norma administrativa para o qual se prevê sanção cuja imposição é decidida por uma autoridade no exercício de função administrativa – ainda que não necessariamente aplicada nesta esfera.

Reconhece-se a natureza administrativa de uma infração pela natureza da sanção que lhe corresponde, e se reconhece a natureza da sanção pela autoridade competente para impô-la.

[...]

Sanção administrativa é a providência gravosa prevista em caso de incursão de alguém em uma infração administrativa cuja imposição é da alçada da própria administração.²⁶⁸

Feita essa distinção, destaca-se que a finalidade da sanção administrativa não é a de conceder uma vantagem, mas sim restringir a esfera de direitos daquele que sofre sua imposição.²⁶⁹ Entretanto, não se pode afirmar que sua finalidade é sempre a de castigar o infrator, ao contrário, correto dizer que tem por objetivo “intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo”.²⁷⁰

As normas relativas às infrações administrativas estão contidas no art. 155, compreendendo (i) infrações leves (dar causa à inexecução parcial do contrato); (ii) infrações médias (dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; dar causa à inexecução total do contrato;²⁷¹ deixar de entregar a documentação

exigida para o certame; não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado); e (iii) *infrações graves* (apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013).

Cediço que a Lei nº 14.133/2021 traz disciplina especial acerca do regime sancionatório, em seus arts. 155 a 163, quais sejam: a vinculação das infrações às sanções, a previsão de regras de procedimento, a desconsideração da personalidade jurídica, trazem requisitos de reabilitação, acionam a assessoria jurídica a se manifestar em pelo menos 3 (três) ritos procedimentais,²⁷² bem como estabelecem como direito do licitante e do contratado a possibilidade expressa de elaboração de defesa prévia, alegações finais, recurso administrativo (art. 166) e pedido de reconsideração (art. 168) durante o processo de responsabilização.²⁷³

Nos termos do art. 19, inciso IV, da Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022, o Modelo de Gestão do Contrato definirá de forma clara e detalhada as sanções administrativas, nos termos dos arts. 155 a 163 da NLLC, observando:

- a) vinculação aos termos contratuais;
- b) proporcionalidade das sanções previstas ao grau do prejuízo causado pelo descumprimento das respectivas obrigações;
- c) as situações em que advertências serão aplicadas;

- d) as situações em que as multas serão aplicadas, com seus percentuais correspondentes, que obedecerão a uma escala gradual para as sanções recorrentes;
- e) as situações em que o contrato será rescindido por parte da Administração devido ao não atendimento de termos contratuais, da recorrência de aplicação de multas ou outros motivos;
- f) as situações em que a contratada terá suspensão a participação em licitações e impedimento para contratar com a Administração;
- e
- g) as situações em que a contratada será declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração, conforme previsto em Lei.

Em caráter complementar, o Item 7.4 do Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022 indica que a Equipe de Planejamento da Contratação deve garantir que o contrato contenha sanções administrativas pelo descumprimento de cada um dos requisitos de segurança da informação e de privacidade que forem especificados.

Sobre *as espécies de sanções*, a NLLC extingue a sanção de suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 anos constante do art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, prevendo *a advertência, a multa, o impedimento de licitar e contratar da Lei nº 10.520/2002 – Lei do Pregão – e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 156).*

Importante *regra de dosimetria sancionatória* consta do §1º, art. 156, já que indica “regra de fixação de aparatos para garantir a justa punição e o devido processo legal, a partir da necessidade de análise de requisitos de proporcionalidade, observando o caso concreto, a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes, os danos que dela se derem e a implantação ou aprimoramento de programa de integridade (normas em sua maioria já destacadas em leis esparsas, editais e jurisprudência). É

um importante norteador do gestor público na instituição de regulamento próprio para a condução de processos administrativos sancionadores”.²⁷⁴

Os §§2º, 3º, 4º e 5º do art. 156 tratam da vinculação da infração ao tipo de sanção a ser aplicada. Ou seja, expressamente comunica a infração ocorrida com a sanção a ser passível de aplicação pelo gestor, oferecendo transparência, razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das sanções, facilitando, e muito, a dosimetria das sanções. Dificuldade hoje vista como uma das piores para avaliação no processo sancionador.

Sobre o procedimento sancionador em si, a NLLC não define o rito para aplicação da advertência, apenas condicionando sua incidência exclusivamente à hipótese de inexecução parcial do contrato e não justificar penalidade mais gravosa.²⁷⁵

Acerca da multa prevista no art. 156, inciso II e §3º, indica como requisitos:

- (i) o cálculo deve ser indicado no edital ou contrato;
- (ii) não pode ser inferior a 0,5%, nem superior a 30% do valor do contrato;
- (iii) pode ser aplicada em todas as infrações;
- (iv) incide de forma cumulativa com as demais sanções;
- (v) previamente a sua incidência, deve ser facultada a defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação (art. 157).

Por sua vez, a multa, de caráter moratório, prevista no art. 162, também deve ser prevista no edital ou no contrato, podendo ser convertida em compensatória, acarretar a extinção unilateral do contrato e ser cumulada com as demais sanções.

A aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar apresenta como requisitos (art. 156, inciso III e §4º):

- (i) deve corresponder às infrações indicadas nos incisos II a VII, do art. 155;

- (ii) tem como âmbito de incidência a Administração direta e indireta do ente federativo que aplicou a sanção;
- (iii) prazo máximo de incidência: 3 (três) anos.

A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, por sua vez, tem como requisitos (art. 156, inciso IV e §5º);

- (i) deve corresponder às infrações indicadas nos incisos VIII a XII, do art. 155;
- (ii) aplicável como qualificadora nas infrações descritas nos incisos II a VII, do art. 155;
- (iii) tem como âmbito de incidência a Administração direta e indireta de todos os entes federativos;
- (iv) prazo de incidência: mínimo de 3 (três) e máximo de 6 (seis) anos.

O art. 158, modernizando o tratamento do processo sancionatório, regulamenta: a necessidade de instauração de processo de responsabilização; de constituição de comissão formada por no mínimo 2 servidores estáveis em caso de órgão composto por servidores estatutários ou, no caso de órgão não composto por servidores estatutários, formada de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade; de providências de intimação para manifestação do licitante ou contratado em 15 dias úteis; da oportunidade de solicitação do licitante ou contratado para produzir provas; e, do deferimento do pedido de produção de provas ou com provas juntadas pela comissão, o dever de proporcionar ao interessado a apresentação de alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Reforçando que a obrigatoriedade de instauração de processo e de designação de comissão é retratada para apenas as sanções restritivas de licitar e contratar (impedimento e suspensão).

Ainda, nas inovações, o art. 160 formaliza a desconsideração da personalidade jurídica, destacando que poderá ser desconsiderada

sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

A última previsão em matéria sancionadora é a do art. 163, que prescreve regras sobre a reabilitação, antes pouco tratada na Lei nº 8.666/1993 e praticamente não utilizada em razão de escassa previsão normativa e dificuldade de compreensão do procedimento. A possibilidade de reabilitação está ligada à necessidade da observância de exigências cumulativas, sendo a especial delas a obrigatoriedade de transcurso mínimo de 1 ano da sanção de impedimento e de 3 anos no caso da aplicação da sanção de inidoneidade. Ou seja, a reabilitação se mostra possível tanto para o caso da imposição da sanção de impedimento como para a sanção de declaração de inidoneidade, desde que se tenha cumprido, entre outros, com os prazos mínimos de sanção estipulados. Por conseguinte, prevê que para a utilização do instituto exista análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo sobre o cumprimento dos requisitos de reabilitação, a reparação integral do dano causado, o pagamento da multa e o cumprimento de demais condições previstas no ato punitivo.^{[276](#)}

Finalizando sobre as novidades, importante papel da assessoria jurídica também é exigido previamente à aplicação da sanção de declaração de inidoneidade, além, é claro, de seu papel junto à decisão de desconsideração da personalidade jurídica e o cumprimento dos requisitos de reabilitação, conforme já destacado.

A instrução processual necessária para a eventual aplicação de sanções, bem como as providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização e o encaminhado da indicação de sanções para a área administrativa, inseridas na atividade de monitoramento da execução do contrato, devem ficar a cargo do Gestor do Contrato (art. 33, inciso I, alíneas “e”, “i” e “m” da Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022).

[205](#) “O acompanhamento e fiscalização do contrato é instrumento poderoso de que o gestor dispõe para defesa do interesse público. É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos” (TCU. Orientações).

[206](#) A Administração tem o poder-dever de nomear o “Fiscal do Contrato” (TCU, Acórdão nº 212/2009, 2ª Câmara).

[207](#) Há que se ter um fiscal para cada contrato (Acórdão nº 3156/09).

[208](#) O TCU recomenda que o profissional designado para ser fiscal deverá ter tempo hábil suficiente para O desempenho das funções a ele confiadas (TCU, Acórdão nº 299/2007).

[209](#) O TCU recomenda que os órgãos e entidades públicas devem ter cuidado para não designar um único servidor para A função de fiscalizar mais de um contrato, evitando-se sobrecarga de trabalho e ineficiência na execução da tarefa (TCU, Acórdão nº 38/13).

[210](#) A responsabilidade dos fiscais da execução do contrato administrativo. *Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP*, Belo Horizonte, ano 10, n. 120, dez. 2011.

[211](#) No *Caderno ENAP*, que trata da fiscalização de contratos, consta entendimento do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão permitindo a designação de servidores temporários, contratados pela Lei nº 8.745/93, para atuarem como fiscais de contratos.

[212](#) Acórdão nº 2.917/2010 – Plenário, Rel. Min. Valmir Campelo.

[213](#) Nesse sentido já se manifestou o TCU no Acórdão nº 4/2006.

[214](#) Acórdão nº 2.917/2010 – Plenário, Rel. Min. Valmir Campelo.

[215](#) Essa é a recomendação do TCU (Acórdão nº 299/2007).

[216](#) A responsabilidade dos fiscais da execução do contrato administrativo. *Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP*, Belo Horizonte, ano 10, n. 120, dez. 2011.

[217](#) Rel. Min. Raimundo Correio.

[218](#) Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Lei nº 12.376/2010.

[219](#) A título de exemplo, a doutrina: a) “na majoração de preços iniciais, destinada a compensar a inflação ou elevações de mercado, decorrente de desvalorização de moeda ou aumento geral de custos durante o período de execução contratual”, sem que isso implique aumento real da lucratividade do contratado. ZANATTA, Luciana; REBELO, Marina de Souza. *Manual de Contratos de Serviços Terceirizados*. 1. ed. Santa Catarina, 2009; b) “o *quantum debeatur* não é alterado. Pelo reajuste, conserva-se íntegro”. FIGUEIREDO, Lúcia Valle. *Curso de direito administrativo*. 3. ed. São Paulo.

[220](#) Recomenda-se conhecer a lista de sugestões a respeito de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos que está disponível na seguinte obra eletrônica: PICININ, Juliana; FORTINI, Cristiana *et al.* *Tomo 11: reequilíbrio econômico-financeiro apud A nova lei de*

licitações: Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. São Paulo: Brasinfra, 2022. Disponível em: <http://brasinfra.com.br/biblioteca/Tomo%2011%20-%20Reequil%C3%ADbrio%20econ%C3%B4mico-financeiro.pdf>. Acesso em: 6 maio 2023. Outros tomos estão disponíveis eletronicamente e que interessam ao conhecimento da nova lei: PICININ, Juliana; FORTINI, Cristiana *et al.* *A nova lei de licitações*: Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. São Paulo: Brasinfra, 2022. Disponível em: <https://brasinfra.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Estudos-Brasinfra-web.pdf>. Acesso em: 6 maio 2023. Outros temas também integram a Biblioteca da BRASINFRA e podem ser consultados em: <https://brasinfra.org.br/biblioteca/>.

221 Apenas a título de exemplo, pense-se na seguinte situação: um contrato foi firmado para vigor por 9 meses, assinado em 1.5.2023 e, portanto, com duração programada até 1.2.2024. Mas a data do orçamento estimado pela Administração é 1.1.2023. Então, no último mês de vigência do contrato, mesmo que não tenha postergação e vença nos exatos 9 meses programados, haverá reajuste dos valores.

222 Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/instrucao-normativa-sgd-me-no-94-de-23-de-dezembro-de-2022>. Acesso em: 6 maio 2023.

223 Em que pese a redação da Lei do Plano Real, que fala de anualidade ao reajuste, acreditamos que o mesmo raciocínio seja possível para os reajustes em situações especiais. Alguns insumos, de forte impacto no preço e no custo dos contratos, têm alterações de preço de mercado extremamente significativas ao longo de um ano (diversos precedentes do TCU, por exemplo, para os insumos betuminosos, mas também é possível citar derivados outros de petróleo e uso de aço). Fazer com que os reajustes sejam apenas anuais pode provocar uma descapitalização considerável para o contratado e, assim, um peso sobre o contrato que lhe faça: a) dar propostas de preço mais elevadas para custear as perdas temporárias e permitir capacidade econômico-financeira de suportar o contrato; b) transferir a contínuos pedidos de revisão os impactos da demora do reajuste sobre a saúde do contrato, eternizando animosidades entre as partes que estão, recorrentemente, avaliando esses pedidos e discutindo durante a execução contratual, mesmo que se trate de insumos conhecidamente impactantes; c) dar propostas de preço com margens de lucratividade mais altas para absorver o risco do negócio; d) espantar possíveis bons competidores, mas que não possuem musculatura suficiente para o compasso de espera; e) tornar factível eventual quebra ou suspensão de execução em razão da afetação do contratado, que suportará os aumentos até que o reajuste ou revisão ocorram; f) eternizar o *mindset* não harmonioso referido neste artigo. Por isso, alguns órgãos públicos começaram a trabalhar com o conceito de “realinhamento”, em que pese não tenha suporte dessa nomenclatura diretamente no texto legal (há suporte de fundamento, mas não de nomenclatura e categorização entre as situações de reequilíbrio). Haveria um “reajuste provisório” nos preços, com verificação anual de eventual compensação desses, de forma a evitar os impactos negativos sobre o contrato ou preços de revisão posteriores. A lógica dessa alternativa tem claro fundamento legal, a exemplo dos seguintes: a) a LINDB permite contratualização e dialogicidade nos contratos administrativos, buscando *solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais* (art. 26, §1º, inc. I), bem como leva em consideração as consequências práticas do decidir e as soluções alternativas (art. 20 a 22) e o que impacta sobre as decisões do gestor à época dos fatos (art. 22); b) a solução já é possível, dessa forma, para a repactuação na nova lei geral e serve, como interpretação analógica, a situações excepcionais do reajuste (não como regra, mas levando em conta o que situações excepcionais podem fazer e assim se diminua/neutralize

o peso das revisões a partir do que, na prática, se concederia de reajuste e que acaba por impactar menos o erário). Essa alternativa já está em alguns normativos, a exemplo da experiência paulista citada neste artigo (nota 7) e vem sendo defendida por algumas entidades. Sugerimos consultar: PICININ, Juliana; FORTINI, Cristiana *et al.* *Tomo 11: reequilíbrio econômico-financeiro apud* A nova lei de licitações: Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. São Paulo: Brasinfra, 2022. Disponível em: <http://brasinfra.com.br/biblioteca/Tomo%2011%20-%20Reequil%C3%ADbrio%20econ%C3%B4mico-financeiro.pdf>. Acesso em: 6 maio 2023.

224 O entendimento da revisão a partir da imprevisão e da equidade já é clássico na consideração dos órgãos de controle e sua jurisprudência, a exemplo das seguintes passagens: a) “a álea econômica extraordinária, que serve como fundamento ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, há que ser entendida como um risco imprevisível, extemporâneo e de excessiva onerosidade e que, sendo insuportável, não se pode exigir que a parte prejudicada arque com suas consequências por um dado período de tempo, sob pena de se concluir que esse fato não decorreu de uma situação de álea econômica extraordinária” – UNIÃO, Tribunal de Contas. Acórdão nº 1.563/2004. Plenário, Relator Ministro Augusto Sherman, j. 6.10.2004; b) “o direito à revisão independe de previsão em edital ou contrato ou de transcurso de prazos. As alterações de preços estão autorizadas sempre que ocorrerem fatos imprevisíveis que desequilibrem significativamente as condições originalmente pactuadas e devem retratar a variação efetiva dos custos de produção” – UNIÃO, Tribunal de Contas. Acórdão nº 1.309/2006. 1ª Câmara, Relator Ministro Guilherme Palmeira, j. 23.5.2006.

225 Podem ser citados, como meros exemplos do início dessa regulamentação, em que pese o posicionamento da autora contra parte considerável de seus conteúdos, especialmente quanto a gatilhos sem fundamentação técnica, indeferimentos em desacordo com a melhor doutrina processual, dentre outros: a) Resolução DNIT nº 13, de 2 de junho de 2021; b) Portaria Conjunta SMOBI / SUDECAP nº 002, de 9 de abril de 2021; c) Portaria 196/2021/GOINFRA, de 15.7.2021; d) Portaria Conjunta SEMOBI/SECONT/PGE/DER nº 004-S, de 22 de julho de 2021, do Governo do Espírito Santo; e e) Portaria SUP/DER-83, de 14.5.2021, do DER-SP.

226 Outro ponto importante é a reiterada jurisprudência do TCU no sentido de que não se avaliem insumos de forma isolada, sem verificar quais insumos tiveram redução ou aumento de preços e, dessa forma, se compensariam na avaliação global dos custos. A título de exemplo, embora remansoso seja esse posicionamento, o seguinte: UNIÃO, Tribunal de Contas da. Acórdão nº 1.604/2015. Plenário, Relator Ministro Augusto Nardes, j. 1.7

consequências imprevisíveis. (...) A Administração não reúne forças para compelir terceiros a operarem em prejuízo ou sem lucro. Então, deve-se proceder à revisão do contrato se as condições da época da proposta são alteradas” – NIEBUHR, Joel de Menezes. *Licitação Pública e Contrato Administrativo*. 2.ed., p. 895; b) “se os particulares tivessem que arcar com as consequências de todos os eventos danosos possíveis, teriam que formular propostas mais onerosas. A Administração arcaria com custos correspondentes a eventos meramente possíveis – mesmo quando inoportunos, o particular seria remunerado por seus efeitos meramente potenciais. É muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a menor proposta possível: aquela que poderá ser executada se não se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior. Concomitantemente, assegura-se ao particular que, se vier a ocorrer seu infortúnio, o acréscimo de encargos será arcado pela Administração. Em vez de arcar sempre com o custo de eventos meramente potenciais, a Administração apenas responderá por eles se e quando efetivamente ocorrerem” – JUSTEN FILHO, Marçal. *Comentários à lei de licitações e contratos administrativos*. 5. ed. São Paulo: Dialética, 1998, p. 518.

229 Um dos maiores exemplos de que a cultura da desconfiança e da postergação merecia uma mudança de padrões se mostrou no período de enfrentamento do novo coronavírus, já que no maior número dos órgãos públicos os pedidos de revisão decorrentes desse período, por mais que houvesse o reconhecimento genérico e generalizado de que a pandemia afetou as relações contratuais, foram ignorados, postergados, inconclusivos, forçando à judicialização de contratos e, em número considerável de casos, responsável pela perda da sustentabilidade contratual ou empresarial, com repercussão sobre o mercado, a empregabilidade, a circulação de riquezas e a arrecadação tributária. Órgãos federais assumiram, posteriormente, ao menos em tese, que a pandemia é fator que afetou os contratos administrativos, reconhecendo a interligação dessa com a imprevisão autorizativa da revisão. A esse respeito sugerimos verificar o Parecer nº 261/2020/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU ementado: “CONSULTA. CONTRATOS DE CONCESSÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. COVID-19. I. Os concessionários têm direito ao reequilíbrio de seus contratos em caso de superveniência de evento cujo risco tenha sido alocado ao poder concedente, caso dele tenha decorrido impacto significativo em suas receitas ou despesas. II. Em regra, o concessionário assume os riscos ordinários do negócio e o poder público retém os riscos extraordinários. Mas nada impede que os contratos estabeleçam uma divisão de riscos diferente. III. Para a aplicação da teoria da imprevisão para fins de revisão de contratos de concessão é necessário que, observada a alocação contratual de riscos, ocorra evento superveniente e extraordinário, cuja ocorrência ou consequências sejam imprevisíveis e inevitáveis e que tenha gerado onerosidade excessiva decorrente de um significativo desequilíbrio no contrato. IV. A pandemia do novo coronavírus configura força maior ou caso fortuito, caracterizando álea extraordinária para fins de aplicação da teoria da imprevisão a justificar o reequilíbrio de contratos de concessão de infraestrutura de transportes, desde que atendidos os demais requisitos indicados neste Parecer”. Íntegra disponível em: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/conjur/Geral00261406894540CS.pdf>. Acesso em: 6 maio 2023. Inobstante, a definição genérica do impacto da pandemia não significa o direito à recomposição nos números propostos em processo administrativo. É indispensável que se avalie, concretamente, em que medida o impacto se deu, encontrando-se a verdadeira expressão de revisão que seja devida no caso concreto. Reconhecemos que isso seja curial. No

entanto, ainda é perceptível o tom que expressa o *mindset* da desconfiança em inúmeros precedentes. Considerando esses aspectos, sugerimos conhecer, com os devidos cuidados, este documento do TCU: “a solução final dada pela Aneel é adequada ao não reconhecer em sede abstrata e geral o direito objetivo das distribuidoras ao reequilíbrio dos contratos, mas apenas o direito subjetivo de solicitarem esse reequilíbrio e de terem seu pedido analisado pela Agência, conforme já previsto na Lei 8.987/1995 e nos respectivos contratos de concessão e permissão. É mister que a Agência exija a comprovação do desequilíbrio pelos concessionários, já que os efeitos da pandemia não são homogêneos para todas as concessões” – UNIÃO, Tribunal de Contas. Acórdão nº 1.905/2020. Plenário, Relator Ministro Ana Arraes, j. 22.7.2020.

230 Sugerimos conhecer a interessante abordagem dos autores, considerando aspectos da pandemia do coronavírus: MARRARA, Thiago; GASIOLA, Gustavo Gil. *Fato do príncipe: o que é e como identificar?* Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-abr-18/fato-principe-identificar>. Acesso em: 6 maio 2023.

231 Taxa de câmbio é “a quantia de uma dada moeda que pode ser trocada por uma unidade de outra moeda”, usando o Brasil o regime de câmbio flutuante, ou seja, as condições do mercado ditam a flutuação. WESTON, J. F.; BRIGHAM, E. F. *Fundamentos da Administração Financeira*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

232 Ilustrativamente, o TCU recomendou à Petrobras, em decorrência da variação cambial e do impacto das oscilações no equilíbrio contratual que: a) “adote medidas para, nos contratos com custos de insumos vinculados à variação cambial, aproximar temporalmente verificações de medições de serviços prestados e respectivos pagamentos, de modo a viabilizar aumento da frequência destes últimos e, com isso, viabilizar rápida compensação de eventuais pagamentos a maior ou a menor” e b) “avalie a viabilidade de incluir em editais cujo objeto possuir forte vinculação com o câmbio, como requisito de qualificação econômico-financeira, a obrigação de adoção pelo contratado de proteção contra variação cambial (‘hedge’ cambial), de forma a prevenir eventuais alegações futuras de necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro decorrentes de oscilações cambiais desfavoráveis excessivas, além de avaliar a possibilidade de a própria Petrobras adotar medida similar, se já não o fizer, como forma de mitigar riscos ao patrimônio da companhia”. UNIÃO, Tribunal de Contas da. Acórdão nº 87/2008. Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz, j. 30.1.2008.

233 Segundo o TCU, “é aplicável a teoria da imprevisão e a possibilidade de recomposição do equilíbrio contratual, em razão de valorização cambial”, havendo precedentes históricos para isso, inobstante a avaliação do impacto seja por caso concreto e se se verificar conforme natureza e objeto do contrato – UNIÃO, Tribunal de Contas. Acórdão nº 1.594/2006. Plenário, Relator Ministro Guilherme Palmeira, j. 30/8/2006. Nesse sentido, “a variação da taxa cambial (para mais ou para menos) não pode ser considerada suficiente para, isoladamente, fundamentar a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Para que a variação do câmbio seja considerada um fato apto a ocasionar uma recomposição nos contratos, considerando se tratar de fato previsível, deve culminar consequências incalculáveis (consequências cuja previsão não seja possível pelo gestor médio quando da vinculação contratual), fugir à normalidade, ou seja, à flutuação cambial típica do regime de câmbio flutuante e, sobretudo, acarretar onerosidade excessiva no contrato a ponto de ocasionar um rompimento na equação econômico-financeira, nos termos previstos no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/1993 (...). abe ao gestor, agindo com a desejável prudência e segurança, ao aplicar o reequilíbrio econômico-financeiro por meio da recomposição, fazer constar dos autos do processo,

análise que demonstre, inequivocamente, os seus pressupostos, de acordo com a teoria da imprevisão, juntamente com análise global dos custos da avença, incluindo todos os insumos relevantes e não somente aqueles sobre os quais tenha havido a incidência da elevação da moeda estrangeira, de forma que reste comprovado que as alterações nos custos estejam acarretando o retardamento ou a inexecução do ajustado na avença, além da comprovação de que, para cada item de serviço ou insumo, a contratada efetivamente contraiu a correspondente obrigação em moeda estrangeira, no exterior, mas recebeu o respectivo pagamento em moeda nacional, no Brasil, tendo sofrido, assim, o efetivo impacto da imprevisível ou inevitável álea econômica pela referida variação cambial” – UNIÃO, Tribunal de Contas da. Acórdão nº 1.431/2017. Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo, j. 5/7/2017. No sentido da verificação concreta, ainda, os seguintes precedentes: a) UNIÃO, Tribunal de Contas da. Acórdão nº 2.837/2010. Plenário, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 27/10/2010; b) UNIÃO, Tribunal de Contas da. Acórdão nº 25/2010. Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler, j. 20/1/2010.

234 Sugerimos a leitura do artigo NOBREGA, Marcos; TORRES, Ronny Charles L. de. *A nova lei de licitações, credenciamento e e-marketplace: o turning point da inovação nas contratações públicas*. Disponível em: <https://www.olicitante.com.br/e-marketplace-turning-point-inovacao-compras-publicas/>. Acesso em: 6 maio 2023.

235 MOREIRA, Egon Bockmann. Execução de contratos, governança e fiscalização na Nova Lei de Licitações. Palestra proferida para o Centro de Estudos da PGE de Mato Grosso. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WKnHSLfpCwU>. Acesso em: 5 maio 2023.

236 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. *Alteração unilateral do contrato administrativo* (interpretação de dispositivos da Lei 8.666/1993). São Paulo: Malheiros, 2003.

237 PÉRCIO, Gabriela Verona. *Contratos administrativos sob a ótica da gestão e da fiscalização*. Curitiba: ResPublica Editora, 2013.

238 OLIVEIRA, Simone Zanotello. Disponível em: https://sollicita.com.br/Noticia/?p_idNoticia=19450&n=as-modifica%C3%A7%C3%B5es-unilaterais-nos-contratos-administrativos. Acesso em: 5 maio 2023.

239 TORRES, Ronny Charles Lopes de. *Leis de licitações públicas comentadas*. 11. ed. Salvador: Juspodivm, 2021.

240 Disponível em: <https://zenite.blog.br/alteracoes-contratuais-na-nova-lei-de-licitacoes/>. Acesso em: 5 maio 2023.

241 NÓBREGA, Marcos; OLIVEIRA NETTO, Pedro Dias de. Disponível em: <https://inovacapacitacao.com.br/alteracoes-contratuais-na-nova-lei-de-licitacao-precos-e-criterios-de-pagamento/>. Acesso em: 5 maio 2023.

242 NOHARA, Irene Patrícia. *Direito administrativo*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 467.

243 JUSTEN FILHO, Marçal. *Comentários à lei de licitações e contratos administrativos*. 18. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1284.

244 Não obstante faça referência à Lei nº 8.666/1993, é possível estender a interpretação para a Lei nº 14.133/2021.

245 NÓBREGA, Marcos; OLIVEIRA NETTO, Pedro Dias de. Disponível em: <https://inovacapacitacao.com.br/alteracoes-contratuais-na-nova-lei-de-licitacao-precos-e-criterios-de-pagamento/>. Acesso em: 5 maio 2023.

246 Texto original e integral. STROPPIA, Christianne de Carvalho; FORTINI, Cristiana. Da extinção do contrato. In: FORTINI, Cristiana; OLIVEIRA, Rafael Sérgio Lima de;

TAMARÃO, Tatiana (coord.). *Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Belo Horizonte; Fórum, 2022.

[247](#) “A extinção contratual é uma categoria abrangente, que compreende uma pluralidade de situações em que se produz a extinção do vínculo jurídico estabelecido entre as partes. Uma parcela significativa desses casos não é objeto de tratamento no art. 137” (JUSTEN FILHO, Marçal. *Comentários à lei de licitações e contratações administrativas*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 1461).

[248](#) FERRAZ, Luciano. Contratos na Nova Lei de Licitações e Contratos. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (coord.). *Licitações e contratos administrativos: inovações da Lei 14.133/21*. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 214.

[249](#) FERNANDES, Felipe; PENNA, Rodolfo. *Nova lei de licitações e contratos para a advocacia pública*. São Paulo: Juspodivm, 2021, p. 231.

[250](#) Art. 25, §5º. O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela:

I – obtenção do licenciamento ambiental;

II – realização da desapropriação autorizada pelo poder público.

[251](#) Art. 124, §2º. Será aplicado o disposto na alínea *d* do inciso II do *caput* deste artigo (teoria da imprevisão) às contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado.

[252](#) JUSTEN FILHO, Marçal. *Comentários à lei de licitações e contratações administrativas*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 1477.

[253](#) Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos.

§1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I – caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II – seguro-garantia;

III – fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

§2º Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

§3º O edital fixará prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista no inciso II do §1º deste artigo.

[254](#) Art. 78 XIV – a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XV – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

255 Esse entendimento está contido de forma expressa no art. 11 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022: Ressalvada a exceção prevista no inciso I do §3º do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado terá direito à extinção do contrato na hipótese de atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos.

256 “Esse direito decorre da ocorrência de fatos supervenientes atribuídos à Administração que impedem ou agravam a execução do contrato (art. 137, §2º, I a V). Alguns deles traduzem *fatos da Administração*, indicando conduta culposa desta e gerando o desfazimento do vínculo pela *resolução* do contrato” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual direito administrativo*. 35. ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 261).

257 JUSTEN FILHO, Marçal. *Comentários à lei de licitações e contratações administrativas*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 1462.

258 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. 35. ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional 109, de 15.03.2021 e a Lei 14.133, de 1.4.2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). São Paulo: Malheiros, 2021, p. 585.

259 “Há situações que podem *autorizar o contratado a pretender a extinção do negócio jurídico*. No caso, ele terá direito a assim o fazer nas hipóteses listadas no §2º do art. 137, as quais, na nossa ótica, são *taxativas*” (HEINEN, Juliano. *Comentários à lei de licitações e contratos administrativos*. Salvador: Juspodvim, 2021, p. 694).

260 Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses; repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas; atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos.

261 “Registre-se que as hipóteses de caso fortuito ou de força maior albergam tanto impossibilidade de cumprimento das prestações devidas pelo particular quanto daquelas que incumbem à Administração. Deve, desse modo, o fato decorrer de circunstâncias completamente alheias a ambas as partes do contrato para ser considerado caso de fortuito externo” (GUSMÃO, Diego Ornellas. Art. 137, V – Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato. *In*: SARAI, Leandro (org.). *Tratado da nova lei de licitações e contratos administrativos: Lei 14133/21 Comentada por Advogados Públicos*. São Paulo: Juspodvim, 2021, p. 1272).

262 JUSTEN FILHO, Marçal. *Comentários à lei de licitações e contratações administrativas*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 1477.

263 ARAGÃO, Luciano. Ultratividade da Norma X Autotutela e Presunção de Legitimidade dos Atos Administrativos. Disponível em: <https://www.lucianoaragao.com.br/ultratatividade-da-norma-x-autotutela-e-presucao-de-legitimidade-dos-atos-administrativos/>. Acesso em: 27 jun. 2021.

- 264 CARDOZO, José Eduardo Martins. *Da retroatividade da lei*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 297.
- 265 Respectivamente, Acórdão nº 845/2017 – Plenário e Acórdão nº 2.612/2016 – Plenário.
- 266 TORRES, Ronny Charles Lopes de. *Leis de licitações públicas comentadas*. 12. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Juspodivm, 2021, p. 709.
- 267 Interpretação efetuada pela Advocacia-Geral da União, constante dos Modelos de Contrato – TIC – Compras e Serviços. Disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/14133/modelos-da-lei-14-133-21-para-bens-e-servicos-de-tic>. Acesso em: 5 maio 2023.
- 268 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2021, p. 808-809.
- 269 FERREIRA, Daniel. Infrações e sanções administrativas. *Enciclopédia Jurídica da PUCSP*. Tomo Direito Administrativo e Constitucional, Edição 1, abril de 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/107/edicao-1/infracoes-e-sancoes-administrativas>. Acesso em: 5 maio 2023.
- 270 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2021, p. 809.
- 271 De acordo com o §5º, art. 90, a recusa em assinar contrato também caracteriza descumprimento total da obrigação.
- 272 MAFISSONI, Viviane. Disponível em: <https://www.novaleilicitacao.com.br/2022/09/22/regime-sancionador-de-licitantes-e-contratados-nas-estatais-o-que-podemos-utilizar-da-nllc-como-modelo-referencial/>. Acesso em: 5 maio 2023.
- 273 BOAVENTURA. Carmen Iêda Carneiro; BRAGAGNOLI. Renila. Disponível em: https://sollicita.com.br/Noticia/?p_idNoticia=19109. Acesso em: 5 maio 2023.
- 274 MAFISSONI, Viviane. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/222988/infra%C3%A7%C3%B5es%20e%20san%C3%A7%C3%B5es%20na%20nova%20lei%20de%20licita%C3%A7%C3%B5es%20-%20as%20inova%C3%A7%C3%B5es%20-%20portal%20lc.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 5 maio 2023.
- 275 Sobre a aplicação da sanção de advertência: FERRAZ, Luciano. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-jul-07/interesse-publico-convem-advertir-advertencia-pena-lei-1413321>. Acesso em: 5 maio 2023.
- 276 BOAVENTURA. Carmen Iêda Carneiro; MAFISSONI. Viviane. Os institutos da reincidência e da reabilitação no processo sancionador. Disponível em: <https://ronnycharles.com.br/os-institutos-da-reincidencia-e-da-reabilitacao-no-processo-sancionador/>. Acesso em: 5 maio 2023.

CONTRATAÇÃO DIRETA DE SOLUÇÃO TIC

Felipe Boselli

O Capítulo VIII da Lei nº 14.133/2021, com os artigos 72 a 75, abordou o tema das contratações diretas na nova lei de licitações. O texto legal trouxe basicamente uma herança da Lei nº 8.666/1993 naquilo que estava disciplinado nos artigos 24 (dispensa de licitação), 25 (inexigibilidade de licitação) e 26 (procedimentos para a realização da contratação direta).

A Lei nº 14.133/2021 apresenta uma melhor organização da contratação direta quando comparada à Lei nº 8.666/1993, visto que a nova lei dedica um capítulo específico para as contratações que são feitas sem prévio procedimento licitatório, diferentemente de como era na Seção I do Capítulo II da Lei nº 8.666/1993, que englobava os artigos 20 a 26, reunindo as modalidades, os limites de valores dessas modalidades, a dispensa e a inexigibilidade.

Também foi um avanço organizacional da nova lei a alteração da ordem em que foram apresentados os dispositivos legais relacionados às contratações diretas no texto, com o processo de contratação direta (Seção I), a inexigibilidade de licitação (Seção II), que antecede logicamente o conceito de dispensa, e, por fim, o rol de hipóteses de licitações dispensáveis (Seção III).

Por outro lado, várias são as críticas que podem ser feitas a este capítulo da Lei nº 14.133/2021 quanto às oportunidades perdidas

pelo legislador. O texto legal poderia trazer muitas melhorias e dirimir discussões que existiam em alguns pontos da inexigibilidade e das dispensas de licitação na Lei nº 8.666/1993, mas que permaneceram dando margem para diferentes interpretações, o que causa uma insegurança jurídica, que poderia ter sido afastada.

O capítulo da contratação direta permanece com um desarranjo estrutural latente. São apresentadas 29 hipóteses de dispensas, com vários casos sobrepostos, nas quais o legislador deixou escapar a chance de fazer uma melhor sistematização tornando a disciplina mais racional.

Como exemplo, citam-se as alíneas “f”, “g”, “h”, e “i” do inciso IV e os incisos VI e VII do artigo 75. São seis hipóteses de dispensa de licitação, todas elas relacionadas ao conceito de atividades militares e segurança nacional, que poderiam, tranquilamente, estar desenhadas em um único caso mais bem estruturado.

Isso também vale para as contratações que tratam do Sistema Único de Saúde (SUS), em que o legislador tem previsões de dispensa na alínea “m” do inciso IV e nos incisos XII e XVI, com três dispositivos ligados à mesma situação que também poderiam estar reunidos, com suas peculiaridades específicas, o que tornaria mais coerente o texto legal.

Também é o caso das contratações ligadas à tecnologia, pesquisa, desenvolvimento ou inovação, que o legislador destinou as alíneas “c” e “d” do inciso IV, além dos incisos V e XV. Novamente, são quatro dispositivos distintos com finalidades muito próximas, que poderiam ser unificadas em um único caso mais bem definido.

Na Lei nº 8.666/1993, de onde essa notória confusão foi herdada, até é compreensível tal confusão, pois a maior parte dos casos de dispensa foi acrescentada ao artigo 24 ao longo do tempo, quase sempre por medida provisória, conforme se identificava a necessidade de mais uma situação de dispensa, ou de uma condição

que não estava perfeitamente amparada pelos dispositivos até então existentes.

Em uma nova lei, nada justifica manter os vícios organizativos que foram cometidos ao longo de mais de duas décadas de vigência da Lei nº 8.666/1993.

Quanto às confusões entre os casos de dispensa e casos de inexigibilidade, o legislador acertou, corrigindo a lei anterior, ao lançar o então inciso X do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993 (compra e locação de imóvel), que era uma clara situação de inviabilidade de competição, ao rol das inexigibilidades (inciso V do art. 74 da Lei nº 14.133/2021). Entretanto, vários outros casos que deveriam ser arrolados como inexigibilidade permanecem como dispensa de licitação, como acontece nas alíneas “a”, “b” e “k” do inciso IV e incisos X e XIII do artigo 75.

Ainda quanto à organização do texto legal, o legislador insistiu no erro cometido pela Lei nº 8.666/1993 quanto às alienações. O Capítulo IX, ao tratar das alienações, traz muito mais questões relacionadas à contratação direta (chamada de licitação dispensada tanto na nova lei quanto na anterior) do que efetivamente o mérito das alienações, o que faz com que o texto legal devesse, a nosso ver, estar reunido no capítulo das contratações diretas.

Feito esse sobrevoo à organização das contratações diretas, passamos à análise da inexigibilidade e da dispensa de licitação.

7.1 A inexigibilidade de licitação

A inexigibilidade de licitação é um instituto fático. São os contornos da situação real que delimitam se é cabível, ou não, a inexigibilidade de licitação. Em suma, *qualquer situação concreta em que for inviável a competição estará caracterizada a inexigibilidade*. Nas palavras de Pereira Júnior (2009, p. 343): “O leque de situações em

que se apresenta tal impossibilidade é largo e variado, por vezes surpreendente”.

Um dos exemplos de situação fática que não viabiliza a competição por meio de procedimento licitatório é a hipótese de contratação de atividades cujo critério é eminentemente subjetivo.

Tiossi Junior (2017, p. 154) explica que, para a licitação ser exigível, deve ser possível assegurar que a Administração possa comparar propostas em condições de igualdade, e inexigível quando não for possível garantir tais condições.

Em outras palavras, a licitação só será aceitável nos casos em que a paridade entre os licitantes puder ser definida, comparada e julgada por critérios objetivos, ao passo que a subjetividade em qualquer um desses parâmetros conduzirá a inexigibilidade de licitação.

A impossibilidade de adotar critérios objetivos para a contratação de um determinado objeto impede a consecução do princípio do julgamento objetivo e, conseqüentemente, inviabiliza a própria realização de uma competição via procedimento licitatório.

Não existe licitação com critérios subjetivos, pois o procedimento licitatório depende, por força do disposto no artigo 5º da Lei nº 14.133/2021, de um sistema objetivo que permita comparar propostas a serem apresentadas de forma técnica e imparcial, garantindo o princípio constitucional da isonomia, objetivo da realização do certame público, nos termos do inciso II do artigo 11 da Lei nº 14.133/2021.

Assim sendo, nas contratações em que não existe a possibilidade de se realizar uma competição que adote critérios objetivos, está caracterizada a inviabilidade de competição formulada no caput do artigo 74, tornando a licitação inexigível e, portanto, lícita a contratação sem procedimento licitatório prévio.

O próprio legislador demonstra a aplicabilidade desse raciocínio ao adotar dois exemplos que se enquadram na situação ora descrita. São os incisos II e III do artigo 74 da Lei nº 14.133/2021.

Se tomada a contratação de artistas para a realização de um show como exemplo, existe uma pluralidade de competidores no mercado, mas não é possível, com a atual legislação de licitações, cotejar propostas para selecionar o artista que se apresentará em um evento público. Nenhum dos critérios possíveis de julgamento é capaz de selecionar a melhor proposta para contratar o show. Seja o menor preço, o maior desconto, a melhor técnica ou conteúdo artístico, a técnica e preço, o maior lance (só cabível no caso de leilão), ou o maior retorno econômico, todos os critérios possíveis pelo que disciplina o artigo 33 da Lei nº 14.133/2021, nenhum é capaz de fazê-lo.

É justamente desta definição de impossibilidade de se realizar o procedimento licitatório que deriva a interpretação extensiva do artigo 74. O legislador tomou o cuidado de afirmar, no *caput* do artigo, que a licitação será inexigível quando houver inviabilidade de competição e ainda concluiu com a expressão “em especial”.

É muito clara a finalidade da norma estabelecida pelo próprio legislador. Nem poderia ser diferente, a inexigibilidade é a resposta para os casos insolucionáveis, que, por razões óbvias, jamais poderiam ser previstos em sua totalidade pelo legislador.

A inexigibilidade, portanto, nada mais é do que a autorização legal implícita para que o gestor público não realize um certame quando este não for possível, quando não alcançará resultados práticos. Ora, se o certame é impossível, pouco importa se o legislador teria autorizado, ou não, a contratação direta. Esta é a conclusão de Rigolin (2007, p. 119), para quem o artigo 25 da Lei nº 8.666/1993 (que corresponde ao artigo 74 da Lei nº 14.133/2021) nem precisaria existir e, inclusive, seria melhor se não existisse, pois os exemplos trazidos pelo legislador acabam confundindo mais do que esclarecendo.

O apontamento feito por Rigolin é acertado ao perceber a dificuldade ainda presente de a doutrina conseguir apresentar uma base sólida para conceituar a noção de inviabilidade de competição, bem como as consequências que tal dificuldade gera na atuação prática, seja na realização de contratações diretas que deveriam ser objeto de licitação, seja pela realização de licitações em situações nas quais eram inexigíveis, gerando ineficiência e o direcionamento de editais.

A contratação direta amplia significativamente o grau de discricionariedade do gestor público que pode, em detrimento da isonomia, optar por esta ou aquela contratação. Em situações que são passíveis de competição e que não foram objeto de dispensa pelo legislador é dever do gestor público realizar a licitação.

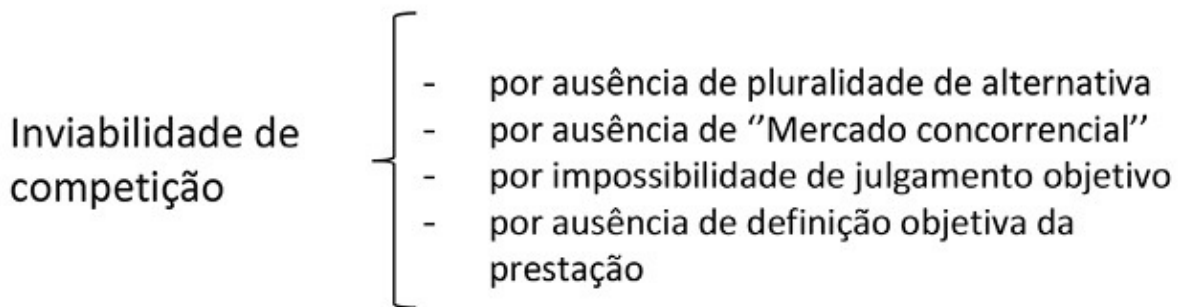
Ocorre que, nos casos em que a licitação é inviável, a sua realização pode gerar consequências nefastas à Administração Pública, como a realização de um certame com regras abertas que resultam na contratação de objeto que não tem serventia nenhuma àquela Administração.

Tome-se, como exemplo, a contratação de um profissional para dar consultoria a um órgão público. A realização de uma licitação que tenha por exigência, exclusivamente, o nível acadêmico do profissional poderá gerar a contratação de um profissional sem o perfil adequado cuja consultoria poderá possuir resultados práticos desastrosos, gerando custo ao Poder Público sem o necessário retorno e, em casos excepcionais, podendo, até mesmo, levar a uma orientação em sentido equivocado.

Por outro lado, a escolha prévia de profissional, ainda que altamente qualificado, e o direcionamento do instrumento convocatório, com determinadas exigências que apenas serão possíveis àquele sujeito inicialmente pretendido, tampouco atendem ao interesse público.

Nota-se que a definição precisa dos contornos da inexigibilidade de licitação não pode ser relegada a uma mera retórica discussão conceitual. Trata-se de importante problema a ser respondido e que não vem sendo satisfatoriamente abordado pela doutrina.

Caminhando nessa direção vem Justen Filho (2014, p. 492), que tenta sintetizar as possibilidades em quatro categorias: É difícil sistematizar todos os eventos que podem conduzir à inviabilidade de competição. A dificuldade é causada pela complexidade do mundo real, cuja riqueza é impossível de ser delimitada por meio de regras legais. Uma tentativa de síntese está adiante exposta:



A estas quatro categorias pode-se acrescentar uma quinta, decorrente da ausência de tempo para realizar a licitação, quando a contratação tem que ser feita quase que de imediato, sem possibilitar transcorrer por todos os trâmites de um procedimento licitatório.

A dificuldade em sistematizar os eventos que podem gerar a inviabilidade de competição é inequívoca. Não obstante, é possível tomar as ideias do autor e avançar nessas categorias propostas trazendo um corpo mais completo, ainda que, saiba-se, de antemão, da impossibilidade prática de se prever um rol extensivo de categorias, mas sim um sistema mais explicativo do que as propostas atualmente vigentes.

A categorização proposta por Justen Filho é a mais completa encontrada na doutrina atualmente, de forma sistematizada. Ainda assim, por ser a inviabilidade de competição um instituto ligado aos

problemas fáticos que podem ocorrer, a categorização poderia ser ampliada, com outros casos possíveis.

Dentre os infinitos casos de inexigibilidade que podem ocorrer, o legislador entendeu conveniente citar cinco exemplos, arrolados nos incisos do art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

7.1.1 A inexigibilidade de licitação por exclusividade em contratos de TIC

Nos casos de contratações de TIC as questões atinentes à inexigibilidade ganham um contorno um pouco mais complexo.

Em regras as contratações de TIC que são realizadas por meio de inexigibilidade tratam da identificação se aquela solução que está sendo contratada possui os requisitos fundadores que a tornam única para a Administração Pública. Estamos diante da hipótese prevista no artigo 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

Nesse primeiro exemplo de inexigibilidade de licitação apresentado na nova lei de licitações, está a situação de inviabilidade de licitar por ausência de múltiplos competidores.

Havendo no mercado um material, equipamento, ou gênero que só possa ser fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, está caracterizada a inviabilidade de licitar por absoluta falta de outros possíveis interessados em disputar o contrato com aquele fornecedor ou prestador de serviços exclusivo.

Não se confunde a situação de exclusividade de fornecimento com a exclusividade de fabricação. É absolutamente comum que a Administração Pública esteja diante de uma necessidade que apenas

um fabricante no mundo consegue atender, é o caso, por exemplo, da aquisição do sistema operacional Windows, adquirido nos casos de padronização. Ainda que apenas a Microsoft produza esse sistema, existem inúmeros fornecedores possíveis, o que afasta a exclusividade de fornecimento e, conseqüentemente, a inviabilidade de competição.

Deve a Administração, nesses casos, realizar o processo licitatório mesmo indicando a marca que, justificadamente, é a única apta a atender às necessidades do órgão.

Na Lei nº 8.666/1993, essa situação está prevista no inciso I do artigo 25, trazendo a hipótese de contratação direta, por inexigibilidade, destinada à aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que sejam fornecidos com exclusividade por determinado agente privado. Naquela norma, essa hipótese de contratação direta só está pautada para os contratos de fornecimento, não abrangendo, portanto, as contratações de serviços.

Logo, em uma leitura restritiva do dispositivo legal, as contratações de serviços prestados com exclusividade por determinada empresa não se realizariam por inexigibilidade, nos termos daquele inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993, que expressamente trata do contrato de fornecimento.

Mesmo antes do advento da Lei nº 14.133/2021, essa era a interpretação, no entanto, não mereceria guarida, ao passo que, como visto, o rol legal de cabimento da inexigibilidade de licitação, ao contrário da dispensa, compõe uma lista de hipóteses exemplificativas, em que será inexigível a licitação, mas sem esgotar os casos de afastamento do procedimento licitatório.

Chaves (2015, p. 20) classifica como “desimportante” a questão de a exclusividade ser sobre compra ou serviço. A distinção seria apenas que na exclusividade de serviço o enquadramento seria no *caput* do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993 e não no seu inciso I.

Esse entendimento é compartilhado por Torres (2021, p. 178), ao apontar como tecnicamente inadequada a fundamentação da contratação de serviço exclusivo no artigo 25, I, da Lei nº 8.666/1993, devendo ser baseada no *caput*.

Se há um único possível contratado no mercado, existe a inexigibilidade por exclusividade, seja ela para compra ou para qualquer outra espécie de contrato, seja na Lei nº 8.666/1993, cuja redação é mais fechada, seja na Lei nº 14.133/2021. Esta sepulta qualquer dúvida quanto à abrangência da inexigibilidade no caso de uma única possível pessoa a ser contratada, pois estende a hipótese de inexigibilidade para a aquisição de materiais, de equipamentos, de gêneros ou contratação de serviços.

Exemplo dessa contratação de serviço que usualmente ocorre por inexigibilidade é o dos contratos de manutenção de *software*, em que exista condição de exclusividade com determinado prestador de serviços, em geral o detentor da licença de uso.

Se não é possível que outros competidores apresentem propostas em um procedimento licitatório para disputar a prestação de determinado serviço, não há que se falar em licitação, mas sim em inexigibilidade.

Logo, acertou o legislador ao ampliar o dispositivo legal da nova lei para estabelecer de forma mais clara que a contratação por inexigibilidade é viável, também, para os casos de prestação de serviços.

Outra condição que deve ser observada no emprego desse inciso I do artigo 74 da Lei nº 14.133/2021, para fundamentar uma contratação direta, é a vedação do legislador à preferência de marca feita no §1º desse mesmo artigo.

Isso não significa que o gestor está totalmente impedido de definir uma marca do produto que pretende adquirir. Cretella Júnior (2008, p. 241-242) defende pela definição de marca em situações em que

isso se faça necessário para atender às necessidades da Administração.

Na Lei nº 14.133/2021, em inovação com relação à Lei nº 8.666/1993, está bem clara a possibilidade de estabelecimento de marca nos casos previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso I do artigo 41.

É possível a eleição de uma marca específica para o objeto, desde que seja, de fato, necessária à Administração. São exemplos nesse sentido os casos de padronização, em razão da compatibilidade com itens preexistentes, como peças para manutenção ou de insumos nos casos em que há regra específica para vigência da garantia do equipamento, entre outros.

O que não se admite é a escolha de uma marca sem que essa opção esteja apoiada no real interesse público, baseado apenas na predileção ou aversão pessoal do administrador. Ainda que a preferência subjetiva seja plenamente admissível na sua vida privada, há total incompatibilidade numa contratação pela Administração Pública.

Em havendo fundamentação concreta que imponha a necessidade de estabelecer uma marca e que isso leve a um único fornecedor, é perfeitamente possível a contratação direta, por inexigibilidade, assentada no *caput* do artigo 74 da Lei nº 14.133/2021.

A grande questão, portanto, ao redor da inexigibilidade de licitação para TIC diz respeito à verificação se aquela solução possui, ou não, características que a tornem única no mercado *E* que sejam fundamentais à execução das atividades da Administração contratante.

O Tribunal de Contas da União debruçou-se sobre o tema no Acórdão nº 511/2023 – Plenário, da relatoria do Min. Augusto Nardes. No caso, foi contratada uma solução de tecnologia por inexigibilidade de licitação e compreendeu o Tribunal de Contas da União que as características exclusivas daquela ferramenta eram

necessárias à atividade que seria desempenhada pelo sistema e a tornavam única perante os seus concorrentes.

Logo, em um mercado no qual a diferença entre os produtos é comum e necessária para que não exista quebra de propriedade intelectual, ainda assim vê-se possível a contratação de soluções de TIC por inexigibilidade de licitação quando as características que tornam aquela solução exclusiva no mercado mostram-se essenciais à atividade que será executada.

7.2 A dispensa de licitação

O conceito de dispensa pode ser extraído da própria nomenclatura utilizada, trata-se de possibilidades nas quais o legislador infraconstitucional, por alguma motivação específica, permitiu ao gestor público o descumprimento do mandamento constitucional de se realizar o procedimento licitatório para chegar às contratações públicas.

A dispensa pode, portanto, ser definida como a autorização legislativa que permite ao gestor público afastar o procedimento licitatório, gerando uma possibilidade de contratar sem licitação prévia. Esta autorização cria uma faculdade, não uma obrigação de não licitar.

Este conceito da licitação dispensável possibilita ao intérprete duas conclusões imediatas e fundamentais: a) os casos em que se admite a dispensa de licitação devem ser previstos em uma lista exaustiva; e b) deve haver uma motivação idônea para que seja elaborada lei autorizando a dispensa.

O primeiro conceito é dedução direta do texto constitucional e da norma positivada pelo legislador infraconstitucional. Se a Constituição estabeleceu a obrigatoriedade de se realizar o procedimento licitatório, o gestor público somente estará autorizado a realizar a contratação afastando a licitação nas hipóteses em que for expressamente autorizado pelo legislativo. Esta premissa é pacífica e está claramente expressa no *caput* do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, onde se lê: “É dispensável a licitação:” que é seguido por 16 incisos.

Note-se que o legislador, claramente, utilizou uma redação que permite inferir que a lista de incisos desse artigo 75 é restritiva, impossibilitando, portanto, interpretações extensivas, analogias ou ampliações de qualquer gênero. Nem poderia ser diferente.

Há que se lembrar que, ao afastar o procedimento licitatório, o gestor público está deixando de atender ao mandamento constitucional, o que só poderia fazer nas hipóteses em que estivesse expressamente autorizado pelo legislador.

Há que se lembrar que, ao afastar o procedimento licitatório, o gestor público está deixando de atender ao mandamento constitucional. Diante dessa máxima, a dispensa da licitação só pode ser realizada nas hipóteses em que estivesse expressamente autorizada pelo legislador, sob pena de inconstitucionalidade do ato administrativo.

Para Carvalho Filho (2018, p. 319), esta é a essência da dispensa de licitação, caracterizada por uma circunstância em que poderia ser realizada a licitação, mas o legislador, por alguma razão, decidiu dispensar essa obrigação.

Deste conceito se desdobra a segunda ideia das dispensas de licitação: a questão da motivação para que o legislador infraconstitucional crie hipótese de licitação dispensável.

A licitação dispensável pode ser caracterizada, portanto, como uma situação bem específica na qual o legislador autorizou o gestor

público a não realizar o procedimento licitatório prévio para formalizar a contratação daquele objeto. Isso não significa, entretanto, que o gestor está proibido de realizar o certame nesses casos. É, sim, uma faculdade de afastar a licitação, quando isso for do interesse público, portanto, que pode ser utilizada ou não, como ensina Gasparini (2008, p. 520).

Não há restrição à realização do procedimento licitatório em detrimento da dispensa de licitação. Do contrário, o artigo 337-E do Código Penal criminaliza a realização de dispensa fora das hipóteses previstas em lei. De outra sorte, não há tipificação da promoção da licitação em detrimento da dispensa de licitação.

Do ponto de vista teórico, até seria possível discutir eventual improbidade administrativa pela realização do procedimento licitatório em detrimento da dispensa de licitação. Para tanto, invocar-se-ia o argumento de redução da eficiência da Administração. Isto porque a Lei nº 8.429/1992 possui, em seu artigo 11, dispositivo que possibilita a condenação por improbidade administrativa por ato que atente contra os princípios da Administração Pública.

Em interpretação bastante pretensiosa seria possível discutir se a realização de licitação em detrimento de uma contratação direta configuraria afronta aos princípios da Administração Pública. Entretanto, apesar de vislumbrar essa possibilidade do ponto de vista teórico, não concordamos com essa análise.

Compreendido o conceito, passa-se a construir as balizas constitucionais para admissão da dispensa de licitação no ordenamento jurídico pátrio.

Como já apresentado, em que pese a existência de um dever constitucional de licitar, a contratação direta é admitida como uma possibilidade de exceção. Dentre as hipóteses de contratação sem prévia licitação, as mais numerosas são as licitações dispensáveis, previstas no artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, que contempla 29

hipóteses nas quais o legislador autorizou dispensar a licitação, além das dispensas previstas em normas esparsas, que continuam existindo.

A nova lei excluiu algumas hipóteses que eram equivocadamente previstas como dispensa na legislação anterior, Lei nº 8.666/1993, como os incisos XXIV, XXX, XXXIII e XXXV do artigo 24.

À primeira vista, outras dispensas de licitação pareceriam ter sido excluídas do texto legal. Contudo, o que houve foi apenas a sua realocação, como no artigo 24 da Lei nº 8.666/1993, inciso X (compra e locação de imóveis), que foi para o artigo 74, V, (inexigibilidade) da Lei nº 14.133/2021; inciso XI (remanescente de obra), agora deslocado para o artigo 90, §7º, da Lei nº 14.133/2021; inciso XVI (impressão de diários oficiais e TI com pessoa jurídica de direito público), que está reunida no inciso IX da Lei nº 14.133/2021; inciso XXII (energia elétrica e gás natural), lançado para inexigibilidade de serviço, quando cabível; e inciso XXIII (subsidiárias de estatais), regulado pela Lei nº 13.303/2016.

7.2.1 A dispensa de licitação em contratos de TIC

Nos casos e contratos de TIC, quando se trata de dispensa de licitação, em regra analisa-se um caso de dispensa de pequeno valor, sendo aquelas que estejam limitadas ao valor disposto no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que no momento da redação do presente texto está fixado em R\$ 57.208,33.

É importante lembrar que este valor deve ser considerado para a despesa do ano-calendário (janeiro a dezembro) do órgão que está contratando.

O §1º do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021 trouxe o teor da pacífica jurisprudência do Tribunal de Contas da União para o corpo da lei. Segundo a regra estabelecida, a Administração não pode, para se

enquadrar no limite legal, fracionar uma contratação maior, que deveria levar à licitação, em duas ou mais contratações diretas.

Por exemplo, se a Administração precisa fazer uma contratação de R\$ 90.000,00 para aquisição de produtos de informática, é uma prática ilegal o fracionamento dessa compra em duas dispensas de licitação de R\$ 45.000,00 cada, com o objetivo de afastar a necessidade de utilização do procedimento licitatório.

Para realizar este cálculo, deve-se tomar todas as contratações realizadas ao longo do exercício financeiro (janeiro a dezembro) que estejam categorizadas como mesmo ramo de atividade.

Na teoria, a questão é bastante simples: basta somar as contratações de mesma natureza que serão feitas ao longo do ano para se considerar se a Administração estará autorizada, ou não, a fazer dispensa de licitação de pequeno valor. Caso o valor anual dispendido com determinada natureza de objeto seja superior aos limites definidos nos incisos I e II do artigo 75, será considerado fracionamento a realização de dispensa de licitação.

Na prática, o tema é mais complexo do que isso. Há inúmeras situações limítrofes, em que a análise se o objeto está, ou não, na mesma natureza é bastante subjetiva. Nestes casos, entende-se que jamais o gestor público poderia ter suas contas rejeitadas ou ser punido, penal ou administrativamente, por uma questão que é duvidosa. Não obstante, considerando o cenário atual do país, recomenda-se aos gestores prudência e muita cautela. Na dúvida, é preferível fazer a licitação a afastá-la e correr o risco de uma interpretação mais restritiva dos órgãos de controle.

Ainda assim, quando ao tratar de contratações de TIC, sobretudo para *softwares*, as questões vão ficando mais complexas.

Não parece, portanto, adequado, por exemplo, realizar o somatório entre duas aquisições de sistemas completamente distintos e independentes. Seria o caso, por exemplo, de um *software*

para controle da folha de pagamento do órgão e outro que fizesse a gestão de prontuários do sistema de saúde do município.

Logo, ainda que necessária a cautela, parece sim possível que a Administração não some o valor de dois *softwares* que tenham destinações absolutamente distintas e que, portanto, não poderiam ser licitados em conjunto, para fins de consideração do conceito de fracionamento de despesa.

7.3 Conclusões

As contratações diretas representam um tema importante para todos aqueles que desejam operar na contratação pública em contratos de TIC.

Neste cenário é fundamental que os atores de mercado conheçam com clareza as regras da dispensa e da inexigibilidade de licitação, com foco em um maior controle de riscos das empresas que atuam na área.

É fundamental destacar que as contratações diretas indevidas podem levar à responsabilização daqueles que praticaram, sejam eles agentes públicos ou privados. É justamente por isso que o conhecimento se mostra um importante diferencial no setor.

É possível realizar um processo de contratação direta com segurança para contratações de TIC, bastando, para tal, que sejam seguidas as premissas da legislação, em especial:

a) para as *contratações por inexigibilidade de TIC*, quando fundadas na premissa da exclusividade, no inciso I do artigo 74 da Lei nº 14.133/2021, é de suma importância que estejam claras as condições que levam à exclusividade da solução escolhida e que afastam as demais concorrentes. Sobretudo, é essencial que

essas condições sejam efetivamente relevantes à execução do contrato; e

b) para as *contratações baseadas na dispensa de licitação para TIC*, quando lastreadas no inciso II do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, é importante que se assegure que o contrato não ultrapasse o limite financeiro legal, além disso, que a soma de contratações similares, no mesmo exercício, também permaneça abaixo do limite legal para a contratação.

Por fim, quando da realização de contratações diretas, deve a Administração atentar-se para os requisitos processuais previstos no artigo 72, em que foram definidos os documentos que devem instruir um processo de dispensa ou de inexigibilidade de licitação.

REFERÊNCIAS

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

CHAVES, Luiz Cláudio de Azevedo. A contratação por inexigibilidade de licitação com fornecedor ou prestador de serviço exclusivo – Breve análise do art. 25, I, da Lei nº 8.666/93. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 13, n. 49, p. 139-154, abr./jun. 2015.

CRETELLA JÚNIOR, José. Das Licitações Públicas. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

FEDICHINA, Marcio A. H. Gestão de compras e estoques. 1. ed. Curitiba: IESDE, 2021.

FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1998.

GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 5. ed. São Paulo: Dialética, 1998, p. 518.

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MAGALDI, Sandro; SALIBI NETO, José. Gestão do amanhã: tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na 4ª Revolução Industrial. São Paulo: Editora Gente, 2018.

MARRARA, Thiago; GASIOLA, Gustavo Gil. Fato do príncipe: o que é e como identificar? Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-abr-18/fato-principe-identificar>. Acesso em: 6 maio 2023.

NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 2. ed. Curitiba: Zênite, 2021.

NOBREGA, Marcos; TORRES, Ronny Charles L. de. A nova lei de licitações, credenciamento e e-marketplace: o turning point da inovação nas contratações públicas. Disponível em: <https://www.olicitante.com.br/e-marketplace-turning-point-inovacao-compras-publicas/>. Acesso em: 6 maio 2023.

PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da administração pública. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

PICININ, Juliana; FORTINI, Cristiana et al. A nova lei de licitações: Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. São Paulo: Brasinfra, 2022. Disponível em: <https://brasinfra.org.br/wp->

content/uploads/2022/02/Estudos-Brasinfra-web.pdf. Acesso em: 6 maio 2023.

PICININ, Juliana; FORTINI, Cristiana et al. Tomo 11: reequilíbrio econômico-financeiro apud A nova lei de licitações: Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. São Paulo: Brasinfra, 2022. Disponível em: <http://brasinfra.com.br/biblioteca/Tomo%2011%20-%20Reequil%C3%ADbrio%20econ%C3%B4mico-financeiro.pdf>. Acesso em: 6 maio 2023.

RIGOLIN, Ivan Barbosa. Contrato administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2007.

TIOSSI JUNIOR, José Roberto. Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços advocatícios na Lei das Estatais. In: REIS, Luciano Elias; CHIESORIN JUNIOR, Laerzio. Lei das empresas estatais: responsabilidade empresarial e o impacto para o desenvolvimento econômico nacional. Curitiba: OAB-PR, 2017. p. 145-163.

TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de licitações públicas comentadas. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2021.

UNIÃO, Tribunal de Contas da. Acórdão nº 1.604/2015. Plenário, Relator Ministro Augusto Nardes, j. 1/7/2015.

UNIÃO, Tribunal de Contas da. Acórdão nº 1.431/2017. Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo, j. 5/7/2017.

UNIÃO, Tribunal de Contas da. Acórdão nº 2.837/2010. Plenário, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 27/10/2010.

UNIÃO, Tribunal de Contas da. Acórdão nº 25/2010. Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler, j. 20/1/2010.

UNIÃO, Tribunal de Contas da. Acórdão nº 87/2008. Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz, j. 30/1/2008.

UNIÃO, Tribunal de Contas da. Acórdão nº 1.309/2006. 1ª Câmara, Relator Ministro Guilherme Palmeira, j. 23/5/2006.

UNIÃO, Tribunal de Contas da. Acórdão nº 1.563/2004. Plenário, Relator Ministro Augusto Sherman, j. 6/10/2004.

UNIÃO, Tribunal de Contas da. Acórdão nº 1.594/2006. Plenário, Relator Ministro Guilherme Palmeira, j. 30/8/2006.

UNIÃO, Tribunal de Contas da. Acórdão nº 1.905/2020. Plenário, Relator Ministro Ana Arraes, j. 22/7/2020.

UNIÃO, Tribunal de Contas da. Acórdão nº 7/2007. 1ª Câmara, Relator Ministro Augusto Nardes, j. 23/1/2007.

UNIÃO. Instrução normativa nº 94. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/instrucao-normativa-sgd-me-no-94-de-23-de-dezembro-de-2022>. Acesso em: 6 maio 2023.

UNIÃO. Parecer nº 261/2020/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU. Disponível em: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/conjur/Geral00261406894540CS.pdf>. Acesso em: 6 maio 2023.

WESTON, J. F.; BRIGHAM, E. F. Fundamentos da Administração Financeira. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

ZANATTA, Luciana; REBELO, Marina de Souza. Manual de Contratos de Serviços Terceirizados. 1. ed. Santa Catarina, 2009.

SOBRE OS AUTORES

Alexandre Ferraz

Bacharel em Ciências da Computação e mestre em Engenharia de Computação pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), com mais de 18 anos de experiência em gestão de projetos e práticas ágeis, ciclo de vida de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de *software*, modelos de maturidade, técnicas de melhoria de processos e desenvolvimento de equipes. Tem ampla experiência e formação em engenharia de *software*, métodos e *frameworks* de agilidade e liderança, como SAFe; Lean Inception, Management 3.0. É SAFe Program Consultant (SPC), SAFe Agilist e possui a certificação Enterprise Business Agility Strategist (EBAS).

Anderson Sant'Ana Pedra

Advogado e Consultor (Anderson Pedra Advogados). Procurador do Estado do Espírito Santo. Pós-doutor em Direito (Universidade de Coimbra). Doutor em Direito do Estado (PUC-SP). Professor de Direito Constitucional e Administrativo da FDV/ES. Autor de obras jurídicas. Membro Fundador do Instituto Nacional de Contratações Públicas (INCP).

Antonio Carlos Dias

Engenheiro de Sistemas, com mais de 30 anos trabalhando no setor de TI, atuou em projetos de transformação digital públicos em diversos países da América Latina, com o objetivo de capacitar e habilitar gestores em seu esforço para modernizar e fornecer serviços mais eficazes aos cidadãos. Liderou tecnicamente projetos como a criação do Centro de Operações da Cidade do Rio de Janeiro (COR-

Rio), foi diretor da sua agência de atração de investimentos (Rio-Negócios) e Vice-Presidente da AMCHAM-Rio.

Camila Cristina Murta

Advogada pública, especialista em Direito Público Municipal pela SBDP, pós-graduada em Direito Constitucional e Administrativo pela EPD, MBA em Gestão Pública pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESP), formada em Governança Corporativa pelo IBGC, certificada em Ética e *Compliance* pela LEC e certificada em Serviço em Computação em Nuvem pela AWS. Autora da obra: “Práticas Licitatórias, Temas Polêmicos” (editora Digipix).

Camila Lousada

Profissional da área de TI, certificada pelo PMI em Projetos Híbridos, com mais de 20 anos de experiência em Projetos, Processos de Negócios, Auditoria, Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Sustentabilidade Empresarial. Trabalhou em grandes empresas internacionais de Auditoria e Advisory, onde participou de projetos de auditoria, *risk management* e controles internos. Implementou o Escritório de Projetos (PMO) e Processos em empresas do setor privado e público, gerenciando projetos (*waterfall*, ágil, híbrido) tanto de infraestrutura como desenvolvimento. Quando diretora de Inovação atuou na transformação digital e cultural em empresa pública. Nos últimos anos especializou-se em Sustentabilidade Empresarial, tendo participado de fóruns e discussões para soluções do setor público.

Christianne de Carvalho Stroppa

Doutora e mestra em Direito Administrativo pela PUC-SP. Assessora de Gabinete I no TCM/SP e professora de Direito Administrativo na PUC-SP.

Claudio Neiva

Engenheiro com amplo conhecimento de tecnologias da informação aplicado ao setor de segurança, especialista em IDS/IPS, *firewalls*, *switching*, roteamento, redes sem fio, Linux, Windows, Active directory e Exchange. Com mais de 16 anos de experiência no setor de TI, ocupou cargos de administração de rede na embaixada americana e foi engenheiro de campo na Enterasys Network, ajudando os clientes do governo a implementar redes confiáveis e seguras.

Everton Batista dos Santos

Diretor de Normas e Sistemas de Logística da Secretaria de Gestão e Inovação Líder da Transformação Digital em Compras Públicas no Brasil. Pós-graduado em Gestão de TI, MBA em Engenharia de *Software*. Certificado Scrum Master, Cobit e ITIL, egresso da 1ª turma do LideraGov.

Felipe Boselli

Doutor em Direito do Estado pela UFSC. Advogado da Boselli & Loss Advogados Associados e sócio da Boselli Licitações. Autor de diversos livros e artigos. Professor em todo o país na matéria de licitações e contratos. Contato: felipe@boselli.com.br.

Gabriela Verona Pécio

Advogada especializada em Direito Administrativo. Mestra em Gestão de Políticas Públicas. Sócia na GVP Parcerias Governamentais. Foi servidora do Tribunal de Contas do Estado do Paraná de 2004 a 2006. Vice-Presidente do Instituto Nacional da Contratação Pública (INCP). Membro associado do Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro (IDASAN). Professora convidada dos cursos de pós-graduação em Licitações e Contratos da Escola Mineira de Direito (EMD), do Instituto Goiano de Direito (IGD) e da Católica SC. Autora da obra “Contratos Administrativos –

Manual para Gestores e Fiscais”, (editora Juruá), e coordenadora da obra “Inteligência e Inovação em Contratação Pública”, (editora Fórum), além de diversos artigos publicados em sites e revistas especializadas.

Jair Eduardo Santana

Mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo. Advogado. Administrador certificado pelo ICSS (ênfase em Investimentos). AETQ de Fundo de Previdência Complementar. Para saber mais, visite: www.jairsantana.com.br.

Juliana Picinin

Mestre em Direito pela UFMG (2005). Especialista em Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano pela UNA (2018). Pós-graduanda em Neurociência. Assessora da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Assessora no Núcleo Técnico Especializado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ex-Assessora-Chefe da Assessoria Jurídica da EMATER-MG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais). Ex-Conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil. Professora de Direito, Psicologia Positiva e Inteligência Emocional. Palestrante.

Karlos Gustavo de Castro Correia

Bacharel em Ciência da Computação com 23 anos de experiência no mercado de tecnologia, Arquiteto de Soluções desde 2009 e atua especificamente com Nuvem desde 2012.

Lucas Lopes

Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUCRS, com especialização em Direito Civil e Processual Civil (IDC) e MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 (PUCRS). Atua há mais de dez anos no ramo de licitações e contratos administrativos. Acredita que se

conectar com as pessoas é o melhor caminho para apoiar no seu desenvolvimento. Apaixonado por tecnologia e pai do Arthur.

Marcos Pires Namekata

Profissional de TI com mais de 20 anos de experiência em TIC. Amplo conhecimento em Infraestrutura e Governança de TIC, Segurança de Informação e Gerenciamento de Projetos. Formado pela Universidade de Fortaleza com pós-graduação em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas. Certificado em ITIL V3 foundations, COBIT foundations e Project Management Professional (PMP)® e ex-professor da UNINORTE na pós-graduação de Segurança da Informação.

Rafael Sérgio Lima de Oliveira

Procurador Federal da AGU e fundador do Portal L&C (licitacaocontrato.com.br). Mestre em Direito e pós-graduado em Direito da Contratação Pública pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Participou do Programa de Intercâmbio Erasmus+ na Università degli Studi di Roma - Tor Vergata. Professor e conferencista em diversos eventos nacionais de contratação pública. Coordenador e coautor do livro “Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021” (editora Fórum, 2022).

Tatiana Camarão

Assessora Técnica Especializada da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Mestra em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Vice-Presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo (IMDA). Professora da pós-graduação em Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Autora das obras: “Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos

– Volumes 1 e 2: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021” (editora Fórum); “Termo de referência: o impacto da especificação do objeto e do termo de referência na eficácia das licitações e contratos” (editora Fórum); “Processo Administrativo. Comentários à Lei nº 9.784/1999” (editora Fórum); “Licitações e contratos – aspectos relevantes” (editora Fórum) e “Manual Prático do Pregão”.

Victor Aguiar Jardim de Amorim

Doutorando em Constituição, Direito e Estado pela Universidade de Brasília (UnB). Mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). Coordenador do curso de pós-graduação em Licitações e Contratos Administrativos do Instituto Goiano de Direito (IGD) e do Observatório da NLLCA. Professor de pós-graduação do ILB, IDP, IGD e CERS. Por mais de 13 anos, atuou como pregoeiro no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (2007-2010) e no Senado Federal (2013-2020). Advogado na área de Direito Administrativo Concorrencial e consultor jurídico.